12 sesiones de derecho de daños (5.11.2012).pdf

12 sesiones de derecho de daños

Curso de introducción al análisis de la responsabilidad civil

2012/13

Pablo Salvador Coderch
Catedrático de derecho civil, abogado, fundador y *senior editor* de InDret

Carlos Gómez Ligüerre
Profesor titular de derecho civil

Antoni Rubí Puig
Doctor en derecho, profesor lector de derecho civil

Sonia Ramos González
Doctora en derecho, investigadora del programa Ramón y Cajal

Antoni Terra Ibáñez
Doctorando en derecho, estudiante de economía

InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO

WWW. INDRET.COM

Índice

Sesión 1ª: Introducción al derecho español de daños y su análisis (I) 2

Sesión 2ª: Introducción al derecho español de daños y su análisis (II).. 17

Sesión 3ª: Negligencia (I)..... 33

Sesión 4ª: Negligencia (II) 48

Sesión 5ª: Negligencia (III)..... 63

Sesión 6ª: Culpa comparativa y culpa contributiva 87

Sesión 7ª: Causalidad de hecho 104

Sesión 8ª: Imputación objetiva.....126

Sesión 9ª: Responsabilidad objetiva 145

Sesión 10ª: Daño.....162

Sesión 11ª: Responsabilidad por hecho ajeno 179

Sesión 12ª: Prescripción.....193

Sesión 1ª
Introducción al derecho español de daños y su análisis (I)

1.1. ¿Qué es responsabilidad civil? / *What is a Tort?* **4**
1.1.1. Atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010) 4
1.1.2. Accidente de ferrocarril 6
1.1.3. Infracción de deberes de información / *Failure to warn* 8
1.2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources* **9**
1.2.1. Legislación / *Statutes* 9
1.2.2. Jurisprudencia / *Case-law* 10
1.2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources* 10
1.3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics* **12**
1.4. Concepto y clases de accidente, y limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes **13**
1.4.1. Concepto y clases de accidente 13
1.4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños 14
1.4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido Calabresi, 1970; Steven Shavell, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños .. 15

Preliminar: cuatro buenas maneras de estructurar el análisis de los casos en derecho y en derecho de daños.

IRAC: el punto de vista del jurista:

a) *Issue*: ¿cuál es o cuáles son las cuestiones legales que plantean los hechos alegados y probados por las partes en el caso?
b) *Rules*: ¿cuáles son las reglas de derecho aplicables a los hechos del caso? En su caso: ¿cuál es la jurisprudencia?
c) *Analysis*: ¿cuáles son las razones, en derecho, de las partes, de cada una de ellas?
d) *Conclusion*: ¿qué concluiría el Juez o Tribunal en un caso como el presentado o qué habría de haber resuelto?

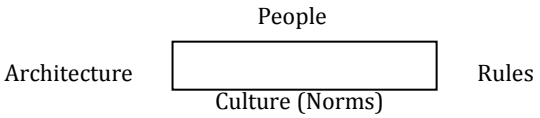
Para más información, véase http://www.csun.edu/~kkd61657/brief.pdf

Lecciones para el futuro: el punto de vista del ingeniero:

J. BUONGIORNO, R. BALLINGER, M. DRISCOLL, B. FORGET, C. FORSBERG, M. GOLAY, M. KAZIMI, N. TODREAS, J. YANCH, *Technical Lessons Learned from the Fukushima-Daichii Accident and Posible Corrective Actions for the Nuclear Industry: An Initial Evaluation*, Nuclear Science & Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Canes publications, May 2011
http://web.mit.edu/nse/pdf/news/2011/Fukushima_Lessons_Learned_MIT-NSP-025.pdf

a) Observations from the accident
b) Key questions
c) Possible corrective actions
d) Possible design improvements in the future

PARC: El punto de vista del científico social:



"Look, no hands", *The Economist*, September 1st 2012 (http://www.economist.com/node/21560989): cada mes mueren en el mundo 108.000 personas en accidentes de tráfico (WORLD HEALTH ORGANISATION, GLOBAL HEALTH OBSERVATORY DATA REPOSITORY, *Mortality and burden of disease, Cause-specific mortality*, 2008, http://apps.who.int/ghodata[1]). Si se mantiene el ritmo creciente de producción de automóviles, en 2020 la cifra mensual de muertos por accidentes de tráfico sobrepasará los 150.000. Sin embargo, las ayudas electrónicas a la conducción y hasta el pilotaje automático ayudarán a reducir el número y gravedad de los accidentes de tráfico, un ejemplo claro de cambio en la arquitectura. A mejor.

Redacción legal: el punto de vista del escritor legal:

Distribuye tu tiempo disponible, de acuerdo con la regla de las cinco E's (PSC (1985)):

- Escucha: mucha gente espera, ansiosa, su turno para hablar, no escuchan.

- Estudia: ni el mejor redactor legal está solo en el mundo, solo lo está ante la pantalla: acompáñala con la mejor literatura, dos referencias de primer nivel suelen bastar, pero busca las mejores. Si el texto que has de escribir es un examen o prueba, las dos primeras E's pueden colapsar en una: Entiende las preguntas que te formulan.

- Esquematiza: prepara, por escrito, un esquema de tu discurso. La organización triádica es ideal: nadie recuerda un discurso basado en siete principios. El ejemplo clásico de buen discurso estructurado en bloque de tres ideas en la década de los dos miles es el de Steve Jobs, *How to Live Before You Die* (accesible en la red. Por ejemplo, en TED Ideas Worth Spreading).

- Escribe: al final, las palabras son el arma principal del abogado, del juez. Y un buen test para un Estado de derecho es calificar de 0 a 10 el grado de coherencia entre las palabras del juez y las verdaderas razones de su decisión. ¿Aprobamos en España?.

- Edita: dedica por lo menos una cuarta parte de tu tiempo a editar el texto que has redactado; hay algunas buenas maneras de editar: una es dejar que lo haga otra persona mayor o más joven que tú; otra, que lo hagas tú al día siguiente de haber redactado el primer borrador.

Las cinco reglas anteriores, las cinco E's ayudan a evitar errores. Hay una sexta que es solo para profesionales auténticos, para maestros:

- ¡Empieza de nuevo!

Un buen libro para aprender a escribir en derecho es el de Terrill POLLMAN, Judith M. STINSON, Richard K. NEUMANN, Jr., Elisabeth POLLMAN, *Legal Writing*, 1st edition, Wolters Kluwer, New York, 2011.

[1] El estudio de WHO consultado por los autores de estas sesiones se refiere a los fallecidos por accidentes de tráfico acaecidos en 2008, que fueron 1.208.691, es decir, 100.724 cada mes.

1.1. ¿Qué es responsabilidad civil? / *What is a Tort?*

1.1.1. Atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010)

http://www.youtube.com/watch?v=_HSmGph9zrA

El 23.6.2010, a las 23:23 horas (vigilia de San Juan), en la estación de trenes de Rodalies (Cercanías) RENFE de Castelldefels Platja (Castelldefels, Barcelona), un convoy arrolló a un grupo numeroso de personas que, en aquellos momentos estaban cruzando las vías del ferrocarril. 12 personas fallecieron y 17 resultaron heridas de diversa consideración.

Las víctimas, viajeros de un tren de Cercanías que había llegado a la estación poco antes de que lo hiciera el convoy de media distancia que les arrolló, habían salido de sus vagones a cierta distancia de un paso subterráneo habilitado para pasar al otro lado del andén del ferrocarril, pero se habían dirigido a una pasarela superior, que estaba más próxima a ellos y que era la antigua salida de la estación, cuando se encontraron con que estaba inhabilitada y el paso cerrado por una cadena. Entonces algunos viajeros resolvieron fatalmente saltar a las vías para cruzarlas y acceder a la playa. Como consecuencia del accidente, se iniciaron diligencias penales.

El 30.6.2010, el Juez entonces encargado de la instrucción del caso dictó un auto por el que se acordó el sobreseimiento libre de las diligencias previas. Las acusaciones particulares interpusieron recurso de reforma y apelación contra dicho auto. Un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10.1.2011, estimó el recurso, revocó el auto recurrido y ordenó la continuación de la instrucción a fin de practicar más diligencias. Las acusaciones particulares presentaron escrito en el que interesaban la imputación de las personas que ocupaban diversos cargos directivos en RENFE y ADIF en la fecha del accidente por 12 presuntos delitos o faltas de homicidio imprudente, así como por 17 delitos o faltas de lesiones imprudentes, a título de comisión por omisión. El Ministerio Fiscal, ADIF y RENFE se opusieron a lo interesado y presentaron escritos de alegación.

El AJPII nº1 Gavà, de 30.5.2012, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas (art. 641.1 LECrim) por "no darse (…) los requisitos que los tipos imprudentes exigen para apreciar su existencia" (FD 2.8) puesto que, "[d]el análisis de las actuaciones obrantes en autos no resulta la existencia de incumplimiento sustancial de la reglamentación y de las normas de cuidado a observar en el ámbito del tráfico ferroviario que permita afirmar la existencia de omisión de un deber de cuidado punible en la esfera penal" (FD 2.1).

En concreto, la Juez consideró probado que

a) "[E]l estado de mantenimiento técnico del tren (…) implicado en el siniestro [era] adecuado" (FD 2.2).

b) [E]l maquinista (…) cumplió en su conducción con todas las exigencias normativas al respecto" (circulación dentro de los límites de velocidad, llevaba encendidas las luces reglamentarias al momento de entrar en la estación, instante en que también accionó el claxon, y el resultado de las pruebas de alcoholemia resultó negativo) (FD 2.2).

c) [E]l apeadero de Castelldefels cumplía "los requisitos de seguridad y accesibilidad exigidos normativamente" (en concreto, había sido reformado en 2009 para adaptarse a las exigencias del RD 1544/2007, de manera que el cruce de pasajeros de un andén al otro mediante una pasarela superior fue sustituido por un paso subterráneo) (FD 2.3). Y,

d) "[L]as condiciones que en particular presentaba el apeadero en el momento de los hechos" eran igualmente adecuadas (iluminación suficiente, paso subterráneo accesible, "sin ningún obstáculo", y –extraordinariamente, por la mayor afluencia de personas en el apeadero con motivo de la noche de San Juan– tornos de salida de la estación abiertos, así como también los portones situados al lado de dichos tornos) (FD 2.3).

Finalmente, la Juez del caso afirmó:

"[N]o era previsible (…) que los pasajeros del tren de cercanías, incurriendo en una notoria negligencia y prescindiendo de las más elementales normas de cuidado, incumpliendo con lo previsto en la normativa aplicable, decidieran, sin buscar el paso habilitado al efecto [ya que "desde que el tren de cercanías abandonó la estación hasta que se produjo la entrada en el mismo del tren causante del siniestro transcurrieron únicamente 15 segundos"], pasar al otro andén cruzando directamente las vías, sin prever que por las mismas se podría acercar otro tren (…) (FD 2.6). "Siendo tal decisión de todo punto imprevisible", sus efectos "no [son] imputable[s] a las personas respecto de las cuales se pretende su imputación por las acusaciones particulares" (FD 2.7).

A continuación, se reproducen tres fotografías de la estación de Castelldefells Playa, donde ocurrió el accidente y otras tres de dos estaciones de ferrocarril suizas, Grindelwald e Interlaken-Ost. En las estaciones secundarias de la Confederación Helvética es frecuente que no haya ni pasos elevados ni subterráneos: los pasajeros esperan a que el empleado del ferrocarril que viaja con ellos en cada tren les indique el momento apropiado para cruzar los andenes.

El contraste entre España y Suiza sugiere una reflexión sobre los comportamientos apropiados en derecho: en ambos países, la gente, las infraestructuras y las normas –la cultura- son distintas, así, las reglas de derecho más apropiadas para evitar accidentes o reducir su número y disminuir su gravedad pueden analizarse habida cuenta de su interacción con aquellas y, en particular, con la gente, con las personas (*people*) quienes, mejor o peor educadas, asumen un nivel de precauciones congenial con su entorno. La modificación de las reglas de derecho o de su interpretación posible pueden llevar a modificar la infraestructura, el sistema de normas culturales o el comportamiento de la gente. La decisión sobre qué efecto es preferible –estaciones como la española o las suizas, por ejemplo- no es autoevidente.

Estación de ferrocarrils de Castelldefels

Der Bahnhof Grindelwald

Der Bahnhof Interlaken-Ost

1.1.2. Accidente de ferrocarril

STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero:

El 19 de marzo de 1994, dos menores, de 15 y 16 años de edad, circulaban en un ciclomotor de una sola plaza. Su conductor, quien carecía de permiso de conducir, cruzó la vía del tren por un paso a nivel sin barreras ni semáforos, en A Rúa (Padrón, A Coruña), y un tren arrolló a ambos muchachos matándoles en el acto. A un lado del paso, había una señal descolorida; al otro, un poste de unos dos metros de altura con señales de atención al tren; pero en ninguno había señal, preceptiva, de stop. Los dos menores, vecinos del lugar, conocían el paso a nivel. En el momento del accidente el tren circulaba a 98 km/hora, la velocidad máxima permitida era de 100 km/hora y el convoy era visible aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar del accidente en línea recta. A unos 600 m. del paso a nivel existía la señal reglamentaria que ordena "silbar".

Los padres y el hermano, respectivamente, de los dos fallecidos interpusieron sendas demandas contra Renfe y el maquinista del tren. Los padres y hermano de una de las víctimas solicitaron que "se declare la obligación de [Renfe] de dotar al paso a nivel e inmediaciones… de las medidas de seguridad, protección y advertencia a los usuarios…, necesarias para evitar riesgos en las personas y en las cosas, atendiendo a las circunstancias de la zona y en particular el cercamiento de la vía al paso por la población y dotación de barreras o mecanismos de obligada detención de vehículos y personas …" y que se condene a los demandados a pagar 90.361,45 euros a cada uno de los padres del fallecido y 60.240,96 euros al hermano, así como 553,48 euros por gastos funerarios. Los padres y el hermano de la otra víctima solicitaron una indemnización de 132.530,12 por el fallecimiento del menor, 90.361,45 euros por daño moral y 1.826,55 euros por gastos funerarios.

El JPI estimó sustancialmente la primera demanda: condenó a Renfe a "dotar el paso a nivel e inmediaciones sito en A Rua de las medidas de seguridad, protección y advertencia que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas" y condenó a ambos demandados a pagar 144.821,15 euros a los padres, 18.807,93 euros al hermano, ambas cantidades en concepto de daño moral, y la cuantía reclamada por gastos funerarios. Asimismo, el JPI estimó sustancialmente la segunda demanda y condenó a ambos demandados a pagar las mismas cantidades en concepto de daño moral y la cuantía reclamada por gastos funerarios.

La Audiencia Provincial (AP) de A Coruña estimó el recurso de apelación de Renfe, revocó la SJPI y desestimó ambas demandas:

"Es obvio por demás que en principio la causa del accidente fue el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren; descuido relativamente explicable por la edad juvenil, pero no por ello prescindible e intrascendente cuando de la aplicación del Derecho se trata (…) no es posible atribuir a los demandados alguna de las omisiones concretas de las que derivar su responsabilidad en el accidente (…)"

"Pero ha sido objeto también de debate otra interesante cuestión: si existe responsabilidad de Renfe por no haber abordado ya la supresión de ese concreto paso a nivel, o, al menos, su reordenación para dotarlo de mejores medios de seguridad, como barreras o semibarreras. Es claro que la actual red viaria, con la existencia de pasos a nivel para cruzar la línea férrea, deriva de razones que en tiempos pretéritos los hicieron necesarios; sin que, por otra parte, creasen tan elevado riesgo como en la actualidad, al haber aumentado tanto la circulación de vehículos a motor que se ven obligados a cruzar por ellos. Pero en los tiempos presentes, con medios técnicos muy superiores, se ha impuesto la política conducente a la eliminación de tan peligrosos obstáculos viarios, que por unas u otras razones se han cobrado muchas vidas, como en el caso que nos ocupa (…) Responde a tal criterio el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/90, de 28 setiembre), que en su artículo 235 contempla tanto lo relativo a nuevos pasos a nivel, que solo permite con carácter excepcional y por causas absolutamente justificadas, como la supresión de los actuales o en otro caso, para los subsistentes, la adopción de sistemas de seguridad y señalización más eficaces… Pero es de advertir que el accidente ocurrió el 19 de marzo de 1994, y que por ello el texto vigente era la primera redacción del artículo 235. A tenor de ella, en su apartado 4, "Los pasos a nivel que resulten subsistentes deberán contar con los sistemas de seguridad y señalización adecuados para garantizar su seguridad que, a tal efecto, se determinen por los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones". Pues bien, estos sistemas de seguridad no se determinaron ministerialmente hasta la Orden de 1 de diciembre de 1994 (BOE de 14 del mismo mes), varios meses después de haber ocurrido el accidente objeto de este litigio. En ella se disponen las medidas de seguridad correspondientes a un paso a nivel como el de litis, que se califica de clase A, en el que ha de procederse a la instalación de la señalización que allí se hace constar (artículos 8 y 9). No cabría, pues, imputar a RENFE un retraso o dejadez en la aplicación de medidas de seguridad que se anunciaban en el Decreto de 1990, con remisión a lo que dispusiesen los Ministerios competentes, y que no se concretaron hasta después de ocurrido el accidente. Pero ha de tenerse muy en cuenta respecto a las medidas de señalización a instalar en la carretera o camino, que la norma, que se remite a las del

Reglamento General de Circulación ya aludidas, al igual que éste, responsabiliza de aquéllas al titular de tales vías (disposición adicional sexta). … [E]s lo que ya establecía la Orden de 8 de mayo de 1982, vigente cuando el desdichado accidente ocurrió ... A RENFE solo correspondía entonces y ahora la señalización establecida para la vía férrea (FD. 4º).

Los actores de la primera demanda interpusieron recurso de casación que el TS desestimó:

"La "defectuosa señalización" del paso a nivel, admitida por la AP, no desempeñó papel relevante alguno en la determinación del nexo de causalidad, sino que, en expresión de la sentencia recurrida, la causa del accidente estuvo en "el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren" (FD. 3º).

En "Trenes"(InDret 1/2000, www.indret.com), un artículo publicado en el año 2000, Carlos Gómez Ligüerre y Pablo Salvador Coderch analizaron la jurisprudencia española de la época a la luz de la experiencia norteamericana, es decir, a la de una cultura industrial mucho más avanzada tecnológicamente que la española. En el artículo, se rememoraba el intento lúcido, brillante, pero finalmente fallido, de un magistrado legendario, William Wendell Holmes, Jr., de establecer una regla única para resolver todos los casos de arrollamiento en pasos a nivel sin barreras. Holmes propuso que, ante un paso a nivel, los conductores de automóviles habían de detener sus vehículos, salir de ellos, mirar a uno y otro lado de las vías y escuchar si se acercaba algún tren (***"Stop, look and listen"***). De no adoptar tales precauciones, opinaba, las víctimas o sus sucesores no podrían reclamar nada por el accidente sufrido. La historia, contada en *Trenes*, enseña que la regla duró pocos años y que, al cabo, los tribunales norteamericanos hubieron de recurrir a criterios más matizados. Probablemente, lo mismo ha sucedido con las propuestas sobre precauciones exigibles que Gómez y Salvador formularon en el artículo citado. El tiempo solo respeta aquello que ha creado.

1.1.3. Infracción de deberes de información / *Failure to warn*

STS, 3ª, de 25 de junio de 2010

El 7.6.1997, Natividad, una niña de 10 años de edad, fue vacunada en Castilla-La Mancha contra la meningitis con vacuna antimeningocócica A+C de polisacáridos (Mencevax A+C). Pocos años después en 2000, la administración sanitaria española tuvo conocimiento de que tal vacuna perdía efectividad al cabo de tres años. En el mismo año 2000, la administración inició una nueva campaña de vacunación contra al meningococo del serogrupo C para niños menores de seis años de edad, razón por la cual, no incluía a Natividad. El 8.4.2003, Natividad ingresó en el Hospital Bichat-Claude Bernard donde se le diagnosticó una meningitis C y le fueron amputados ambos pies. El 2.6.2003, fue trasladada al Hospital Saint Maurice de Paris, donde permaneció hasta el 27.6.2003. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Central de la Defensa de Madrid, donde estuvo ingresada hasta el 13.9.2003. En noviembre de 2003, la Comunidad de Castilla-La Mancha llevó a cabo otra campaña para vacunar a todos los menores de diecinueve años.

El 4.2.2004, la madre de la menor interpuso en nombre y representación de su hija una reclamación administrativa contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha en la cual alegaba que la Administración había hecho dejación de funciones en el campo epidemiológico, al no haber realizado una campaña informativa adecuada sobre la persistencia de la meningitis, ni haber reaccionado ante la pérdida de efectividad de la vacuna Mencevax A+C. La reclamación fue desestimada por silencio administrativo. Posteriormente, por Sentencia de 22 de octubre de 2007, el TSJ de Castilla-La Mancha desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la reclamante.

En casación, el TS declaró el derecho de la recurrente a ser indemnizada en la cantidad de 800.000 euros:

"(…) aunque la incertidumbre es consustancial a la práctica de la medicina (…) los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a

disposición de las administraciones sanitarias", y "en la falta de información (…) radica la dejación de funciones de la Administración (…) [El administrado no tiene] el deber de soportar el daño consistente en las lesiones y secuelas de por vida provocadas por la nefasta enfermedad" (FD 5º).

1.2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources*

En responsabilidad civil, la ley o la jurisprudencia establecen los casos y circunstancias en los cuales el demandado ha de ser condenado civilmente a reparar los daños causados por un suceso o acontecimiento dañoso que no debería haber ocurrido, que ha causado el demandado mismo y que el derecho puede considerar que ha de ser puesto a su cargo. Es muy difícil ofrecer una definición de la responsabilidad civil que sea, a la vez, omnicomprensiva, operativa y fecunda. Véase la siguiente, tomada de un libro clásico de un especialista norteamericano:

"A tort is a conduct that amounts to a legal wrong and that causes harm for which courts will impose civil liability" (Dan Dobbs, *The Law of Torts,* West, 2000)**.**

1.2.1. Legislación / *Statutes*

Hay muchas reglas de derecho español que establecen supuestos de responsabilidad civil o, más generalmente, de responsabilidad extracontractual. Las principales son las siguientes:

— Artículos 1902 y ss. del Código Civil de 1889.
— Artículos 109-125 del Código Penal de 1995.
— Artículos 139-146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
— Artículos 42-54 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
— Artículos 128 y ss. RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
— Artículo 123 del RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Hoy en día, la ley y los reglamentos, el derecho legislado y regulatorio, ocupan un lugar creciente en la prevención de los accidentes y en la resolución de los conflictos a que su ocurrencia dan lugar. Aquí es importante destacar las diferencias básicas entre el derecho regulatorio de los accidentes y el derecho de daños creado y desarrollado por los tribunales:

—Las regulaciones miran al futuro, se establecen *ex ante*. En cambio, el derecho judicial de daños mira al pasado, se decide *ex post*.
—Las regulaciones suelen ser crecientemente detalladas, son conjuntos de reglas, no de principios o no solo de ellos. En cambio, el derecho de daños parte de principios o estándares que los tribunales concretan de modo mucho más fluido y, muchas veces, de modo intersticial.

Por ello, una pregunta capital del moderno derecho de daños es si la regulación detallada de una actividad cierra o clausura el sistema de modo tal que excluya toda pretensión adicional por derecho de daños o, por el contrario, el demandante pueda ejercitar una pretensión de responsabilidad civil además de los remedios previstos por la regulación específica del caso: es el tema de la "*preemption*", de la cuestión de si el derecho regulatorio cierra o no el paso a ulteriores reclamaciones por responsabilidad civil.

Un ejemplo: ¿cierra la regulación vigente en España sobre la disolución del matrimonio y sus consecuencias la posibilidad de que uno de los cónyuges ejercite una pretensión de responsabilidad civil contra el otro y en cuyo fundamento alegue los daños morales que, presuntamente, le ha causado la infidelidad del demandado?

1.2.2. Jurisprudencia / *Case-law*

En España, el derecho de daños es fundamentalmente derecho jurisprudencial, *case-law*. Y lo es, entre otras razones, porque las disposiciones más importantes sobre la materia del derecho legislado son principios o estándares muy genéricos. Así, dos fuentes positivas básicas del derecho español de daños --el art. 1902 del Código Civil de 1889 y el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común— se formulan como principios (*standards*), no como reglas (*rules*). Por ello, su concreción y desarrollo quedan para la jurisprudencia y esta ha venido decidiendo constelaciones de casos que, muy aproximadamente, delimitan poco a poco grupos de supuestos de responsabilidad civil. Tales supuestos cambian con el tiempo y las circunstancias, como hemos visto que ocurre en los casos de accidentes de ferrocarril. El jurista que trabaja la interpretación del derecho a partir del estado de los conocimientos científicos y técnicos puede ofrecer criterios razonables sobre el sentido de las resoluciones que defiende. Sin embargo, no existe ninguna teoría que permita predecir y explicar la dinámica del derecho de daños y no existe por la misma razón por la cual no hay una ciencia de la Historia que nos permita predecir y explicar el devenir de una colectividad: el derecho y el derecho de la responsabilidad civil son partes de la Historia. Pero la razonabilidad del jurista es crucial a la hora de decidir, de nuevo por ejemplo, casos de accidentes de ferrocarril, si queremos encaminar a la colectividad hacia Castelldefells, o hacia Grindelwald o Interlaken. Siempre es importante que el jurista sepa hacer llegar a los tribunales y la colectividad misma el sentido último, las consecuencias de las decisiones que vayan a adoptar.

En derecho español, la Jurisprudencia en sentido estricto es solo la establecida por el Tribunal Supremo y, más concretamente, por cada una de sus Salas en asuntos de su competencia (*Spanish Supreme Court's Case-law*), pero la denominada jurisprudencia menor, las sentencias de las Audiencias Provinciales (*Spanish Courts of Appeals' Case-law*) son cada vez más importantes: en la actualidad, conocer cómo deciden las Audiencias las distintas constelaciones de casos es imprescindible en la buena práctica de cualquier abogado especializado en responsabilidad civil.

Dos buenas bases de datos de consulta:
— Westlaw Aranzadi (www.upf.edu/bibtic/recursos/bd/bd-a.html)
— CGPJ – CENDOJ (www.poderjudicial.es/jurisprudencia)

El equipo de investigadores que, en 1999, fundó InDret mantiene al día una selección de sentencias del Tribunal Supremo español sobre responsabilidad civil de los últimos años. Su contenido integra las páginas de este curso y ofrece un panorama de la jurisprudencia española reciente:

Pablo SALVADOR CODERCH, Sonia RAMOS GONZÁLEZ (Coords), Laura ALASCIO CARRASCO, Laura ALLUEVA AZNAR, Esther FARNÓS AMORÓS, Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, Ignacio MARÍN GARCÍA, Rosa MILÀ RAFEL, Magalí RIERA ROCA, Carlos Alb. RUIZ GARCÍA, "110 casos de derecho de daños (2004-2010)", *InDret* 4/2011 (http://www.indret.com/pdf/863_es.pdf).

1.2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources*

Hay muchos buenos tratados, comentarios, monografías y artículos sobre responsabilidad civil. Los autores de este e-libro hemos seleccionado los siguientes, la mayor parte de los cuales versan sobre el derecho español, pero no todos, como los lectores comprobarán:

— Hugo ACCIARRI, *Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños*, 1ª ed., Asociación latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE) & George Mason

University, Law & Economics Center, Berkeley, California, 2009. Junto con el libro de Bullard, dos de las más brillantes referencias latinoamericanas, utilísimas y usadas en las mejores universidades del cono sur por quienes ya son estudiantes de excelencia mundial.

— Mario BARCELLONA, *Trattato della Responsabilità Civile*, Ed. Utet, 2011. Tratado italiano de referencia.
— Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios al Código Civil*, 3ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009 (Fernando PEÑA LÓPEZ, comentario a los arts. 1902 a 1910, pp. 2153-2171). Uno de los dos mejores comentarios globales al código civil español.
— Alfredo BULLARD, *Derecho y Economía. El Análisis Económico de las Instituciones Legales*, 2ª ed., Palestra Editores, Lima, 2006. Síntesis académica y profesional de primer nivel.
— Ana CAÑIZARES LASO/Pedro DE PABLO CONTRERAS/Javier ORDUÑA MORENO/Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ (Dirs.), *Código civil comentado*, Vol. 4, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011 (Javier PLAZA PENADÉS, "Comentario al art. 1902", pp. 1454-1464; y Esther GÓMEZ CALLE, "Comentario al art. 1903", pp. 1464-1476). El otro.
— Robert D. COOTER/Thomas ULEN, *Law and Economics,* 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2011. Presentación asequible, muy meditada y muy bien escrita: una excelente introducción para estudiantes que no cursen doble grado.
— DEUTSCH/AHRENS, *Deliktsrecht*, 5. Aufl, Verlag Carl Heymanns Verlag, 2009. Buen libro de introdución.
— Ricardo DE ÁNGEL YÁGÜEZ, *Tratado de responsabilidad civil*, 3ª ed., Universidad de Deusto, Civitas, Bilbao, Madrid, 1993. La visión del abogado.
— Simon DEAKIN, Angus JOHNSTON, Basil MARKESINIS, *Markesinis and Deakins' Tort Law*, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2007. Obra británica de referencia.
— Luis DÍEZ-PICAZO, *Fundamentos de derecho civil patrimonial*, Tomo V, 1ª ed. Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011. Referencia española: da razón del pensamiento dominante.
— Richard A. EPSTEIN/Catherine M. SHARKEY, *Cases and Materials on Torts*, 10th edition, Aspen Publishers, 2012. La vieja y sabia América de Richard Epstein se encuentra con la joven y brillante Caty Sharkey, ambos trabajan en la universidad más potente en derecho académico de daños. Al menos hoy.
— Michael FAURE, *Tort Law and Economics* (*Encyclopedia of Law and Economics*, Vol. 1, 2nd edition), Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) – Northampton, Massachussetts (USA), 2009. La enciclopedia.
— Massimo FRANZONI (Dir.), *Trattato della Responsabilità Civile* (Vol. 1: *L'illecito*, Vol 2: *Il danno risarcibile*), 2ª ed., Dott. A. Giuffrè – Editore, Milano, 2010. El otro tratado italiano de referencia.
— James A. HENDERSON/Richard N. PEARSON/Douglas A. KYSAR/John A. SICILIANO, *The Tort Process*, 7th edition, Aspen Publishers, New York, 2007. Tres generaciones de académicos de primer nivel suman sus fuerzas para producir un case-book extraordinario
— InDret. Revista para el análisis del derecho: www.indret.com. El origen de todo esto: un producto muy costoso, acaso de algún valor y gratis (para sus lectores). Editado y escrito por tres generaciones de civilistas.
— Hein KÖTZ/Gerhard WAGNER, *Deliktsrecht*, 11., neu bearbeitete Auflage, Verlag Vahlen, München, 2010. El mejor puente entre el derecho alemán, el *common law* y el moderno análisis del derecho de daños, escrito por dos especialistas de primer nivel y de distintas generaciones, un clásico. Comparte con los case-books angloamericanos un lenguaje admirable, pues está muy bien escrito.
— José Luis LACRUZ BERDEJO et. al., *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones,* Vol. 2º, Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito. 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2009. Manual español de referencia.
— Miquel MARTÍN-CASALS, La "modernización" del Derecho de la responsabilidad extracontractual", XV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, http://www.derechocivil.net/jornadas/APDC-2011-PONENCIA-CASALS.pdf, 2011. La visión del comparatista.
— Thomas J. MICELI, *The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008 (óptima introducción analítica, indicada para estudiantes de doble grado).
— *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (Band 5: *Schuldrecht - Besonderer Teil III §§ 705 – 853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz*), 5. Auflage, C.H. Beck, 2009. Presentación clásica, panorama para práctica y academia.

— Fernando PANTALEÓN PRIETO, "Comentario al artículo 1902 CC", en Cándido PAZ-ARES, Luis DÍEZ-PICAZO, Rodrigo BERCOVITZ, Pablo SALVADOR, *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1993, pp. 1971-2003. Los años transcurridos desde su publicación revalidan el comentario como la referencia clásica del derecho español de la negligencia.
— L. Fernando REGLERO CAMPOS (Coord), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 4ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2008. El testamento de un gran profesor, prematuramente desaparecido.
— Encarna ROCA TRÍAS/Mónica NAVARRO MICHEL, *Derecho de daños. Textos y materiales*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. La voz de profesoras de dos generaciones, una de ellas magistrada del Tribunal Supremo y, desde 2011, del Tribunal Constitucional.
— SCHWARZ/WANDT, *Gesetzliche Schuldverhältnisse – Deliktsrecht, Shadensrecht, Bereicherungsrecht, GoA*, 4. Auflage, Verlag Vahlen, 2011. Imprescindible para la formación de un académico versado en *Civil Law*: el derecho de daños en la primera potencia industrial y exportadora de Europa, un país cuyos sectores de actividad están intensamente regulados y que no se puede permitir inseguridad jurídica ni incertezas de ningún tipo a la hora de delimitar las incumbencias de cada persona u organización en el marco de una división extrema y excelente del trabajo.
— Steven SHAVELL, *Foundations of Economic Analysis of Law*, 1st edition, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2004. Paradigma implacablemente neoclásico del análisis económico del derecho, sin casos.
— Geneviève VINEY, Patrice JOURDAIN, *Introduction a la responsabilité* (2008), *Les conditions de la responsabilité* (2006), *Les effets de la responsabilité* (2011), 3ème éd. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), (Collection Jacques GHESTIN [Dir.], *Traité de droit civil*). Manuales franceses de referencia.

1.3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics*

La economía, la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Paul Krugman/Robin Wells), puede aplicarse al análisis del derecho –como también pueden serlo la psicología, la ciencia política o la sociología- y, durante el último medio siglo, lo ha sido con mucho éxito y algunos fracasos -notablemente, algunos excesos-.

El análisis económico del derecho puede ser positivo o normativo.

El análisis positivo pregunta sobre las consecuencias económicas del establecimiento y aplicación de una regulación determinada, por ejemplo, ¿qué efectos tendría establecer una regla general de defecto en cuya virtud la velocidad máxima en vías urbanas no debe superar los treinta kilómetros por hora?

El análisis normativo pregunta sobre cuál es la mejor regla, de entre varias reales o posibles, en términos de eficiencia económica y, por ello, de entre las distintas alternativas razonablemente posibles en términos de limitación de velocidad en vías urbanas, considera preferible aquella que resulte más eficiente en términos de costes y beneficios sociales.

El análisis económico puede aplicarse al derecho de daños, al derecho de accidentes abordado con las técnicas de la responsabilidad civil, y parte de considerar las consecuencias probables, positivas y negativas, de las distintas actividades sociales cuyo desarrollo genera accidentes.

Thomas J. MICELI (*The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008), uno de los mejores analistas económicos del derecho, señala que el riesgo de causar algún daño es el subproducto inevitable de muchas –si no de todas- las actividades sociales globalmente beneficiosas. Y aunque, escribe, normalmente no podemos eliminar el riesgo sin suprimir de raíz la actividad de que se trate, deberíamos adoptar todas las medidas, justificadas en términos de costes y beneficios, para minimizar el riesgo: deberíamos, pues, invertir en reducción de riesgos cantidades crecientes de recursos hasta el punto en que un euro adicional empleado en evitar pérdidas derivadas de los accidentes solo consigue impedir accidentes estimados justamente en otro euro.

Cualquier sociedad avanzada dispone de muchos medios distintos, jurídicos y no jurídicos, para controlar los riesgos derivados de las actividades peligrosas –de casi todas-, pues, además de la responsabilidad civil, tales actividades pueden estar sujetas a regulaciones de seguridad, a impuestos, al derecho administrativo o, incluso, al derecho penal, además de estarlo a medidas físicas de seguridad o a tradiciones educativas y cívicas que nada tienen que ver con el derecho.

En todo caso, la esencia de la responsabilidad civil es la obligación potencial, asumida por el demandado, de reparar los daños causados a la víctima de un accidente y que esta o un allegado suyo, si la víctima falleció, reclama ante un tribunal de justicia.

1.4. Concepto y clases de accidente, y limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes

1.4.1. Concepto y clases de accidente

Accidente: suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas (DRAE).

A mishap, a mischance, especially one causing injury or death (Collins English Dictionary).

Clases de accidentes: la implosión de la distinción entre accidentes naturales y accidentes causados por conductas humanas

Tradicionalmente los accidentes pueden ser naturales o causados o cocausados por una conducta humana, individual o colectiva.

Ejemplos de accidentes naturales (*natural accidents, acts of God*) son los terremotos, como los de Haití y Chile, de 2010, o los maremotos (*tsunami*), como el de Japón en 2011. También los huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones, incendios de origen natural. Los accidentes naturales no siempre son acontecimientos discretos, sino que, en ocasiones, son fenómenos que tienen lugar muy lentamente y cuyos efectos se manifiestan a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo: así los denominados *Medieval Warm Period (950-1250*) o *The Little Ice Age, 16th-19th centuries.* Pero en estos últimos casos, la noción de accidente se difumina hasta desaparecer. Luego, no todos los accidentes naturales son catastróficos (Pablo SALVADOR CODERCH/Sonia RAMOS GONZÁLEZ/Rosa MILÁ RAFEL, "Catastrophic Damages: Liability and Insurance", in Karen B. BROWN/David V. SNYDER [Eds.], *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*, 1st edition, Springer, New York, 2012, p. 85-103, esp. 90), sino que muchos de ellos dañan únicamente a una o a muy pocas víctimas, como la caída de un rayo o de un árbol.

Los accidentes causados por una conducta humana (*caused by human agency*) son tales como los de trabajo, los de tráfico, los iatrogénicos, los domésticos: en estas páginas nos centramos en los accidentes causados o agravados por conductas humanas.

La distinción entre accidentes naturales –*Acts of God*- y accidentes causados por los seres humanos está en crisis: 2008 fue el año en el cual, por primera vez en la historia de la Humanidad, más habitantes de la Tierra vivían en ciudades que en el campo. Ciertamente, el campo es una idealización que, al menos desde la Revolución Neolítica, desde la última glaciación, hace 10.000 años, cada vez ha tenido menos que ver con la Naturaleza, con el mundo silvestre, no humanizado. Tanto es así que, para muchos geólogos –rendidos a la geografía, una ciencia humana-, ya no vivimos en el Holoceno, la fase del Cuaternario posterior a la última Glaciación, sino estamos en pleno Antropoceno, en la Era del Hombre (Paul Crutzen y Eugene Stoermer).

Así, el terremoto de Haití, de 12 de enero de 2010, mató quizás a 200.000 personas, pero el poco posterior de Chile, de 27 de febrero de 2010, de mayor intensidad, a menos de 600: Chile estaba

mucho mejor preparado que Haití para soportar la catástrofe. El Tsunami de Japón, de 11 de marzo de 2011, mató a casi 16.000 personas, pero su consecuencia más destacada culturalmente fue su efecto sobre la central nuclear de Fukushima Daiichi y sobre la política energética mundial de una generación. Para muchas personas, los accidentes naturales no existen. No es así, pero el jurista hará bien en apuntar a las posibilidades que la ciencia y la técnica ponen a nuestra disposición para prevenir un accidente y los costes de todo tipo de la prevención. Un ejemplo de libro es la susceptibilidad de algunas localidades del Sureste español a un terremoto: sabemos que se producirá, pero no estamos en condiciones de decir cuándo (véase la web del Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento).

1.4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños

Otras distinciones en crisis son las que dividen al mundo en sistemas nacionales de derecho. Desde 2009, se discute sobre el concepto de límites, linderos o fronteras ecológicos del planeta (*environmental boundaries of the world*) que se construye sobre nueve categorías de problemas, algunas de las cuales, al menos, no reconocen fronteras políticas ni, por tanto, sistemas nacionales de derecho (cambio climático, acidificación de los océanos, desaparición de la capa de ozono, intervención en el ciclo del nitrógeno, roturación y urbanización crecientes, extinción, incremento de los polucionantes químicos y su creciente concentración en la atmósfera). Algunas de estas fronteras no son globales, pero otras lo son y todas obligan a poner de manifiesto las limitaciones del derecho de daños como derecho de los accidentes: tratados internacionales, políticas mundiales, derecho público y regulatorio, derecho sancionador, impulso del desarrollo tecnológico son instrumentos aparentemente mucho más eficaces para afrontar los retos del Antropoceno que el viejo derecho nacional de daños.

Sin embargo, el derecho de daños juega un rol esencial en tanto en cuanto constituye un instrumento de cambio del derecho mismo de los accidentes, es un motor de su dinámica: típicamente, los nuevos supuestos de responsabilidad civil impulsan cambios de legislación, las iniciativas descentralizadas de los abogados especializados en responsabilidad civil anuncian con frecuencia los cambios que han de llegar.

Así, los derechos de daños son fundamentalmente nacionales, pertenecen a sistemas estatales de derecho –aunque haya macrosistemas regionales armonizados de derecho de daños, como sucede con el derecho europeo de la responsabilidad civil del fabricante--.

Se trata de sistemas caracterizados por rasgos comunes: son, como acabamos de señalar, fundamentalmente nacionales, pero las herramientas analíticas utilizadas para su explicación y mejora son globales permitiendo una valoración también global de cada sistema nacional. En todos ellos, podemos preguntar sobre los costes y beneficios de la responsabilidad civil –que es muy costosa de aplicar-, sobre su contribución a mejorar la eficiencia, en sentido económico, de las conductas humanas, sobre la que puedan tener, psicosociológicamente, a corregir los sentimientos de maltrato, de trato injusto, que la causación de un daño pueda haber generado en sus víctimas o en la sociedad, sobre los efectos meramente distributivos de su aplicación, etc.

Luego, son sistemas basados en la aplicación privada del derecho, en el ejercicio de pretensiones resarcitorias por decisión de las víctimas de un daño o –si estas fallecieron- de sus herederos o allegados. Operan *ex post*, después de que el accidente y, por tanto, el daño hayan tenido lugar. Y su rasgo más característico consiste en que toda acción de daños en cualquier sistema de derecho consiste en el ejercicio judicial de una pretensión tendente a la reparación del daño o a su indemnización en dinero, dirigida contra el causante del daño, la persona, natural o jurídica, que ha de responder por aquel, o la compañía aseguradora de ambos.

1.4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido Calabresi, 1970; Steven Shavell, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños

Durante el último medio siglo la idea de que el derecho de daños puede contribuir, con otras ramas del derecho, a reducir y, específicamente, a minimizar los costes sociales de los accidentes ha ido a más. Aunque los sectores doctrinales más tradicionales del derecho civil español se aferran a la idea de que el derecho de la responsabilidad civil persigue principalmente compensar daños, nadie hasta ahora ha sido capaz de negar fundadamente que la compensación perfecta supone prevención óptima: la prevención de daños es la sombra de su compensación. Y es que a poco que se paren a pensar, cualquier sistema de reglas de responsabilidad civil que consiguiera que todos los casos de accidentes por los cuales alguien ha de responder se transigieran o litigaran con el resultado de que el demandante obtuviera una compensación integral de los daños, prevendría óptimamente la ocurrencia potencial de tales daños: yo no voy a pagar un daño de 100 si tengo la certeza de que me van a condenar a pagar esa cantidad, pero *ex ante* puedo evitar el accidente invirtiendo 75 en precauciones (75< 100).

Al respecto, los modelos más sencillos del análisis económico parten de asunciones simples, escasamente realistas, pero heurísticamente muy fecundas, pues, en términos generales, las personas razonablemente bien informadas y que no estén trastornadas responden a los incentivos. Básicamente, los modelos parten de suponer que, primero, podemos identificar un nivel de precaución que minimiza el coste total de los accidentes para cada tipo de actividad (fabricar objetos, conducir automóviles, prestar servicios médico-sanitarios, etc.). El coste total incluye los costes privados, es decir, los que sufre la víctima, y los costes sociales, los que experimentan terceros.

En segundo lugar, los modelos asumen, también muy drásticamente, que los agentes sociales son neutrales al riesgo, que están perfectamente informados de las consecuencias de sus actos –o de sus omisiones- y que sus conductas individuales son la única causa de cada accidente, es decir, que las víctimas nada pudieron hacer para evitar el daño.

Asumen además que los individuos son económicamente racionales en el sentido de que responden a los incentivos de forma tal que su comportamiento se ajusta siempre al que resulta más eficiente, dada una regla de derecho que se les aplicará inexorablemente en todos y cada uno de los casos en que incurran en una conducta dañosa por la que hayan de responder.

Finalmente, se suele suponer que las reglas de derecho de daños objeto de análisis permiten conseguir una compensación perfecta de los accidentes, de modo tal que sus víctimas son compensadas de forma tan ajustada al daño sufrido que si, antes del accidente, fueran preguntadas sobre qué preferirían, si no sufrir el accidente o sufrirlo y ser indemnizados por ello, responderían que les daría igual.

A lo largo de este curso, veremos que ninguna de estas asunciones puede mantenerse incólume, pero, como en otros muchos experimentos, conviene comenzar pensando qué ocurrirá si los realizamos en el vacío. Luego, tiempo habrá para complicar las condiciones de partida. Pero, por muchas complicaciones que añadamos, nunca prescindiremos de la idea básica de que, a la larga, la gente responde a los incentivos.

Frente a las limitaciones del análisis moderno del derecho de daños, el análisis doctrinal tradicional insiste en la de que la responsabilidad civil pretende únicamente compensar íntegra o limitadamente daños causados, corrigiendo en su caso la injusticia generada por el daño mismo. Mas, como ya hemos señalado, si el derecho de daños en acción compensa adecuadamente, es decir, íntegramente, a todas las víctimas en todos los casos de causación de un daño por los que se haya de responder, también minimiza los costes de los accidentes de que se trate. Últimamente, el análisis tradicional admite la función preventiva del derecho de daños, pero solo como una consecuencia de hecho, no como una efecto normativo del derecho de la responsabilidad civil. La observación sobre la dualidad entre efectos de derecho y de hecho roza la metafísica. Mucho más relevante es otra distinta que relaciona el derecho de daños con una

función correctiva, catártica, restauradora del orden jurídico y social alterado por el causante y responsable de los daños. Esta es mucho más digna de atención que la anterior y apela a la psicología social, un punto de vista desconsiderado por el análisis económico neoclásico del derecho.

Sesión 2ª
Introducción al derecho español de daños y su análisis (II)

2.1. Las cuatro grandes reglas de responsabilidad: ausencia de responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta 17
2.1.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros 17
2.1.2. La causación dolosa, intencional, de daños 20
2.1.3. La regla de la negligencia 20
2.1.4. La regla de la responsabilidad objetiva 23
2.2. Tipos de daño/*Types of Harm* 25
2.2.1. Análisis doctrinal/*Doctrinal Analysis* 25
2.2.2. Análisis económico del derecho/*Economic Analysis of Law* 27
2.3. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime* 27
2.4. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract* 28
2.5. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida? 31
2.6. ABC de un pleito de daños 32

2.1. Las cuatro grandes reglas de responsabilidad: ausencia de responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta

Como hemos visto en la Sesión 1ª, en responsabilidad civil, las circunstancias en las cuales el demandado ha de responder por los daños sufridos por la víctima son muy diversas y dependen de la regulación y la jurisprudencia aplicables al caso. Pero, en términos muy generales, hay cuatro grandes reglas de responsabilidad civil:

2.1.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros

El estatuto más básico de una conducta dañina –pero más beneficiosa que dañina—es aquel según el cual su realización no comporta ningún deber de indemnizar a sus víctimas. Contra lo que a menudo se cree, la regla de la no responsabilidad es, afortunadamente, muy frecuente: las pérdidas se quedan donde se han producido; los daños, allí donde han tenido lugar.

Un soldado, jurista y juez norteamericano, Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) expresó muy gráficamente esta idea, en su obra *The Common Law* (1881):

"Sound policy lets the losses lie where they fall except where a special reason can be shown for interference".

Muchos siglos antes, el Derecho romano lo había hecho con óptimo laconismo:

"casum sentit dominus".

Y en España lo mismo ha escrito la dos veces magistrada Encarna Roca en la Introducción a la 6ª edición de *Derecho de Daños. Textos y Materiales* (en colaboración con Mónica Navarro):

"En este libro se parte de un principio general: la persona que sufre un daño está obligada a asumir sus consecuencias, excepto si existen razones jurídicas para trasladarlas a quien lo ha producido" (p. 15).

Si la regla aplicable es la de ausencia de responsabilidad por los propios actos, no hay indemnización por daños, las víctimas se lamen sus propias heridas –si sobreviven a ellas- y el mundo sigue su curso. La regla incentiva niveles máximos de precaución en las víctimas potenciales (para evitar sufrir el daño), pero también un nivel cero de precaución en los causantes potenciales de daños (pues no habrá de pechar con sus consecuencias). La regla parte de que, para tales o cuales conductas, es preferible un principio de libertad individual sin consideración a los daños que la actividad de que se trate puede causar a terceros:

- Alguno de ustedes estará, sin duda, resfriado, pero sus compañeros no tienen derecho a reclamar indemnización alguna si, por ello, se contagian, mucho menos a exigirle que se quede en su casa, en cuarentena, hasta que cure del resfriado (en cambio, si hubiera contraído la tuberculosis, una enfermedad grave, quizás podrían reclamar por el contagio sufrido si el primer enfermo no adoptó precaución alguna).

- Todos ustedes tienen que soportar que su vecino compre el diario o se conecte a la radio en i-Tunes que ustedes detestan, que se peine, deje de hacerlo o que se atilde como guste o, más opinablemente, que se vista o medio desvista como le plazca.

- En nuestro derecho, nadie tiene derecho a ser amado, es decir, nadie puede ejercitar una pretensión judicial –una pretensión indemnizatoria, en nuestro caso– porque otra persona se niega a quererle, a amarle: no hay derecho al amor aunque ello pueda causar el suicidio del desesperado amante [***The Sorrows of Young Werther*** (*Die Leiden des jungen Werthers*) una novela de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), publicada en 1774]. Más discutiblemente, nadie tiene derecho a seguir siendo amado, aunque algunos juristas defienden que la infidelidad matrimonial y sus consecuencias biológicas deberían dar lugar a una pretensión indemnizatoria a favor del cónyuge afligido por ella.

- Parecidamente, varios aficionados a la práctica del noble deporte del rugby pueden decidir fundar un club deportivo, contratar un seguro de daños y comprometerse a no obligarse a responder recíprocamente por las lesiones causadas en el juego. En general y en derecho de contratos, las partes pueden excluir limitadamente su responsabilidad por accidentes. A cambio de ello, la ley puede exigirles que contraten un seguro obligatorio de accidentes y, en todo, caso prohíbe la exclusión de responsabilidad por daños causados dolosa, intencionadamente, o acaso también los causados por negligencia muy grave, rayana en el dolo.

- Tampoco responden los padres ante un hijo suyo por el hecho de haberle traído al mundo en condiciones tales que el hijo dice luego que preferiría no haber nacido -o alguien lo dice por él, una asociación o una fundación, por ejemplo-. El derecho de familia obliga a los padres a cuidar al hijo precisado de ayuda, pero no concede a éste una pretensión de daños contra aquéllos. El derecho de daños se niega a comparar una vida dura, acaso invivible para muchos, con el vacío absoluto del nihilismo. Pero incluso esto también resulta polémico para algunas personas que se niegan a traer hijos a este mundo, por no tener que convivir con seres temporalmente heterónomos y absolutamente dependientes, al tiempo que defienden que quienes lo hagan, respondan por ello en casos como el presentado aquí.

- La competencia, sumada al desarrollo tecnológico, es, literalmente, destrucción creadora: las tabletas han arrasado las librerías tradicionales del mismo modo que la bombilla de Edison acabó con las cererías y el motor de explosión con las caballerías, o que LED está ahora acabando con las bombillas incandescentes y el motor eléctrico pueda acabar

desplazando al de explosión. Pero competencia no es competencia desleal. Es, simplemente, competencia. Causa daños, causa muchos más beneficios que daños, disloca comunidades, acaba con estilos de vida cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, pero, en una sociedad abierta, no impide que una comunidad resuelva libremente vivir al margen del desarrollo tecnológico y de la competencia misma (un claustro monástico, una comunidad de Amish, otra neorrural, etc.), eso también, de modo mucho más sencillo y probablemente menos rico que el del resto de los consociados.

- En general, el ejercicio legítimo de cualesquiera derechos fundamentales puede originar y, de hecho, origina daños, pero son daños por los cuales el causante no habrá de responder. Una madre atea puede llegar a precisar asistencia psicológica, incluso a enfermar después de que su hijo entre en religión y un padre puede pasar por lo mismo o peor porque su hijo deja el oficio paterno, aborrece la ideología de los abuelos o abandona el país que les vio nacer a todos. Pero, afortunadamente, es ley de vida. Igualmente, mis vecinos pueden comprar los diarios, ver las películas o ser socios de los clubes que detesto, practicar la religión, educar a sus hijos, o votar de los modos más alejados a aquellos que considero apropiados para hacer real mi idea del bien común. Y así sucesivamente: no hay responsabilidad.

STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo. Asunción de riesgo en la práctica deportiva.

El 16.11.1991, Luis Manuel, quien jugaba a golf en el "Club de Golf Terramar" de Sitges, falleció tras recibir el impacto de una pelota lanzada por Ismael, que se encontraba en una calle distinta y separada de la de la víctima por una arboleda que impedía a ambos jugadores verse. El lanzamiento en cuestión había sido técnicamente incorrecto a causa del viento que soplaba en la zona.

Lucía, viuda del fallecido, en su nombre y en el de sus hijos menores, demandó a Ismael, al "Club de Golf Terramar", a "La Estrella S.A. de Seguros" y a "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y solicitó una indemnización de 281.237 € de las tres primeras y de 1.803 € de la cuarta.

El JPI nº 2 de Vilanova i la Geltrú (22.5.1996) estimó en parte la demanda y condenó al pago de 111.908 €, con el límite de 1.803 € para "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros". La AP de Barcelona (Sección 15ª, 12.5.1999) estimó los recursos de "Club de Golf Terramar", "La Estrella S.A. de Seguros" e Ismael, a quienes absolvió.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Lucía:

"La idea del riesgo, fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materiales peligrosos, y en los beneficios que a través de ello se obtienen, en modo alguno puede trasladarse a la práctica deportiva, no organizativa, para fundamentar un régimen de responsabilidad distinto del de la culpa. Se asume el riesgo desde la idea de que se conoce y se participa de él y de que el jugador es consciente de que no existe en el desarrollo de una buena práctica deportiva, más allá de lo que impone la actividad en concreto, porque confía en la actuación de los demás" (F.D. 3º).

Así, la regla de no responsabilidad consigue básicamente dos cosas: potencia la libertad individual o colectiva por el procedimiento de demarcar o fijar los límites de las actividades por cuyo desarrollo y consecuencias no se habrá de responder, y ahorra de paso los costes de compensar accidentes, caso por caso, por responsabilidad civil, que es una institución jurídica muy cara de gestionar (típicamente por cada euro gastado en un caso litigado y ganado por el demandante, la mitad, cincuenta céntimos, se quedan por el camino).

Su contraria, una regla de responsabilidad absoluta y universal, por todos los daños derivados de la convivencia, del roce social, nos arruinaría a todos, nos paralizaría y la sociedad colapsaría en pocos años. Nadie defiende seriamente semejante totalitarismo del derecho de daños. No existe tal regla en ningún ordenamiento del mundo. Asombrosamente, muchos la piden. Sin pensar.

2.1.2. La causación dolosa, intencional, de daños

Es el caso más grave y, desde luego, es difícil encontrar un supuesto de causación intencional de daños, sobre todo si tiene como consecuencia la muerte o las lesiones de la víctima, que no constituya un delito o una falta tipificados por el Código Penal, además de ser un ilícito civil. Pero, en todo caso, junto con la responsabilidad penal surgirá la civil, la cual, con independencia de la anterior, obligará al imputado o a las personas de quienes dependiera a reparar los daños causados.

El dolo es grave en todos los sistemas jurídicos históricos y contemporáneos y es intuitivo que así sea:

- La probabilidad de causar dolosamente un daño suele ser mayor que la de causar el mismo tipo de daño con una conducta similar pero simplemente descuidada o negligente.

- Luego, el causante doloso de daños destruye riqueza dos veces: cuando se hace con el instrumento dañino y cuando lo usa.

- Finalmente, la psicología explica bien por qué los miembros de casi cualquier sociedad reaccionan de manera mucho más intensamente hostil contra quienes les causan daños de intento, a sabiendas y, a menudo, con la precisa voluntad de hacer daño. En el fondo, el principio básico de justicia correctiva, de retribución, en cuya virtud quien ha causado un daño -y sobre todo, quien lo ha causado a ciencia y conciencia-- ha de pagar por ello está presente en todas la culturas históricas y contemporáneas (Neil VIDMAR, "Retribution and Revenge", en Joseph SANDERS/V. Lee HAMILTON [Eds.], *Handbook of Justice Research in Law*, reprint of 1st ed. 2001, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2010). El reto más serio al análisis económico del derecho de daños proviene de la psicología y de la psicología social, que muestran tanto que la conducta humana no siempre es económicamente racional como que la revancha, el rencor y el resentimiento forman parte de la condición humana. Otra cosa es que, paradójicamente, castigar pueda ser mucho más costoso para la víctima que perdonar y olvidar (Kevin M. CARLSMITH/Daniel T. GILBERT/Timothy T. WILSON, "The Paradoxical Consequences of Revenge", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 95, No. 6, 2008, p. 1316–1324).

2.1.3. La regla de la negligencia

La causación de daños por culpa o negligencia, por descuido más o menos grave, es decir, por no haber puesto en práctica, al desarrollar tal o cual actividad, las precauciones razonablemente exigibles, es el supuesto de partida de nuestro sistema jurídico en derecho privado: todos estamos sujetos a deberes de cuidado, de precaución, y si al llevar a cabo una actividad los infringimos, habremos de responder civilmente por los daños causados, es decir, habremos de repararlos, normalmente, indemnizando al demandante.

Además de definirse como infracción de deberes de cuidado, la negligencia puede caracterizarse como creación o incremento irrazonable de riesgos: toda actividad humana comporta riesgos –si estoy resfriado y salgo de casa puedo contagiar a las personas que se acerquen a mí-, pero la mayor parte de los riesgos normalmente asociados a una conducta son riesgos permitidos –ni la ley ni los tribunales me obligan a quedarme encerrado en casa por un simple resfriado-. Mi responsabilidad comienza allí donde el nivel razonable, socialmente admisible, económicamente sostenible, psicológicamente tolerable, éticamente soportable de riesgos sobrepasa el umbral de los riesgos permitidos –si soy un médico internista y he de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, tal vez deba abstenerme de acudir a mi hospital si estoy muy constipado; si soy seropositivo de VIH, habré de abstenerme de tener contactos sexuales sin protección adecuada-.

La regla de la responsabilidad por culpa o negligencia está presupuesta en el art. 1902 del Código Civil, pero no está definida allí.

El análisis doctrinal del *tort* de la *Negligence* en el *Common Law* distingue varios elementos - tres, cuatro o cinco, según los puntos de vista [David G. OWEN, "The Five elements of Negligence" 35 Hofstra L.R. 1671 (2007)]:

1) y 2) Existencia de un deber de precaución o de cuidado, establecido por la ley, los reglamentos o la jurisprudencia, que desarrolla la ley o que concreta estándares sociales de razonabilidad en cada sector de actividad (*Duty of care*); e infracción de tal deber (*Breach of duty*. En la cultura jurídica alemana se habla parecidamente de *Verkehrspflichten*, "deberes del tráfico" atendidas las circunstancias, de acuerdo con el criterio de un tercero, observador razonable). Si se prefiere, se puede concebir la negligencia como la creación o incrementos irrazonables de un riesgo de causar un daño, pero este punto de vista tiene ventajas (permite cuantificar mejor la gravedad del riesgo generado o incrementado) e inconvenientes (oscurece la doble caracterización del deber y de su infracción).

La idea, escribe Shavell, es "that an injurer is held liable for the accident losses he causes only if he was negligent, that is only if his level of care was less than a level called due care that the courts specify" (*Foundations*, p. 180).

3) Daño, causado a los bienes sobre los cuales el demandante tiene algún derecho de propiedad o similar (*property harm*); o daño causado a su persona: muerte (*wrongful death*, en cuyo caso el demandante no será obviamente la víctima), daño corporal (*bodily injury*), pero también daños morales (*pain and suffering*); también daños puramente económicos (*economic losses*), es decir, no derivados de un daño personal o material, pero solo en algunos casos.

4) y 5) Causalidad naturalística o de hecho (*cause of fact*) y de Derecho o imputación objetiva (*proximate causation, scope of liability*). Relación entre la causa, la conducta precisamente negligente del demandado, y el efecto, el daño sufrido por la víctima. Para la causalidad de hecho, suele seguirse el test de la *condicio sine qua non, But-For test*: de no haber sido por la negligencia del demandado su víctima no habría sufrido el daño causado. Mas, como veremos, el *test* es muy burdo. Los criterios de causalidad jurídica tratan de acotar el alcance infinito de la causalidad de hecho: también muy aproximadamente, requieren que entre la conducta negligente del causante material del daño y el daño mismo la relación de causalidad sea razonablemente próxima: no se condena al bisabuelo por los daños causados por alguno de sus biznietos.

Una buena definición de negligencia se encuentra en el ***§ 3 Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010), del *American Law Institute* (ALI):

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances. Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are the foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm, the foreseeable severity of any harm that may ensue, and the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm".

La regla de la negligencia incentiva precaución adecuada en el agente de la actividad arriesgada, peligrosa, pero ninguna en su víctima potencial (si el daño que puede sufrir es compensable, reparable: muchos no lo son y sus víctimas potenciales tratan por ello de evitar sufrirlos).

La regla de la negligencia simple mira solo al causante potencial de daños, al demandado, no a su víctima potencial, al demandante ni a su conducta. La unilateralidad de la regla de la negligencia, su falta de consideración al comportamiento de la víctima potencial no es, por definición, problema alguno en la causación precisamente unilateral de daños, es decir, en un acontencimiento dañoso tal que la víctima nada pudo hacer por evitar o paliar el daño causado.

Así, un ejemplo posible de negligencia médica (*medical malpractice*) –aunque se discutió en el caso- es el planteado y resuelto por la **STS, 1ª, 1152/2002, de 29 de noviembre**: el cirujano demandado había intervenido quirúrgicamente, en diciembre de 1974, a un hombre de 34 años de edad para extirparle un tumor en su espina dorsal. Durante la operación, el cirujano dejó olvidada una gasa alrededor de la columna lumbar del paciente y, por ello, hubo de intervenirle

de nuevo tres meses más tarde para retirarla. Con posteridad a esta segunda operación, el paciente presentó unas secuelas irreversibles que dieron lugar a su incapacidad permanente y demandó al cirujano una indemnización de 240.000 euros.

Otro caso, esta vez, absolutamente claro, de negligencia unilateral es el que resolvió la **STS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre**, que trataremos al inicio de la sesión 3ª: la víctima, una mujer de edad madura, se había sometido, a principios de año 1984, a una operación de extirpación de un quiste ovárico en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Un tornillo minúsculo (4x3 mm.) se soltó de uno de los aparatos empleados durante la intervención, pero ni el el cirujano ni sus ayudantes se percataron de ello. Años después, la presencia del tornillo en el abdomen de la víctima fue detectada casualmente con ocasión de unas radiografías practicadas a la paciente con motivo de un accidente doméstico. En junio de 1987, operaron de nuevo a la actora para retirarle el tornillo que había acabado por adherirse a su útero, por lo que fue preciso practicarle una histerectomía. La víctima demandó al cirujano de la primera intervención y al Instituto Nacional de Salud (INSALUD) del que dependía. En la demanda solicitaba una indemnización de 60.000 euros, que le fueron concedidas por la primera instancia. La Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo desestimaron el recurso presentado por el INSALUD.

La **STS, 1ª, 340/2011, de 20 de mayo** recoge la doctrina jurisprudencial según la cual la responsabilidad civil del médico es en todo caso por negligencia: el 30.6.2005, Agustina, de 52 años, fue intervenida en la Clínica Clideba (Badajoz) de artrodesis instrumentalizada lumbar L4-L5 con tornillos pediculares y prótesis espaciadora intersomáticas por presentar espondilolistesis L4-L5 estenosis del canal L4-L5 y hernia foraminal L5-S1. Tras dicha intervención, se detectó la existencia de un sangrado abdominal precisándose el traslado de la paciente al Hospital Infanta Cristina, donde se procedió a ligar la arteria hipogástrica y al lavado de la cavidad. El 11.7.2005, Agustina fue reintervenida quirúrgicamente de sigma, pero falleció el 4.8.2005. La causa de la muerte fue el shock séptico inducido por la ligadura de la arteria mesentérica inferior, que, a su vez, había provocado una falta de riego y consiguiente necrosis isquémica del sigma del paciente y posterior sepsis al perforarse el sigma con desalojo de material fecal de la propia paciente.

Gaspar y sus cinco hijos, Maximino, Vicente, Abelardo, Zaira y Daniela (marido e hijos de Agustina) demandaron a Eugenio (neurocirujano), a la Compañía de Seguros Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) y a la Compañía de Seguros Caser Salud, en reclamación de la suma de 525.000 euros.

El JPI nº1 de Badajoz (28.5.2007) estimó en parte la demanda y condenó a la Compañía de Seguros Caser Salud al pago de 46.583,47€ a Gaspar, 7.763,91€ a Daniela y 3.881,95€ al resto de los demandantes.

La AP de Badajoz (Sección 2ª, 16.11.2007) desestimó sendos recursos de apelación interpuestos por Gaspar y sus cinco hijos y la Compañía de Seguros Caser Salud.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los actores:

"La obligación del médico es de medios y no de resultados y estos medios que se deben poner a disposición del paciente se deben valorar no sólo en función de la economía del contrato de prestación de servicios médico-sanitarios sino en razón a los que derivan de esta relación y conoce la paciente, sin que sea posible cuestionar la actuación médico-sanitaria fundándose en la evolución posterior de la misma, lo que se conoce como la prohibición de regreso, para responsabilizar al médico de la materialización de un riesgo excepcional del que había sido previamente informada la paciente, que hacía innecesarios más medios de los que se disponían en esos momentos en una previsión lógica y ponderada de la intervención quirúrgica llevada a cabo." (FD 2º). Además, "[…] la responsabilidad fundada en la Ley de Consumidores y Usuarios no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la *lex artis ad hoc*. Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de

consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios." (FD 3º)

Adelantemos que la regla de responsabilidad por negligencia permite controlar bien la calidad de la actividad, pero no su cantidad, el nivel de la actividad misma. Baste hoy con dejar dicho que la regla de la negligencia solo funciona bien si su contenido captura todas las dimensiones de la precaución (la calidad exigible de la actividad, pero también su nivel o cantidad, por ejemplo). Dicho sea a modo de ejemplo: un cirujano precavido interviene a sus pacientes, de acuerdo con las reglas de la profesión médica, la *lex artis*, pero no trabaja 24 horas seguidas sino que descansa entre operación y operación.

Sobre el concepto económico de negligencia en *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F2d Cr. 1947), el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX, véase el apartado 2.2.3.

2.1.4. La regla de la responsabilidad objetiva

El tercer gran supuesto de responsabilidad civil es la denominada responsabilidad objetiva o por riesgo, que cubre los casos en los cuales el demandado responde por los daños que ha causado simplemente por haberlo hecho aunque no haya habido ningún género de culpa o negligencia –ningún incremento irrazonable de riesgos o ninguna infracción de deberes de cuidado--.

En el derecho comparado de los países tecnológica y económicamente avanzados, el criterio más común en esta materia es que la responsabilidad objetiva requiere una decisión legal que la establezca o una jurisprudencia que la justifique sostenidamente. En el derecho español, la responsabilidad objetiva no es la regla general de defecto de llegada en derecho privado – lo es la responsabilidad por culpa, art. 1902 CC—, pero, por razones históricas asociadas con la pobreza endémica de nuestro país y la influencia del derecho de la expropiación forzosa, es el principio general del cual partió el legislador administrativo al establecer la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, art. 139 L. 30/1992. Sin embargo, el sistema es impracticable –por ejemplo, no se puede aplicar a los casos de responsabilidad por omisión— y en la vida legal cotidiana, las soluciones a las que llega la Sala 3ª del Tribunal Supremo (que parte de un estándar de responsabilidad objetiva) no son muy distintas de aquellas adoptadas por su Sala 1ª (que lo hace de otro de negligencia): dicho en términos aproximados, sería contrario al buen sentido que el paciente de una clínica privada dispusiera de una pretensión por daños culposos mientras que el de un hospital público tuviera una pretensión por responsabilidad objetiva; o que el alumno de una escuela privada estuviera sujeto a un régimen distinto al de una escuela pública. Tiempo habrá de discutir esta cuestión, pero aquí bastará con dejar apuntado que los regímenes de responsabilidad han de establecerse, en su caso, por sectores o tipos de actividad, no por la condición, pública o privada, de quienes la realizan. Con todas las salvedades que correspondan, el principio general es que una actividad que pueden llevar a cabo tanto agentes públicos como privados ha de estar sujeta a un mismo régimen de responsabilidad por daños. A igualdad de actividad corresponde igualdad de estándar de responsabilidad.

De acuerdo con la regla de la responsabilidad objetiva, los agentes sociales responden por todos los daños que causan aunque no hayan incurrido en culpa o negligencia alguna: es responsabilidad por mera causación de daños, por creación de un riesgo que, en el caso, se concreta en un daño sufrido por un tercero.

La responsabilidad objetiva se llama, en inglés, *strict liability*: "injurers must pay for all accidents losses that they cause" (Shavell, *Foundations*, p. 179).Los alemanes hablan de *Gefährdungshaftung,* responsabilidad por riesgo. Y los italianos de *responsabilità per rischio*. En España, algunos autores escriben "responsabilidad objetiva" y otros "responsabilidad por riesgo". En este e-libro se sigue la primera convención.

La regla de la responsabilidad objetiva incentiva a los causantes potenciales de daños a adoptar los niveles requeridos de precaución, pero no incentiva a sus víctimas potenciales a adoptar

ningún género de cuidado (siempre que los daños puedan ser reparados sin demasiados problemas, muchos no pueden serlo: solo se muere una vez, por ejemplo). Asimismo, la responsabilidad objetiva permite controlar no sólo la calidad de la precaución de los agentes de actividad, sino también su nivel mismo de actividad, también la cantidad, por tanto.

En derecho privado español, la responsabilidad objetiva no es la regla general, sino que requiere mandato legal, al menos en principio:

- Accidentes de circulación: Real Decreto Legislativo 8/2004**,** de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

- Administraciones públicas: arts. 139 y ss. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Animales: art. 1905 CC.

- Caza: art. 33.5 Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

- Cosas que se arrojen o caigan de una casa: art. 1910 CC

- Energía nuclear: art. 45 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

- Medio ambiente: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

- Navegación aérea: art. 120 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea

- Productos defectuosos: Art. 1 de la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos; arts. 128 y ss. RDL 1/1007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

- Responsabilidad del propietario por los humos excesivos nocivos para las personas o las propiedades y caída de árboles colocados en sitios de tránsito: art. 1908. 2º y 3º CC.

- Servicios: arts. 147-148 RDL 1/2007

STS, 1ª, 581/2007, de 28 de mayo. Accidente en helicóptero

José Augusto trabajaba como retén de incendios forestales para "TRAGSA", sociedad que había contratado con "HELICSA" los medios aéreos para la campaña 1991-92. El 18.9.1992, a causa de una tormenta, el helicóptero que transportaba a José Augusto se vio afectado por una turbulencia, chocó contra la ladera de una montaña y se incendió. Como consecuencia del accidente, José Augusto resultó herido y sufrió una incapacidad permanente total.

José Augusto demandó a "HELICSA" y a su aseguradora, "Allianz", en solicitud de una indemnización de 135.040,03 €.

El JPI de Purchena (23.9.1998) estimó la demanda. La AP de Almería (Sección 2ª, 31.3.2000) estimó en parte el recurso de apelación de los demandados, condenándoles a pagar 18.030,36 €.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por José Augusto e incrementó el importe de la indemnización a 21.035.42 €. Si bien el accidente aéreo constituyó un caso fortuito, sostuvo el Tribunal, el transportista está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva con limitación del quantum indemnizatorio que no admite moderación alguna por los tribunales (art. 120 Ley de Navegación Aérea).

STS, 1ª, 1243/2007, de 4 de diciembre. Caída de una maceta desde el quinto piso de un edificio

El 21.7.1989, una mujer de 65 años de edad, falleció como consecuencia de ser golpeada en la cabeza por una maceta que, durante un fuerte temporal de viento, cayó desde el quinto piso de un inmueble de Madrid. La propietaria había arrendado el inmueble a Carina y tenía contratado un seguro multirriesgo de comunidades de propietarios con "AGF Unión Fénix, S.A.".

Bernardo, viudo de la fallecida, demandó a Romeo, Luis Enrique y Lourdes, viudo e hijos de la propietaria del piso, "AGF Unión Fénix, S.A." y Carina, arrendataria del piso, y solicitó una indemnización de 90.151,82 €.

El JPI núm. 58 de Madrid (11.7.1997) estimó en parte la demanda, condenó a Carina a pagar 48.080,97 € y absolvió al resto de demandados. La AP de Madrid (Sección 13ª, 12.7.2000) desestimó el recurso de apelación interpuesto por Carina y estimó el de Bernardo en el sentido de condenar a todos los demandados a pagar 60.101,21 €.

El TS estimó los recursos de casación interpuestos por Romeo, Luis Enrique, Lourdes y la aseguradora, a quienes absolvió. La propietaria no incurrió en negligencia por no haber advertido a la inquilina del peligro que representaban las macetas, pues ello supone "(...) la imposición al propietario-arrendador de un exacerbado deber de vigilancia o supervisión en la conducta del inquilino" (FD 2º).

2.2. Tipos de daño/*Types of Harm*

2.2.1. Análisis doctrinal/*Doctrinal Analysis*

En principio, la existencia de un daño actual es condición necesaria de responsabilidad: sin aquel no hay esta. En ausencia de daños actuales, pero ante la probabilidad de causarlos, el demandante puede disponer de acciones negatorias, de cesación y abstención de la actividad amenazante de causar daños (incluso de acciones tendentes a indemnizar al afectado por los costes de los chequeos y pruebas analíticas, periódicas para descartar la contración de la enfermedad), pero no de una acción de daños en sentido estricto. Hay excepciones, pero las veremos más adelante (pérdida de oportunidad, *loss of chance*). El paciente expuesto a una sustancia tóxica o radioactiva que, estadísticamente, sabe que la probabilidad de contraer tal o cual enfermedad ha pasado del 0,0001% al 0,001% no tiene una acción por el 0,001 % de los daños probables.

Ahora bien, qué consecuencias se consideran dañinas es una cuestión de política jurídica –y económica, social, etc.- cuyo alcance depende de la intensidad de los deberes de precaución que se resuelva establecer, de los riesgos que se quieran prevenir.

Un buen punto de partida para abordar esta cuestión es tener en cuenta un núcleo claro de daños sencillos de identificar y, solo luego, el halo de posibles daños que rodea a los primeros, pero que son mucho más difíciles de estimar y probar –mucho más costoso de establecer, mucho más susceptible de error o de engaño sobre su realidad y cuantía-.

Así:

- Los **daños corporales** causados por un trauma externo son fáciles de determinar y suelen estar incluidos sin más en el ámbito de daños resarcibles. En cambio, los daños psicológicos, lo que los angloamericanos denominan *"pain and suffering"* o los alemanes llaman *"Schmerzengeld",* el daño o sufrimiento originados por el dolor de una herida, por la pérdida de un ser querido o por la destrucción de un bien son mucho más difíciles de determinar y, consecuentemente, mucho más fáciles de exagerar. Es normal, pues que la indemnizabilidad de los segundos sea menos fácil de admitir que la de los primeros.

- Los **daños a la propiedad** o a cualquier bien sobre el cual el demandante tenga un derecho subjetivo resultan también fácilmente identificables: una casa se incendia, un automóvil es destruido o gravemente dañado en un accidente. Pero la pérdida puramente económica –

en inglés *"pure economic loss"-,* es decir, la pérdida o reducción de las ventajas económicas a que da normalmente lugar la explotación de un bien, o la prestación de un servicio es mucho más delicuescente y difícil de indemnizar: el demandante no causó ningún daño en mi establecimiento de restauración, pero sufrió un accidente en el túnel que permite acceder al pueblo en el que está situado y, durante todo el tiempo de interrupción del tráfico, el giro y tráfico del establecimiento se redujo considerablemente. En términos técnicos suele definirse el daño puramente económico como aquel que no está asociado a la producción de un daño material o físico, o –si es a las personas- corporal.

Dobbs resume bien el estado de la cuestión para el *common law* norteamericano y Ward Farnworth recoge el concepto más general de pérdida puramente económica:

"Actual damage or injury is a necessary element of tort liability (for negligence). What qualifies as actionable damage is a question of policy largely defined by the duty rules considered in the 5th chapter:

- While **bodily injury** from external trauma is categorically included, liability for mental distress is more hedged, depending on whether it results from an external injury or mere mental processes.

- **Property damage** is widely conceived, embracing any interference which diminishes the value of the object. Purely economic loss, -or loss not resulting neither from propoerty damage,nor from personal injury- however, is actionable only under limited controlled conditions.

  For merely threatened harm, an injunction but no claim for damages will lie. In other words, merely creating a risk of injury is not actionable; injury must have become actual. And, consequently, no cause of action accrues until damage has occurred.

  But what precisely qualifies as damage in cases of bodily injury or property damage, and when does it occur as to start the limitation period running? Asbestosis often remains undiagnosed for many years after exposure, yet the injury is evidently deemed to occur as soon as a lesion would have been discoverable by x-ray (...)"

Restatement of the Law Third, Torts: Liability for Economic Harm (Tentative Draft Tentantive Draft No. 1, April 4, 2011): "Pecuniary loss is pecuniary damage not arising from injury to the plainiff's person or from physical harm to the plaintiff's property".

El análisis doctrinal tradicional del derecho de daños se adecua razonablemente a los accidentes discretos, casuales o negligentes, que afectan a una persona o a un número reducido de ellas y que provocan un resultado instantáneo o evaluable al cabo de algún –poco tiempo-: la destrucción de un bien mueble o inmueble, la causación de la muerte de un peatón, la causación de heridas que sanan al cabo de algún tiempo o que dejan secuelas que pueden evaluarse sin demasiada complejidad.

Pero el análisis tradicional y el derecho mismo de daños funcionan muy limitadamente en los casos de accidentes masivos (*mass torts*), en aquellos en los cuales los daños se manifiestan al cabo de muchos años, acaso de décadas, de exposición de las víctimas a sustancias tóxicas (*toxic torts*) o de la realización de actividades que causan enfermedades óseas, cardiovasculares o de otro tipo (*working place accidents*): en estos casos y en otros semejantes, el derecho regulatorio, el establecimiento de fondos de compensación específicos o, aún mejor, la asunción de los costes de los accidentes y enfermedades por los sistemas generales de la seguridad social pueden constituir una alternativa al derecho de daños, cuyo lugar debe ceñirse al tratamiento de los casos más graves o de los residuales. Al respecto, puede verse Alberto AZAGRA MALO, *La tragedia del amianto y el derecho español*, 1ª ed., Atelier, Barcelona, 2007 y *Daños del amianto: litigación, aseguramiento de riesgos y fondos de compensación*, 1ª ed., Fundación Mapfre – Instituto de Ciencias del Seguro, Madrid, 2011.

2.2.2. Análisis económico del derecho/*Economic Analysis of Law*

El análisis económico del derecho reduce las categorías de daño a dos:

- **Daños patrimoniales o pecuniarios**, es decir, aquellos que afectan a bienes o servicios que pueden ser objeto de tráfico y, por tanto, de valoración en un mercado legal. Por ejemplo: daños causados a un automóvil, a un edificio, o daños que imposibilitan a un profesional desarrollar su actividad profesional durante unos días, semanas, meses o años.

- **Daños no patrimoniales o morales**. Son los que se causan a bienes únicos, insustituibles, o, por decirlo de otro modo, a personas o a bienes que no son objeto de tráfico, ni por tanto de apreciación, en ningún mercado, sea ya porque no existe, sea ya porque la ley no admite su existencia o funcionamiento: hay, efectivamente y como escribe Michael Sandel, bienes que no se pueden comprar (Michael J. SANDEL, ***What Money Can't Buy****: The Moral Limits of Market*, 1st ed., Farrar, Straus and Giroux, 2012): no está bien comprar un esclavo, no se puede vender un amigo a los amigos, no es fácil comprar amor, ni suele parecer razonable comerciar hijos, la lista es potencialmente muy larga pero solo su contenido básico no es polémico, pues hay mucha controversia en sus márgenes, pero esta es una cuestión que solo se puede analizar cumplidamente con conocimiento de causa, más adelante. En todo caso, hace más de un siglo que los ordenamientos de los países de nuestra cultura reconocen que los daños causados a objetos únicos, irremplazables, imposibles de comprar o vender, o muchos de los daños personales –y paradigmáticamente, la muerte en muchos casos (no en todos)—son indemnizables de alguna manera. El problema suele ser cómo, pues ¿cómo valorar la pérdida de un hijo?, ¿cómo indemnizar un daño cuya ocurrencia futura nadie o casi nadie aseguraría?, ¿cómo valorar la destrucción de la única fotografía del padre?, ¿el atropello mortal de nuestra vieja perra de trece años de edad, atrítica, sorda y casi ciega?, ¿cómo el insulto vulgar de quien, disparándose un tiro en el zapato, le chilla a otro ---"¡Eres un auténtico hijo de puta"!—o el del cínico bien leído y exquisitamente educado, que, sonriendo, susurra ---¡"Huérfano, que eres como Jon Snow"! ?

2.3. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime*

En derecho de accidentes y en general, interesa la distinción entre derecho público y derecho privado: el derecho público establece infinidad de regulaciones que establecen, *ex ante*, cuáles son las condiciones de seguridad (precauciones) bajo las cuales puede desarrollarse tal o cual actividad y, *ex post*, las consecuencias de no haber observado las precauciones establecidas, normalmente, una multa pecuniaria, pero también, la suspensión de la actividad, su cese, o, incluso, la imposición de penas en sentido estricto (aplicación del derecho penal). En España, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestra área cultural, los delitos y faltas tipificados en el Código Penal comportan una pena, una sanción específicamente penal, pero además, en el mismo proceso en el cual se ventilan las eventuales responsabilidad penales de los imputados, se resuelve sobre sus responsabilidades estrictamente civiles o aquellas de las personas de quienes dependen.

El derecho penal, el derecho de la responsabilidad penal es primariamente derecho público que tutela intereses públicos: los consistentes en evitar la comisión de delitos y en restablecer la justicia quebrantada por el delincuente. El derecho civil de daños, el derecho de la responsabilidad civil no es incongruente con el anterior, pues también pretende abordar la reducción razonable o la supresión de riesgos que afectan a miembros de la colectividad o a toda ella. Pero ello se consigue, en el caso del derecho civil, con pretensiones puramente civiles ejercitadas normalmente en un proceso civil y queda siempre a la decisión del demandante la relativa al ejercicio de la pretensión de daños. El derecho de daños es privado por dos razones: el demandante elige entre accionar o no hacerlo y la indemnización que, en su caso, obtenga, quedará en su patrimonio, no es ninguna multa que engrose las arcas de la Hacienda Pública.

Sin embargo, ya hemos señalado que un mismo acto puede ser, al mismo tiempo, un delito (o falta) y un supuesto de responsabilidad civil: de derecho, todos los delitos y faltas pueden

general una acción de responsabilidad civil por los daños eventualmente causados, acción que, normalmente, se ejercerá en el proceso penal, pero que los afectados pueden reservarse para ejercitarla en un proceso civil independiente (art. 112 LECr), algo que raramente sucede.

2.4. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract*

En derecho privado interesa la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual o civil (derecho de daños en sentido estricto). En una primera aproximación, la conducta cuya realización implica el incumplimiento de un contrato conlleva la responsabilidad de la parte incumplidora frente a su contraparte, pero no es considerada un supuesto de responsabilidad civil. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de transporte de personas no genera responsabilidad civil aunque, claramente, pueda dar lugar a responsabilidad contractual en los términos previstos por el contrato mismo o la ley. Sin embargo, si, con ocasión del transporte, quien lo realiza, hiere o veja al viajero, este dispondrá de una pretensión específica de responsabilidad civil con independencia de las que puedan derivarse del contrato mismo.

En virtud de lo genéricamente establecido por el art. 1255 CC o, menos formalistamente, en virtud del ingenio precisamente humano, los humanos mismos y las organizaciones creadas por ellos pueden entablar relaciones contractuales muy diversas y con un contenido infinitamente diverso: el incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de una de las partes en un contrato válido da derecho a la otra a llevar a la primera ante un Juez para que este establezca las consecuencias de la infracción según el mismo contrato. Así, los deberes y obligaciones contractuales son creados por el ingenio y promesas de las partes del contrato. En cambio, los deberes derivados del derecho de daños dimanan directamente de la legislación y de los reglamentos aplicables o del derecho judicial, al margen de todo pacto o acuerdo entre las partes.

En el *Common Law,* la responsabilidad contractual es fundamentalmente objetiva, mientras que la responsabilidad civil es mayormente por negligencia. Sin embargo, en el *Civil Law* y, concretamente, en derecho español, la responsabilidad contractual parte de un principio general de negligencia, aunque la cuestión es muy discutida.

En la práctica, la dinámica del derecho de contratos es estrictamente privada: los contratos surgen y se desarrollan de abajo arriba –*bottom-up*—a partir de las soluciones ingeniadas por los abogados de las partes, para cada sector del tráfico económico, ante el desarrollo de la tecnología y la comercialización de nuevos productos y servicios cuyo acceso al mercado y distribución exigen nuevas soluciones contractuales. En cambio, la dinámica del derecho de daños, de responsabilidad civil, es regulatoria –*top-down*- o judicial –*bottom-up*, pero pública. Ello genera diferencias estructurales importantes: el derecho de contratos mira a crear o facilitar rutas comerciales, tráfico económico y solo secundariamente litigación. En cambio, el derecho de daños está centrado en la litigación, pues su énfasis está puesto en la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios en un proceso judicial. La diferencia es tan marcada que, en algunos países, los abogados de contratos y los abogados de litigación se diferencian claramente los unos de los otros.

La **STS, 1ª, 349/2012, de 11 de junio** resuelve la cuestión relativa a si el propietario de una finca que la contamina en el ejercicio de una actividad industrial lícita y que después vende la finca misma responde extracontractualmente frente al tercer adquirente por los daños económicos sufridos.

En palabras del Tribunal Supremo:

"Se trata de decidir si una sociedad mercantil constituida por entes públicos para la regeneración y consiguiente explotación de un puerto deportivo-pesquero y su zona residencial contigua puede repercutir retrospectivamente los costes de la descontaminación a la sociedad mercantil que en tiempos contaminó la zona, y ello pese a haber tenido que cesar esta en su actividad industrial y haber vendido en su día los terrenos a bajo precio debido precisamente a

su contaminación, conocida por todas las entidades que sucesivamente fueron adquiriendo derechos sobre dichos terrenos. Y esta decisión se somete por la actora-recurrente a la jurisdicción civil con base en el Código Civil pero invocando el principio "quien contamina paga" , presente en diversas normas administrativas de protección medioambiental que se consideran aplicables al caso".

Hechos:

Ercros, S.A. "explotaba desde el primer tercio del siglo XIX una fábrica sita en un terreno de su propiedad ubicado en la fachada marítima de Badalona, y destinada a la fabricación de … productos químicos y abonos en general… siendo su actividad la de gran industria".

El 7.5.1987, la Corporación Metropolitana de Barcelona (luego Consell Comarcal Barcelonés) aprobó el Plan Especial de la Fachada Marítima de Barcelona, que contemplaba la ubicación del futuro puerto de Badalona al norte de los mencionados terrenos, y los calificaba como terrenos para pequeña y mediana industria, con la excepción de una zona destinada a uso residencial.

El 14.5.1987, Ercros, S.A. vendió mediante escritura pública a la Corporación una porción de terreno de unos 71.000 m² ubicada en primera línea de mar por 3.906.579 euros (650 millones de ptas.). En ese momento, el precio de mercado del terreno vendido era muy superior, de 5.318.957 euros (885 millones de ptas.). Los terrenos estaban altamente contaminados porque presentaban un elevado contenido de plomo y arsénico.

El 31.7.1987, Ercros cesó su actividad industrial y consta acreditado que, con posterioridad, el lugar fue utilizado como zona de extracción de arenas y vertido incontrolado de residuos de diferentes procedencias

En 1989, Ercros vendió el resto de los terrenos a Prima Inmobiliaria, S.A., que, a su vez, se los vendió mediante escritura pública el 9.5.1990 a Inmobiliaria Industrial Urbana, S.A. y esta, a su vez, se los vendió al ICO en 1994 en pago de deudas.

En 1991, el Ayuntamiento de Badalona decidió ubicar el puerto en los antiguos terrenos de la demanda, pese a ser conocida la contaminación de la zona por los estudios que había iniciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 1990, y dividió la zona en dos polígonos: uno destinado a suelo residencial y el otro a sistema portuario. El Gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de construcción del puerto deportivo de Badalona y otorgó a Marina Badalona, S.A., sociedad participada al 50% por el Consell Comarcal Barcelonés y el Ayuntamiento de Badalona, la concesión para la construcción y explotación del puerto, con asunción, entre otras obligaciones, de descontaminar los terrenos.

En 2001, 2002 y 2003 el Consell Comarcal Barcelonés aportó la porción de terreno que había comprador a Ercros a Marina Badalona, S.A. como aportación no dineraria con ocasión de tres sucesivas ampliaciones de capital realizadas en tales años. Del valor de la finca se descontaron en aquel momento 3.432.981 de euros (571 millones de ptas.) en concepto de gastos de descontaminación.

El 19.12.2002 y por escritura pública, ICO vendió a Marina Badalona, S.A. los terrenos que originariamente habían pertenecido a Ercros haciendo constar que tales terrenos iban a verse afectados por las obras de construcción del puerto de Badalona y que como existía un remanente de contaminación del suelo el coste de la contaminación (valorado en 8.005.481 euros) debía descontarse del precio de la venta de los terrenos, que quedaba en 11.419.230 euros.

Procedimiento:

Marina Badalona, S.A. demandó a Ercros, S.A. y le reclamó el pago de 25.444.530,10 euros por daños y perjuicios asociados a la contaminación de las fincas con base en el art. 1902 CC, pero también en haber cumplido con la obligación de descontaminación que incumbía a Ercros, por lo que invocaban la subrogación, el reembolso la repetición y el enriquecimiento injusto, así como la STSJ de Cataluña núm. 308/2004 de 28.4.2004, que habría impuesto a Ercros la obligación de descontaminación.

El 3.6.1997 la Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña había dirigido a Ercros, S.A. un requerimiento para que en el término de dos meses procediese a la retirada de escombros y residuos y a la realización de un estudio sobre el alcance de la contaminación. Requerimiento que fue reiterado el 26.6.1997 y el 28.11.1997. Ercros presentó un recurso administrativo contra el último requerimiento de la Junta, que fue inadmitido el 11.11.1998. Ercros, a su vez, interpuso un recurso ordinario contra la inadmisión, que el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya desestimó mediante resolución de 31.1.2000. Ercros interpuso recurso contencioso-administrativo esta última resolución y el TSJ de Cataluña en Sentencia de 28.4.2004 lo admitió en el sentido de revocar las decisiones administrativas en cuanto a sus pronunciamientos de inadmisibilidad del recurso y, entrando en el fondo del asunto, desestimó el recurso contra la resolución de la Junta de 28.11.1997:

"[E]l apartado a) del ... artículo 15 [de la Ley 6/1993, de 15 de julio, de residuos de Cataluña] considera como responsable directo de la regeneración de los espacios degradados por descargas incontroladas a la persona que ha efectuado la descarga y solidariamente al productor o el poseedor del residuo, siendo responsable únicamente subsidiario de la misma..., según su apartado b), el propietario de la finca ...o en su caso el titular del dominio público afectado, y constituyendo obligación del productor y del poseedor de los residuos, según el art. 17.1.a), la de garantizar su gestión de acuerdo con sus prescripciones desde luego inmediatamente aplicables a un requerimiento de descontaminación producido bajo su vigencia, y ante una contaminación que se mantuvo en el tiempo tras ella, cualesquiera que fuesen los acuerdos, privados o incluso de carácter o alcance urbanístico, que pudieran haberse alcanzado al momento de la venta de los terrenos" (FD. 5º).

La SJPI nº 27 Barcelona (8.1.2008) estimó en parte la demanda y condenó a Ercros al pago de 8.895.785,28 euros. En apelación, la AP (Sección 16ª) de Barcelona (31.3.2009) estimó el recurso de apelación interpuesto por Ercros, S.A., desestimó el de la demandante, y revocó la SJPI, desestimando la demanda:

"El coste de la descontaminación de un suelo contaminado debe ponerse en relación con el uso urbanístico de ese suelo... [en este sentido, art. 15 Ley 6/1993, en su redacción dada por la Ley 9/1998, y actual art. 19 b Decret Legislatiu *1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus*: "Que les persones causants de la contaminació d'un emplaçament resten obligades a sanejar-lo en funció de l'ús urbanístic que tenia quan el van transmetre. No es poden requerir mesures de sanejament complementàries vinculades als nous usos urbanístics del sòl, llevat que hagin estat promoguts per elles mateixes" (…)

"[L]a reclamación fundada en el art. 1902 producía una sensación de perplejidad porque los daños se habrían causado a una finca propia de la demandada cuando ejercía una actividad industrial que cesó en 1987;... descartada cualquier obligación contractual de Ercros para con Marina, ya que ésta no compró directamente los terrenos a aquella ni funda su demanda en acciones derivadas del contrato de compraventa, tampoco cabía la responsabilidad extracontractual por faltar el elemento de alteridad, como consideró la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 rectificando el criterio de la de 29 de octubre del mismo año...; en último extremo, la acción para exigir responsabilidad civil extracontractual habría prescrito conforme al art. 1968 CC, pues el caso no sería de daños continuados sino permanentes y, además, conocidos desde mucho años antes de la interposición de la demanda, de modo que nada habría impedido... reclamar en su momento por los daños, al margen de una responsabilidad por saneamiento que parece haber sido asumida y resuelta convencionalmente en su momento" (...)

"La demandante no hizo propiamente una regeneración del solar por sustitución de una obligación concreta y exigible a la demandada impuesta por la Administración en interés general, sino que lo que hizo fue urbanizar la zona en propio interés y, ciertamente, ello implicó la descontaminación de la finca" (FD. 2º STS).

Marina Badalona, S.A. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El segundo, por infracción de los arts. 1210 y 1158 CC, arts. 33, 43 y 45 CE y art. 1902 CC, así como por infracción del art. 1968 CC. El TS desestimó ambos recursos y confirmó la SAP:

"[E]ntre los dos referidos criterios opuestos de decisión [el de la STS, 1ª, de 29.10.2008 (RJ 5801), en la que el Tribunal Supremo condenó a Ercros con base en la responsabilidad extracontractual y el de la STS, 1ª, núm. 1135/2008 de 22.12.2008, en la que el Tribunal, en cambio, le absolvió porque los daños fueron causados a una finca propia] esta Sala considera que debe reiterar [el segundo criterio, según el cual] (FD. 4º):

"Cuando se trata de daños originados en la cosa vendida … el daño sufrido por el comprador resulta, en principio, del deficiente cumplimiento o del incumplimiento del contrato de compraventa; la relación de responsabilidad que resulta del cumplimiento o deficiente incumplimiento tiene el mismo alcance subjetivo que el que media, dentro de la órbita contractual, entre el que causa el daño (vendedor) y el que lo recibe (comprador); el ordenamiento jurídico prevé consecuencias específicas para los casos de defectos en la cosa vendida; y, finalmente, los bienes afectados son de carácter patrimonial, en tanto no se demuestre la afectación de bienes o derechos de mayor trascendencia. En suma, los daños originados en la cosa vendida que suponen un menoscabo de su valor o una imposibilidad de dedicarla al uso al que está destinada deben ser reclamados mediante el ejercicio de las acciones contractuales que correspondan, entre las cuales figuran las acciones para pedir el saneamiento de la cosa por vicios o defectos ocultos (acción redhibitoria y *quanti minoris* [de disminución del precio 'en cuanto menos']) o la acción resolutoria dimanante del incumplimiento del contrato cuando la cosa entregada es sustancialmente distinta de aquélla que se pactó como objeto de la compraventa o inhábil para el uso a que se destina (una cosa por otra, o *aliud pro alio*).

Esta reclamación debe ir dirigida contra el vendedor mediante, si procede, la subrogación que a tenor del artículo 1511 CC se opera en favor del comprador respecto de las acciones que corresponden al primero contra los transmisores anteriores…

El hecho de que el comprador no sea el primer adquirente no lo autoriza por sí mismo para el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual contra los anteriores propietarios por los daños que haya sufrido la cosa vendida" (FD. 4º, véase un análisis de las SSTS de 2008 en Sonia RAMOS GONZÁLEZ y Rosa MILÀ RAFEL, "Responsabilidad civil y daños a los propios bienes", InDret 3/2009).

En último extremo, aunque se admitiera una obligación *ex lege* de Ercros, resultaría que esta ya se habría cumplido frente a la demandante, como razona la sentencia impugnada, mediante los sucesivos descuentos del coste de la descontaminación en los negocios jurídicos privados de transmisión de los terrenos" (FD. 5º).

2.5. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida?

Sí, pero quizás sólo por oposición al derecho de la responsabilidad contractual o al derecho sancionador y, desde luego, está mucho menos definido en España que en otros países, señaladamente, que en los Estados Unidos de América.

El derecho de daños tiene una especificidad clara y distinta si se analiza desde el punto de vista del remedio típico que le es paradigmáticamente propio: las acciones de reparación e indemnización de daños. **Los remedios dan unidad al derecho de daños**.

Pero casi nada más lo hace: hoy en día, en un país occidental tecnológicamente avanzado es crecientemente difícil de concebir que una abogada esté especializada, al mismo tiempo, en litigación derivada de difamación, de protección de datos, de daños masivos, de accidentes de circulación, de daños biofarmacéuticos, de prevención de riesgos laborales, de exposición a sustancias tóxicas, etc. La razón es que el derecho de daños descansa sobre regulaciones crecientemente intrincadas y su conocimiento y dominio es, en la práctica, condición necesaria

de la viabilidad de un escrito de demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Nadie domina a la vez el acoso sexual, la difamación, la litigación por inhalación de sustancias tóxicas o los accidentes de aviación. Ya no.

Mas queda, anclado bien en el análisis de los remedios, algún otro punto de apoyo a la idea de la unidad positiva del derecho de daños –es decir, a la idea de que este se define por algo más que por su contraposición al derecho de contratos, al derecho penal y al derecho regulatorio---

Así, y en primer lugar, la cuestión de la culpa, de la negligencia del demandado ocupa un lugar central en casi todos los casos de derecho de daños regidos por el estándar de la culpa misma, como es el supuesto general del derecho del art. 1902 del Código Civil español de 1889.

Más aún, en torno a las cuestiones la causalidad en sentido amplio, que abarcan la causalidad empírica o de hecho (*Cause in Fact*) y causalidad, de derecho, normativa o imputación objetiva (*Proximate Causation, Scope of Liability*), comunes a la responsabilidad por negligencia y a la objetiva.

Luego, la naturaleza esencialmente procesal del ejercicio de las acciones y pretensiones de derecho de daños centran a la responsabilidad civil en torno a su litigación y transacción: a diferencia del derecho de contratos, que es extrajudicial y *ex ante*, el derecho de daños es judicial y *ex post*. En los países con juicio de jurado para la responsabilidad civil, la unidad procesal y profesional del derecho de daños aún es más marcada, pero no es el caso de España.

Finalmente, esencial al derecho de daños, es su dinamismo: el cambio forma parte de su naturaleza. El contrato pretende atar el futuro, el derecho de daños reanudar el pasado.

2.6. ABC de un pleito de daños

Explicación al abogado de los hechos, averiguación y análisis para ver si el cliente tiene pretensiones razonables (si hay una o más *legal issues* razonablemente planteables ante un tribunal); luego análisis de posibilidades de mediación, arbitraje o transacción (*Alternative Dispute Resolution*); redacción de la demanda o de la contestación, audiencia previa, juicio, pruebas, conclusiones, sentencia, apelación...

— Consulta de documentos relativos a un pleito de responsabilidad civil por daños causados por incendio.

a) Escrito de demanda
b) Escrito de contestación a la demanda
c) Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
d) Sentencia de la Audiencia Provincial

Sesión 3ª
Negligencia (I)

3.1. Panorama de la negligencia: la negligencia como infracción de deberes de precaución 33
3.1.1. Negligencia y circunstancias personales del causante 36
3.1.1.1. Edad, minoría de edad, estado de salud 36
3.1.1.2. Edad, salud y responsabilidad civil en el derecho comparado 39
3.1.1.2.a Common Law 40
a) *Daniels v. Evans* (224 A.2d 63 (N.H. 1966)) 40
b) *Purtle v. Shelton* (474 S.W.2d 123 (Ark. 1971)) 41
3.1.1.2.b Civil Law: Francia y Alemania 43
3.1.1.2.c Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbusch (BGB)) 43
3.1.1.3. Víctimas especialmente sensibles. Eggshell Skull Doctrine or The Thin Skull Rule or You take your victim as you find him 43
3.1.1.4. Negligencia y riqueza del causante 44
3.1.1.5. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado (o su ausencia) 44
3.1.1.6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: Sudden emergency doctrine 45

3.1. Panorama de la negligencia: la negligencia como infracción de deberes de precaución

STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre. Responsabilidad civil médica por error de diagnóstico.

El 12.12.1996, Eva se sintió súbitamente enferma, perdió el habla, sintió cosquilleos con adormecimiento y pérdida de la fuerza en el brazo derecho. Acudió al Hospital General de Caranza, donde fue atendida de urgencias por el médico de guardia Pío, quien le diagnosticó una bajada de azúcar, le inyectó glucosa y le dio de alta. Tres días después, Eva volvió a presentar la misma sintomatología y acudió nuevamente al mismo servicio de urgencias, donde fue atendida por el doctor Luis Miguel, quien ordenó su ingreso. En la madrugada del día siguiente, ante la situación de la paciente, el doctor Carlos decidió trasladarla a un nuevo centro hospitalario donde se le pudo realizar un TAC. En el nuevo centro se le diagnosticó un infarto isquémico cerebral. Como consecuencia de ello, Eva quedó con una afasia de tipo motor, problemas en el habla, alexia, agrafía, parálisis espástica de extremidad superior derecha con contractura en flexión de dedos y parálisis espática en la extremidad inferior derecha.

Eva demandó a Pío, a Luis Miguel, a Carlos, al "Hospital General de Caranza Ferrol" y a las compañías de seguros "Compañía de Seguros Aegon" y "Compañía de Seguros Ama Previsión Sanitaria S.L." y solicitó una indemnización de 780.000 euros por los daños y perjuicios sufridos.

EL JPI núm. 6 de Ferrol (16.2.2004) desestimó la demanda. La AP de La Coruña (Sección 5ª, 4.12.2006) desestimó el recurso de apelación.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por la actora y condenó a Pío y a las compañías de seguros (a estas hasta el límite de los seguros concertados) al pago de 235.112,98 euros:

"[A] la relación causal material o fáctica ha de sumarse el reproche causabilístico, sin lo cual no hay responsabilidad sanitaria, como sucede en este caso, si bien solo respecto de la actuación negligente o culposa del Dr. Pío por consecuencia de un error de diagnóstico que desembocó en

el resultado dañoso generador de la responsabilidad, puesto que produjo un tratamiento equivocado, ineficaz y perjudicial para la paciente, que se identifica a partir de la valoración de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento en que los hechos tuvieron lugar y no después, al haberla dado de alta sin haber confirmado o descartado dicha lesión, cuando la sintomatología así lo exigía, sin que ello suponga, por tanto, una regresión a partir del desgraciado curso posterior seguido por la paciente (…)" (FD 2º).

— Encarna ROCA TRIAS/Mónica NAVARO MICHEL, *Derecho de daños*, 6ª edición, 2011, pp. 27-28:

"El retorno a la culpa como criterio de imputación": "el Tribunal Supremo ha vuelto a los criterios de imputación subjetiva" [a la culpa como criterio general por oposición a la responsabilidad objetiva].

— Pablo SALVADOR/Carlos GÓMEZ, "El Derecho de Daños y la Minimización de los Costes de los Accidentes", *InDret* 1/2005 (www.indret.com), pp. 3-6:

"El derecho de daños puede contribuir a reducir los costes de los accidentes por el procedimiento de establecer quién ha de cargar con sus consecuencias. Así, si se asume que el objetivo es minimizar los costes de los accidentes, ello resultará algo sencillo de conseguir en algunos casos, pero de dificultad variable y creciente en otros, como se muestra a continuación:

1. En un primer caso resuelto por la **STS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre**, un cirujano del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, dependiente del Instituto Nacional de Salud (INSALUD), intervino a principios de 1984 a la actora, una mujer mayor, para extirparle un quiste ovárico. Durante la intervención, un minúsculo tornillo (4x3 mm.), de uno de los retractores empleados para separar las paredes abdominales y abrir un campo quirúrgico suficiente para operar, que estaba muy flojo, se soltó y cayó en las entrañas de la paciente. Nadie, ni el cirujano, ni sus ayudantes se percataron de ello. Años después, la presencia del tornillo en el abdomen de la víctima fue detectada casualmente en unas radiografías practicadas con motivo de un accidente doméstico. En junio de 1987, otro cirujano del mismo hospital intervino a la actora para retirarle el tornillo que, tras más de tres años en el interior de la víctima, se había adherido a las paredes del útero y, por ello, hubo que practicarle una histerectomía (extirpación total o parcial del útero). La víctima demandó a ambos cirujanos y al INSALUD y solicitó una indemnización de 60.000 euros. El JPI estimó en parte la demanda: condenó al INSALUD y absolvió a los facultativos. La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo. La responsabilidad se imputa a quien hubiera podido evitarlo más fácilmente: "se exime de responsabilidad a los facultativos intervinientes, por haberse ajustado a la 'lex artis ad hoc' […y] se le imputa la responsabilidad al ente recurrente [INSALUD] por lo que respecta al material preciso para la intervención, que el mismo no había sido conservado con la exquisita atención o diligencia; cometido este, que incumbe al ente recurrente" (FD 2º).

Cinco años después, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en **STS, 1ª, 1152/2002, de 29 de noviembre**, resolvió un caso muy similar. En esta ocasión, el cirujano demandado intervenía en noviembre de 1974 a un hombre de 34 años de edad para extirparle un tumor en la espina dorsal. Durante la operación, el facultativo dejó olvidada una gasa alrededor de la columna lumbar del paciente y, por ello, hubo de intervenirlo de nuevo tres meses más tarde. Con posterioridad a esta segunda operación, el paciente presentó unas secuelas irreversibles que dieron lugar a su incapacidad permanente absoluta. El actor demandó al cirujano y solicitó 240.404,84 euros. El JPI y la AP desestimaron la demanda al entender que no había prueba suficiente del nexo causal entre la gasa olvidada y la incapacidad. El Tribunal Supremo casó la sentencia absolutoria de la Audiencia y dictó nueva sentencia en virtud de la cual aplicó la doctrina del daño desproporcionado en la responsabilidad civil médica y condenó al cirujano a abonar una indemnización por daño moral de 120.000 euros. El Tribunal omite las razones para cuantificar la indemnización en la mitad de lo solicitado.

Ambos son casos claros de negligencia unilateral, es decir, supuestos en los cuales la víctima nada podía haber hecho para evitar el daño que finalmente sufrió, cuando, además, queda bien a las claras que los demandados podían haber adoptado más y mejores precauciones.

El caso siguiente plantea más dificultades tanto a la hora de identificar a los responsables de los daños sufridos por la víctima como a la de concretar las medidas que podrían haberse adoptado para evitarlos:

2. Una mañana del mes de marzo de 1992, la víctima esperaba la llegada del Metro en la estación de la calle Rocafort de Barcelona. El convoy llegó, abrió las puertas y la abigarrada muchedumbre que esperaba en el andén se abalanzó hacia el interior de los vagones. Empujada por el resto de viajeros, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones de gravedad por las que reclamó un total de 37.743,55 euros a la entidad "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA" gestora del servicio público de transporte por metro en la ciudad de Barcelona cuando de produjo el accidente. La Audiencia Provincial estimó el recurso de la víctima contra la sentencia desestimatoria de la demanda de la primera instancia y concedió una indemnización de 28.518,02 euros con cargo a la entidad demandada. La **STS, 1ª, 1121/2001, de 3 de diciembre**, que puso fin al proceso, desoyó los argumentos de "Ferrocarril Metropolità" y convalidó la condena decidida por la Audiencia de Barcelona.

El tercer caso que presentamos a continuación manifiesta aún más palmariamente las dificultades de atribuir responsabilidad al titular de una organización por los daños causados por un tercero ajeno al ámbito de influencia de la organización misma:

3. En la madrugada del 6 de mayo de 1990, la Sra. Ángela M.R. entró en una de las oficinas de la entidad bancaria demandada para retirar dinero de un cajero automático. En nuestro país, algunas oficinas de bancos y cajas disponen de cajeros a pie de calle, pero es más frecuente que tras la puerta de entrada de la oficina, haya un primer espacio en el que están instalados uno o varios cajeros automáticos, que pueden ser usados, por lo general, las 24 horas del día. La puerta de acceso a este local puede cerrarse con un pestillo. Durante las horas de oficina, los clientes pueden superar este espacio y entrar donde se encuentran los empleados que ofrecen los servicios bancarios de que se trate. En el asunto, el pestillo de la puerta estaba roto y un atracador, que estaba al acecho, entró en el local cuando la víctima ya había tecleado el número secreto de su tarjeta de crédito. Forcejearon, el atracador sacó una navaja con la que hirió a la actora en su mano izquierda y le robó la cantidad retirada. La víctima reclamó 90.152 euros a la entidad bancaria titular del cajero automático. En primera instancia, su demanda fue estimada en parte, pero la entidad demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda. El Tribunal Supremo, en **STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril**, desestimó el recurso de la víctima: "[…] no puede afirmarse que las lesiones sufridas por la recurrente al ser asaltada por un desconocido, sean una consecuencia […] del estado en que e encontraba el cerrojo instalado en la puerta de acceso al cajero automático y que impedía cerrar la puerta desde el interior, sino que tales lesiones son imputables exclusivamente, en una relación de causa a efecto, a la violencia ejercida sobre la actora por el tercero desconocido que la atacó" (FD 2º).

En ocasiones, quien causa el accidente es su víctima. En otras, el responsable nada tuvo que ver con el accidente que motiva finalmente su responsabilidad. En unas terceras, la víctima carga con las consecuencias del daño que sufre. La imputación de daños no depende siempre del relato causal. Así lo confirman los dos casos siguientes.

4. La **STS, 1ª, 2034/1997, de 31 de diciembre** condenó a la Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE) por la muerte de dos menores de edad quienes, durante las fiestas mayores del pueblo de Manzanares (Madrid), jugaban con sus compañeros a ver quién aguantaba más sobre la vía del tren cuando se acercaba la locomotora. RENFE había denunciado varias veces los hechos al Ayuntamiento de Manzanares que había ordenado vigilar la zona durante unas horas al día. Fuera de ellas, grupos de muchachos volvían a la vía para hablar, reír, beber y jugarse la vida. El día 21 de julio de 1990, Miguel Ángel C. y José Gabriel P., ambos de quince años, estaban de pie sobre las vías, con 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre el primero, cuando un Tren Expreso que circulaba a 130 km/h., les arrolló. Ambos murieron en el acto. Los padres de las víctimas reclamaron una indemnización de 150.253 euros al Ayuntamiento de Manzanares, a RENFE y al maquinista del tren. Las instancias condenaron únicamente a RENFE y al Ayuntamiento a pagar 36.061 euros a cada uno de los demandantes. El Tribunal Supremo

desestimó el recurso de casación interpuesto por la compañía ferroviaria. La actividad de los jóvenes, en absoluto justificable, era conocida y debían haberse adoptado todas las medidas necesarias, incluso la detención del convoy a su paso por el pueblo, para evitar daños como los que sucedieron.

5. El demandante en el proceso que resolvió la **STS, 1ª, de 10 de octubre de 1998** era un trabajador de una empresa de productos congelados a quien una máquina termoselladora le amputó la mano derecha. Inmediatamente después del accidente, la enfermera de la empresa acudió al lugar de los hechos para atender al trabajador, cortó la hemorragia e instruyó a un compañero del trabajador para que envolviera la mano traumáticamente amputada en hielo natural. Mientras esperaban a la ambulancia, el compañero de la víctima metió la mano amputada en una caja de *porexpan* llena de dióxido de carbono sólido, comúnmente conocido como hielo seco, de las que utilizaban para el transporte de productos congelados, pues creía que procuraría una mejor conservación de la mano. Cuando la víctima fue ingresada en el centro sanitario los tejidos de la mano amputada estaban destruidos por congelación y no fue posible practicar el implante. El trabajador quedó manco de por vida y demanda a la empresa y a la enfermera de la misma por no haber comprobado cómo se trasladó la mano amputada al hospital. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la concesión de 120.202 € que el demandante reclama, pero el Tribunal Supremo condenó a la enfermera a pagar una indemnización de 9.015 euros. La enfermera no fue del todo diligente y debía responder por la pérdida de las expectativas de reimplantar el miembro amputado.

6. En el caso resuelto por la **STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre**, un joven de 21 años practicaba descenso por aguas bravas en el río Gállego al cruzar un desfiladero de especial dificultad, el "Paso del Embudo" en el término municipal de Murillo (Zaragoza), cayó de la balsa neumática, se golpeó la cabeza con una roca y falleció en el acto. Poco después, el padre de la víctima demandó a la asociación organizadora de la actividad deportiva, a la compañía aseguradora y al monitor que había dirigido la actividad. Por el hecho se siguieron diligencias penales posteriormente archivadas. En el pleito civil, las sentencias de las instancias desestimaron la demanda. Igual suerte corrió el demandante en casación".

3.1.1. Negligencia y circunstancias personales del causante

3.1.1.1. Edad, minoría de edad, estado de salud

El criterio comúnmente adoptado por la mejor doctrina es que los niños de muy corta edad (los menores de 7 años aproximadamente) son inimputables –por ellos responden sus padres o guardadores ex art. 1903 CC-; es más, si el menor carece de capacidad natural –un niño de tres años de edad, por ejemplo-, no hay acción, no hay agencia social. Si el menor tiene capacidad natural –y patrimonio con el que responder-, entonces puede efectivamente ser condenado a indemnizar por los daños causados. Mas, en el derecho positivo, la cuestión solo ha sido regulada por el Código Penal, arts. 19, 118.1 y 120.1 CP y 3 y 61 y ss. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En particular, la LO 5/2000 considera penal y civilmente responsables a los menores de edad desde que cumplen los catorce años (arts. 1.1 y 61.3 LO 5/2000). Además, la doctrina mayoritaria admite la aplicabilidad del art. 1902 CC al menor civilmente imputable (Esther GÓMEZ CALLE (2006), "Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno", en L. Fernando Reglero Campos (Coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, pp. 461-538, 480).

El derecho comparado de países próximos a nuestra cultura ofrece soluciones similares, pero discrepantes en el detalle de la regulación propuesta.

La jurisprudencia de la Sala 1ª del TS tiende a juzgar la conducta de los menores con edades comprendidas entre 7 y 15 años en términos de negligencia, pero el estándar de diligencia exigible es más leve que el de los adultos. Hay que tener en cuenta también que, si bien los tribunales tienden a excusar travesuras y avatares de los juegos propios de la infancia, no hacen lo mismo con la conducta claramente despreciativa de peligros que todo niño de su edad

debería prever, y tampoco la conducta antijurídica: los terceros no tienen por qué anticipar y prevenir el daño conexo a un acto voluntario, arriesgado y a veces incluso ilícito cometido en vísperas de la pubertad (Josep FERRER I RIBA y Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, "Niños y adolescentes", *InDret* 1/2000, pp. 7 y ss.)

Responsabilidad civil de menores en derecho español

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 118.1.1:

1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:

1. En los casos de los números 1 y 3, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.

Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

Artículo 120. Responsables civiles subsidiarios

Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:
1º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. (…)

STS, 2ª, 619/2005, de 11 de mayo

El 8.7.2002 en Medina de Pomar (Burgos), sobre las 17:30 horas, Rodrigo, nacido el 31.7.1983 (19 años), con una dotación intelectual inferior al promedio (entre la normalidad y el retraso mental leve) y educado en un contexto familiar desestructurado (abandono de la madre a los cuatro años de edad, y padre alcohólico), tras comprar en una tienda un cuchillo de unos 11 cms. de hoja, entró en la Óptica Medina Centro, sita en la misma calle que el primer establecimiento. Esperó a que la dependienta, Soledad, atendiese a otro cliente y, cuando se encontraban solos en la óptica, le solicitó que le graduase la vista, Rodrigo y Soledad entraron al gabinete habilitado al efecto y, después de realizada tal operación, Soledad se levantó para rellenar el correspondiente impreso, mientras el joven permanecía sentado. Rodrigo, entonces, clavó el cuchillo que portaba consigo en la zona abdominal de Soledad, causándole graves lesiones que tardaron 235 días en sanar y secuelas consistentes en cicatriz queloidea de 17 cms. de longitud y 1 cm. de anchura en la línea media abdominal, cicatriz de 2 cms. en hipocondrio izquierdo y síndrome de estrés postraumático. El día en que ocurrieron los hechos Rodrigo había obtenido una autorización de salida de la Residencia en la que se encontraba ingresado (Residencia Los Robles de Villasante de Montija). No consta que el titular de dicha residencia, Hogadema, S.A. (que tenía contratado el seguro de responsabilidad civil con Mapfre Industrial, S.A.), hubiera adoptado medida alguna para evitar los hechos.

La SAP Burgos, Secc. 1ª, 7.5.2004, condenó al acusado Rodrigo como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasiva durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximación a la víctima a una distancia inferior de 200 metros y de comunicarse en cualquier forma con ella durante cinco años. También condenó a Rodrigo a indemnizar a Soledad con 30.680 € por lesiones y con 20.000 euros por secuelas. De dichas cantidades había de responder directamente Mapfre Industrial, S.A., en solidaridad con Hogadema, S.A.

La STS, 2ª, 11.5.2005, estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por Hogadema, S.A. de manera que redujo la responsabilidad civil de esta entidad de solidaria a subsidiaria, ya que el TS consideró aplicable el art. 120.1 CP "al Organismo que tenía bajo su guarda y tutela a quien cometió un hecho delictivo por concurrir un cierto nivel de negligencia que guarda con el delito cometido una relación de causa/efecto". Y añadió que "en la sentencia de esta Sala 1527/2001, de 21 de julio, se declara que un requisito esencial de la responsabilidad civil subsidiaria es la existencia de una relación de causalidad –a la que se refiere claramente la expresión legal «siempre que haya mediado»– entre la culpa o negligencia de quienes tengan al exento de responsabilidad criminal –total o parcialmente– bajo su potestad o guarda y la comisión por aquél de un hecho punible (…); exclusión [de la responsabilidad del centro psiquiátrico] que no puede afirmarse en el presente caso (…) ya que no se produjo una cesión temporal de la guarda de hecho a favor de la familia o de tercera persona a quien le incumbiera la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación de Rodrigo, sino que se mantuvo la guarda de hecho por parte de Hogadema, S.A. durante las salidas autorizadas por su Dirección" (FD 2º).

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores

Artículo 1. Declaración general

1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España.

Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Título VIII
De la responsabilidad civil

Artículo 61. Reglas generales

1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.

Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil

La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.

STS, 1ª, 205/2002, de 8 de marzo

Patricia G.N., de 16 años, perdió la visión casi total del ojo derecho al sufrir un balonazo en la cara, lanzado por Mariano M.Q., de 17 años, que jugaba al fútbol con unos amigos, mientras estaba sentada en un banco del jardín municipal del Paseo de la Playa de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Georgina N.M., en nombre de su hija Patricia G.N., demandó a Mariano M.Q., a sus padres (Eusebio M.S. y Dulce Nombre Q.Z.) y al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y solicitó una indemnización de 90.151,81 euros.

El JPI nº 3 de Chiclana de la Frontera (29.12.1995) desestimó la demanda. La AP de Cádiz (Sección 5ª, 10.7.1996) estimó parcialmente el recurso de casación y condenó a Mariano M.Q. y a sus padres a satisfacer a la actora una indemnización de 60.101,21 euros.

El TS desestimó el recurso de casación y confirmó la SAP. No es necesario acudir a criterios de responsabilidad por riesgo para fundamentar la responsabilidad del menor. Basta analizar la imputación subjetiva del daño: la edad (17 años, 7 meses y 22 días) y los factores psicológicos del menor indican que podía haber previsto que jugando con un balón de cuero ligeramente deshinchado en un lugar inidóneo se podían causar daños a terceros ajenos al juego. La responsabilidad de los padres tiene su fundamento en la presunción de culpa contenida en el art. 1903 CC.

3.1.1.2. Edad, salud y responsabilidad civil en el derecho comparado

3.1.1.2.a Common Law

a) *Daniels v. Evans* (224 A.2d 63 (N.H. 1966))

[Plaintiff's decedent, a 19-year-old youth, was killed when his motorcycle collided with defendant's automobile. A trial by jury resulted in a verdict for plaintiff, and the only alleged error argued on appeal was the trial court's charge pertaining to the standard of care required of the decedent].

LAMPRON, J. As to the standard of care to be applied to the conduct of the decedent Robert E. Daniels, 19 years of age, the Trial Court charged the jury in part as follows:

"Now, he is considered a minor, being under the age of twenty-one, and a minor child must exercise the care of the average child of his or her age, experience and stage of mental development. In other words, he is not held to the same degree of care as an adult."

Concededly these instructions substantially reflect the rule by which the care of a minor has been judged heretofore in the courts of our state. However an examination of the cases will reveal that in most the minors therein were engaged in activities appropriate to their age, experience and wisdom. These included being a pedestrian, riding a bicycle, riding a horse [and] coasting.

We agree that minors are entitled to be judged by standards commensurate with their age, experience, and wisdom when engaged in activities appropriate to their age, experience, and wisdom. Hence when children are walking, running, playing with toys, throwing balls, operating bicycles, sliding or engaging in other childhood activities their conduct should be judged by the rule of what is reasonable conduct under the circumstances among which are the age, experience, and stage of mental development of the minor involved.

However, the question is raised by the defendant in this case whether the standard of care applied to minors in such cases should prevail when the minor is engaged in activities normally undertaken by adults. In other words, when a minor undertakes an adult activity which can result in grave danger to others and to the minor himself if the care used in the course of the activity drops below that care which the reasonable and prudent adult would use, the defendant maintains that the minor's conduct in that instance, should meet the same standards as that of an adult.

Many recent cases have held that "when a minor assumes responsibility for the operation of so potentially dangerous an instrument as an automobile, he should . . . assume responsibility for its careful and safe operation in the light of adult standards." The rule has been recognized in Restatement (Second), Torts and in Prosser, Torts. In an annotation in [the] A.L.R. it is said that recent decisions "hold that when a minor engages in such activities as the operation of an automobile or similar power driven device, he forfeits his rights to have the reasonableness of his conduct measured by a standard commensurate with his age and is thenceforth held to the same standard as all other persons."

One of the reasons for such a rule has been stated thusly in Dellwo v. Pearson: "To give legal sanction to the operation of automobiles by teen-agers with less than ordinary care for the safety of others is impractical today, to say the least. We may take judicial notice of the hazards of automobile traffic, the frequency of accidents, the often catastrophic results of accidents, and the fact that immature individuals are no less prone to accidents than adults. . . . [I]t would be unfair to the public to permit a minor in the operation of a motor vehicle to observe any other standards of care and conduct than those expected of all others. A person observing children at play . . . may anticipate conduct that does not reach an adult standard of care or prudence. However, one cannot know whether the operator of an approaching automobile . . . is a minor or an adult, and usually cannot protect himself against youthful imprudence even if warned." [...]

RSA 262, which establishes rules of the road for the operation of motor vehicles on our highways, reads as follows: "Required obedience to traffic laws. It is unlawful and . . . a

misdemeanor for any person to do any act forbidden or fail to perform any act required in this chapter." (Emphasis supplied). This is some indication of an intent on the part of our Legislature that all drivers must, and have the right to expect that others using the highways, regardless of their age and experience, will, obey the traffic laws and thus exercise the adult standard of ordinary care […].

The rule charged by the Trial Court pertaining to the standard of care to be applied by the jury to the conduct of the minor plaintiff Robert E. Daniels in the operation of the motorcycle was proper in "the bygone days" when children were using relatively innocent contrivances. See A.L.R.. However in the circumstances of today's modern life, where vehicles moved by powerful motors are readily available and used by many minors, we question the propriety of a rule which would allow such vehicles to be operated to the hazard of the public, and to the driver himself, with less than the degree of care required of an adult.

We are of the opinion that to apply to minors a more lenient standard in the operation of motor vehicles, whether an automobile or a motorcycle, than that applied to adults is unrealistic, contrary to the expressed legislative policy, and inimical to public safety. Furthermore when a minor is operating a motor vehicle there is no reason for making a distinction based on whether he is charged with primary negligence, contributory negligence, or a causal violation of a statute and we so hold.

We hold therefore that a minor operating a motor vehicle, whether an automobile or a motorcycle, must be judged by the same standard of care as an adult and the defendant's objection to the Trial Court's charge applying a different standard to the conduct of plaintiff's intestate was valid.

Exception sustained.

b) *Purtle v. Shelton* (474 S.W.2d 123 (Ark. 1971))

GEORGE ROSE SMITH, Justice.

This is an action for personal injuries suffered by Jerry Purtle, a sixteen-year-old minor, in a hunting accident during the 1969 deer hunting season. The defendants are Kenneth Shelton and his son, Kenneth, Jr., who was seventeen at the time of the accident. The jury attributed half the negligence to Jerry Purtle and half to young Shelton; so there was no recovery. For reversal the appellant, Jerry's father and next friend, contends that the trial court erred in its instructions defining the standard of care to be observed by a minor while hunting deer with a high-powered rifle.

There were some conflicts in the testimony, but the salient facts are not really in dispute. Jerry and young Kenneth had spent the night at the home of L. D. McMullen, who owned a deer camp in Union county. Early the next morning, before daylight, McMullen took the two youths (and a third lad not involved in the case) to the area where they were to hunt. Kenneth's deer stand was next to the road, but Jerry had to walk a short distance through the woods to his stand. MaMullen had cautioned both boys to make their presence known when they were walking in the woods and not to shoot at anything without knowing it to be a deer.

Jerry failed to find his stand immediately and actually walked toward Kenneth's stand, without making his presence known. Kenneth thought he saw a deer and fired at it with his 30.06 rifle. The soft projectile apparently hit a tree, broke into shrapnel, and ricocheted toward Jerry, causing serious injuries to both his eyes.

The trial court submitted the case to the jury upon the theory that Kenneth was required to use that degree of care which a 17-year-old minor would use in the same circumstances. […]

We are unable to find any authority holding that a minor should be held to an adult standard of care merely because he engages in a dangerous activity. There is always the parallel

requirement that the activity be one that is normally engaged in only by adults. So formulated, the rule is logical and sound, for when a youth is old enough to engage in adult activity there are strong policy reasons for holding him to an adult standard of care. In that situation there should be no magic in the attainment of the twenty-first birthday.

We have no doubt that deer hunting is a dangerous sport. We cannot say, however, either on the basis of the record before us or on the basis of common knowledge, that deer hunting is an activity normally engaged in by adults only. To the contrary, all the indications are the other way. A child may lawfully hunt without a hunting license at any age under sixteen. We know, from common knowledge, that youngsters only six or eight years old frequently use .22 caliber rifles and other lethal firearms to hunt rabbits, birds, and other small game. We cannot conscientiously declare, without proof and on the basis of mere judicial notice, that only adults normally go deer hunting.

In refusing to apply an adult standard of care to a minor engaged in hunting deer, we do not imply that a statute to that effect would be unwise. Indeed, we express no opinion upon that question. As judges, we cannot lay down a rule with the precision and inflexibility of a statute drafted by the legislature. If we should declare that a minor hunting deer with a high-powered rifle must in all instances be held to an adult standard of care, we must be prepared to explain why the same rule should not apply to a minor hunting deer with a shotgun, to a minor hunting rabbits with a high-powered rifle, to a twelve-year-old shooting crows with a .22, and so on down to the six-year-old shooting at tin cans with an air rifle. Not to mention other dangerous activities, such as the swinging of a baseball bat, the explosion of firecrackers, or the operation of an electric train. All we mean to say in this case is that we are unwilling to lay down a brand-new rule of law, without precedent and without any logical or practical means of even surmising where the stopping point of the new rule might ultimately be reached. […]

Affirmed.[…]

BYRD, Justice (dissenting).

"Because a bullet fired from the gun by a minor is just as deadly as a bullet fired by an adult, I'm at a loss to understand why one with 'buck fever' because of his *532 minority is entitled to exercise any less care than any one else deer hunting. One killed by a bullet so fired would be just as dead in one instance as the other and without any more warning.

For the reasons stated, I respectfully dissent".

§ 10 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010): **Children**

"(a) A child´s conduct is negligent if it does not conform to that of a reasonable person of the same age, intelligence, and experience, except as provided by section (b) or (c).

(b) A child less than five years of age is incapable of negligence.

(c) The special rule in Subsection (a) does not apply when the child is engaging in a dangerous activity that is characteristically undertaken by adults."

§ 11 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010)**: Disability**

(a) The conduct of an actor with a physical disability is negligent only if the conduct does not conform to that of a reasonable careful person with the same disability.

(b) The conduct of an actor during a period of sudden incapacitation or loss of consciousness resulting form physical illness is negligent only if the sudden incapacitation or loss of consciousness was reasonably foreseeable for the actor.

(c) An actor´s mental or emotional disability is not considered in determining whether conduct is negligent, unless the actor is a child.

3.1.1.2.b Civil Law: Francia y Alemania

Francia : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Article 3

"Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi".

3.1.1.2.c Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbusch (BGB))

§ 828 Minderjährige

"(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern Seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat".

3.1.1.3. Víctimas especialmente sensibles. Eggshell Skull Doctrine or The Thin Skull Rule or You take your victim as you find him

¿Debe el demandado atender a las circunstancias personales de la víctima que la sitúan en una posición de extrema vulnerabilidad y que, a menudo, no son aparentes? La respuesta es afirmativa en todos aquellos casos o circunstancias en los cuales el demandado había de contar con la posible presencia de víctimas potenciales especialmente frágiles, por ejemplo, en las calles y plazas de la ciudad, en general, en los escenarios habituales de la vida cotidiana. La razón es sencilla de entender: si para medir la intensidad del deber de precaución no se tuviera en cuenta al 5% o al 10% o al 15% de población más frágil, los incentivos para comportarse adecuadamente serían subóptimos.

En cambio, en espacios o, en general, en ocasiones en las cuales el demandado puede contar con que aquellas personas con las cuales va a interactuar son homogéneamente sanas y fuertes, sus deberes de precaución no incluirán la consideración hacia aquellas que precisen de una

protección especial salvo que su indefensión resulte aparente a ojos de un observador razonable. El ejemplo clásico es la práctica de un deporte de equipo y de contacto en un espacio cerrado, un estadio o un campo de deporte.

Los casos de la ley suelen seguir esta línea de razonamientos:

"One rule of the tort law … is that the defendant takes his victim as he finds him. In Smith v. Brain Leech & Co. Ltd (1962) 2 Q.B. 405, plaintiff's deceased was burned on his lip by splashing molten metal because defendant negligently failed to provide an adequate guard. Because of prior exposures of another kind in the past, deceased had (according to the court) developed a tendency toward cancer. In any event, the burned lip did develop a cancer from which he died. The court acknowledged that death by cancer was unforeseeable…" (EPSTEIN, Cases and Materials on Torts, 9th ed., p. 542).

3.1.1.4. Negligencia y riqueza del causante

¿Deben de tenerse en cuenta los medios de que dispone el demandado, su riqueza en términos económicos, culturales, biológicos? La respuesta es negativa en el caso de la riqueza económica, pero como veremos en seguida, hay muchas formas de riqueza que no son estricta y directamente mente económicos, aunque admitan valoración, al menos parcial, en tales términos:

— *Denver & Rio Grande R.R. v. Peterson* (69 P. 578 (Colo. 1902))

"CAMPBELL, C.J. The care required of a warehouseman is the same, whether he is rich or poor. For, if the fact that he is rich requires of him greater care than if he possessed only moderate means or is poor, then, if he were extremely poor, the care required might be such as practically to amount to nothing; and no one would claim that such an uncertain and sliding rule should be the measure of his liability…"

3.1.1.5. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado (o su ausencia)

El punto de partida en la responsabilidad profesional es que el demandado responde por el incumplimiento del cuerpo de reglas propias de su profesión, arte u oficio: la *lex artis*. ¿Pero responden más intensamente los mejores, en cada profesión, oficio o práctica o lo hacen de acuerdo con las reglas generales del arte, con la media de su profesión? ¿Está penalizado ser de los mejores? La respuesta suele ser que quien dispone de conocimientos especiales ha de actuar desde luego de acuerdo con las reglas propias del cuerpo de conocimientos correspondientes, es decir, más prudentemente que el lego. En cambio, dentro de la profesión u oficio, la respuesta es que la pericia extraordinaria del demandado es una de las circunstancias de que delimitan sus deberes de cuidado, pero no la única de ellas. En todo caso, quien carece de las habilidades propias de un especialista, no ya porque sea lego, sino porque, siendo profesional, dispone solo de los conocimientos generales de su oficio, ha de abstenerse de ejercer una especialidad para cuyo ejercicio no está preparado suficientemente.

§ 12 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010):

"If an actor has skills or knowledge that exceed those possessed by most others, these skills or knowledge are circumstances to be taken into account in determining whether the actor has behaved as a reasonably careful person."

- When the actor is one of a limited number of parties that engage in an activity that poses distinctive and significant dangers [electric-power company].

- When the actor that possesses an above-average knowledge has a pre-existing relationship with the other party. [STS, 1ª, 836/2004, de 22 de julio]

- Substandard judgment is usually ignored. Learners and beginners.

- Intoxication. The foreseeability test: voluntary intoxication is ignored. Iced tea spiked with liquour.

En tal sentido, puede verse la **STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre**, ya tratada *supra* (véase epígrafe 3.1): "Faltaron en el caso los conocimientos médicos necesarios para hacer posible el diagnóstico que hubiera prevenido o evitado la obstrucción completa de la arteria carótida a partir de una previa sintomatología neurológica que no fue detectada por el médico de guardia, como "sin duda" lo habría hecho el perito, lo que a la postre no viene sino a indicar que cualquier otro médico con una base mínima de conocimientos para estos supuestos o supliendo sus carencias mediante un consejo médico complementario, habría detectado de inmediato la razón de su ingreso y le hubiera proporcionado con la urgencia y diligencia necesaria todos los medios curativos de que disponía" (FD. 2º).

STS, 1ª, 798/2009, de 9 de octubre (en el mismo sentido, STS, 1ª, 815/2010, de 15 de diciembre). Comentada por Marian GILI SALDAÑA e Ignacio MARÍN GARCÍA (2009), "Sentencia de 9 de octubre de 2008 (RJ 2008, 6042)", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,* núm. 80, pp. 751-778. Fin de protección de la norma y ausencia de responsabilidad de auditores.

Desde 1993, "XM Patrimonios Agencia de Valores, S.A." creó la apariencia de que compraba valores por cuenta de clientes cuando, en realidad, desviaba los fondos que recibía a otras sociedades. "Price Waterhouse Auditores, S.A." auditó las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios de 1993 y 1994. Las auditorías, que fueron realizadas efectivamente por Iván, no contenían salvedad alguna y expresaban la opinión de que las cuentas de la sociedad auditada reflejaban la imagen fiel de su patrimonio.

"Lepanto Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", Luis Enrique, "Penedés, S.A." y "Alto Penedés, S.A." demandan a "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván, y solicitan una indemnización de 8.961.322,55 € para "Lepanto"; 1.526.244,80 € para Luís Enrique; 846.379,26 € para "Penedés, S.A.", y 65.599,71 € para "Alto Penedés, S.A.".

El JPI nº 24 de Barcelona (21.10.1998) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 31.7.2000) estimó íntegramente el recurso de apelación y condenó a los demandados a pagar 8.961.322,55 € a "Lepanto", 1.526.244,80 € a Luís Enrique, 846.379,26 € a "Penedés, S.A." y 65.599,71 € a "Alto Penedés, S.A.".

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván y revoca la SAP y dictó una nueva sentencia. El hecho de que la CNMV no hubiera actuado a tiempo para impedir las inversiones efectuadas por los demandantes es una causa extraña al ámbito de protección de la norma a cuya infracción se vincula la responsabilidad del auditor (art. 11 Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas – ahora art. 22 RDL 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas), pues la finalidad de esta norma es permitir que tanto la sociedad auditada como los terceros pudieran conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versaba la opinión emitida por el auditor de cuentas.

3.1.1.6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: **Sudden emergency doctrine**

Una emergencia es, dice el DRAE, una "situación de peligro que requiere una acción inmediata" (3ª acepción) y la pregunta es si, ante una emergencia, los deberes de precaución son menos

intensos que ante una situación de riesgo normalmente esperable. La respuesta es que la emergencia se tiene en cuenta como una de las circunstancias que modulan los deberes de cuidado, pero que, probablemente, no hay necesidad de construir una doctrina específica en la cual quepa encasillar multitud de acontecimientos inesperados, pero muy heterogéneos entre sí.

***Lyons v. Midnight Sun Transportation Services, Inc.*(928 P.2d 1202 (Alaska 1996))** (http://www.onlinelawtutoring.com/Case_Reference/Lyons_v_Midnight_Sun_Transportation_Services_Inc_928_P2d_1202_1996.htm)

PER CURIAM.

I. FACTS AND PROCEEDINGS

Esther Hunter-Lyons was killed when her Volkswagen van was struck broadside by a truck driven by David Jette and owned by Midnight Sun Transportation Services, Inc. When the accident occurred, Jette was driving south in the right-hand lane of Arctic Boulevard in Anchorage. Hunter-Lyons pulled out of a parking lot in front of him. Jette braked and steered to the left, but Hunter-Lyons continued to pull out further into the traffic lane. Jette's truck collided with Hunter-Lyons's vehicle. David Lyons, the deceased's husband, filed suit, asserting that Jette had been speeding and driving negligently.

At trial, conflicting testimony was introduced regarding Jette's speed before the collision. Lyons's expert witness testified that Jette may have been driving as fast as 53 miles per hour. Midnight Sun's expert testified that Jette probably had been driving significantly slower and that the collision could have occurred even if Jette had been driving at the speed limit, 35 miles per hour. Lyons's expert later testified that if Jette had stayed in his own lane, and had not steered to the left, there would have been no collision. Midnight Sun's expert contended that steering to the left when a vehicle pulls out onto the roadway from the right is a normal response and is generally the safest course of action to follow.

Over Lyons's objection, the jury was given an instruction on the sudden emergency doctrine. The jury found that Jette, in fact, had been negligent, but his negligence was not a legal cause of the accident. Lyons appeals, arguing that the court should not have given the jury the sudden emergency instruction.

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

The sudden emergency doctrine is a rule of law which states that a person confronted with a sudden and unexpected peril, not resulting from that person's own negligence, is not expected to exercise the same 1204 judgment and prudence the law requires of a person in calmer and more deliberate moments. The person confronted with the imminent peril must, however, act as a reasonable person would under the same conditions.

[The Court first held that the use of the sudden emergency instruction count was harmless error since the jury decided in favour of defendant on the ground that his conduct was not the legal cause of plaintiff's injury.]

B. Sudden Emergency Instruction Disapproved

[W]e take this opportunity to disapprove of the instruction's further use. It adds nothing to the established law that the duty of care, which all must exercise, is to act reasonably under the circumstances. The instruction is potentially confusing. Although we cannot say that the instruction is never appropriate, we discourage its employment. In support of this admonition, we offer the following background.

The sudden emergency doctrine arose as a method of ameliorating the, sometimes harsh, "all or nothing" rule in contributory negligence systems. [...]

Although the doctrine came out of the contributory negligence regime, there is nothing about it which is inherently incompatible with a comparative fault system. Comparative negligence is a method of apportioning liability for a particular accident among the various parties who have been deemed negligent. The sudden emergency doctrine, in turn, is an expression of the applicable standard of care against which particular actions are judged in order to determine whether they were negligent in character. The fault of one person, determined in the light of a sudden emergency instruction, can be compared to the fault of another person, whose negligence may have created the emergency, with no logical inconsistency. […]

We believe that the sudden emergency instruction is a generally useless appendage to the law of negligence. With or without an emergency, the standard of care a person must exercise is still that of a reasonable person under the circumstances. With or without the instruction, parties are still entitled to present evidence at trial which will establish what the circumstances were, and are also entitled to argue to the jury that they acted as a reasonable person would have in light of those circumstances. Thus, barring circumstances that we cannot at the moment hypothesize, a sudden emergency instruction serves no positive function. Further, the instruction may cause confusion by appearing to imply that one party is less blameworthy than the other. Therefore, we hold that it should not be used unless a court finds that the particular and peculiar facts of a case warrant more explanation of the standard of care than is generally required […].

AFFIRMED.

§ 9 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010):

"If an actor is confronted with an unexpected emergency requiring rapid response, this is a circumstance to be taken into account in determining whether the actor´s resulting conduct is that of the reasonable careful person".

- This section addresses the situation in which an actor faces two or more choices of conduct, each of which entails its own combination of advantages and disadvantages. In an emergency, the fact of the emergency itself may mean that the response is instinctive rather than deliberative; at the least, it indicates that the opportunities for deliberation have been limited by severe time pressures.

- The emergency can be created by the conduct of another person, or without human action (failure of the brakes).

- Emergency. The kind of event that prevents reasonable people from exercising the kind of good judgment that such people ordinarily exercise.

- Prior negligence of the defendant. A number of courts adopt the rule that the emergency doctrine does not apply when the emergency is due to the defendant´s prior negligence, but not all.

Sesión 4ª
Negligencia (II)

4.1. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence* **48**
4.1.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871)) 48
4.1.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre 50
4.1.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)) 50
4.2. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk* **53**
4.2.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974)) 53
4.2.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008 55
4.2.3. STS, 1ª, 150/2008, de 28 de febrero 55
4.2.4. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero 55
4.2.5. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo 56
4.3. Costumbre / *Custom* **56**
4.3.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932)) . 58
4.3.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12 60

4.1. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence*

La idea de que, en un mundo finito, con recursos limitados, la precaución que hay que aplicar a la realización de una actividad lícita, pero peligrosa, no es infinita es muy antigua:

4.1.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871))

"[…] The case, as made by the plaintiff, was that the deceased received an injury from a locomotive engine of the defendant, which resulted in his death, on the 26th day of November, 1867, under the following circumstances:

He was standing in the afternoon of the day named, in conversation with another person about fifty feet from the defendant's track in East New York, as a train of cars was coming in from Jamaica at a rate of speed estimated by the plaintiff's witnesses of from twelve to twenty miles an hour. The plaintiff's witnesses heard no signal either, from the whistle or the bell upon the engine. The engine was constructed to run either way without turning and it was then running backward with the cowcatcher next the train it was drawing, and nothing in front to remove obstacles from the track. The claim of the plaintiff was that the evidence authorized the jury to find that the speed of the train was improper and negligent in that particular place, it being a thickly populated neighborhood and one of the stations of the road.

The evidence on the part of the plaintiff also showed that a child three or four years old was sitting or standing upon the track of the defendant's road as the train of cars approached and was liable to be run over, if not removed; and the deceased, seeing the danger of the child, ran to it, and, seizing it, threw it clear of the track on the side opposite to that from which he came, but, continuing across the track himself, was struck by the step or some part of the locomotive or tender, thrown down, and received injuries from which he died the same night.

The evidence on the part of the defendant tended to prove that the cars were being run at a very moderate speed, not over seven or eight miles an hour, that the signals required by law were

given, and that the child was not on the track over which the cars were passing, but on a side track near the main track.

So far as there was any conflict of evidence or question of fact, the questions were submitted to the jury. At the close of the plaintiff's case, the counsel for the defendant moved for a nonsuit upon the ground that it appeared that the deceased's negligence contributed to the injury and the motion was denied and an exception taken. After the evidence was all in, the judge was requested by the counsel for the defendant to charge the jury, in different forms, that if the deceased voluntarily placed himself in peril from which he received the injury, to save the child, whether the child was or was not in danger, the plaintiff could not recover and all the requests were refused and exceptions taken, and the question whether the negligence of the intestate contributed to the accident was submitted to the jury. The jury found a verdict for the plaintiff and the judgment entered thereon was affirmed, on appeal, by the Supreme Court and from the latter judgment the defendant has appealed to this court.

GROVER, J. The important question in this case arises upon the exception taken by the defendant's counsel to the denial of his motion for a nonsuit, made upon the ground that the negligence of the plaintiff's intestate contributed to the injury that caused his death. The evidence showed that the train was approaching in plain view of the deceased, and had he for his own purposes attempted to cross the track, or with a view to save property placed himself voluntarily in a position where he might have received an injury from a collision with the train, his conduct would have been grossly negligent, and no recovery could have been had for such injury. But the evidence further showed that there was a small child upon the track, who, if not rescued, must have been inevitably crushed by the rapidly approaching train. This the deceased saw, and he owed a duty of important obligation to this child to rescue it from its extreme peril, if he could do so without incurring great danger to himself. Negligence implies some act of commission or omission wrongful in itself. Under the circumstances in which the deceased was placed, it was not wrongful in him to make every effort in his power to rescue the child, compatible with a reasonable regard for his own safety. It was his duty to exercise his judgment as to whether he could probably save the child without serious injury to himself. If, from the appearances, he believed that he could, it was not negligence to make an attempt so to do, although believing that possibly he might fail and receive an injury himself. He had no time for deliberation. He must act instantly, if at all, as a moment's delay would have been fatal to the child. The law has so high a regard for human life that it will not impute negligence to an effort to preserve it, unless made under such circumstances as to constitute rashness in the judgment of prudent persons. For a person engaged in his ordinary affairs, or in the mere protection of property, knowingly and voluntarily to place himself in a position where he is liable to receive a serious injury, is negligence which will preclude a recovery for an injury so received; but when the exposure is for the purpose of saving life it is not wrongful, and therefore not negligent, unless such as to be regarded either rash or reckless. The jury was warranted in finding the deceased free from negligence under the micas above stated. The motion for a nonsuit was therefore properly denied. That the jury was warranted in finding the defendant guilty of negligence in running the train in the manner it was running requires no discussion. None of the exceptions taken to the charge as given, or to the refusals to charge as requested, affect the right of recovery. Upon the principle above stated, the judgment appealed from must be affirmed, with costs.

CHURCH, C. J., and PECKHAM and RAPALLO, JJ., concur.

ALLEN, J., wrote a dissenting opinion, in which FOLGER, J., concurred.

Judgment affirmed".

En la jurisprudencia española, la idea de que la precaución exigible ha de ser conmensurable con el riesgo aparece en muchas sentencias, pero casi nunca de forma central:

4.1.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre

El 18.8.1990, José Manuel intentó socorrer a otra persona que se estaba ahogando en la playa de Cullera (Valencia) en una zona alejada de la de uso habitual de los bañistas, sin que existiera en las cercanías miembros del servicio de socorristas municipales y cuando el mar estaba picado. A pesar de que una zódiac de socorristas acudió a rescatarles, ambos fallecieron.

La viuda de José Manuel, en nombre propio y en el de su hijo, demandó al Ayuntamiento de Cullera y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 1 de Sueca estimó la demanda (2.7.1996) y condenó al Ayuntamiento al pago de 102.172 €, de los cuales 72.121,45 € para la actora y 30.050,60 € para su hijo. La AP de Valencia (Secc. 8ª, 4.5.1998) estimó el recurso de apelación, revocó la SJPI y absolvió al Ayuntamiento.

El TS desestimó el recurso de casación al considerar que la actuación de la víctima fue negligente, pues no tuvo en consideración el mal estado del mar, y que la del equipo de salvamento fue adecuada: "el hecho en cuestión no puede ser reprochado culpabilísticamente al eventual responsable –el Ayuntamiento de Cullera- ya que aparte de la actuación personal del fallecido creadora del riesgo por su comportamiento, que aunque impregnado de un sentimiento solidario de amistad y altruismo, no tuvo en cuenta el mal cariz que presentaba el mar, que en ese momento suponía un peligro serio"(FD 1º).

En el caso debe tenerse en cuenta el criterio de la provocación, según el cual debe afirmarse la imputación objetiva del daño cuando el dañado asume el riesgo del que finalmente resulta víctima en su intento de salvar la vida, integridad física o bienes de un tercero en situación de peligro creada negligentemente por la víctima misma.

Obviando la posible responsabilidad de la persona a quien se intentó salvar–que la actora parece olvidar aferrándose a una entidad más solvente, el Ayuntamiento- , la cuestión radica en determinar si el Ayuntamiento, en concreto, los servicios de salvamento, incumplieron, por omisión, el deber de interrumpir el curso causal anteriormente mencionado.

Puede pensarse que, dada la autopuesta en peligro –o, dicho de otro modo, la asunción del riesgo- por parte de los bañistas, la Administración no incumplió su deber de protección y salvamento, pues no tiene la obligación de prever todo tipo de accidentes ni de proveer servicios de salvamento de forma que se reduzca el número de accidentes hasta cero, incluyendo los gravemente negligentes.

En este sentido, según el TS, la actuación de los servicios de salvamento fue "lógica y correcta", pues "no se puede exigir que haya una abundancia tal de socorristas que puedan actuar de inmediato"(FD 1º).

U.S. v. Carroll, resuelto en 1947, es el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX quizás porque acuñó el concepto económico de negligencia en el cénit cultural de un sistema económico. Todavía hoy, es inconcebible un curso de responsabilidad civil impartido en cualquiera de las cincuenta facultades de derecho más prestigiosas según los rankings al uso que no mencione *U.S. v. Carroll*, aunque solo sea para tratar de superarlo. Como ha de ser:

4.1.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947))

[The incident out of which this admiralty case arose was the sinking of a barge, along with its cargo, allegedly because of the defendant's negligence. A crucial issue in the case involved whether the person in charge of the barge, the barge, was negligent in being ashore, away from the barge, during the period when the barge got into difficulties and sank. If the barge's absence was negligence, and if it contributed substantially to the loss of the barge, then the barge's employer, the owner of the barge, would not receive full recovery from the other parties whose negligence put the barge into difficulties in the first place].

L. HAND, J.

It appears … that there is no general rule to determine when the absence of a barge or other attendant will make the owner of the barge liable for injuries to other vessels if she breaks away from her moorings. However, in any cases where he would be so liable for injuries to others obviously he must reduce his damages proportionately, if the injury is to his own barge. It becomes apparent why there can be no such general rule, when we consider the grounds for such a liability. Since there are occasions when every vessel will break from her moorings, and since, if she does, she becomes a menace to those about her; the owner's duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function of three variables:

(1) the probability that she will break away;
(2) the gravity of the resulting injury, if she does;
(3) the burden of adequate precautions.

Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B less than PL. Applied to the situation at bar, the likelihood that a barge will break from her fasts and the damage she will do, vary with the place and time; for example, if a storm threatens, the danger is greater; so it is, if she is in a crowded harbor where moored barges are constantly being shifted about. On the other hand, the barge must not be the barge's prison, even though he lives aboard; he must go ashore at times. We need not say whether, even in such crowded waters as New York Harbor a barge must be aboard at night at all; it may be that the custom is otherwise… and that, if so, the situation is one where custom should control. We leave that question open; but we hold that it is not in all cases a sufficient answer to a barge's absence without excuse, during working hours, that he has properly made fast his barge to a pier, when he leaves her. In the case at bar the barge left at five o'clock in the afternoon of January 3rd, and the flotilla broke away at about two o'clock in the afternoon of the following day, twenty-one hours afterwards. The barge had been away all the time, and we hold that his fabricated story was affirmative evidence that he had no excuse for his absence. At the locus in quo- especially during the short January days and in the full tide of war activity- barges were being constantly 'drilled' in and out. Certainly it was not beyond reasonable expectation that, with the inevitable haste and bustle, the work might not be done with adequate care. In such circumstances we hold- and it is all that we do hold- that it was a fair requirement that the Conners Company should have a barge aboard (unless he had some excuse for his absence), during the working hours of daylight.

El remolcador de la compañía demandada remolcaba una línea de barcazas o gabarras, aguas arriba y aguas abajo, en el río Hudson. La línea incluía la Anna C., propiedad de la Connors Company. La Anna C. rompió sus amarras y, llevada por el viento y la marea, abordó un petrolero cuya hélice rasgó el casco de la barcaza que, a continuación, se hundió.

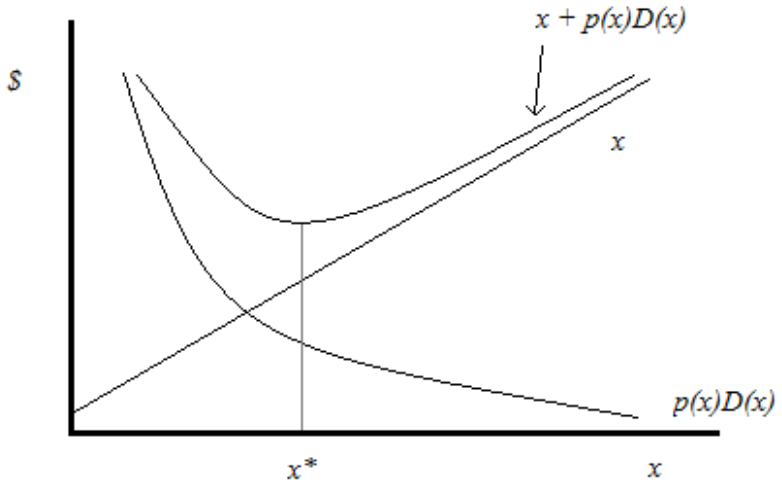
Una cuestión ante el tribunal era si el armador o dueño de la barraca había incurrido en negligencia, había sido contributivamente negligente, pues podría –se alegaba- haber destacado a un barge –gabarrero, marinero- en la barcaza.

Juez Hand: No hay regla general, ni legal ni consuetudinaria que establezca cuándo la ausencia de un gabarrero, barquero hará al armador responsable por los daños derivados de la rotura de las amarras de la barcaza. Está claro por qué no puede haber una regla general semejante, pues hay ocasiones en las que cualquier barco se soltaría de sus amarras… El deber de cuidado del dueño es una función de tres variables: B = PxL.

Puede ser que la costumbre sea distinta, en cuyo supuesto, gobernará el caso.

En la literatura: Richard POSNER, *A Theory of Negligence* 1 J. Legal Stud. 29 (1972).

Gráfico de John PRATER BROWN (1983)/Steven SHAVELL (1987).



§ 3 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010): **Negligence**

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances."

Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are:

1) The foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm.
2) The foreseeable severity of any harm that may ensue.
3) And the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm.

Análisis crítico:

1) Una simple plantilla: *Judex non calculat*, es decir, los tribunales no son consultorías, sino que aplican el derecho a los hechos del caso, tal y como resultan probados en el proceso.
2) La objeción filosófica de la inconmensurabilidad y los problemas empíricos de medición: *Helling v. Carey* (519 P. 22d 981 (Wash. 1974)). Entre los años 1959 y 1968, el demandante acudía a la consulta del oftalmólogo demandado para visitarse y tratarse de una irritación en los ojos causada por lentes de contacto. A finales de 1968, cuando el demandante tenía 32 años de edad, el demandado sospechó que aquel podría sufrir de glaucoma –una enfermedad de los ojos causada por un exceso de presión sobre el nervio óptico- cuando el paciente le dijo que había perdido visión periférica. El oftalmólogo le aplicó entonces un test de presión que confirmó el diagnóstico. El paciente acabó por perder la vista, pero un tratamiento temprano habría evitado el daño. En el pleito que siguió por mala praxis médica, el demandado alegó que el estándar profesional no exigía practicar pruebas de presión a pacientes menores de cuarenta años de edad, pues se trataba de una enfermedad muy poco común que sólo se presentaba en 1/25.000 casos. Suponiendo que el coste de cada test aplicado a cada niño o persona joven que se visite es de 5 USD, ¿había que haber practicado el test o no? Fíjense que tenemos B = 5, P= 1/25.000, pero que nos falta L, la

evaluación de la pérdida de la visión. Si B = PxL, entonces 5 = 125.000/25.000. Mas ¿cuánto vale un ojo de la cara?

3) Un caso similar, apropiado para ser discutido en un seminario, es la STS, 3ª, de 26 de junio de 2008: neuritis óptica de origen tóxico por tratamiento con medicación antituberculosa, Rifinah 300 (principio activo: isoniazida), reacción adversa, muy rara (que se produce en uno de cada diez mil tratamientos) y en caso en el que no existe indicación previa de propensión del paciente a neuritis.
4) Otra cuestión derivada de la presencia masiva de falsos positivos, que encarece mucho la práctica del test: si el test de presión sale positivo en muchos casos, de forma tal que sólo el 4% de los positivos es auténtico, es decir, desarrollarán glaucoma, la cosa se complica. Volveremos sobre la conveniencia o inconveniencia de estar a los estándares profesionales, a la costumbre.
5) Precaución absoluta o precauciones marginales: los primeros 60 euros o dólares USA evitan daños por una evaluación de 120, pero los segundos 40 sólo 30. Entonces, aunque (60 + 40 =) 100 < (120 + 30)= 150, es mejor, menos malo quedarse en 60 de gasto en precauciones, pues los segundos 40 superan en 10 a los 30 que se ahorran con ellos. Si no aprecian contar en unidades económicas, en dinero, pueden hacerlo en cualquier otra unidad que no les repela, por ejemplo, en *quality adjusted years of life, QUALY's.*
6) La fórmula no captura el autorriesgo (PORAT-COOTER, 29 J. Legal, Stud 19 (2000)), la autopuesta en riesgo, es decir, que no tiene en cuenta los daños probables causados por el comportamiento del demandado a sus propios bienes y, que en tal sentido, no incentiva la adopción óptima de precauciones.
7) La neutralidad al riesgo es poco plausible como supuesto general: muchas personas prefieren un 10% de probabilidad de perder 100 al 100% de perder 10. La función de utilidad crece menos proporcionalmente que la renta.
8) ¿Por qué es negligente la gente? Si es racional, no debería serlo.
9) Discontinuidades: pequeños errores en la apreciación del estándar llevan a discontinuidades en la función de responsabilidad: el médico cirujano pasa de ser un prudente profesional a un homicida negligente. Por un pequeño error. Y
10) ¿Sabemos realmente calcular las consecuencias de todas y de cada una de nuestras decisiones arriesgadas para nosotros mismos y para los demás? ¿Lo hacemos así?.

4.2. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk*

Tal y como se ha venido señalando en estas Sesiones, la otra cara de la definición de la negligencia concebida como infracción de deberes de cuidado es su concepción como incremento irrazonable de un riesgo. En el contexto del análisis de la regla de Hand, *Helling v. Carey* ilustra muy claramente este enfoque:

4.2.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974))

HUNTER, ASSOCIATE JUSTICE. This case arises from a malpractice action instituted by the plaintiff (petitioner), Barbara Helling.

The plaintiff suffers from primary open angle glaucoma. Primary open angle glaucoma is essentially a condition of the eye in which there is an interference in the ease with which the nourishing fluids can flow out of the eye. Such a condition results in pressure gradually rising above the normal level to such an extent that damage is produced to the optic nerve and its fibers with resultant loss in vision.... The disease usually has few symptoms and, in the absence of a pressure test, is often undetected until the damage has become extensive and irreversible.

The defendants (respondents), Dr. Thomas F. Carey and Dr. Robert C. Laughlin, are partners who practice the medical specialty of ophthalmology. Ophthalmology involves the diagnosis and treatment of defects and diseases of the eye.

The plaintiff first consulted the defendants for myopia, nearsightedness, in 1959. At that time she was fitted with contact lenses. [She consulted the defendants several times over the next nine years.] Until the October 1968 consultation, the defendants considered the plaintiff's visual problems to be related solely to complications associated with contact lenses. On that occasion, the defendant, Dr. Carey, tested the plaintiff's eye pressure and field of vision for the first time. This test indicated that the plaintiff had glaucoma. The plaintiff ... was then 32 years of age.

Thereafter, in August of 1969, after consulting other physicians, the plaintiff filed a complaint against the defendants alleging, among other things, that she sustained severe and permanent damage to her eyes as a proximate result of the defendants' negligence. During trial, the testimony of the medical experts for both the plaintiff and the defendants established that the standards of the profession for that specialty in the same or similar circumstances do not require routine pressure tests for glaucoma upon patients under 40 years of age. The reason the pressure test for glaucoma is not given as a regular practice to patients under the age of 40 is that the disease rarely occurs in this age group. Testimony indicated, however, that the standards of the profession do require pressure tests if the patient's complaints and symptoms reveal to the physician that glaucoma should be suspected.

The trial court entered judgment for the defendants following a defense verdict. The plaintiff thereupon appealed to the Court of Appeals, which affirmed the judgment of the trial court (...).

We find this to be a unique case. (…) The issue is whether the defendants' compliance with the standard of the profession of ophthalmology, which does not require the giving of a routine pressure test to persons under 40 years of age, should insulate them from liability under the facts in this case where the plaintiff has lost a substantial amount of her vision due to the failure of the defendants to timely give the pressure test to the plaintiff.

The incidence of glaucoma in one out of 25,000 persons under the age of 40 may appear quite minimal. However, that one person, the plaintiff in this instance, is entitled to the same protection as afforded persons over 40, essential for timely detection of the evidence of glaucoma where it can be arrested to avoid the grave and devastating result of this disease. The test is a simple pressure test, relatively inexpensive. There is no judgment factor involved, and there is no doubt that by giving the test the evidence of glaucoma can be detected. The giving of the test is harmless if the physical condition of the eye permits. The testimony indicates that although the condition of the plaintiff's eyes might have at times prevented the defendants from administering the pressure test, there is an absence of evidence in the record that the test could not have been timely given (...).

Under the facts of this case reasonable prudence required the timely giving of the pressure test to this plaintiff. The precaution of giving this test to detect the incidence of glaucoma to patients under 40 years of age is so imperative that irrespective of its disregard by the standards of the ophthalmology profession, it is the duty of the courts to say what is required to protect patients under 40 from the damaging results of glaucoma.

We therefore hold, as a matter of law, that the reasonable standard that should have been followed under the undisputed facts of this case was the timely giving of this simple, harmless pressure test to this plaintiff and that, in failing to do so, the defendants were negligent, which proximately resulted in the blindness sustained by the plaintiff for which the defendants are liable (...).

The judgment of the trial court and the decision of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for a new trial on the issue of damages only.

En la jurisprudencia española, la problemática abordada por Helling aparece en numerosas sentencias. Destacamos algunas:

4.2.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008

En abril de 1999, el Sr. Octavio acudió a un Centro de Atención Primaria de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) donde el Dr. Millán, médico de cabecera del actor, le diagnosticó tuberculosis, que no fue confirmada por médico especialista, e inició tratamiento farmacológico con Rifinah (F: Sanofi Aventis, S.A.; PA: Isoniazida, Rifampicina; AT: tratamiento de la tuberculosis). En agosto de 1999, se retiró la medicación al Sr. Octavio porque su consumo le había causado una neuritis óptica bilateral, lo que devino en una incapacidad permanente absoluta. Consta acreditado que la neuritis óptica es una reacción poco frecuente (1/10.000 tratamientos) de la isoniazida y que puede paliarse con vitamina B 6, que no se le administró al paciente.

El Sr. Octavio interpuso, primero, reclamación administrativa contra la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de la Salud y Mapfre Industrial, S.A. en la que solicitaba 26 millones de ptas. (156.263 euros), que fue desestimada por silencio administrativo y, después, recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que también fue desestimado (3.3.2004). El actor interpuso finalmente recurso de casación.

El TS estimó dicho recurso de casación, en el que se alegaba infracción del art. 141.1 Ley 30/1992, y condenó a la Administración General del Estado al pago de 30.000 euros porque "debe entenderse que siendo médicamente conocidos los efectos secundarios de la administración de isoniacida y que estos hubieran podido, si no prevenirse, sí minimizarse con la administración conjunta de la vitamina B 6, la no pautación de dicha vitamina al recurrente, a quien como a cualquier paciente, según el informe pericial, se le podían producir dichos efectos secundarios, sin olvidar además que al mismo no se le había realizado prueba que hubiese permitido una mejor confirmación del diagnóstico de presunción, supone una infracción de la "lex artis" que le ha generado una pérdida de oportunidad, en cuanto los resultados hubieran podido ser otros, si se le hubiese administrado conjuntamente la vitamina B 6" (FD 5ª).

4.2.3. STS, 1ª, 150/2008, de 28 de febrero

El 20.9.1992, el Dr. Braulio operó a Rodolfo de hernia discal. Sin embargo, operó el disco L3-L4 y no el L4-L5, que era el objeto de la intervención. Consta que el disco L3-L4 estaba dañado en forma de profusión coincidente con el L4-L5.

Rodolfo demandó a Braulio en petición de una indemnización de 150.253,03 €.

El JPI núm. 1 de Langreo (29.11.1999) desestimó la demanda. La AP de Oviedo (Sección 5ª, 2.11.2000) desestimó el recurso de apelación.

El TS desestimó el recurso de casación. El actor no ha probado que el disco L3-L4 estuviera sano, así como tampoco que su situación actual guarde relación alguna con la operación (FD 4º).

4.2.4. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero

El 3.3.2001, Isaac esquiaba en la estación de La Molina (propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), junto a su familia, cuando cayó y se deslizó hasta impactar contra un cañón de nieve artificial. A raíz del accidente, a Isaac se le rompieron las vértebras D7, D8, D11 y D12, pertenecientes a dos zonas diferentes de la columna, y sufre paraplejia L1, con afectación de esfínteres rectales y urinarios.

Isaac y su mujer África demandaron, en su nombre y en el de sus tres hijas menores de edad –Maite, Melisa y Noemí–, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y a su aseguradora Winterthur y solicitaron una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (no consta cuantía).

El JPI nº 7 de Barcelona (15.12.2004) estimó en parte la demanda y condenó a las demandadas (a Winterthur solamente hasta los 300.005,99€) al pago de 646.803,97€ a Isaac y de 90.000€ por el daño moral causado a la mujer y a las hijas del actor.

La AP de Barcelona (Sección 1ª, 20.9.2006) estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por los actores y aumentó la indemnización a pagar por las demandadas a 790.220,60€ y a 110.000 € respectivamente.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los demandados:

"(…) debe juzgarse como razonable la decisión de calificar como no diligente la conducta de la empresa titular de la estación pues […] el dueño de una estación de esquí se encuentra obligado a poner los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que gestiona, y con mayor motivo, cuando contribuyó a incrementar el riesgo propio de la actividad deportiva colocando en un lugar próximo a la pista un elemento artificial, rígido y duro, como un cañón artificial, que generó un riesgo evidente de lesiones en caso de colisión, incluso si esta se producía por consecuencia de un deslizamiento subsiguiente a una caída. Y siendo todo ello previsible, las caídas, las colisiones y el daño, no podía limitarse a señalar el elemento sino que le incumbía adoptar medidas de seguridad encaminadas a evitar o a disminuir el riesgo de lesiones, lo que no hizo". (FD 4º)

Vídeo de un accidente similar en Vallter 2000 en el año 2008
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/11638/el-terrible-accidente-en-la-nieve-que-costo-la-vida-a-un-joven-colombiano-en-espana/

4.2.5. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo

Una mujer de 65 años de edad y con problemas óseos y articulares, que habían determinado en 1987 el reconocimiento de una situación de invalidez absoluta, no advirtió que, en la entrada de un restaurante había un escalón, por lo que tropezó y se cayó. Como resultado de la caída, sufrió facturas del subcapital de fémur derecho, de la vértebra C1 sin desplazamiento y de la vértebra C2, que agravaron su artrosis previa.

La víctima demandó a la sociedad limitada propietaria del restaurante y a su compañía de seguros. El JPI desestimó la demanda. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora y condenó a los demandados al pago de 45.076 euros. El TS desestimó el recurso de casación de los demandados y confirmó la SAP:

"[E]l tribunal de apelación no infringió el art. 1902 CC (…) porque en definitiva esta Sala sí comparte el juicio esencial de dicho tribunal sobre la negligencia inherente a la disposición o configuración del acceso del hostal al restaurante, con un escalón intermedio a escasísima distancia del umbral y precisamente en la zona de claroscuro provocado, simultáneamente, por los diferentes colores del pavimento y la luz solar a la entrada y al fondo, quedando en penumbra precisamente el punto en que se encontraba el escalón (…) [L]a causa de la caída no fue sólo esa omisión negligente dado que también contribuyó de forma importante el estado físico de la demandante que afectaba a su capacidad de deambulación. En suma, el problema no es tanto de culpa de la víctima, pues ninguna culpa hay en padecer enfermedades o limitaciones ósea y articulares, cuanto de imputación al demandado de la causa de lo sucedido y de sus consecuencias (FD. 4º).

4.3. Costumbre / *Custom*

Pablo SALVADOR CODERCH - La costumbre como fuente de los deberes de precaución

La costumbre, los usos de la profesión, arte u oficio, sus buenas prácticas, son índices de calidad, de conducta adecuada, por diligente, del demandado, pero son solo eso: indicios, pues ni siquiera constituyen una presunción en sentido estricto. Por cierto, ¿conoce el lector la distinción entre presunciones, indicios y sospechas?

En cualquier caso, para valorar el comportamiento del demandado, hay que tener en cuenta, en primerísimo lugar, las disposiciones de la ley o, más frecuentemente, de los reglamentos que la desarrollan en tema de estándares de precaución. Aquí es importante destacar que, entre la ley (y el reglamento), por un lado, y la costumbre, hay muchas posibilidades alternativas. Véase si no, la lista siguiente:

[First of all, statutory standards of care have to be taken into account:

a. *Specific Safety Regulations.*
b. *Best Available Technology (BAT)*
c. *As Low As Reasonably Achievable (ALARA)*
d. *Cost-benefit: Entergy Corp. v. Riverkeeper Inc. et al.*
e. *The utmost care standard…*
f. *…*

And then, there is:]

g. *Custom*

The general principles of negligence ("The reasonable person standard"), writes Epstein (p. 221), leave judges a great deal of latitude in deciding cases. This generality introduces a large element of uncertainty even in ostensible routine cases. Using custom to set the standard of care is one way to reduce this uncertainty.

The question is then: Should custom be given the same deference in actions between strangers as in actions arising out of consensual relationships? Does "reasonable safe" mean "safe according to the usages, habits, and ordinary risks of the business"? See *Titus v. Bradford, B & K.* R. Co. 20 A. 517 (Pa. 1890).

El caso de referencia sobre usos, costumbre y tecnología es *The T.J. Hopper*. Resuelto hace ochenta años, su lectura es todavía un magnífico punto de partida para el análisis de la cuestión de si la costumbre induce diligencia:

4.3.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932))

Petition by the Eastern Transportation Company, as owner of the tugs Montrose and T. J. Hooper, for exoneration from, or limitation of, liability; separate libels by the New England Coal & Coke Company and by H. N. Hartwell & Son, Inc., against the Northern Barge Corporation, as owner of the barge Northern No. 30 and the barge Northern No. 17; and libel by the Northern Barge Corporation against the tugs Montrose and Hooper. The suits were joined and heard together. From the decree rendered [53 F.(2d) 107], the petitioner Eastern Transportation Company and the Northern Barge Corporation, appeal.

[The operator of a tugboat was sued for the value of two barges and their cargoes, which were lost at sea during a coastal storm in March 1928. The basis of the claim was that the tug was negligently unseaworthy in that it was not equipped with a radio receiver, and thus could not receive reports of an impending storm. There was evidence that the master, had he heard the weather reports, would have turned back]

L. HAND,

It is not fair to say that there was a general custom among coastwise carriers so to equip their tugs. One line alone did it; as for the rest, they relied upon their crews, so far as they can be said to have relied at all. An adequate receiving set suitable for a coastwise tug can now be got at small cost and is reasonably reliable if kept up; obviously it is a source of great protection to their tows. Twice every day they can receive these predictions, based upon the widest possible information, available to every vessel within two or three hundred miles and more. Such a set is the ears of the tug to catch the spoken word, just as the master's binoculars are her eyes to see a storm signal ashore. Whatever may be said as to other vessels, tugs towing heavy coal laden barges, strung out for half a mile, have little power to manoeuvre, and do not, as this case proves, expose themselves to weather which would not turn back stauncher craft. They can have at hand protection against dangers of which they can learn in no other way.

Is it then a final answer that the business had not yet generally adopted receiving sets? There are, no doubt, cases where courts seem to make the general practice of the calling the standard of proper diligence; we have indeed given some currency to the notion ourselves. Indeed in most cases reasonable prudence is in fact common prudence; but strictly it is never its measure; a whole calling may have unduly lagged in the adoption of new and available devices. It never may set its own tests, however persuasive be its usages. Courts must in the end say what is required; there are precautions so imperative that even their universal disregard will not excuse their omission. But here there was no custom at all as to receiving sets; some had them, some did not; the most that can be urged is that they had not yet become general. Certainly in such a case we need not pause; when some have thought a device necessary, at least we may say that they were right, and the others too slack. The statute (section 484, title 46, U. S. Code [46 USCA § 484]) does not bear on this situation at all. It prescribes not a receiving, but a transmitting set, and for a very different purpose; to call for help, not to get news. We hold the tugs therefore because had they been properly equipped, they would have got the Arlington reports. The injury was a direct consequence of this unseaworthiness.

Decree affirmed.

The Restatement (Third) of Torts "downgrades the role of custom" (Epstein) holding that compliance with the custom of the community is evidence that the actor's conduct is not negligence, but does not preclude a finding of negligence".

§ 13 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010)**: Custom**

(a) An actor's compliance with the custom of the community, or of others in like circumstances is evidence that the actor's conduct is not negligent but does not preclude a finding of negligence.

(b) An actor's departure from the custom of the community, or of others in like circumstances, in a way that increases risk is evidence of the actor's negligence but does not require a finding of negligence.

Epstein's dissenting analysis from The T. J. Hooper:

Hand's view has received overwhelming acceptance. Epstein disagrees. First, in cases that arise out of a consensual arrangement, negligence is often the appropriate standard of liability, and where it is so, custom should be regarded as conclusive evidence of due care in absence of any contractual stipulation to the contrary. Second, in stranger cases, negligence should normally not be the appropriate standard of care, so that reliance on custom is as irrelevant as the negligence issue to which custom alone is properly directed (…) because it registers the preferences of the parties to the custom, not those who are victimized by it.

Compare: custom in international law –as a source of legal obligations-; custom in contract law.

Discuss:

- Compliance with the custom of the community. Widespread reliance on custom.
- Private standards ("codes") and public recommendations. Example: National Electric Safety Code, issued by the American National Standards Institute.
- Actor's departure from the custom of the community (typically: a large-scale defendant that has adopted standards applicable to its own operations or its own employees). Departure impugns any claim by the defendant that the risk is unforeseeable or that the safety practice is unfeasible. What happens when the actor departs from its own standard? The main question is the admissibility of introducing evidence regarding the defendant's violation of its own standard as admissible on the issue of negligence. Divided results. Grounds: if the admission of evidence is to be used against the defendant as an admission of departure, he would naturally find it to his interest NOT to adopt any rules at all. Counterargument: The defendant itself had made these decisions, *facta propria*.

Trimarco v. Klein (N.Y. 1982): plaintiff injured in 1976 when he slipped in his bathroom and received serious lacerations from crashing against a shower door made of ordinary glass estimated to be between 1/16 and ¼ an inch thick. The shower had been installed in the 1950´s, when the use of ordinary glass was standard practice. Since the mid-60´s , the common practice in NYC had been to use safer tempered glass… Must all old shower doors be replaced? Sprinklers and burglar alarms be retrofitted in old buildings?

Why should conformity to the practice protect a physician from liability? One good ground: no other standard is practical. The battle of the experts. The (technical) incompetence of courts.

Local or national standards?: "The time has come when the medical profession should no longer be Balkanized by the application of varying geographic standards" (Brune v. Bellinkoff, Mass 1968). The proper standard is whether the physician has exercised the degree of care and skill of the average qualified practitioner, taking into account the advances in the profession.

Read:

Kenneth S. ABRAHAM, *Custom, Non-customary Practice, and Negligence*, 109 Colum , l. Rev. 1784 (2009).

4.3.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12

"*El Derecho de Daños como instrumento de control social: un ejemplo sencillo aplicado a la instalación de dispositivos ABS para vehículos*

Para ilustrar cómo el derecho, y el derecho de daños en particular, contribuye a pasar de peores a mejores situaciones puede servir un ejemplo inspirado en otro que se puede encontrar en SCÄFER/OTT (2000) y que hemos reformulado para adaptarlo al sistema de frenado ABS (***Anti-Block System***) para automóviles. Éste es un dispositivo electrónico antibloqueo que controla la presión de líquido de los frenos y de esta forma evita que las ruedas se bloqueen cuando se ejerce una presión excesiva sobre el pedal, generalmente en situaciones de alto riesgo. En 1978, Mercedes Benz instala el primer sistema ABS en un coche de serie como sistema opcional. Con posterioridad, muchas firmas lo incorporaron a sus vehículos como equipo de serie, aunque todavía no era obligatorio[2].

Es indudable que este dispositivo mejora la capacidad de frenado de un vehículo bajo cualquier circunstancia por lo que evita accidentes individuales y también colectivos. Pero además, si todos disponen del mismo, contribuye a disminuir en gran medida la probabilidad de colisión entre vehículos. Es este segundo efecto el que nos interesa destacar aquí.

En un sencillo ejemplo, dos conductores (C1 y C2) barajan la posibilidad de instalar sendos sistemas de frenado ABS. La utilidad anual que cada conductor obtiene del disfrute de su automóvil es de 1200 €, y sus costes esperados serán de 600 € que resultan de una probabilidad del 6% de sufrir un accidente que le comportará daños por valor de 10.000 € (0,06 x 10.000). La instalación de un dispositivo de ABS tiene un coste de 100 € anuales ya que este sistema requiere de revisiones periódicas. Pero disponer de él reduce la probabilidad de sufrir un accidente de un 6% a un 2%, por lo que los costes esperados bajarán a 200 € (0'02 x 10.000).

Los *pay-offs* de una y otra opción para C1 y C2 figuran en la tabla siguiente:

		C2	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900, 900	500, 600
	NoABS	600, 500	600, 600

Supongamos que C2 opta por instalar el ABS. Entonces C1 hará lo propio, pues 900 > 600 como podemos observar en la primera columna. Por el contrario, si C2 resuelve no instalarlo, C1

[2] El sistema de antibloqueo de ruedas al frenar (ABS) se convirtió en un dispositivo de serie obligatorio para todos los turismos nuevos vendidos en la Unión Europea a partir de 2003, en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión «Protección de los peatones: Compromiso de la industria europea del automóvil» (COM(2001) 389 — C5-0537/2001— 2001/2216(COS)), de 13 de junio de 2002 (P5_TA(2002)0323; DO C 261 E/576, de 30.10.2003). Sin embargo, la normativa se ha visto ya superada en este punto por el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200\1, de 31.7.2009), el cual estableció el ESP (*Electronic Stability Control*, que incluye la función de ABS) como dispositivo de serie obligatorio en todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en la Unión Europea desde el 1 de noviembre de 2011.

tampoco lo hará, pues estaremos en la segunda columna, 600 > 500. Si partimos de la decisión de C1 llegaremos a la misma conclusión, resultando las dos situaciones de equilibrio señaladas en la tabla. Se observa que existe un equilibrio eficiente (casilla superior izquierda) y otro ineficiente (casilla inferior derecha) que se corresponden con sendos equilibrios de Nash. A cuál de ellos se llegará, dependerá de circunstancias externas como señalan SCHÄFER y OTT para un ejemplo similar: si C1 sabe que C2 ha instalado el ABS, hará lo propio, pero si sabe que no lo ha hecho, tampoco lo hará él, pues un solo ABS no disminuye suficientemente la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos. *A priori*, bajo un sistema de ausencia de responsabilidad *(no liability rule)*, no hay garantías de que ninguna de las dos partes se comportará correctamente tras asumir que la otra lo hará.

Supongamos ahora una situación en la que existe una serie de n conductores C1, C2, C3,... Cn, para $1<n<\infty$ y p es la probabilidad de que un conductor haya instalado el sistema ABS en su vehículos. Entonces los beneficios esperados para C1 serán:

Beneficios en caso de ABS → B(ABS)= p· 900 + (1-p)· 500= p· 400 + 500
Beneficios en caso de No ABS → B(NoABS)= p· 600 + (1-p)· 600= 600
(donde probabilidad: p ϵ [0,1])

C1 optará por instalar ABS siempre que:

B(ABS)>B(NoABS), entonces:
p· 400 + 500 > 600,
p> 0'25

De donde resulta que C1 instalará el ABS en su automóvil siempre que la probabilidad sea superior a 25%, esto es, cuando más de una cuarta parte de los vehículos dispongan de él, pero no lo hará si la proporción es inferior, pues no le saldrá a cuenta. El ejemplo ilustra un caso típico de instalación de dispositivos en los que se produce un efecto de externalidades de red – *network externalities*- ya que a mayor número de usuarios de un mismo producto o servicio, mayor será la utilidad que cada uno de ellos obtendrá de él. Pero, a pesar de que todos los interesados coincidan en que la difusión generalizada del producto sería socialmente beneficiosa, la existencia de dos equilibrios puede comportar que los sucesivos intentos de comercializar el uso del producto fracasen debido a que la red no esté lo suficientemente extendida para crear los incentivos privados necesarios para la instalación. Pero un cambio de jurisprudencia o, por supuesto, de legislación podría dar un vuelco a esta situación: por ejemplo, si el Tribunal Supremo, ante un caso de reclamación de daños y perjuicios por colisión entre dos vehículos, resuelve que la falta de instalación de ABS es negligencia y que ésta reduce o anula la indemnización a que tendría derecho el actor, entonces ningún conductor podrá reclamar si no disponía de ABS y, en cambio, deberá pagar los daños resultantes al otro vehículo. Los pagos para C1 se verían modificados de la manera siguiente:

		C2, C3, C4,... Cn	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900 900	0 1100
	NoABS	0 1100	600 600

(donde indemnización esperada: I = 0,06 x 10.000= 600)

Si instala ABS, en caso de colisión será indemnizado por aquél que fue negligente porque no lo instaló. En cambio, si no instala el sistema deberá pagar una indemnización a quién lo había instalado, o bien, en caso de que el otro tampoco lo hubiera instalado cada uno asumirá sus propios daños.

Podemos observar cómo independientemente de la decisión de los demás individuos, para C1 resulta más beneficioso instalar ABS ya que los pagos de la fila superior son siempre superiores a los de la inferior. De esta forma, el precedente jurisprudencial habría inducido los incentivos privados necesarios para la generalización del producto, que de otra forma no hubiera podido producirse".

Sesión 5ª
Negligencia (III)

5.1. Negligencia *per se*. Infracción de normas legales. Presunciones..... 63
5.1.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874))..... 66
5.1.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920))..... 67
5.1.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939))..... 68
5.1.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926))..... 69
5.1.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio..... 71
5.1.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999))..... 74
5.1.7. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre..... 76
5.1.8. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero..... 77
5.1.9. *Preemption*..... 78
5.2. *Res ipsa loquitur*..... 80
5.2.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863))..... 81
5.2.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986))..... 81
5.2.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687)..... 84
5.2.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre..... 85
5.2.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla..... 85
5.2.6. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados..... 86

5.1. Negligencia *per se*. Infracción de normas legales. Presunciones

YouTube Pablo Salvador Coderch - Leyes y reglamentos como fuente de los deberes de precaución

En esta Sesión, tratamos fundamentalmente de tres cuestiones:

En el Common Law, la conducta de quien infringe una ley escrita –o un reglamento—se presume negligente si el fin de protección de la normativa violada es justamente amparar a la víctima de los daños causados: si así es, el demandante no habrá de probar la negligencia del demandado sino únicamente el daño y la causalidad. La presunción admite prueba en contrario

(negligencia *per se*). En cambio, si la ley quebrantada no persigue proteger a la víctima de los daños sufridos, su infracción conllevará la aplicación de las consecuencias de derecho previstas por la ley violada, pero será irrelevante a efectos de apreciar la negligencia. Y, finalmente, si el demandado desarrolló su actividad dañina cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, ello es un indicio de que actuó correctamente, pero, de nuevo, cabe probar que no fue así.

Más allá de la ley escrita o de las regulaciones aplicables a un sector de actividad, una doctrina jurisprudencial común al Common Law y al Civil Law establece que si un accidente tiene lugar en circunstancias tales que su ocurrencia normalmente solo se explica porque su causante ha infringido un deber de cuidado, entonces también se presume su negligencia, siempre con posibilidad de prueba en contrario (res ipsa loquitur).

En tercer lugar, uno de los temas más importantes de los derechos contemporáneos, en entornos intensamente regulados es el relativo a si la regulación legal y reglamentaria de tal o cual actividad, con la consiguiente aplicación de las consecuencias de derecho legalmente previstas que correspondan en caso de infracción, cierran el sistema e impiden el ejercicio de las pretensiones de daños previstas por el derecho común, por ejemplo, por el art. 1902 CC (preemption), o bien y por el contrario, dejan abierta tal posibilidad. En el Common Law angloamericano, la cuestión es muy debatida, pero hay acuerdo en que el legislador puede clausurar el sistema. El problema es doble: si lo hace expresamente, hay que interpretar la delimitación legal del cierre categorial. Y si el cierre es implícito, las dudas interpretativas suelen ser aún mayores.

El derecho español vigente trata de estas cuestiones algo idiosincrásicamente, sobre todo en el caso de la negligencia per se, pues, como veremos, todavía es frecuente encontrar afirmaciones de los tribunales conforme a las cuales la producción del daño permite inferir la negligencia de su causante incluso si cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias.

Comenzaremos analizando los criterios del ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010) -RTT-, que extractamos del original en inglés y que ofrecen una buena base para una discusión de la negligencia per se en términos de razonabilidad, pero, como acabamos de señalar, no dan razón cabal del derecho español vigente:

§ 14 RTT. Statutory Violations as Negligence Per Se

An actor is negligent if, without excuse, the actor violates a statute that is designed to protect against the type of accident the actor´s conduct causes, and if the accident victim is within the class of persons the statute is designed to protect.

- This section applies to statutes, regulations and ordinances.

- Express and implied statutory causes of action: Some statutes declare conduct unlawful, impose a public-law penalty on the person whose conduct violates the statute, and also specify that the violator is civily liable in damages to the victim of the violation. Certain other statutes simply state that, if certain conduct causes harm, the actor is liable to a victim. Yet large numbers of statutes (…) are silent as to private liability in the event of a statutory violation. Then, the court, relying on ordinary principles of legislative interpretation, may in appropriate cases infer a cause of action for damages.

- Rationales:

a) It would be akward for a court in a tort case to commend as reasonable that behavior that tle legislature has already condemned as unlawful.

b) The judgement of the legislature is the authoritative representative of the community.

c) The negligence standard encounters difficulty in dealing with problems of recurring conduct. (…) statutes address conduct that conspicuously recurs in a way that brings it

to the attention of the legislature. Negligence per se hence replaces decision making by juries [career judges].
d) Furthermore, negligence has been settled doctrine in American tort law for many decades, [not under Spanish Law: see infra].

- Negligence per se applies only when the accident that injures the plaintiff is the type of accident that the statute seeks to avert. In some cases, negligence per se does not apply because the statute is not a safety statute at all.

- Licensing statutes: One general purpose of such licensing statutes is to protect the public against physical and emotional harm (…) but in many cases, the immediate reason for the person´s lack of license is unrelated to the state´s general safety purpose. For example, a motorist may lack a license only because of a failure to file for license renewal. If this motorist is involved in an accident, the lack of license has no bearing on the motorist´s negligence. Similarly, a physician may lack a license in a state only because the physician has not yet satisfied the state´s residency requirement. In other cases, however, this general assessment does not pertain. If, for example, a person operates a motorcycle in a way that suggests a lack of skill, and if the evidence shows that the person does not have a license to operate a motorcycle because the person has failed the test that assesses skills, then, depending on the jurisdiction´s rules, the lack of a license may be negligence per se or admissible as tending to show the person´s negligent unskillfulness. Same if a property owner has installed a furnace without securing a permit required by a city ordinance, and the evidence indicates that the inspector would not have issued the permit (…).

- Negligence per se is clearly inappropriate when the actor´s conduct fall below the requirements of a statute enacted **after** the conduct occurred. However, a later-enacted statute can be admissible evidence bearing on the actor´s negligence.

Viceversa, el cumplimiento por el demandado de las regulaciones dictadas para proteger los intereses o la integridad del demandante no excluirá la posibilidad de que este último pruebe la negligencia de aquel, pero será un indicio de que la conducta puesta en cuestión fue correcta, diligente.

Como hemos señalado al inicio de esta Sesión, esta doble construcción no ha sido recibida por el derecho español ni, específicamente, por su jurisprudencia. Esta, como se verá a continuación, a menudo ha sostenido que el cumplimiento de las disposiciones dictadas para prevenir el daño causado no es óbice a la declaración de la existencia de negligencia, pues esta existiría porque el hecho mismo de que se haya producido el accidente implica que las regulaciones eran o habían devenido insuficientes y que alguna negligencia había debido de tener lugar: es una especie de animismo jurídico, acaso propio de un pensamiento primitivo.

Sin embargo y en ocasiones, esta jurisprudencia es contrarrestada por otra según la cual no cabe alegar en casación y ante la Sala 1ª la infracción de normas reglamentarias y puramente administrativas. Tampoco aquí parece que el Tribunal Supremo ande acertado: la mayor parte de las actividades que no pertenecen a los actos más sencillos de la vida cotidiana están intensamente reguladas y la consideración de los estándares establecidos por los agentes reguladores debería de ser un elemento muy importante para evaluar la diligencia o negligencia del demandado. La división jurisdiccional genera así una doctrina oracular e ignora el principio de la unidad del ordenamiento jurídico, de la vieja y buena idea conforme a la cual una tarea básica del intérprete es concordar razonadamente cánones discordantes.

§ 16 RTT Statutory Compliance

(a) An actor´s compliance with a pertinent statute, while evidence of nonnegligence, does not preclude finding that the actor is negligent under § 3 for failing to adopt precautions in addition to those mandated by the statute.

(b) If an actor´s adoption of a precaution would require the actor to violate a statute, the actor cannot be found negligent for failing to adopt that precaution.

- While Subsection (a) states the [U.S.] general common-law rule, this rule can be overcome by a particular statute expressing a contrary understanding.
- In each instance, compliance is evidence of non negligence but it is not conclusive.
- Statutes that merely set minimum standards.
- Unusual circumstances. A finding that additional precautions are called for despite the actor´s compliance with the statute is clearly appropriate if the precaution relates to some unusual situation beyond the generality of situations anticipated by the statute itself.

5.1.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874))

The plaintiffs were entitled to assume that the defendant would perform all the duties cast upon him by the law, including compliance with these orders; and that being so, the defendant has impliedly contracted with the plaintiffs that he would perform them.

Kelly, C.B. This is an action to recover damages for the loss of a number of sheep which the defendant, a shipowner, had contracted to carry, and which were washed overboard and lost by reason (as we must take it to be truly alleged) of the neglect to comply with a certain order made by the Privy Council, in pursuance of the Contagious Diseases (Animals) Act, 18G9. The Act was passed merely for sanitary purposes, in order to prevent animals in a state of infectious disease from communicating it to other animals with which they might come in contact. Under the authority of that Act, certain orders were made; amongst others, an order by which any ship bringing sheep or cattle from any foreign port to ports in Great Britain is to have the place occupied by such animals divided into pens of certain dimensions, and the floor of such pens furnished with battens or foot-holds. The object of this order is to prevent animals from being overcrowded, and so brought into a condition in which the disease guarded against would be likely to be developed. This regulation has been neglected, and the question is, whether the loss, which we must assume to have been caused by that neglect, entitles the plaintiffs to maintain an action.

The argument of the defendant is, that the Act has imposed penalties to secure the observance of its provisions, and that, according to the general rule, the remedy prescribed by the statute must be pursued ; that although, when penalties are imposed for the violation of a statutory duty, a person aggrieved by its violation may sometimes maintain an action for the damage so caused, that must be in cases where the object of the statute is to confer a benefit on individuals, and to protect them against the evil consequences which the statute was designed to prevent, and which have in fact ensued ; but that if the object is not to protect individuals against the consequences which have in fact ensued, it is otherwise ; that if, therefore, by reason of the precautions in question not having been taken, the plaintiffs had sustained that damage against which it was intended to secure them, an action would lie, but that when the damage is of such a nature as was not contemplated at all by the statute, and as to which it was not intended to confer any benefit on the plaintiffs, they cannot maintain an action founded on the neglect. The principle may be well illustrated by the case put in argument of a breach by a railway company of its duty to erect a gate on a level crossing, and to keep the gate closed except when the crossing is being actually and properly used. The object of the precaution is to prevent injury from being sustained through animals or vehicles being upon the line at unseasonable times; and if by reason of such a breach of duty, either in not erecting the gate, or in not keeping it closed, a person attempts to cross with a carriage at an improper time, and injury ensues to a passenger, no doubt an action would lie against the railway company, because the intention of the legislature was that, by the erection of the gates and by their being kept closed individuals should be protected against accidents of this description. And if we CO see that it was the object, or among the objects of this Act, that the owners of sheep and cattle coming from a foreign port should be protected by the means described against the danger of their property being washed overboard, or lost by the perils of the sea, the present action would be within the principle. But, looking at the Act, it is perfectly clear that its provisions were all enacted with a totally different view ; there was no purpose, direct or indirect, to protect against such damage ; but, as is recited in the preamble, the Act is directed against the possibility of sheep or cattle being exposed to disease on their way to this country. The preamble recites that "it is expedient to confer on Her Majesty's most honourable Privy Council power to take such measures as may

appear from time to time necessary to prevent the introduction into Great Britain of contagious or infectious diseases among cattle, sheep, or other animals, by prohibiting or regulating the importation of foreign animals," and also to provide against the " spreading " of such diseases in Great Britain. Then follow numerous sections directed entirely to this object. Then comes s. 75, which enacts that "the Privy Council may from time to time make such orders as they think expedient for all or any of the following purposes." What, then, are these purposes? They are "for securing for animals brought by sea to ports in Great Britain a proper supply of food and water during the passage and on landing," " for protecting such animals from unnecessary suffering during the passage and on landing," and so forth, all the purposes enumerated being calculated and directed to the prevention of disease, and none of them having any relation whatever to the clanger of loss by the perils of the sea. That being so, if by reason of the default in question the plaintiffs' sheep had been overcrowded, or had been caused unnecessary suffering, and so had arrived in this country in a state of disease, I do not say that they might not have maintained this action. But the damage complained of here is something totally apart from the object of the Act of Parliament, and it is in accordance with all the authorities to say that the action is not maintainable.

Judgment for the defendant.

5.1.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920))

[The decedent was killed in a collision between the buggy he was driving and defendant's automobile. The accident occurred after dark, and decedent was driving the buggy without any lights, in violation of a statute. The defendant requested a ruling that the absence of a light on the plaintiff's vehicle was "prima facie evidence of contributory negligence". This request was refused, and the jury was instructed that it might consider the absence of lights as some evidence of negligence, but not conclusive evidence of negligence. The plaintiff next requested a charge that "the fact that the plaintiff's intestate was driving without a light is not negligence in itself", and to this the court acceded. The jury found the defendant liable and the decedent free from contributory negligence and the plaintiff had judgment. The appellate division reversed for error in the instructions. Affirmed].

CARDOZO, J. [...] We think the unexcused omission of the statutory signals is more than some evidence of negligence. It is negligence in itself. Lights are intended for the guidance and protection of other travelers on the highway. By the very terms of the hypothesis, to omit, willfully or heedlessly, the safeguards prescribed by law for the benefit of another that he may be preserved in life or limb, is to fall short of the standard of diligence to which those who live in organized society are under a duty to conform. [...] In the case at hand, we have an instance of the admitted violation of a statute intended for the protection of travelers on the highway, of whom the defendant at the time was one. Yet the jurors were instructed in effect that they were at liberty in their discretion to treat the omission of lights either as innocent or as culpable. They were allowed to "consider the default as lightly or gravely" as they would (Thomas, J., in the court below). They might as well have been told that they could use a like discretion in holding a master at fault for the omission of a safety appliance prescribed by positive law for the protection of a workman. Jurors have no dispensing power by which they may relax the duty that one traveler on the highway owes under the statute to another. It is error to tell them that they have. The omission of these lights was a wrong, and being wholly unexcused was also a negligent wrong. No license should have been conceded to the triers of the facts to find it anything else.

We must be on our guard, however, against confusing the question of negligence with that of the causal connection between the negligence and the injury. A defendant who travels without lights is not to pay damages for his fault unless the absence of lights is the cause of the disaster. A plaintiff who travels without them is not to forfeit the right to damages unless the absence of lights is at least a contributing cause of the disaster. To say that conduct is negligence is not to say that it is always contributory negligence.

[...] A statute designed for the protection of human life is not to be brushed aside as a form of words, its commands reduced to the level of cautions, and the duty to obey attenuated into an option to conform. [...]

5.1.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939))

LEHMAN, J.

While walking along a highway, Anna Tedla and her brother, John Bachek, were struck by a passing automobile, operated by the defendant Hellman. She was injured and Bachek was killed. Bachek was a deaf-mute. His occupation was collecting and selling junk. His sister, Mrs. Tedla, was engaged in the same occupation. They often picked up junk at the incinerator of the village of Islip. At the time of the accident they were walking along 'Sunrise Highway' and wheeling baby carriages containing junk and wood which they had picked up at the incinerator. It was about six o'clock, or a little earlier, on a Sunday evening in December. Darkness had already set in. Bachek was carrying a lighted lantern, or, at least, there is testimony to that effect. The jury found that the accident was due solely to the negligence of the operator of the automobile. The defendants do not, upon this appeal, challenge the finding of negligence on the part of the operator. They maintain, however, that Mrs. Tedla and her brother were guilty of contributory negligence as matter of law.

Sunrise Highway, at the place of the accident, consists of two roadways, separated by a grass plot. There are no footpaths along the highway and the center grass plot was soft.

It is not unlawful for a pedestrian, wheeling a baby carriage, to use the roadway under such circumstances, but a pedestrian using the roadway is bound to exercise such care for his safety as a reasonably prudent person would use. The Vehicle and Traffic Law (Cons. Laws, ch. 71) provides that 'Pedestrians walking or remaining on the paved portion, or traveled part of a roadway shall be subject to, and comply with, the rules governing vehicles, with respect to meeting and turning out, except that such pedestrians shall keep to the left of the center line thereof, and turn to their left instead of right side thereof, so as to permit all vehicles passing them in either direction to pass on their right. Such pedestrians shall not be subject to the rules governing vehicles as to giving signals.' (§ 85, subd. 6.) **Mrs. Tedla and her brother did not observe the statutory rule and, at the time of the accident, were proceeding in easterly direction on the east-bound or right-hand roadway**. The defendants moved to dismiss the complaint on the ground, among others, that violation of the statutory rule constitutes contributory negligence as matter of law. They did not, in the courts below, urge that any negligence in other respect of Mrs. Tedla or her brother bars a recovery. The trial judge left to the jury the question whether failure to observe the statutory rule was a proximate cause of the accident; he left to the jury no question of other fault or negligence on the part of Mrs. Tedla or her brother, and the defendants did not request that any other question be submitted. Upon this appeal, the only question presented is whether, as matter of law, disregard of the statutory rule that pedestrians shall keep to the left of the center line of a highway constitutes contributory negligence which bars any recovery by the plaintiff [...].

The plaintiffs showed by the testimony of a State policeman that 'there were very few cars going east' at the time of the accident, but that going west there was 'very heavy Sunday night traffic. Until the recent adoption of the new statutory rule for pedestrians, ordinary prudence would have dictated that pedestrians should not expose themselves to the danger of walking along the roadway upon which the 'very heavy Sunday night traffic' was proceeding when they could walk in comparative safety along a roadway used by very few cars. It is said that now, by force of the statutory rule, pedestrians are guilty of contributory negligence as matter of law when they use the safer roadway, unless that roadway is left of the center of the road. Disregard of the statutory rule of the road and observance of a rule based on immemorial custom, it is said, is negligence which as matter of law is a proximate cause of the accident, though observance of the statutory rule might, under the circumstances of the particular case, expose a pedestrian to serious danger from which he would be free if he followed the rule that had been established by custom. If that be true, then the Legislature has decreed that pedestrians must observe the general rule of conduct which it has prescribed for

their safety even under circumstances where observance would subject them to unusual risk; that pedestrians are to be charged with negligence as matter of law for acting as prudence dictates. It is unreasonable to ascribe to the Legislature an intention that the statute should have so extraordinary a result, and the courts may not give to a statute an effect not intended by the Legislature [...].

The statute upon which the defendants rely is of different character. It does not prescribe additional safeguards which pedestrians must provide for the preservation of the life or limb or property of others, or even of themselves, nor does it impose upon pedestrians a higher standard of care. What the statute does provide is rules of the road to be observed by pedestrians and by vehicles, so that all those who use the road may know how they and others should proceed, at least under usual circumstances. A general rule of conduct -- and, specifically, a rule of the road -- may accomplish its intended purpose under usual conditions, but, when the unusual occurs, strict observance may defeat the purpose of the rule and produce catastrophic results.

Negligence is failure to exercise the care required by law. Where a statute defines the standard of care and the safeguards required to meet a recognized danger, then, as we have said, no other measure may be applied in determining whether a person has carried out the duty of care imposed by law. Failure to observe the standard imposed by statute is negligence, as matter of law. On the other hand, where a statutory general rule of conduct fixes no definite standard of care which would under all circumstances tend to protect life, limb or property but merely codifies or supplements a common-law rule, which has always been subject to limitations and exceptions; or where the statutory rule of conduct regulates conflicting rights and obligations in manner calculated to promote public convenience and safety, then the statute, in the absence of clear language to the contrary, should not be construed as intended to wipe out the limitations and exceptions which judicial decisions have attached to the common-law duty; nor should it be construed as an inflexible command that the general rule of conduct intended to prevent accidents must be followed even under conditions when observance might cause accidents. We may assume reasonably that the Legislature directed pedestrians to keep to the left of the center of the road because that would cause them to face traffic approaching in that lane and would enable them to care for their own safety better than if the traffic approached them from the rear. We cannot assume reasonably that the Legislature intended that a statute enacted for the preservation of the life and limb of pedestrians must be observed when observance would subject them to more imminent danger.

[...] A pedestrian is, of course, at fault if he fails without good reason to observe the statutory rule of conduct. The general duty is established by the statute, and deviation from it without good cause is a wrong and the wrongdoer is responsible for the damages resulting from his wrong.

In each action, the judgment should be affirmed, with costs.

5.1.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926))

LEHMAN, J. The plaintiff employed the defendant to give chiropractic treatment to her for a disease or physical condition. The **defendant had no license to practice medicine**, yet he held himself out as being able to diagnose and treat disease, and under the provisions of the Public Health Law he was guilty of a misdemeanor. The plaintiff became paralyzed after she had received nine treatments by the defendant. She claims, and upon this appeal we must assume, that the paralysis was caused by the treatment she received. She has recovered judgment in the sum of $ 10,000 for the damages caused by said injury. [...]

At the close of the plaintiff's case the plaintiff was permitted to amend the complaint to allege "that in so treating the plaintiff the defendant was engaged in the practice of medicine contrary to and in violation of the provisions of the Public Health Law of the State of New York in such case made and provided, he at the time of so treating plaintiff not being a duly licensed physician or surgeon of the State of New York." Thereafter the trial judge charged the jury that they might bring in a verdict in favor of the plaintiff if they found that the evidence established

that the treatment given to the plaintiff was not in accordance with the standards of skill and care which prevail among those treating disease. He then continued: "This is a little different from the ordinary malpractice case, and I am going to allow you, if you think proper under the evidence in the case, to predicate negligence upon another theory. The public health laws of this State prescribe that no person shall practice medicine unless he is licensed so to do by the Board of Regents of this State and registered pursuant to statute. This statute to which I have referred is a general police regulation. Its violation, and it has been violated by the defendant, is some evidence, more or less cogent, of negligence which you may consider for what it is worth, along with all the other evidence in the case. If the defendant attempted to treat the plaintiff and to adjust the vertebrae in her spine when he did not possess the requisite knowledge and skill as prescribed by the statute to know what was proper and necessary to do under the circumstances, or how to do it, even if he did know what to do, you can find him negligent." In so charging the jury that from the violation of the statute the jury might infer negligence which produced injury to the plaintiff, the trial justice in my opinion erred.

The provisions of the Public Health Law prohibiting the practice of medicine without a license granted upon proof of preliminary training and after examination intended to show adequate knowledge, are of course intended for the protection of the general public against injury which unskilled and unlearned practitioners might cause. If violation of the statute by the defendant was the proximate cause of the plaintiff's injury, then the plaintiff may recover upon proof of violation; if violation of the statute has no direct bearing on the injury, proof of the violation becomes irrelevant. For injury caused by neglect of duty imposed by the penal law there is civil remedy; but of course the injury must follow from the neglect.

Proper formulation of general standards of preliminary education and proper examination of the particular applicant should serve to raise the standards of skill and care generally possessed by members of the profession in this State; but the license to practice medicine confers no additional skill upon the practitioner; nor does it confer immunity from physical injury upon a patient if the practitioner fails to exercise care. Here, injury may have been caused by lack of skill or care; it would not have been obviated if the defendant had possessed a license yet failed to exercise the skill and care required of one practicing medicine. True, if the defendant had not practiced medicine in this State, he could not have injured the plaintiff, but the protection which the statute was intended to provide was against risk of injury by the unskilled or careless practitioner, and unless the plaintiff's injury was caused by carelessness or lack of skill, the defendant's failure to obtain a license was not connected with the injury. The plaintiff's cause of action is for negligence or malpractice. The defendant undertook to treat the plaintiff for a physical condition which seemed to require remedy. Under our law such treatment may be given only by a duly qualified practitioner who has obtained a license. [...]

No case has been cited where neglect of a statutory duty has given rise to private cause of action where it has not appeared that private injury has been caused by danger against which the statute was intended to afford protection, and which obedience to the statute would have obviated. [...]

It is said that the trial justice did not charge that plaintiff might recover for defendant's failure to obtain a license but only that failure to obtain a license might be considered "some evidence" of defendant's negligence. Argument is made that even if neglect of the statutory duty does not itself create liability, it tends to prove that injury was caused by lack of skill or care. That can be true only if logical inference may be drawn from defendant's failure to obtain or perhaps seek a license that he not only lacks the skill and learning which would enable him to diagnose and treat disease generally, but also that he lacks even the skill and learning necessary for the physical manipulation he gave to this plaintiff. Evidence of defendant's training, learning and skill and the method he used in giving the treatment was produced at the trial and upon such evidence the jury could base finding either of care or negligence, but the absence of a license does not seem to strengthen inference that might be drawn from such evidence, and a fortiori would not alone be a basis for such inference. Breach or neglect of duty imposed by statute or ordinance may be evidence of negligence only if there is logical connection between the proven neglect of statutory duty and the alleged negligence.

Crane, J. (dissenting) [...] What is the rule which is to guide us in determining whether a violation of a statute or ordinance is evidence of negligence? It is no answer to say that the statute provides a penalty, and, therefore, no other consequences can follow. Such is not the law. We are to determine it, as I read the authorities, from the purpose and object of the law, and also from the fact whether a violation of the law may be the direct and proximate cause of an injury to an individual. [...]

The prohibition against practicing medicine without a license was for the very purpose of protecting the public from just what happened in this case. The violation of this statute has been the direct and proximate cause of the injury. The courts will not determine in face of this statute whether a faith healer, a patent medicine man, a chiropractor, or any other class of practitioner acted according to the standards of his own school, or according to the standards of a duly licensed physician. The law, to insure against ignorance and carelessness, has laid down a rule to be followed, namely, examinations to test qualifications, and a license to practice. If a man, in violation of this statute, takes his chances in trying to cure disease, and his acts result directly in injury, he should not complain if the law, in a suit for damages, says that his violation of the statute is some evidence of his incapacity.

5.1.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio

ANTECEDENTES DE HECHO

[...] Hechos probados

«El acusado Antonio N. G, mayor de edad y sin antecedentes penales con título de Licenciado en Medicina y Cirugía, habilitado mediante el oportuno certificado del Ministerio de Sanidad y Consumo para despeñar las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema nacional de Sanidad Español, así como en los sistemas Públicos de Seguridad Social de los demás Estados miembros de la Unión Europea, desde fechas no concretadas es el titular de la Clínica "Nueva Andalucía", sita en la calle Blas Infante, ..., de Almería que se anunciaba públicamente al menos hasta 1998 en las páginas amarillas de la guía telefónica dentro del apartado "Médicos: Cirugía Plástica y Reparadora" como clínica de estética pero donde se practican Cirugía Plástica, Liposucciones y Microcirugía, y en la que efectivamente el acusado ha venido realizando ese tipo de intervenciones de cirugía plástica y liposucciones sin estar en posesión del título correspondiente de cirugía Plástica que le habilite para ello, junto a otro tipo de intervenciones quirúrgicas, y sin adoptar las mínimas precauciones exigidas por la "lex artis" de la Medicina.

Así, en fechas próximas a los meses de marzo y abril de 1994 el acusado atendió en dicha Clínica que regenta a doña Carmen Bernardina G. H. y a doña Isabel A. T., que acudieron a su consulta para tratar sus problemas de obesidad, aconsejando el acusado a cada una en su caso que deberían someterse a una intervención de liposucción y, previamente a ello, a un tratamiento que ambas pacientes aceptaron, consistente en una formulación magistral que al principio encargaba al Farmacéutico de Málaga, don Juan M. S., quien la preparaba y encapsulaba y enviaba con su etiqueta, por indicación del acusado, a ambas pacientes a sus respectivos domicilios y que ellas abonaban directamente al citado Farmacéutico, formulación esta que con posterioridad el acusado –pese a no estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia– decidió prepararlas y encapsularlas en su clínica, y facilitarlas así a ambas pacientes, alterando la composición de los medicamentos, añadiendo otras sustancias que no figuraban en la etiqueta [...].

Posteriormente, en fechas 29 de marzo y 11 de mayo de 1994, fueron sometidas por el acusado a sendas intervenciones, previo pago por parte de cada una de ellas de 200.000 pesetas, quienes decidieron someterse a las mismas voluntariamente, concretamente de liposucción de cadera y rodillas en el caso de doña Carmen, y de caderas, parte interna de los muslos y rodillas en el caso de doña Isabel, sin observar dicho individuo las más mínimas reglas de la práctica de la Medicina, realizando análisis de sangre incontrolados en los resultados, sin disponer del apoyo de profesionales especializados para evitar complicaciones, que eran perfectamente posibles e, incluso, aparecieron, aplicando en ambas mujeres con diversas anomalías estéticas y

funcionales en las zonas intervenidas consecuencia del empleo por parte del acusado de una técnica quirúrgica y terapéutica inadecuada, lo que ha producido: En el caso de doña Carmen: secuelas: a nivel de la región femoral anterior y externa una zona de induración producida por el tacto de la fascia lata (incluso con reacción de fibrosis), con desaparición de todo el panículo adiposo a este nivel; dolor a este nivel; falta de fuerza muscular; limitación de la flexión en ambas rodillas de 120º (siendo la anormal de 135º); defecto estético a nivel de región glútea por aspiración insuficiente, no equilibrada, de exceso adiposo y cutáneo a nivel lateral de ambas rodillas y sobrecorrección zona medial, y de asimetría de las regiones femorales anteriores por sobrecorrección mayor nivel de miembro derecho; todo ello con 130 días de incapacidad, de los cuales 30 estuvo impedida para sus ocupaciones habituales. Durante la intervención sufrió un espasmo de glotis, que precisó de sutura.

En el caso de doña Isabel: Secuelas consistentes en zona de induración a nivel de cara posterior de ambas piernas, más acentuada y palpable al tacto en movimientos de fuerza o de extensión completa; este defecto se debe a una sobre corrección durante la liposucción, desapareciendo todo el panículo adiposo y habiendo originado incluso un proceso de fibrosis de la fascia muscular de la masa muscular gemelar; también, abultamientos y depresiones en piel a nivel de regiones femorales producidos por acúmulos de grasa (seromas), originados por una resección irregular; defecto a nivel cara interna de muslo derecho por resección excesiva; defecto a nivel de ambas rodillas, visible en extensión y flexión, producido por una resección excesiva; cicatriz de rasgos leves en cara posterior de pierna derecha de 3 x 2 cm; defecto estético de la silueta, ya que al tratar la región femoral y no la cresta ilíacas (están por encima), se acentúa la silueta con deformidad en violín; todo ello tardando 131 días en curar, de los que estuvo 30 incapacitada para sus ocupaciones habituales. Tras la intervención, la paciente desarrolla un cuadro de alergia al esparadrapo utilizado, pese a que constaba en la historia su alergia a una clase determinada.

Ambas mujeres necesitaron para la curación, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico, pero, además, para quedar totalmente restablecidas precisarán además de tratamiento quirúrgico mediante cirugía plástica y reparadora, con un coste estimado para cada intervención de 1.800.000 pesetas».

TERCERO

[La Sentencia del Juzgado Penal] contiene el siguiente fallo: «Que debo condenar y condeno a Antonio N. G., como autor de dos delitos de imprudencia temeraria genérica de los arts. 565,1º y 4º con relación al art. 420-1º CP 1973, a la pena, por cada uno de ellos, de seis meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del ejercicio de la profesión de Médico durante el tiempo de duración de las respectivas condenas. También, como autor de un delito de intrusismo profesional del art. 403, párrafo primero, inciso segundo, con relación al subtipo agravado del párrafo segundo del CP 1995 (carencia de título oficial referente a la especialidad médica de Cirugía Plástica y Reparadora, con ostentación pública de ello), a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico durante el tiempo de la condena. Igualmente, como autor de otro delito de intrusismo profesional de párrafo primero, inciso primero, del art. 403 CP (falta de título académico de farmacéutico) a la pena de multa de nueve meses, con cuota diaria de 2.000 pesetas, lo que hace un total de 540.000 pesetas, que se pagarán en dos plazos como máximo, y caso de impago de la misma, previa excusión de bienes, a un arresto sustitutorio equivalente a un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas. […].

En cuanto a responsabilidad civil indemnizará:

A doña Carmen Bernardina G. H. en 150.000 pesetas por los 30 días de incapacidad sufridos; por los 130 días de curación 390.000 pesetas; por la intervención quirúrgica que tiene pendiente, la cantidad de 1.800.000 pesetas; por secuela, alzadamente 7.000.000 de pesetas.

A doña Isabel A. T. en 150.000 pesetas por los 30 días de incapacidad sufridos; en 393.000 pesetas por los 131 días de curación; en 1.800.000 pesetas por la intervención quirúrgica de la que pende; en 7.000.000 de pesetas por las secuelas […]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

[…E]s doctrina extensa y pormenorizada respecto de la imprudencia médica la que recuerda:

> a) Que el error de diagnóstico, por regla general no es tipificable, salvo que por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable.
> b) Que queda fuera del ámbito penal, por la misma razón, la falta de pericia cuando ésta sea de naturaleza extraordinaria y excepcional.
> c) Que la determinación de la responsabilidad médica debe hacerse en contemplación de las circunstancias concretas del caso sometido a enjuiciamiento.
> d) Que la imprudencia nace cuando el tratamiento médico y quirúrgico incide en comportamientos descuidados, de abandono y omisión de los cuidados exigibles, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas y naturaleza de la lesión o enfermedad que olvidando la "lex artis" conduzca a resultados lesivos».

Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa resulta que […] existen una serie de datos probatorios que acreditan un proceder negligente en la conducta del facultativo porque el mismo carecía de la titulación suficiente para que llevara a cabo este tipo de operaciones, que por su envergadura y complejidad no debe ser realizado con la titulación de médico de medicina general, ya que la otra titulación aportada consistente en un documento expedido por la denominada Sociedad Española de Medicina Estética, se desconoce en qué consiste el mismo ni la naturaleza de la entidad que lo expide ya que no tiene el carácter de un organismo oficial. […].

Por otra parte no podemos ignorar las circunstancias previas a la operación de las perjudicadas en donde la analítica no resulta debidamente contrastada. […] Por consiguiente no hay constancia de que se hubiese llevado a cabo un preoperatorio adecuado.

Además las operaciones se efectuaron en un quirófano preparado para cirugía menor utilizando anestesia local a pesar de la larga duración de dichas operaciones […].

Finalmente debe tenerse en cuenta el resultado alcanzado consistente en lesiones graves y deformidades en los miembros inferiores de las denunciantes que necesitan de una operación de cirugía plástica para reparar las mismas […].

Con tales presupuestos fácticos no podemos sino considerar […] que el resultado producido ha sido por una culpa o negligencia inexcusable, por pretenderse efectuar unas operaciones de gran complejidad con escasos medios y utilizando técnicas de cirugía menor, sin tener la titulación adecuada para desarrollar dicha actividad, ni siquiera la experiencia que hubiese suplido dicha falta de titulación como lo acredita el resultado producido. […]

Se alega también por la parte recurrente una errónea valoración de la prueba. […] Se fundamenta este recurso en el hecho de que para realizar este tipo de operaciones de liposucción no es necesario tener una titulación específica bastando tener la titulación de médico de medicina general para poder atender problemas como el que motivó la intervención quirúrgica, es decir una obesidad de las denunciantes que fue tratada inicialmente con pastillas hasta que se vio conveniente la necesidad de efectuar la liposucción. En apoyo de su tesis se citan las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 23 marzo (RJ 1995\2699) y 16 junio de 1995 (RJ 1995\4917), entre otras, que precisan que la profesión de médico es una y sólo una siendo las especialidades variaciones de una única profesión... «en general cualquier médico sea o no especialista puede atender cualquier enfermedad a cualquier enfermo, incluso sobre aspectos de especialidad ajena, ya que el título de médico especialista sólo es necesario para ejercer la profesión con este carácter, es decir, no para ejercer la profesión, sino para ejercerla como especialista» […].

Con independencia de que la argumentación de la sentencia que se invoca debe ser aceptada por este Tribunal, en cuanto que supone una formulación genérica de la obligación y derecho de todo médico de prestar asistencia sanitaria de un modo general para atender cualquier tipo de enfermedad sin necesidad de ser especialista, sin embargo ello no supone que se pueda dar licencia o autorización para que cualquier médico ejercite la medicina desarrollando actividades propias de las especialidades médicas que como tales vienen definidas en el artículo 1 del Real Decreto 127/1984 de 11 de enero por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista. El límite entre la especialidad y la medicina general vendrá determinado en cada caso por las circunstancias concurrentes puesto que frecuentemente desde un médico generalista se llega al médico especialista a través del consejo y dirección de este último, sin perjuicio de que pueda tratarse y curar determinadas dolencias de escasa importancia, o de mayor en caso de urgencia médica, según las circunstancias, siendo el propio médico el que mejor puede trazar esa línea divisoria entre la especialización y la medicina general ya que ha estudiado las distintas asignaturas y ramas de la medicina sobre las que posteriormente se configuran las especialidades médicas. Es precisamente en esta línea divisoria en donde en cada caso concreto habrá que examinar en qué medida el médico que no tiene la especialización, equivalente a título oficial a efectos penales, ha podido incurrir en un delito de intrusismo por carecer de la titulación oficial necesaria sin perjuicio de que tenga la titulación de médico de medicina general.

[...] Este tipo de intervenciones quirúrgicas son propias de la cirugía plástica y reparadora, siendo ésta una especialidad médica para la que se requiere cinco años de preparación tras haber aprobado el correspondiente examen selectivo, lo que unido a los seis años de duración normal de la carrera de medicina determinan una preparación altamente cualificada para llevar a cabo intervenciones encuadrables en este tipo de especialidad [...].

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Antonio N. G. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Almería, de fecha 24-2-2000 debemos confirmar y confirmamos el fallo de dicha resolución, con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada.

5.1.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999))

ROSENBLATT, J. Education Law § 905(1) requires school authorities in the State of New York to examine students between eight and sixteen years of age for scoliosis at least once in each schoolyear. The principal issue on this appeal is whether the statute authorizes a private right of action.

During the 1992–1993 school year, the infant plaintiff was a seventh grade student at the Goff Middle School, operated by defendant East Greenbush Central School District. In October 1992, as part of a school program, a nurse screened her for scoliosis. The results were negative. She was examined during the following school year (1993–1994) by a school nurse who checked her height, weight and vision but allegedly did not screen her for scoliosis.

In March 1995, when the infant plaintiff was a ninth grader during the 1994–1995 school year at Columbia High School (also operated by the East Greenbush Central School District), a school nurse screened her for scoliosis and the examination proved positive. Her parents, who are also plaintiffs in this action, then had her examined by an orthopedic doctor who concluded that her scoliosis had progressed to the point that surgery was required instead of the braces that often can be utilized when the condition is diagnosed earlier. The infant plaintiff underwent surgery in July 1995.

Plaintiffs have alleged two causes of action against the East Greenbush Central School District and its Board of Education (collectively "the District"). One is based on a claimed violation of Education Law § 905(1), one on common law negligence. Plaintiffs assert, in essence, that the District was negligent in failing to examine the infant plaintiff for scoliosis during the 1993–

1994 school year, as a result of which her ailment was allowed to progress undetected, to her detriment. Supreme Court granted the District's motion for summary judgment, holding that Education Law § 905(1) does not create a private right of action, and that plaintiffs had otherwise failed to state a claim for common law negligence. The Appellate Division affirmed. We granted leave to appeal to this Court and now affirm.

THE RELEVANT STATUTES

[...] Education Law § 905(1) states that "[m]edical inspectors or principals and teachers in charge of schools in this state shall . . . examine all . . . pupils between eight and sixteen years of age for scoliosis, at least once in each school year." Education Law § 905(2) provides that "[n]othwithstanding any other provisions of any general, special or local law, the school authorities charged with the duty of making such tests or examinations of pupils for the presence of scoliosis pursuant to this section shall not suffer any liability to any person as a result of making such test or examination, which liability would not have existed by any provision of law, statutory or otherwise, in the absence of this section." Finally, Education Law § 911 charges the Commissioner of Education with the duty of enforcing the provisions of sections 901 through 910 of the Education Law and authorizes the Commissioner to "adopt rules and regulations" for such purpose.

THE TEST FOR THE AVAILABILITY OF A PRIVATE RIGHT OF ACTION

The District's obligation to examine for scoliosis is, as plaintiffs point out, plain enough. A statutory command, however, does not necessarily carry with it a right of private enforcement by means of tort litigation.

The availability of a private right of action for the violation of a statutory duty –– as opposed to one grounded in common law negligence –– is not a new concept. When a statute itself expressly authorizes a private right of action, there is no need for further analysis. When a statute is silent, as it is here, courts have had to determine whether a private right of action may be fairly implied. [...] In making the determination, we ask:

"(1) whether the plaintiff is one of the class for whose particular benefit the statute was enacted;
"(2) whether recognition of a private right of action would promote the legislative purpose; and
"(3) whether creation of such a right would be consistent with the legislative scheme".

[After concluding that the plaintiffs satisfied the first two parts, the court discussed the last requirement]. Plaintiffs argue that a private right of action is not only consistent with Education Law § 905(1) but also necessary for its operation. They assert that the statute offers no other practical means of enforcement and that a private right of action is imperative, in order to give it life. We disagree and conclude that a private right of action would not be consistent with the statutory scheme. To begin with, the statute carries its own potent official enforcement mechanism. The Legislature has expressly charged the Commissioner of Education with the duty to implement Education Law § 905(1) and has equipped the Commissioner with authority to adopt rules and regulations for such purpose (see, Education Law §§ 905[1], 911). Moreover, the Legislature has vested the Commissioner with power to withhold public funding from noncompliant school districts. Thus, the Legislature clearly contemplated administrative enforcement of this statute. The question then becomes whether, in addition to administrative enforcement, an implied private right of action would be consistent with the legislative scheme.

It would not. The evolution of Education Law § 905(2) is compelling evidence of the Legislature's intent to immunize the school districts from any liability that might arise out of the scoliosis screening program. By the language of Education Law § 905(2) the Legislature deemed that the school district "shall not suffer any liability to any person as a result of making such examination" (emphasis added). Plaintiffs contend that by implication, the District is denied immunity for failing to perform the examination. In effect, plaintiffs would interpret the statute as conferring immunity for misfeasance but not nonfeasance. On the other hand, the District

contends that it would be incongruous for the Legislature to accord immunity for one circumstance but not the other.

Plaintiffs' reading of the statute might have some appeal if we did not have persuasive evidence as to the Legislature's intent to immunize the school districts for both nonfeasance and misfeasance. [...] Revealingly, the Legislature evidently saw no need to amend Education Law § 905 in any other way, although obviously aware of the two Appellate Division decisions on that point. Its failure to otherwise amend the statute is strong evidence of the Legislature's conclusion that the Appellate Divisions had correctly interpreted the statute's immunity provision.

There is also the matter of cost to the school districts, as evidenced by the Legislature's expressed sensitivity in that regard. Orthopedists through the New York State Society of Orthopaedic Surgeons and other professionals from the Scoliosis Association, Inc. agreed to volunteer their time and expertise to train existing school personnel on the relatively simple examination procedure. In forecasting its cost, the Legislature anticipated that the program would have minimal financial impact on school districts (Budget Report on Bills, Bill Jacket, L 1978, ch 202). Allowing a private right of action against the government as opposed to a private entity has direct and obvious financial consequences to the public.

Given the Legislature's concern over the possible costs to the school districts –– as evidenced by the statutory immunity provision and the other legislative statements reflecting those concerns –– we conclude that the Legislature did not intend that the districts bear the potential liability for a program that benefits a far wider population. If we are to imply such a right, we must have clear evidence of the Legislature's willingness to expose the governmental entity to liability that it might not otherwise incur. The case before us reveals no such legislative intent.

In sum, we conclude that a private right of action to enforce Education Law § 905(1) is inconsistent with the statute's legislative scheme and therefore cannot be fairly implied.

COMMON LAW NEGLIGENCE

[The Court then held that the plaintiffs did no state a cause of action for common law negligence]

Affirmed.

La Sala Primera del Tribunal Supremo acoge la figura de la negligencia per se, aunque, normalmente, de acuerdo con la doctrina del fin de protección de la norma, un criterio de imputación objetiva. Sin embargo, el Tribunal, incluso en sentencias recientes, se aferra a la noción según la cual el cumplimiento de la normativa no excusa de la negligencia imputada al demandado si hubo daño, pues la producción del daño implica culpa en cuanto señaliza que el demandado no adoptó precauciones suficientes o las necesarias para evitar la producción del daño: las necesarias y exigibles, pero no todas, habría que matizar: las precauciones necesarias para evitar la producción del daño pueden ser infinitas.

5.1.7. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre

El 20.8.1992, la U.T.E, formada por "Obras Subterráneas, S.A." y "Auxini, S.A.", encargó al mecánico Miguel Ángel la sustitución de una pieza del sistema de freno de una retroexcavadora en el exterior de una mina situada en Balsareny (Barcelona). Para ello, el conductor de la retroexcavadora hincó una palanca en el suelo a fin de que la presión ejercida por ésta levantara la rueda trasera y, cuando Miguel Ángel se disponía a colocar debajo un taco de madera, uno de los pistones del mecanismo de la palanca cedió provocando la caída brusca de la parte trasera de la máquina que le aprisionó y le causó la muerte.

Luisa, viuda de Miguel Ángel, en nombre propio y en el de su hijo menor Francisco, demandó a "Obras Subterráneas, S.A." y a "Auxini, S.A." y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 5 de Manresa (23.5.1997) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 9.12.1998) estimó el recurso de apelación y condenó a las sociedades demandadas a pagar 120.202,42 €.

El TS desestima el recurso de casación: resuelve que el encargado y el capataz de las sociedades demandadas omitieron negligentemente medidas de precaución, pues consintieron que, como ya había ocurrido en otras ocasiones, se acometiera la reparación de forma arriesgada cuando el resultado finalmente producido era previsible. Señala el Tribunal en el Fundamento 2º de la Sentencia:

"No basta para excluir dicha declaración de culpabilidad la inexistencia de infracción reglamentaria sostenida por las recurrentes en base a ciertos informes incorporados a los autos, ya que, dada la naturaleza de la operación que se estaba realizando, es claro que la misma no era objeto de regulación de tal clase. Además, ha de citarse en este sentido la doctrina de esta Sala expresada, entre otras, en sentencias de 22 de abril de 2003 (RJ 2003, 3545) , 18 de junio (RJ 2004, 4431) y 8 de octubre de 2004 (RJ 2004, 6693), según la cual la imputación subjetiva del acto lesivo, con un fundamento de reproche culpabilístico, se basa en que la producción del daño indica que no se han tomado las precauciones o no se ha actuado con el cuidado necesario para impedirlo, revelando que las garantías adoptadas conforme a las disposiciones vigentes para evitar los daños posibles no han ofrecido resultado positivo, poniéndose de manifiesto la insuficiencia de las mismas y que no se hallaba completa la diligencia, y así precisa la última de las sentencias citadas que «no resulta suficiente la que podría denominarse diligencia reglamentaria, si la realidad fáctica evidencia que las medidas adoptadas para evitar los daños previsibles han resultado ineficaces, pues la diligencia que ha de adoptarse en el cumplimiento de las obligaciones comprende no solo las prevenciones y cuidados reglamentarios sino además todos los que la prudencia imponga para evitar los eventos dañosos".

5.1.8. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero

Un joven de 27 años falleció por inhalación de monóxido de carbono desprendido por un calentador de agua a gas que se hallaba en la cocina del piso que compartía con Daniel.

Los padres del fallecido, Leonardo y Rosa, demandan a "Repsol Butano, SA", a Daniel, y a los propietarios del piso, Luis Pedro y Eva, y solicitan una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 3 de León (2.5.1997) estima la demanda en parte: absuelve a Daniel y condena a "Repsol Butano, SA" por deficiencias en la instalación y en el funcionamiento del calentador y a Luis Pedro y Eva por carecer la cocina de rejillas de ventilación al pago de una indemnización de 49.619,56 €, por cuotas del 50 % la primera y 50 % los segundos. La AP de León (Sección 2ª, 27.1.1998) estima el recurso de apelación de "Repsol Butano, SA", revoca la SJPI y condena sólo a Luis Pedro y Eva a abonar a los actores una indemnización de 36.060,73 €.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación de los actores. El TS resuelve que la casación no es una tercera instancia en la que pueda modificarse el relato de los hechos probados: "Repsol Butano, SA" sólo era suministradora de las bombonas de butano utilizadas en el calentador y, además, no las entregaba siquiera en el domicilio citado. Señala el Tribunal Supremo:

> "FJ 4º: No se cita [en el motivo de casación sobre posible culpa exclusiva de la víctima] norma ni jurisprudencia alguna como infringida, sin que a tal efecto pueda valer la de un artículo del Decreto de 11 de septiembre de 1992 sobre obligaciones del usuario de una instalación de gas, pues bien sabido es que según reiteradísima jurisprudencia de esta Sala las normas administrativas o reglamentarias carecen de idoneidad para sustentar por sí solas un motivo de casación civil".

5.1.9. *Preemption*

Como indicábamos al inicio de la Sesión, una de las cuestiones básicas del moderno derecho de daños es si las previsiones del legislador sobre la regulación de tal o cual actividad cierran o no el sistema de remedios al ejercicio de una pretensión civil de reparación o indemnización del daño causado. Así por ejemplo, cabe preguntar:

¿En el caso de que una conducta dañina esté prevista por una legislación específica que establezca las consecuencias de su realización, se aplica además el art. 1902 CC? ¿Si es así, se aplica cumulativamente?, ¿lo hace subsidiariamente?, ¿lo hace solo en la medida en que el daño no haya quedado íntegramente reparado con la aplicación de la ley infringida?

¿Tiene un trabajador accidentado una pretensión civil adicional a aquella o a aquellas que le reconoce el derecho laboral y de la seguridad social?

¿Tiene un cónyuge, excónyuge o persona integrante de una relación de pareja análoga a la matrimonial acciones de daños además de las pretensiones previstas por la legislación matrimonial para el caso de las crisis de pareja?

¿Responde el Estado legislador por la aprobación de una ley cuya aplicación daña al demandante?

Fernando Gómez Pomar, "Responsabilidad extracontractual y otras fuentes de reparación de daños: Collateral Source Rule y afines", InDret 1/1999 (www.indret.com).

Textos relacionados con las cuestiones planteadas:

a) Artículo 123 LGSS. Recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

b) Competencia de jurisdicción:

b.1) STS, 1ª, 1217/2008, de 15 de diciembre

La Sala de lo Social es la única competente para conocer de las demandas de responsabilidad civil por accidente de trabajo entre empleado y empleador.

El 27.11.1997, Juan Alberto, quien prestaba servicios para "Colafe Construcciones Extremeñas, S.A.", sufrió un accidente cuando trabajaba en la colocación de un ascensor en una obra, causado por un fallo en la sujeción del chasis en el puntal de aquél. El trabajador no llevaba el cinturón de seguridad. Como consecuencia del accidente, Juan Antonio quedó impedido para la realización de las tareas habituales de su profesión.

Juan Antonio demandó la constructora y solicitó una indemnización de 180.303,63 €. El JPI núm. 6 de Badajoz (3.3.2000) desestima la demanda. La AP de Badajoz (Sección 2ª, 24.11.2000) desestima el recurso de apelación y confirma la SJPI.

El TS se abstuvo de conocer el recurso de casación y declaró la nulidad de todas las actuaciones. Apreció falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer la reclamación de responsabilidad planteada, pues es consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo por parte del empresario (FD 3º).

En el mismo sentido: STS, 1ª, 1395/2008, de 15 de enero; STS, 1ª, 267/2008, de 16 de abril; STS, 1ª, 367/2008, de 19 de mayo; STS, 1ª, 513/2008, de 4 de junio; STS, 1ª, 1060/2008, de 17 de noviembre; STS, 1ª, 1061/2008, de 17 de noviembre. *Cfr.* con STS, 1ª, 1118/2008, de 19 de noviembre.

b.2) STS, 1ª, 587/2009, 11 de septiembre

Competencia del orden civil para conocer de demandas por accidentes de trabajo interpuestas con anterioridad a la STS, 1ª, Pleno, 15.1.2008.

El 15.12.1993, a las 16:30 horas, Millán, de 27 años de edad, realizaba tareas de selección de pescado en una embarcación propiedad de Constanza. Iba vestido con impermeable y botas de goma de suela antideslizante, y cargaba unas cajas vacías cuando, a causa de un golpe de mar, perdió el equilibrio y cayó al agua por un hueco que, de haber tendido dimensiones inferiores, hubiera impedido la caída, y falleció ahogado.

La mujer e hijos de la víctima demandaron a Constanza, propietaria del barco, y solicitaron una indemnización de 480.809,68 €.

El JPI núm. 48 de Barcelona (15.6.1999) estimó en parte la demanda y condenó a la demandada al pago de 48.080,97 euros con base en los arts. 1902 y 1903 CC. Ambas partes recurrieron en apelación. La AP de Barcelona (Sección 1ª, 15.4.2000) desestimó el de la demandada y estimó en parte el de la actora en el sentido de aumentar la indemnización a 209.278,72 euros.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada:

"[L]os usos y costumbres de la mar aceptan determinados riesgos. Ahora bien, estos riesgos están pensados más en la efectividad de la pesca que en la seguridad del trabajador … El golpe de mar es un hecho previsible y previsible era también que un marinero pudiera caer, como cayó, por efecto de este golpe de mar y de la inclinación del barco por un hueco que, de haber tenido unas dimensiones inferiores, nunca se hubiera producido" (FD. 3º).

El Tribunal resolvió, en contra de los precedentes judiciales, a favor de la competencia del orden civil:

"Sin duda la jurisdicción es un presupuesto procesal absoluto para el válido desarrollo de la relación jurídico procesal y como tal de obligada observancia por su naturaleza de orden público … Sin embargo, la aceptación de las anteriores conclusiones, no es suficiente para considerar que la competencia jurisdiccional sobre la pretensión ejercitada en este proceso corresponde al orden social y negar la legitimidad del orden jurisdiccional civil para conocer de un asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada jurisprudencia al respecto. Lo contrario contradice la misma esencia del derecho a la tutela judicial efectiva, pues contrario a esta tutela es que a partir de una interpretación posterior de la normativa, y después de que han pasado más de diez años desde que se interpuso la demanda, se inadmita a trámite en la jurisdicción en la que había sido planteada, pasando absolutamente por alto que este mismo Tribunal, en ocasiones y, precisamente tras ponderar las circunstancias del caso, acuñó la doctrina del peregrinaje enraizando principios procesales con los constitucionalmente protegidos -la tutela judicial efectiva sin indefensión, y la evitación de dilaciones indebidas-".

Con posterioridad, el TS ha mantenido este nuevo criterio en la STS, 1ª, 9.3.2010 (JUR 2010 131735; MP: Juan Antonio Xiol Ríos).

b.3) Art. 2 b) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

"**Artículo 2.** Ámbito del orden jurisdiccional social.
Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
(…)
b. En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

c) STS, 3ª, de 3 de noviembre de 2008

A las 11:30 h. del 29.11.1996, Patricia, celadora en el centro de especialidades del complejo hospitalario "Xeral Calde" (Lugo), dependiente del Servicio Gallego de Salud ("SERGAS"), bajaba en el ascensor de dicho complejo cuando, debido a un fallo mecánico, el ascensor cayo desde la 3ª planta, chocando con el amortiguador situado en el foso del sótano del edificio. Como consecuencia del accidente, Patricia sufrió traumatismos múltiples y precisó de atención psiquiátrica hasta 1998. La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo (29.1.1999) declaró que las secuelas derivadas del accidente de trabajo por Patricia eran constitutivas de invalidez permanente absoluta en grado de gran invalidez y reconoció el derecho de ésta a percibir una pensión mensual de 1.404,84 € con un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad.

Patricia demandó al "SERGAS" y a la Xunta de Galicia y solicitó una indemnización de 1.031.171,25 €, que la Consellería denegó por silencio administrativo. El TSJ Galicia (Sección 1ª, 3.3.2004) estimó el recurso contencioso administrativo y condenó a las administraciones codemandadas al pago de 300.500 €

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por el "SERGAS" y la Xunta de Galicia. El TS, tras desestimar los argumentos por los cuales la demandante debería haber llamado al proceso a la empresa fabricante del ascensor y la encargada de su mantenimiento, analizó el motivo central del recurso, a saber, si la existencia de una relación de empleo público entre víctima y Administración anulaba la responsabilidad patrimonial de esta última. El TS resolvió que, por más que el daño se habuiera producido en el desarrollo de una relación de servicio público, el accidente quedaba fuera de los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión, de manera que la lesión era antijurídica, máxime cuando la empleada no tuvo la más mínima intervención en el accidente (F. D. 5º).

5.2. *Res ipsa loquitur*

Los tribunales españoles han recibido la doctrina de denominada *"Res ipsa loquitur"* –"las cosas hablan por sí mismas"–, en virtud de la cual si el accidente ha tenido lugar en circunstancias tales que, normalmente y a ojos de un observador razonable, tales accidentes suelen ocurrir por negligencia del demandado, entonces la existencia de esta última se presume salvo prueba en contrario. Se trata así de conductas que normalmente son dañinas solo porque son negligentes, pues en ausencia de culpa el daño no tiene lugar. La doctrina encuentra su mayor dificultad en aquellos casos, que son legión, en los cuales a la presumible negligencia del demandado se suma la presunta negligencia del demandante. Los casos que se citan a continuación dan razón del alcance de esta doctrina y de sus límites.

5.2.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863))

[Plaintiff's complaint stated that he was passing along the highway in front of defendant's premises when he was struck and badly hurt by a barrel of flour that was apparently being lowered from a window above, which was on the premises of the defendant, a dealer in flour. Several witnesses testified that they saw the barrel fall and hit plaintiff. The defendant claimed "that there was no evidence of negligence for the jury". The trial court, agreeing, nonsuited plaintiff after the jury had assessed the damages at £50. On appeal in the Court of Exchequer, the plaintiff argued that the evidence was sufficient to support a verdict in his favor. In response, the defendant's lawyer argued that it was consistent with the evidence that the purchaser of the flour or some complete stranger was supervising the lowering of the barrel of flour and that its fall was not attributable in any way to defendant or his servants. POLLOCK, C.B.: "The presumption is that the defendant's servants were engaged in removing the defendant's flour. If they were not it was competent to the defendant to prove it". Defendant's attorney replied that "Surmise ought not to be substituted for strict proof when it is thought to fix a defendant with serious liability. The plaintiff should establish his case by affirmative defense [...] The plaintiff was bound to give affirmative proof of negligence. But there was not a scintilla of evidence, unless the occurrence is of itself evidence of negligence". POLLOCK, C.B.: "There are certain cases of which it may be said res ipsa loquitur and this seems one of them. In some cases the Court had held that the mere fact of the accident having occurred is evidence of negligence, as, for instance, in the case of railway collisions"].

POLLOCK, C.B. We are all of opinion that the rule must be absolute to enter the verdict for the plaintiff. The learned counsel was quite right in saying that there are many accidents from which no presumption of negligence can arise, but I think it would be wrong to lay down as a rule that in no case can presumption of negligence arise from the fact of an accident. Suppose in this case the barrel had rolled out of the warehouse and fallen on the plaintiff, how could he possibly ascertain from what cause it occurred? It is the duty of persons who keep barrels in a warehouse to take care that they do not roll out, and I think that such a case would, beyond all doubt, afford prima facie evidence of negligence. A barrel could not roll out of a warehouse without some negligence, and to say that a plaintiff who is injured by it must call witnesses from the warehouse to prove negligence seems to me preposterous. So in the building or repairing a house, or putting pots on the chimneys, if a person passing along the road is injured by something falling upon him, I think the accident alone would be prima facie evidence of negligence. Or if an article calculated to cause damage is put in a wrong place and does mischief, I think that those whose duty it was to put it in the right place are prima facie responsible, and if there is any state of facts to rebut the presumption of negligence, they must prove them. The present case upon the evidence comes to this, a man is passing in front of the premises of a dealer in flour, and there falls down upon him a barrel of flour. I think it apparent that the barrel was in the custody of the defendant who occupied the premises, and who is responsible for the acts of his servants who had the control of it; and in my opinion the fact of its falling is prima facie evidence of negligence, and the plaintiff who was injured by it is not bound to shew that it could not fall without negligence, but if there are any facts inconsistent with negligence it is for the defendant to prove them. [Judgment affirmed].

5.2.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986))

BOWNES, Circuit Judge.

Appellants are plaintiffs in a diversity action to recover damages for injuries they suffered in an accident while riding an escalator. After the parties had presented their evidence, the defendants moved for and were granted a directed verdict. The court held that there was no evidence of negligence and that the doctrine of res ipsa loquitur, which would raise a presumption of negligence, did not apply. We reverse the directed verdict and remand the case to the district court because we hold that res ipsa loquitur does apply.

I. BACKGROUND

The relevant facts are not in dispute. On February 12, 1984, Jose Domingo Colmenares Vivas and his wife, Dilia Arreaza de Colmenares, arrived at the Luis Muñoz Marin International Airport in Puerto Rico. They took an escalator on their way to the Immigration and Customs checkpoint on the second level. Mrs. Colmenares was riding the escalator on the right-hand side, holding the moving handrail, one step ahead of her husband. When the couple was about halfway up the escalator, the handrail stopped moving, but the steps continued the ascent, causing Mrs. Colmenares to lose her balance. Her husband grabbed her from behind with both hands and prevented her from falling, but in doing so, he lost his balance and tumbled down the stairs. Mr. and Mrs. Colmenares filed a direct action against the Sun Alliance Insurance Company, who is the liability insurance carrier for the airport's owner and operator, the Puerto Rico Ports Authority. Sun Alliance brought a third-party contractual action against Westinghouse Electric Corporation based on a maintenance contract that required Westinghouse to inspect, maintain, adjust, repair, and replace parts as needed for the escalator and handrails, and to keep the escalator in a safe operating condition. […]

The trial was conducted on January 30 and 31, 1986. Appellants called four witnesses. The Ports Authority's contract and maintenance supervisor testified about his daily weekday inspections of the escalator, about the maintenance contract with Westinghouse, about inspection and maintenance procedures, and about the accident report and subsequent repair and maintenance of the escalator. The Ports Authority's assistant chief of operations testified about the accident report. Appellants' testimony concerned the accident and their injuries.

[…] After hearing the parties' arguments, the court ruled that there was no evidence that the Ports Authority had been negligent, and that the case could not go to the jury based on res ipsa loquitur because at least one of the requirements for its application -- that the injury-causing instrumentality was within the exclusive control of the defendant -- was not met […].

II. RES IPSA LOQUITUR

Under Puerto Rico law, three requirements must be met for res ipsa loquitur, ("the thing speaks for itself"), to apply: "(1) the accident must be of a kind which ordinarily does not occur in the absence of someone's negligence; (2) it must be caused by an agency or instrumentality within the exclusive control of defendant; [and] (3) it must not be due to any voluntary action on the part of plaintiff." Community Partnership v. Presbyterian Hospital.. . If all three requirements are met, the jury may infer that the defendant was negligent even though there is no direct evidence to that effect. […]

A. The First Requirement: Inference of Negligence

The first requirement that must be met for res ipsa loquitur to apply is that "the accident must be such that in the light of ordinary experience it gives rise to an inference that someone has been negligent". It is not clear to us whether the district court decided that this requirement was met, although the court did suggest that it was giving the benefit of the doubt on this question to the appellants. We hold that this requirement was met because an escalator handrail probably would not stop suddenly while the escalator continues moving unless someone had been negligent.

This requirement would not be met if appellants had shown nothing more than that they had been injured on the escalator, because based on this fact alone it would not be likely that someone other than the appellants had been negligent. […]. Here, it was not disputed that the handrail malfunctioned and stopped suddenly, an event that foreseeably could cause riders to lose their balance and get injured. Thus, the evidence gave rise to an inference that someone probably had been negligent in operating or maintaining the escalator, and the first requirement for the application of res ipsa loquitur was met.

B. The Second Requirement: Exclusive Control

The second requirement for res ipsa loquitur to apply is that the injury-causing instrumentality -- in this case, the escalator -- must have been within the exclusive control of the defendant. The district court found that this requisite was not met, despite the parties' stipulation that "the escalator in question is property of and is under the control of the Puerto Rico Ports Authority." We agree that this stipulation was not by itself enough to satisfy the res ipsa loquitur requirement. It did not exclude the possibility that someone else also had control over the escalator; indeed, the stipulation said that Westinghouse maintained the escalator. We hold, however, that the Ports Authority effectively had exclusive control over the escalator because the authority in control of a public area has a nondelegable duty to maintain its facilities in a safe condition.

Few courts have required that control literally be "exclusive." [...]. The exclusive control requirement, then, should not be so narrowly construed as to take from the jury the ability to infer that a defendant was negligent when the defendant was responsible for the injury-causing instrumentality, even if someone else might also have been responsible. The purpose of the requirement is not to restrict the application of the res ipsa loquitur inference to cases in which there is only one actor who dealt with the instrumentality, but rather "to eliminate the possibility that the accident was caused by a third party." [...] It is not necessary, therefore, for the defendant to have had actual physical control; it is enough that the defendant, and not a third party, was ultimately responsible for the instrumentality. Thus, res ipsa loquitur applies even if the defendant shares responsibility with another, or if the defendant is responsible for the instrumentality even though someone else had physical control over it. [...] It follows that a defendant charged with a nondelegable duty of care to maintain an instrumentality in a safe condition effectively has exclusive control over it for the purposes of applying res ipsa loquitur. [...] Unless the duty is delegable, the res ipsa loquitur inference is not defeated if the defendant had shifted physical control to an agent or contracted with another to carry out its responsibilities.

We hold that the Ports Authority could not delegate its duty to maintain safe escalators. There are no set criteria for determining whether a duty is nondelegable; the critical question is whether the responsibility is so important to the community that it should not be transferred to another. [...]. The Ports Authority was charged with such a responsibility. It was created for a public purpose, which included the operation and management of the airport. ... A concomitant of this authority is the duty to keep the facilities it operates in a reasonably safe condition. The public is entitled to rely on the Ports Authority -- not its agents or contractors -- to see that this is done. The Ports Authority apparently recognized this responsibility, for its maintenance and contract supervisor conducted daily weekday inspections of the escalators despite the maintenance contract with Westinghouse.

Duties have been seen as nondelegable in several analogous situations. For example, a public authority may not delegate to an independent contractor its responsibility to see that work in a public place is done carefully. [...] Also, a government may not delegate its responsibility to maintain safe roads and similar public places. [...] Finally, an owner has a nondelegable duty to keep business premises safe for invitees. [...] These examples demonstrate a general tort law policy not to allow an entity to shift by contract its responsibility for keeping an area used by the public in a safe condition. It would be contrary to this policy to allow the owner and operator of an airport terminal to delegate its duty to keep its facility safe. We hold, therefore, that the district court erred in ruling that the exclusive control requirement was not met.

C. The Third Requirement: The Plaintiffs' Actions

The third requirement that must be met for res ipsa loquitur to apply is that the accident must not have been due to the plaintiff's voluntary actions. The district court found, and we agree, that there was no evidence that Mr. and Mrs. Colmenares caused the accident. Indeed, there is no indication that they did anything other than attempt to ride the escalator in the ordinary manner. Therefore, we hold that all three requirements were met and that the jury should have

been allowed to consider whether the Ports Authority was liable based on the permissible inference of negligence raised by the application of res ipsa loquitur. [...]

TORRUELLA, Circuit Judge dissenting. I must regretfully dissent. […] In my view, solely because the handrail stopped and Mrs. Colmenares fell, without further evidence as to why or how the handrail malfunctioned, does not give rise to an inference of negligence by the Ports Authority. […]

The malfunctioning of an escalator presents an even stronger argument against the raising of an inference of negligence without additional proof as to the cause of the malfunction. Although a court can take notice that an escalator is a complicated piece of machinery, it has no basis of common knowledge for inferring that its malfunction is the result of the operator's negligence.

5.2.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687)

GIBSON, C. J. This is an action for damages for personal injuries alleged to have been inflicted on plaintiff by defendants during the course of a surgical operation. The trial court entered judgments of nonsuit as to all defendants and plaintiff appealed.

On October 28, 1939, plaintiff consulted defendant Dr. Tilley, who diagnosed his ailment as appendicitis, and made arrangements for an appendectomy to be performed by defendant Dr. Spangard at a hospital owned and managed by defendant Dr. Swift. Plaintiff entered the hospital, was given a hypodermic injection, slept, and later was awakened by Drs. Tilley and Spangard and wheeled into the operating room by a nurse whom he believed to be defendant Gisler, an employee of Dr. Swift. Defendant Dr. Reser, the anesthetist, also an employee of Dr. Swift, adjusted plaintiff for the operation, pulling his body to the head of the operating table and, according to plaintiff's testimony, laying him back against two hard objects at the top of his shoulders, about an inch below his neck. Dr. Reser then administered the anesthetic and plaintiff lost consciousness. When he awoke early the following morning he was his hospital room attended by defendant Thompson, the special nurse, and another nurse who was not made a defendant.

Plaintiff testified that prior to the operation he had never had any pain in, or injury to, his right arm or shoulder, but that when he awakened he felt a sharp pain about half way between the neck and the point of the right shoulder. He complained to the nurse, and then to Dr. Tilley, who gave him diathermy treatments while he remained in the hospital. The pain did not cease but spread down to the lower part of his arm, and after his release from the hospital the condition grew worse. He was unable to rotate or lift his arm, and developed paralysis and atrophy of the muscles around the shoulder. He received further treatments from Dr. Tilley until March, 1940, and then returned to work, wearing his arm in a splint on the advice of Dr. Spangard. […]

We have no doubt that in a modern hospital a patient is quite likely to come under the care of a number of persons in different types of contractual and other relationships with each other. For example, in the present case it appears that Drs. Smith, Spangard and Tilley were physicians or surgeons commonly placed in the legal category of independent contractors; and Dr. Reser, the anesthetist, and defendant Thompson, the special nurse, were employees of Dr. Swift and not of the other doctors. But we do not believe that either the number or relationship of the defendants alone determines whether the doctrine of res ipsa loquitur applies. Every defendant in whose custody the plaintiff was placed for any period was bound to exercise ordinary care to see that no unnecessary harm came to him and each would be liable for failure in this regard. Any defendant who negligently injured him, and any defendant charged with his care who so neglected him as to allow injury to occur, would be liable. The defendant employers would be liable for the neglect of their employees; and the doctor in charge of the operation would be liable for the negligence of those who became his temporary servants for the purpose of assisting in the operation. […]

The judgment is reversed.

5.2.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre

La esposa del actor, de 78 años de edad, fue intervenida satisfactoriamente de halux valgus bilateral, esto es, juanetes. A los pocos días de la intervención, sin embargo, la paciente presentó un cuadro de contractura muscular progresiva a nivel cervical, con dificultad de deglución, por lo que, ante la sospecha de que se tratara de tétanos postquirúrgico se inició el oportuno tratamiento y la enferma fue trasladada a otro hospital donde, confirmado el diagnóstico fue ingresada en la UCI. La paciente falleció a los quince días por tétanos grave postquirúrgico. El actor demandó a la congregación religiosa titular del hospital, al cirujano, al médico que le asistió en la operación y a la Mutua General de Seguros en reclamación de una indemnización 120.202,42 €. El Juzgado desestimó la demanda, mas la Audiencia revocó la sentencia y condenó a la congregación religiosa y a la compañía aseguradora a pagar 90.151,82 € más las costas causadas en primera instancia. El Tribunal Supremo revocó la Sentencia de la Audiencia únicamente en lo referente a la condena en costas, en el sentido de no imponer las de primera instancia a ninguna de las partes. La Sentencia imputóa el resultado dañoso al mal cumplimiento por la entidad titular del centro hospitalario, de la prestación de tener el espacio, el instrumental y el material a utilizar en el estado que sea preciso para evitar infecciones. Y ello porque, aunque se afirma que la obligación médica es de medios, no de resultado, ello no obsta a la presunción desfavorable que nace del daño, cuando éste es desproporcionado en relación con lo que es usual.

Por primera vez el Tribunal Supremo identifico la doctrina del daño desproporcionado con las medidas de facilitación de la prueba existentes en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno:

«[C]onviene recordar la doctrina sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor (así, la Sentencia de 13 diciembre 1997 [A.8816]), que corresponde a la regla «res ipsa loquitur» (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla del *Anscheinsbeweis* (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la *faute virtuelle* (culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima» (FD. 2º).

5.2.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla

El 7.1.1991 Marisol sufrió un accidente de esquí en Baqueira Beret que le causó una fractura de espina tibial, de la que fue auxiliada *in situ* y trasladada a Barcelona, donde fue atendida por el doctor Carlos Antonio, que tenía contratado un seguro con Winterthur y pertenecía a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA". El tratamiento se prolongó hasta mayo de 1992, en cuyo transcurso la paciente se sometió a tres intervenciones. Finalmente, Marisol acudió a otro doctor para que acabase el tratamiento, pero le quedaron secuelas graves que consisten en limitación de la movilidad de la rodilla derecha, atrofia muscular y una cojera irreversible.

Marisol demanda al doctor Carlos Antonio, a Winterthur y a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA" y solicita una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 25 de Barcelona (7.4.1995) estima en parte la demanda y condena a Carlos Antonio y a Winterthur al pago de 72.121,45 €. La AP de Barcelona (Sección 11ª, 8.5.1997) estima el recurso de apelación, revoca la SJPI y absuelve a los condenados en la instancia previa.

El TS estima el recurso interpuesto por la actora, revoca la SAP y confirma la SJPI. Considera que el largo periodo de tratamiento, con tres intervenciones de por medio y con el resultado de graves secuelas, es suficiente para deducir la negligencia médica de acuerdo con la regla *res ipsa loquitur*. Así:

"[U]na caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves, ni complicados, tienen un tratamiento largo y doloroso con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una cojera irreversible; lo cual crea una deducción de negligencia («res ipsa loquitur»), una apariencia de prueba de ésta ("Anscheisbeweis"), una culpa virtual ("faute virtuelle").No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad sino de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradichos por hechos considerados acreditados por prueba pericial. Se produce un suceso y un daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (…), ni se menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, por ende, la responsabilidad" (FD 3º).

5.2.6. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados

STS, 1ª, 417/2007, de 16 de abril

El 9.2.1994, el Dr. Jorge intervino quirúrgicamente a Maite de una hernia discal y le implantó un injerto óseo y una placa de titanio que le produjeron una infección bacteriana. En el postoperatorio, la paciente fue visitada en tres ocasiones por dolores, pero la infección no fue detectada por falta de empleo del medio diagnóstico adecuado. El 3.9.1994, Maite ingresó en el "Hospital Virgen de las Nieves" de Granada, donde fue intervenida en tres ocasiones porque se le encontró un absceso de pus en la zona en la que había sido intervenida. Maite sufrió secuelas consistentes en una tetraparesia con incapacidad del 76%, perjuicio estético derivado de traqueotomía y depresión grave.

Maite demandó a Jorge y a "Neurosan, S.L." *(no consta relación con el caso)*, y solicitó una indemnización de 901.518,6 €.

La SJPI nº 25 de Barcelona, 16.2.1999, estimó en parte la demanda, condenó a Jorge a pagar 540.910,89 € y absolvió al otro demandado. La SAP de Barcelona, Secc. º7ª, 31.1.2000, desestimó el recurso de apelación interpuesto por Jorge y confirmó la SJPI.

El TS desestimó el recurso de casación, pues:

"[A]nte el daño desproporcionado (…) se espera del agente una explicación o una justificación cuya ausencia u omisión puede determinar la imputación por culpa que ya entonces se presume" y en este caso, "no se ha producido por parte del demandado una explicación que excluya la apreciación de negligencia por falta de atención durante el postoperatorio" (FD 2º).

— SSTS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre; 593/1999, de 29 de junio; 1038/1999, de 9 de diciembre.
— Bibliografía específica: Álvaro LUNA YERGA, *La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria. Culpa y Causalidad*, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 186 y ss.

Sesión 6ª
Culpa comparativa y culpa contributiva

6.1. Negligencia bilateral / *Bilateral Care or Joint Care* **87**
6.2. Negligencia contributiva / *Contributory Negligence* **88**
6.2.1. Butterfield v. Forrester (103 Eng. Rep. 926 (K.B. 1809)) 88
6.2.2. LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry., 232 US. 340 (1914) 89
6.2.3. STS, 1ª, 3 de junio de 1901. Colección Legislativa, 91 p. 867 90
6.2.4. STS, 4ª, 6 de julio de 1990. Inexistencia de error judicial al presentar un documento en idioma extranjero sin acompañar traducción 91
6.3. *The Last Clear Chance Doctrine* **92**
6.3.1. Davies v. Mann (152 Eng. Rep. 588) 93
6.3.2. Restatement (Second) of Torts (1965, updated April 2012) 93
6.4. Negligencia comparativa o concurrencia de culpas / *Comparative Negligence* **94**
6.4.1. STS, 1ª, 967/2002, de 21 de octubre. Accidente de tráfico por colisión de una motocicleta con un montón de grava y arena 94
6.4.2. Antonio FERNÁNDEZ/Víctor M. SÁNCHEZ (2003), "Negligencia Multilateral en Accidente de Motocicleta, ¿cuál es el Estándar Óptimo de Responsabilidad?", InDret 3/2003, (*www.indret.com*), pp. 10-11 95
6.4.3. STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo 96
6.5. Negligencia comparativa modificada **98**
6.5.1. Cuantitativamente 98
6.5.2. Cualitativamente 99
6.6. Culpa exclusiva de la víctima **101**
6.7. Negligencia imputada / *Imputed Negligence* **101**

6.1. Negligencia bilateral / *Bilateral Care or Joint Care*

Tanto en el modelo normativo del análisis doctrinal tradicional de la negligencia, que en Derecho español arranca del art. 1902 CC de 1889, como en el paradigma analítico del *Law & Economics* neoclásico, se parte siempre de la causación unilateral de daños por la posible negligencia del demandando o demandados, pero sin que el demandante haya contribuido a causar el daño, o habiéndolo hecho, haya infringido también deberes de precaución exigibles, es decir, haya sido, a su vez, negligente: hay, por así decirlo, una sola dirección causal posible que va del demandado al demandante y este no pudo hacer nada para evitar el daño que sufrió. Quizás el ejemplo de referencia sea el del paciente anestesiado y tendido en una mesa de operaciones quien es víctima de una negligencia médica: parece claro que nada pudo hacer por evitar el daño.

En la realidad, sin embargo, son poco frecuentes los casos de causación puramente unilateral de daños. Y ello es así no solo en el sentido trivial de que todos contribuimos al daño, aunque solo sea por el hecho de estar donde y cuando sería mejor que no hubiéramos estado cuando sufrimos el accidente. Es que muchas veces, la víctima contribuye causal y negligentemente a empeorar las cosas: en el ejemplo que acabamos de poner, el abogado del médico y del hospital demandados pueden tratar de probar que el paciente, con anterioridad a ponerse en manos del médico, había descuidado las instrucciones que este le había dado sobre la conducta que debía observar antes de la intervención. Es decir, si no siempre, casi siempre cabe plantear la cuestión

de la contribución del demandado a la producción negligente del daño y, caso de que la pregunta admita respuesta, afirmativa, la relativa a las consecuencias de tal contribución.

Y en la actualidad, es frecuente que la negligencia del demandante, por más que contribuya a la causación del daño –a su cocausación--, no se toma normativamente en consideración si no es suficientemente relevante o --como ocurre, por ejemplo, en el derecho español de los accidentes de trabajo-- si no es crasa, si no constituye negligencia grave. Históricamente se ha pasado de un sistema en el cual la contribución culposa del demandante a la causación del accidente generaba una excepción total a favor del demandado a otro en el cual esta solo puede oponerse si es significativa, cuantitativa o cualitativamente, y, en tales casos, únicamente por la parte en la cual se considera que ha contribuido a causar los daños. Por último, si la causación culpable es imputable sólo al demandante su pretensión será desestimada. Los casos que, a continuación, se resumen trazan el arco de esta evolución (en los derechos de daños de los Estados Unidos de América y en 2011, todos los estados menos cuatro y el Distrito de Columbia tienen un sistema u otro de negligencia comparativa, normalmente modificada, que en España se llama compensación de culpas o concurrencia de causas y que es el comúnmente aplicado por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo).

6.2. Negligencia contributiva / *Contributory Negligence*

6.2.1. Butterfield v. Forrester (103 Eng. Rep. 926 (K.B. 1809))

This was an action on the case for obstructing a highway, by means of which obstruction the plaintiff [Butterfield], who was riding along the road, was thrown down with his horse, and injured, etc. At the trial before Bailey, J. at Derby, it appeared that the defendant [Forrester], for the purpose of making some repairs to his house, which was close by the roadside at one end of the town, had put up a pole across part of the road, a free passage being left by another branch or tree in the same direction. That the plaintiff left a public house not far distant from the place in question at 8 o'clock in the evening in August, when they were just beginning to light candles, but while there still was light enough to discern the obstruction at one hundred yards distance; and the witness who proved this, said that if the plaintiff had not been riding very hard he might have observed and avoided it; the plaintiff, however, who was riding violently, did not observe it, but rode against it, and fell with his horse and was much hurt in consequence of the accident; and there was no evidence of his being intoxicated at the time. On this evidence, Bailey, J., directed the jury, that if a person riding with reasonable and ordinary care could have seen and avoided the obstruction; and if they were satisfied that the plaintiff was riding along the street extremely hard, and without ordinary care, they should find a verdict for the defendant, which they accordingly did.

Lord Ellenbrough, C.J. A party is not to cast himself upon an obstruction, which had been made by the fault of another, and avail himself of it, if he does not himself use common and ordinary caution to be in the right. In case of persons riding upon what is considered to be the wrong side of the road that would not authorize another purposely to ride up against them. One person being in fault will not dispense with another's using ordinary care for himself. Two things must occur to support this action: an obstruction in the road by the fault of the defendant, and no want of ordinary care to avoid it on the part of the plaintiff.

6.2.2. LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry., 232 US. 340 (1914)

As part of its business of making flax, plaintiff [appellant] stored about 700 tons of straw units own land. The stacks were lined in two rows. The defendant's right of way ran about 70 feet from the first row and 85 feet from the second. One day a high wind carried sparks from a passing train to one of the stacks of flax located I the row further from the tracks. That fire eventually consumed all the flax. Appellant brought an action against respondent to recover the value of flax straw that was destroyed due to the alleged negligence of the respondent. Respondent alleged that Appellant was guilty of contributory negligence in placing the inflammable stacks of flax straw too near to the railroad track, though the straw was still on Appellant's land.

MCKENNA, J. The questions certified present two facts -- (1) The negligence of the railroad was the immediate cause of the destruction of the property. (2) The property was placed by its owner near the right of way of the railroad, but on the owner's own land. The query is (...) whether one is limited in the use of one's property by its proximity to a railroad; or, to limit the proposition to the case under review, whether one is subject in its use to the careless as well as to the careful operation of the road. (...) That one's uses of his property may be subject to the servitude of the wrongful use by another of his property seems an anomaly. It upsets the presumptions of law and takes from him the assumption and the freedom which comes from the assumption, that the other will obey the law, not violate it. It casts upon him the duty of not only using his own property so as not to injure another, but so to use his own property that it may not be injured by the wrongs of another. How far can this subjection be carried? Or, confining the question to railroads, what limits shall be put upon their immunity from the result of their wrongful operation? In the case at bar, the property destroyed is described as inflammable, but there are degrees of that quality; and how wrongful must be the operation? In this case, large quantities of sparks and "live cinders" were emitted from the passing engine. Houses may be said to be inflammable, and may be, as they have been, set on fire by sparks and cinders from defective or carelessly handled locomotives. Are they to be subject as well as stacks of flax straw, to such lawless operation? And is the use of farms also, the cultivation of which the building of the railroad has preceded? Or is that a use which the railroad must have anticipated and to which it hence owes a duty, which it does not owe to other uses? And why? The question is especially pertinent and immediately shows that the rights of one man in the use of his property cannot be limited by the wrongs of another. The doctrine of contributory negligence is entirely out of place. Depart from the simple requirement of the law, that every one must use his property so as not to injure others, and you pass to refinements and confusing considerations. There is no embarrassment in the principle even to the operation of a railroad. Such operation is a legitimate use of property; other property in its vicinity may suffer inconveniences and be subject to risks by it, but a risk from wrongful operation is not one of them.

MR. JUSTICE HOLMES, partially concurring. If a man stacked his flax so near to a railroad that it obviously was likely to be set fire to by a well-managed train, I should say that he could not throw the loss upon the road by the oscillating result of an inquiry by the jury whether the road had used due care. I should say that although of course he had a right to put his flax where he liked upon his own land, the liability of the railroad for a fire was absolutely conditioned upon the stacks being at a reasonably safe distance from the train. If I am right so far, a very important element in determining the right to recover is whether the plaintiff's flax was so near

to the track as to be in danger from even a prudently managed engine. Here certainly, except in a clear case, we should call in the jury. I do not suppose that any one would call it prudent to stack flax within five feet of the engines or imprudent to do it at a distance of half a mile, and it would not be absurd if the law ultimately should formulate an exact measure, as it has tended to in other instances; ... but at present I take it that if the question I suggest be material we should let the jury decide whether seventy feet was too near by the criterion that I have proposed (...) I do not think we need trouble ourselves with the thought that my view depends upon differences of degree. The whole law does so as soon as it is civilized. See Nash v. United States (. . .) Negligence is all degree -- that of the defendant here degree of the nicest sort; and between the variations according to distance that I suppose to exist and the simple universality of the rules in the Twelve Tables or the Leges Barbarorum, there lies the culture of two thousand years.

I am authorized to say that THE CHIEF JUSTICE concurs in the opinion that I express.

6.2.3. STS, 1ª, 3 de junio de 1901. Colección Legislativa, 91 p. 867

El *pendant* español del caso americano *LeRoy Fibre Co. v. Chicago* es la STS, 1ª, 3.6.1901. La estación de Málaga destinaba un espacio a almiares de paja, situado junto a uno de los andenes. Una locomotora que se encontraba en ese andén inició la marcha, pero se vio obligada a dar contravapor. Puesto que mientras había estado parada un empleado había alimentado sus calderas para avivar el fuego, de su chimenea comenzaron a saltar chispas que provocaron el incendio del almiar y de unas mercancías almacenadas cerca, propiedad del actor. Éste demandó a la Compañía de ferrocarril. Tanto el JPI de Málaga como la AP de Granada desestimaron la demanda. El TS declaró no haber lugar al recurso: "La sentencia recurrida, en virtud de los hechos que consigna con relación a las pruebas del pleito, declara que no han incurrido en culpa o negligencia los dependientes de la Compañía de, a la cual no afecta en este caso responsabilidad directa, ni indirecta, porque ninguna obligación había contraído y porque los almiares de paja, sin convenio o pacto que limitase el derecho de la empresa a utilizar la vía llamada del Peso, se colocaron en la inmediación de la misma por los dueños de aquella mercancía a sabiendas del uso constante que se podía hacer de la vía, por cuya razón no hay vínculo jurídico ni precepto legal que ampare la indemnización que pide el recurrente" (FJ 2º).

— Pablo SALVADOR/Carlos GÓMEZ, "El Derecho de Daños y la Minimización de los Costes de los Accidentes", *InDret* 1/2005 (www.indret.com), pp. 15-16:

"[...E]n la mayor parte de los casos, las víctimas potenciales *también* pueden influir en la frecuencia y gravedad de los accidentes: los conductores de automóviles, por ej., pueden conducir prudentemente y los peatones pueden caminar también con mayor o menor precaución. En tales casos, se habla de precaución o causación bilateral de daños (*bilateral care, joint care*) y el concepto de precaución óptima se complica un poco, pues depende del cuidado adoptado por ambas partes.

Supongamos, en un ejemplo tomado, con algunas modificaciones, de Richard A. POSNER (*Economic Analysis of Law,* 6ª ed., Aspen Law & Business, New York, 2003, p. 172), a su vez inspirado en un caso *(LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry. Co., 232 U.S. 340 (1914))* real de principios del siglo XX, un granjero es propietario de una plantación de algodón

que es atravesada por una vía de ferrocarril. El paso de las locomotoras de vapor provoca ocasionalmente chispas, con el consiguiente riesgo de incendio de los campos. Ambas partes pueden adoptar tres niveles distintos de precaución: ninguna, media o alta. Así, el granjero puede plantar algodón junto a las vías del ferrocarril, hacerlo a 75 m. de distancia o alejarlo hasta 200 m. de las vías. Por su parte, la compañía propietaria del ferrocarril puede instalar en las chimeneas de sus locomotoras un artilugio apaga chispas de calidad media o alta, pero también puede resolver no instalar ninguno.

En la **tabla 2**, sus tres columnas recogen los distintos niveles de precaución que pueden adoptar las partes, así como sus costes respectivos. Los beneficios esperados en ahorro de daños son los mismos en los tres primeros casos e importan 150 € (en la cuarta columna, donde ni granjero ni ferrocarril adoptan ningún género de precaución, los daños suben a 300 €). La combinación óptima es aquella en la cual el granjero aleja su plantación a 75 m. de las vías y el ferrocarril instala en sus máquinas un mecanismo de calidad media. De este modo se previene un accidente cuyo daño esperado es de 150 €, con un coste de precaución de 75 €.

	Alta/0 m.	**Media/ 75 m.**	---/200 m.	---/0 m.
Coste precaución ferrocarril (F)	100	**50**	0	0
Coste precaución granjero (G)	0	**25**	110	0
Coste total precauciones (G+F)	100	**75**	110	0
Coste del daño (D)	150	**150**	150	300

Tabla 2.

6.2.4. STS, 4ª, 6 de julio de 1990. Inexistencia de error judicial al presentar un documento en idioma extranjero sin acompañar traducción

"La demanda sobre la que debemos pronunciarnos llega a la conclusión de que se ha producido error judicial indemnizable con arreglo a los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial-LOPJ en la sentencia del Tribunal Central de Trabajo (TCT) de 2 de octubre de 1987 (RTCT 1987\20512), que denegó el reintegro de gastos médicos por asistencia urgente y de carácter vital, al margen de la Seguridad Social española. A la petición de declaración de error judicial se llega en la demanda mediante la argumentación siguiente: 1) La sentencia adolece de «error en la construcción de la resolución» al aceptar en sus antecedentes los hechos probados de la sentencia de instancia, corrigiéndolos luego en la fundamentación jurídica en el punto relativo a la fecha de la operación quirúrgica que originó el litigio del que procede esta demanda; 2) La referida sentencia del Tribunal Central de Trabajo incurre en «error craso» en la apreciación de la fecha de tal intervención quirúrgica (7-3-81) según la convicción del Tribunal -cuando en realidad el día de la operación fue el 3-7-81; 3) Este error -continúa el

argumento de la parte demandante- se ha debido a ignorancia de la «secuencia normal para indicar las fechas en la documentación mercantil norteamericana», que sigue el orden mes-día-año en lugar del orden día-mes-año convencionalmente establecido en España y en otros muchos países; y 4) La equivocación del juzgador en la interpretación de los guarismos que figuran en las facturas e informes de la clínica en que se practicó la operación reúne -de nuevo según la demanda de la declaración de error judicial- los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial para la indemnización a que se refiere el artículo 121 de la Constitución Española, al tratarse de un «error craso» «inexplicable» «evidente» y trascendente para la resolución.

En apoyo de esta argumentación se acompaña a la demanda entre otros elementos de convicción, un informe del Consejero Comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América, con fecha 12 de noviembre de 1989, en el que se indica que los escritos procedentes de dicho país en los que figuran fechas cifradas, deben ser interpretados atribuyendo la primera cifra al mes, la segunda al día y la tercera al año" (FD 1º).

"Ciertamente, el argumento de más peso de la demanda es el que se refiere al modo de ser leídas las fechas de los documentos acreditativos de la intervención quirúrgica de la demandante. La afirmación de la parte demandante de que la sentencia impugnada incurrió en error en este punto es convincente, y así lo debemos reconocer de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal. Ahora bien, la equivocación imputada no cumple los requisitos del error indemnizable que se deducen de los artículos 292 y 295 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tales requisitos son, entre otros, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial, el carácter ostensible o patente del error -T. S. 1.ª, 16-6-88 (RJ 1988\4934); T. S. 4.ª 11-10-89 (RJ 1989\7159); T. S. 1.ª 13-4-88 (RJ 1988\3143)-; su influencia determinante (condición sine qua non) en el fallo -T. S., soc. 24-11-86 (RJ 1986\6716)-, y que no haya sido provocado o producido por la conducta dolosa o culposa de la parte perjudicada (T. S. 2.ª, 24-11-86).

En el presente supuesto es claro que el comportamiento procesal de la parte, que no cumplió con el requisito establecido en el artículo 601 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de acompañar una traducción de los documentos presentados en lengua extranjera, ha contribuido decisivamente a la equivocación del juzgador, sin que la mera advertencia contenida en el escrito de impugnación del recurso de suplicación fuera bastante para compensar el malentendido provocado por tal carencia.

El error padecido por el Tribunal Central de Trabajo (en el que no hubiera incurrido seguramente de haberse acompañado las traducciones preceptivas, o incluso de haberse aportado en un momento anterior el informe de la Embajada USA que se adjunta como documento nº 4 a la demanda de error judicial) no puede decirse tampoco que sea un error ostensible o patente. En verdad, hoy por hoy, no cabe estimar hecho notorio en España el orden de lectura en las representaciones numéricas de las fechas que se practican en los Estados Unidos de América.

De acuerdo con todo lo anterior no puede accederse a la petición indemnizatoria que se deduce de la demanda" (FD 3º).

6.3. *The Last Clear Chance Doctrine*

6.3.1. Davies v. Mann (152 Eng. Rep. 588)

At the trial, before Erskine, J., it appeared that the plaintiff, having fettered the fore-feet of an ass belonging to him, turned it into a public highway, and at the same time in question the ass was grazing on the off side of a road about eight yards wide, when the defendant's wagon, with a team of three horses, coming down a slight descent, at what the witness termed a smartish pace, ran against the ass, knocked it down, and the wheels passing over it, it died soon after. … The learned judge told the jury, that … if they thought that the accident might have been avoided by the exercise of ordinary care on the part of the driver, to find for the plaintiff. The jury found their verdict for the plaintiff…

[The defendant's attorney] moved for a new trial, on the ground of misdirection. The act of the plaintiff in turning the donkey into the public highway was an illegal one, and, as the injury arose principally from that act, the plaintiff is not entitled to compensation for that injury which, but for his own unlawful act would never have occurred. …The principle focus of law ... is, that where an accident is the result of faults on both sides, neither party can maintain an action. Thus, in Butterfield v. Forrester, 11 East 60, it was held that one who is injured by an obstruction on a highway, against which he fell, cannot maintain an action, if it appear that he was riding with great violence and want of ordinary care, without which he might have seen and avoided the obstruction. …

Lord Abinger, C.B. …[A]s the defendant might, by proper care, have avoided injuring the animal, and did not, he is liable for the consequence of his negligence, though the animal may have been improperly there.

Parke, B. … [T]he negligence which is to preclude a plaintiff from recovering in anaction of this nature, must be such as that he could, by ordinary care, have avoided the consequences of the defendant's negligence. … [A]lthough the ass may have been wrongly there, still the defendant was bound to go along the road at such a pace as would be likely to prevent mischief. Were this not so, a man might justify the driving over goods left on a public highway, or even over a man lying asleep there, or the purposely running against a carriage going on the wrong side of the road. …

6.3.2. Restatement (Second) of Torts (1965, updated April 2012)

§479. Last Clear Chance: Helpless Plaintiff.

A plaintiff who has negligently subjected himself to a risk of harm from the defendant's subsequent negligence may recover for harm caused thereby if, *immediately preceding the harm*,

(a) the plaintiff is unable to avoid it by the exercise of reasonable vigilance and care, and

(b) the defendant is negligent in failing to utilize with reasonable care and competence his then existing opportunity to avoid the harm, when he

(i) knows of the plaintiff's situation and realizes or has reason to realize the peril involved in it or

(ii) would discover the situation and thus have reason to realize the peril, if he were to exercise the vigilance which it is then his duty to the plaintiff to exercise.

§ 480. Last Clear Chance: Inattentive Plaintiff

A plaintiff who, by the exercise of reasonable vigilance, could discover the danger created by the defendant's negligence in time to avoid the harm to him, can recover if, but only if, the defendant

(a) knows of the plaintiff's situation, and

(b) realizes or has reason to realize that the plaintiff is inattentive and therefore unlikely to discover his peril in time to avoid the harm, and

(c) thereafter is negligent in failing to utilize with reasonable care and competence his then existing opportunity to avoid the harm.

6.4. Negligencia comparativa o concurrencia de culpas / *Comparative Negligence*

6.4.1. STS, 1ª, 967/2002, de 21 de octubre. Accidente de tráfico por colisión de una motocicleta con un montón de grava y arena

Manuel R.C., propietario de una casa en Gines (Sevilla) situada junto a la carretera a Valencia, estaba realizando obras en su domicilio y había contratado el transporte de grava y arena con "Polvero Manuel Ruiz García, S.A.". El 25.5.1992, sobre las 19:00 h., José G.S., conductor al servicio de la entidad mencionada, descargó un montón de grava y arena de tal forma que ocupaba, sin señalización alguna, 1,25 m de calzada sobre una anchura total de 12,8 m. Cuatro horas después, hacia las 23:00 h., Alberto José L.R., que conducía sin casco una motocicleta a una velocidad superior a la permitida, colisionó con el montón de grava y arena. Como consecuencia del impacto, la motocicleta salió despedida a varios metros y Alberto José L.R. cayó al suelo, lo cual le ocasionó lesiones de gravedad, cuyas secuelas fueron declaradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como invalidez permanente en grado de incapacidad permanente.

La víctima demandó a Manuel R.C., a "Polvero Manuel Ruiz García, SA", sociedad encargada del abastecimiento, a José G.S., conductor contratado de la misma, y al Ayuntamiento de Gines y solicitó una indemnización de 362.879,69 € por los daños sufridos.

El JPI nº 18 de Sevilla (27.2.1996) desestimó la demanda y absolvió a todos los demandados por falta de reclamación previa en vía administrativa. El actor interpuso recurso de apelación contra la SJPI, que la SAP Sevilla (Sec. 6ª, 25.11.1996) estimó parcialmente: absolvió a los demandados "Polvero Manuel Ruiz García, S.A." y a José G.S. y condenó solidariamente al Ayuntamiento de Gines y a Manuel R.C. al pago de una indemnización de 108.863,9 € por los daños sufridos, con fundamento en el art. 1902 CC. Esta cantidad se corresponde con una rebaja del 70% de lo solicitado en la demanda, ponderando el tribunal la concurrencia de culpa del actor. El

Ayuntamiento codemandado y el actor, Alberto José L.R., interpusieron sendos recursos de casación contra la SAP.

El TS estimó parcialmente el primero de los recursos y desestimó el segundo. En su sentencia el TS casó el *quantum* indemnizatorio y redujo la indemnización a un 10% de las pretensiones iniciales, es decir, a una cuantía de 38.333,15 €, resultado de ponderar de nuevo la culpa de la víctima en un 90%. Los hechos esenciales que toma el TS a la hora de apreciar la culpa de la víctima en un 90% son (FD B. 2º):

- El montón de grava y arena ocupaba 1,25 m de una calzada de 12,8 m, o lo que es lo mismo, sólo obstaculizaba el 10% del paso.
- El momento de la colisión no circulaba ningún otro vehículo en ninguno de los dos sentidos.
- Había diversas señales que limitaban la velocidad a 30 km/h y que avisaban del peligro de paso de peatones, a las cuales el actor hizo caso omiso circulando a una velocidad superior a la permitida, hecho que viene corroborado porque la motocicleta salió despedida a 29 metros del lugar del accidente.
- El actor no llevaba el casco puesto.

Sin embargo, el TS no exoneró al Ayuntamiento de Gines, pues consideró que éste también incurrió en negligencia por omisión de su deber de cuidado y mantenimiento de las condiciones de seguridad en las carreteras locales por medio de la policía local (art. 10.2 DL 339/1990 y art. 4 de su Reglamento de 7 de enero de 1992). El TS apreció que el tiempo durante el cual el montón de grava y arena estuvo en la carretera había sido más que suficiente para que, en una localidad pequeña, la policía local se percatase del peligro. Por ello establece su culpa en un 10%.

6.4.2. Antonio FERNÁNDEZ/Víctor M. SÁNCHEZ (2003), "Negligencia Multilateral en Accidente de Motocicleta, ¿cuál es el Estándar Óptimo de Responsabilidad?", InDret 3/2003, (*www.indret.com*), pp. 10-11

"Un mínimo de negligencia es inevitable, ya sea porque la tecnología avanza y el comportamiento antes diligente pasa a ser negligente, porque el agente no es capaz de ajustar su nivel de diligencia al estándar establecido según una persona media o porque el oportunista se aprovecha de su situación.

Además, los jueces tienen serios problemas de información a la hora de precisar los vagos estándares establecidos por la ley. El error judicial se hace patente tanto en la determinación del estándar como en la subsunción de la conducta de cada parte a éste.

Tampoco es del todo cierto que las interacciones sean reiteradas y que los agentes tomen sus decisiones simultáneamente.

> Pongamos un ejemplo: en el ámbito de la ***contributory negligence***, si asumimos que la interacción no es repetida (*one shot game*) y que la víctima ha iniciado el curso causal culposamente, entonces, al no tratarse de acciones simultáneas, el demandado no tendrá incentivos a evitar el accidente. De ahí la introducción de la cláusula *"last clear chance"*. Del mismo modo, con ésta tenemos el problema que la víctima que inicia la acción se puede

comportar negligentemente esperando a que el demandado tenga la última oportunidad de evitarla.

Ante todos estos problemas debemos afirmar que los niveles de precaución de cada parte dependen, efectivamente, de la regla que adoptemos. Así, el demandado, bajo una regla de *contributory negligence*, toma niveles más bajos de precaución (Y(CnN)), ya que se verá exonerado de responsabilidad siempre que la víctima haya sido negligente. En el ámbito de la *comparative negligence* su grado de negligencia se verá compensado con el de la víctima, por esto tomará un nivel medio de precaución (Y(CmN)). Y, finalmente, con *simple negligence*, el juez sólo tendrá en cuenta su grado de negligencia, por lo que será más precavido que en los anteriores casos (Y(SN)). Los niveles de precaución del demandado bajo las distintas reglas quedan ordenados de la siguiente manera:

$$Y(CnN) < Y(CmN) < Y(SN)$$

Por contra, la víctima tiene incentivos a comportarse más diligentemente cuando el demandado tiene menos incentivos, debido a que la víctima deberá soportar los costes de los daños no compensados. De esta forma los niveles de precaución de la víctima son:

$$X(SN) < X(CmN) < X(CnN)$$"

6.4.3. STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo

El 13 de agosto de 2000 una embarcación a motor conducida por Máximo atropelló a un submarinista, Fermín. El accidente ocurrió en zona rocosa, en línea oblicua al puerto natural y a la playa de l'Estany, a unos 50 metros del espacio de protección de los bañistas establecido por la normativa de aplicación; la velocidad de la embarcación era de 10 nudos (estando el límite de 3 nudos restringido a dicha zona de protección); las condiciones meteorológicas eran de cierta intensidad, con olas de más de un metro de altura; y el submarinista no iba acompañado de la preceptiva embarcación ni llevaba boya de señalización.

El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Tortosa condenó al piloto y la AP revocó la SJI y lo absolvió en atención a que las dudas existentes sobre el lugar exacto en que había ocurrido el accidente impedían imputarle un comportamiento negligente.

El perjudicado demandó al piloto de la embarcación, su propietaria (Otilia), y la entidad que aseguraba su responsabilidad civil, Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

El JPI apreció concurrencia de conductas culposas y atribuyó un 25% de responsabilidad a la propia víctima. La AP estimó en parte todos los recursos con revocación de la sentencia recurrida en el sentido de repartir al 50% la responsabilidad.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la aseguradora y confirmó la SAP:

"Responsabilidad del piloto de la embarcación por omitir la diligencia exigida por las circunstancias.

La jurisprudencia (SSTS de 5 de abril de 2010 (RJ 2010, 4034), RC n.º 449/2005, 11 de septiembre de 2006 (RJ 2006, 8541), 10 de junio de 2006, 6 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 6745), 17 de junio de 2003, 10 de diciembre de 2002, 6 de abril de 2000 (RJ 2000, 2508)), no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con fundamento en el artículo 1902 CC , y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad civil no se adecua a los principios que informan su regulación positiva.

Por estas razones la aplicación de la doctrina del riesgo, además de que solo es posible en supuestos de riesgos extraordinarios (riesgo considerablemente anormal en relación a los parámetros medios, SSTS de 18 de julio de 2002 (RJ 2002, 6257), RC n.º 238/1997 y de 21 de mayo de 2009 (RJ 2009, 3030), RC n.º 2005/2004), no implica una responsabilidad objetiva fundada en el resultado o en el propio riesgo creado (que no tiene en encaje en el artículo 1902 CC , como declara, entre otras, la STS de 25 de marzo de 2010 (RJ 2010, 4347), RC n.º 1018/2006), sino que, sin prescindir del elemento esencial de la culpa, a lo más que llega es aceptar la aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia a daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño, cuando éste está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole.

De esto se sigue que, al margen de cómo se distribuya la carga de la prueba, la doctrina del riesgo no elimina la necesidad de acreditar la existencia de una acción u omisión culposa a la que se pueda causalmente imputar el resultado lesivo, sin perjuicio, eso sí, de que, en orden a apreciar la concurrencia del elemento subjetivo o culpabilístico, **deba de tenerse en cuenta que un riesgo mayor conlleva un deber de previsión mayor por parte de quien lo crea o aumenta.**

En esta línea se enmarca la STS de 21 de mayo de 2009, RC n.º 2005/2004 . En ella se afirma que ni siquiera la obligatoriedad del aseguramiento determina la presencia de un sistema de responsabilidad civil objetivo puro que permita fundarla exclusivamente en el resultado o en el riesgo creado al margen del elemento culpabilístico, siendo necesario la acreditación de la culpa o negligencia del asegurado, como consecuencia de que el Real Decreto 607/1999 de 16 de abril (RCL 1999, 1091), por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas, reconoce sustentarse en el clásico esquema de responsabilidad civil subjetiva del artículo 1902 CC basado en la concurrencia de culpa o negligencia (el artículo 1 del citado RD dice: "1. El seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria tiene por objeto, en el ámbito y dentro de los límites fijados en el presente Reglamento, de la responsabilidad civil extracontractual en que puedan incurrir los navieros o propietarios de embarcaciones de recreo o deportivas [...] por los daños materiales y personales y por los perjuicios que sean consecuencia de ellos que, mediando culpa o negligencia causen a terceros [...]". Y la "Parte expositiva" del citado RD despeja cualquier duda al respecto al declarar expresamente el acogimiento del sistema tradicional y subjetivo de responsabilidad).

(...)

La AP no se aparta de la doctrina expuesta.

En primer lugar, la sentencia declara probada la relación de causalidad desde el punto de vista físico o fenomenológico, entre la conducta del agente y el resultado, y lo hace a partir de considerar acreditados determinados hechos que ahora no pueden ser desvirtuados (el impacto entre el buceador y el casco de la nave).

En segundo lugar, y desde el punto de vista de la imputación objetiva del resultado lesivo al agente, contrariamente a lo que se sostiene, la responsabilidad del piloto de la embarcación no se hace descansar únicamente en el riesgo creado por la conducción de una embarcación deportiva sino que, con absoluto respeto al sistema tradicional culpabilístico, se asienta en la omisión de la diligencia extrema que cabía exigirle en atención al extraordinario riesgo que

origina quien conduce una embarcación de recreo, superior y completamente ajeno al asumido por la propia víctima con la práctica deportiva…

Ciertamente, quien conduce una embarcación, habida cuenta del específico y extraordinario riesgo creado por su conducción - mayor que el propio de la práctica del submarinismo desde el momento que el deportista asume su propia puesta en peligro mientras que de la conducción de un barco se deriva un peligro para bienes ajenos-, debe agotar la diligencia que le marcan las circunstancias en aras a evitar un accidente con otras embarcaciones o con bañistas.

Por el principio de facilidad probatoria, el cumplimiento de ese deber de diligencia corresponde acreditarlo a quien patronea la embarcación.

En el caso enjuiciado, ese especial deber de diligencia resulta, asimismo, de las disposiciones administrativas sobre la materia, que obligaban a reducir la velocidad en las zonas más próximas a la costa, y especialmente a la playa, en previsión de la presencia de bañistas o nadadores. Pero, contrariamente a lo que se sostiene, no es circunstancia que excluya la posibilidad de imputar el resultado al comportamiento culpable del agente el que la embarcación impactase con la víctima más allá de los límites acotados reglamentariamente para el baño. Consta acreditado que la embarcación circulaba a una velocidad elevada (no menos de diez nudos) y por una zona que, aún fuera de la acotada, seguía encontrándose relativamente próxima a la costa (a una distancia de 100 a 150 metros), donde había calas y playas cercanas, era posible el submarinismo, y en la que, atendiendo al día, hora y época del año (mediodía de un domingo del mes de agosto, época vacacional), resultaba, asimismo, presumible, una notoria afluencia de bañistas. Y en esas circunstancias, y en atención al riesgo generado, el piloto no ha probado la adopción de las especiales medidas de precaución que le eran exigibles para evitar riesgos a la vida e integridad físicas de los bañistas, las cuales no cabe circunscribir a una zona determinada desde el momento que el deber de precaución subsiste desde la puesta en marcha de la embarcación, momento en que el agente desencadena el riesgo, hasta que se detenga, y debe acomodarse en cada momento a las concretas circunstancias que se encuentre durante la conducción" (FD. 3º).

6.5. Negligencia comparativa modificada

6.5.1. Cuantitativamente

— STS, 1ª, 772/2008, de 21 de julio

La madrugada del 24.2.1996, María Pilar se encontraba en la discoteca "Charlot" de Valladolid cuando el personal estaba realizando las labores de limpieza antes del cierre del local. El camarero Aurelio dejó encima de la barra un envase original de agua mineral, con etiqueta y tapón, que había rellenado de sosa cáustica, y salió del local para tirar la basura. María Pilar bebió del envase y sufrió graves lesiones esofágicas, que precisaron 19 intervenciones quirúrgicas, 1.103 días de incapacidad, gastos por un importe de 6.304,82 €, y de las que derivaron secuelas graves.

María Pilar demanda a Aurelio, a José Luis, propietario de la discoteca, y a su aseguradora, "Seguros A.G.F", y solicita una indemnización de 6.304,82 € por gastos, 53.033,31 € por incapacidad, 300.506,05 € por secuelas físicas, y 90.151,82 € por secuelas psíquicas, con el límite de 150.253,03 € para la aseguradora.

El JPI núm. 2 de Valladolid (9.11.2000) estima en parte la demanda y condena a los demandados al pago de 90.151,82 €. La AP de Valladolid (Sección 1ª, 15.3.2001) estima en parte el recurso de la actora en el sentido de aumentar la indemnización a 209.591,14 €.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por los demandados. El daño fue consecuencia directa y prácticamente exclusiva de la acción de Aurelio. "La mayor entidad de la principal negligencia del demandando Aurelio, absorbe o neutraliza prácticamente, cualquier negligencia levísima que quepa apreciar de la demandante" (FJ 1º).

— STS, 1ª, 1130/2008, de 12 de diciembre

La noche del 25.9.1999, Víctor atropelló con su vehículo a un peatón, que se encontraba en la zona de la calzada correspondiente al sentido contrario de circulación al que llevaba el vehículo, y se dio a la fuga. La trayectoria del automóvil era anómala y las circunstancias concurrentes, las fiestas patronales, exigían una circulación prudente. Como consecuencia del atropello, Jaime sufrió lesiones graves que provocaron su hospitalización durante 139 días, secuelas graves determinantes de gran invalidez y perjuicios económicos *(no consta cuantía)*. Con posterioridad, Víctor se suicidó y sus herederos repudiaron la herencia.

Jaime demanda a la aseguradora del vehículo, "Multinacional Aseguradora", y solicita una indemnización *(no consta cuantía).* El JPI núm. 4 de Santiago de Compostela (19.2.2001) condena a la aseguradora a pagar 556.875,27 €. La AP de A Coruña (Sección 6ª, 28.6.2002) estima en parte el recurso interpuesto por la aseguradora y reduce la indemnización a 296.028,03 €, al apreciar la concurrencia de la conducta negligente de la víctima.

El TS estima el recurso de casación interpuesto por Jaime, revoca la SAP y confirma la SJPI. "La negligencia del peatón, consistente en penetrar en la calzada por una parte por la que no era previsible que el vehículo circulase, y en circunstancias que imponían al conductor especiales deberes de precaución, tiene un carácter secundario que impide atribuirle relevancia a los efectos de exonerar al conductor de la imputación del daño producido como ajeno, en todo o en parte, a su responsabilidad objetiva por los riesgos de la circulación" (FD 3º).

6.5.2. Cualitativamente

— **Art. 21.4 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales**

"Artículo 21. Riesgo grave e inminente.

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de[l] riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse (…).
b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad (…)
c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico (…) esté en condiciones (…) de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo (…)
(…)

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**".

— **Art. 115 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social**

"Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo.

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo (…)

a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e. Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo (…)
b. **Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**".

— Sostienen la imprudencia temeraria del trabajador la STS, 4ª, 22.1.2008 (RJ 2076) -accidente de circulación de trabajador que circulaba en bicicleta en dirección prohibida y colisionó con un vehículo que circulaba correctamente-; y las SSTSJ, Sala de lo Social, País Vasco,

Bilbao, 9.2.2010 –la víctima, quien realizaba trabajos en una obra a 8 metros de altura, que no le correspondía realizar, con 2,63 g/l de alcohol en sangre y 0,05 ug/ml de cocaína en sangre, y sin arnés, sufrió un desvanecimiento, cayó al vacío y murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico; Castilla y León, Valladolid, 1274/2010, 21.9.2010 -accidente de circulación de trabajador por circular con una tasa de alcohol superior en más del doble a la permitida-; Andalucía, Granada, 187/2007, 24.1.2007 -accidente *in itinere* de trabajador que decidió salir de su vivienda por el balcón al encontrarse bloqueada la puerta de entrada; y Andalucía, Málaga, 706/2006, 2.3.2006 -accidente de circulación de trabajador que conducía una motocicleta a velocidad excesiva, haciendo equilibrios en una sola rueda, llevando el casco desabrochado, sin seguro ni permiso de conducir-.

6.6. Culpa exclusiva de la víctima

Como señalábamos al inicio de esta sesión, los casos en los cuales el tribunal resuelve que los daños fueron imputables sólo al actuar negligente de la víctima cierran el círculo: de la causación bilateral de daños por el demandado y demandante a la auto causación unilateral del daño por el demandante. Véase la STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero, comentada en la primera de estas sesiones, que resuelve el caso en el que dos menores –de 15 y 16 años respectivamente–viajaban en un ciclomotor de una sola plaza, sin permiso de conducir, y fueron arrollados por un tren en un paso a nivel sin barreras ni semáforos y con una señalización defectuosa.

— Miguel Ángel DE DIOS DE DIOS, *Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación*, La Ley Actualidad, Madrid, 2012.

6.7. Negligencia imputada / *Imputed Negligence*

¿Puede o, incluso, debe tenerse en cuenta la contribución culposa del padre o guardador del menor a la causación del daño que este sufre para descontarla de la cuota de responsabilidad del demandado? Piénsese en el caso de un conductor que atropella a un niño de cuatro años de edad mientras su padre o madre están distraídamente hablando con un vecino. Muchas jurisdicciones U.S.A. han rechazado tal posibilidad , es decir, se han negado a aplicar la doctrine de la denominada *imputed negligence* (Labier v. Pelletier, 665 A.2d 1013 (Me. 1995) y otros han legislado al efecto, pero surge la pregunta: ¿debe de ser de peor condición el demandado que contribuyó a causar un daño al menor demandante con sus padres o guardadores que aquel que lo hizo con un extraño? ¿Y qué ocurre en un caso en el cual una persona mentalmente discapacitada e internada en un establecimiento psiquiátrico se suicida? ¿Pueden los tribunales imputar parte de la responsabilidad al paciente mismo y reducir en consecuencia la indemnización que hubiera de afrontar el establecimiento por sus fallos de atención (*Limited capacity*)?

Pensemos en dos parejas de casos muy similares. En la primera, una madre descuida por un momento el cuidado de su hijo muy pequeño y este es dañado accidentalmente por un tercero. En tal circunstancia los tribunales acaso podrían dejar de imputar la cuota de contribución materna a la causación del daño y no descontarla de la indemnización que pagará el tercero demandado. Sin embargo, si el niño estaba en una escuela y sus responsables descuidan los cuidados exigibles ningún tribunal dejará de tener en cuenta la responsabilidad de la escuela y

del tercero. Parecidamente, en la segunda pareja hipotética de casos. En el primero, el marido de una mujer afectada por una enfermedad neurodegenerativa grave no cierra la puerta de su casa, la enferma sale de ella y sufre un daño causado por un tercero negligentemente. También aquí la negligencia del marido tenderá acaso a ser pasada por alto por los tribunales. Pero imaginemos que la paciente estaba al cuidado de una residencia especializada, supuesto en el cual la residencia y el tercero responderán claramente por los daños ocasionados. ¿Por qué en el primer grupo de casos la madre y el marido parecen ser de mejor condición que la escuela y la residencia? Una posible respuesta: desde la perspectiva de la disuasión, de la prevención de daños, los familiares suelen ser los interesados en que el hijo y la mujer desvalida no sufran daños, es más, sufren aquello que los penalistas llaman una pena de daño. Y la condena derivada del éxito de la pretensión resarcitoria no les disuade mucho más o sólo lo hace marginalmente. Desde el punto de vista de la compensación, la familia sigue siendo una unidad económica de consumo y las redistribuciones internas de sus miembros no serán realmente compensatorias. Naturalmente, el análisis anterior es perfectamente discutible, pero para esto se han redactado estas sesiones.

Recientemente el Fiscal responsable de seguridad vial ha dado instrucciones a los fiscales para que investiguen en profundidad los accidentes de circulación con resultado de daños a menores que no iban adecuadamente sujetos y ha propuesto que la Fiscalía solicite penas más graves en estos casos (Fiscalía Seguridad Vial, "Seguridad Vial presenta las conclusiones del Proyecto de Investigación sobre accidentes en menores", 5.6.2012; "La Fiscalía de Seguridad Vial plantea que el Fiscal de Menores actúe contra padres multados por no usar 'sillita'", europapress.es**).** ¿Aplicaría sistemáticamente esta directiva a los accidentes domésticos?

— **STS, 1ª, 80/2007, de 26 de enero**

El 30.7.1994, Lucio y Cecilia fueron a visitar el Museo Gaudí anejo al "Templo Expiatorio de la Sagrada Familia" (Barcelona) junto a sus hijos, Lorenzo, de 5 años de edad, y Rocío, también menor de edad. En el museo había expuestas varias esculturas a las que el público podía acercarse e incluso tocar sin que existieran medidas de seguridad o carteles de advertencia que lo impidieran. Una de las obras de la exposición era un conjunto escultórico de varias piezas ensambladas, con estructura asimétrica, de inestabilidad acusada y cuya parte más saliente estaba a una altura de 1,45 m. Lorenzo, de 1,13 m. de altura, se acercó y se colgó de ella. La estatua basculó y las tres piezas superiores del conjunto cedieron y cayeron encima del menor, causándole la muerte por rotura de la base del cráneo.

Lucio y Cecilia, en nombre propio y en representación de Rocío, demandaron a la "Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia" y solicitaron una indemnización a determinar en ejecución de sentencia.

El JPI nº 30 de Barcelona (16.9.1998) estimó la demanda y condenó a la demandada al pago de la indemnización a determinar en ejecución de sentencia. La AP Barcelona (Sección 16ª, 22.10.1999) estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la "Junta Constructora", revocó la sentencia de instancia, apreció concurrencia de culpas de los padres, y condenó a la demandada al pago de 40.067,47 € para cada uno de los padres y 12.020,24 € para la hermana en concepto de daño moral, así como 3.400,27 € en concepto de daños materiales por los gastos del sepelio.

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por Lucio y Cecilia, revocó en parte la sentencia de apelación y condenó a la "Junta Constructora" al pago de 60.101,21 € a cada progenitor y 18.030,63 € a la hermana en concepto de daño moral, más 5.100,41 € en concepto de daños materiales:

"[N]o puede admitirse la relevancia causal que la SAP aprecia en la conducta de los padres del menor, pues no contribuyó eficazmente a la producción del daño (…). [A]ún cuando el menor se encontrara sometido a la más estrecha vigilancia de sus padres, no quedaba excluida la causación del accidente" (FD 3º).

— **STS, 1ª, 144/2007, de 7 de febrero**

El 23.10.1991, Jorge, de 9 años, subió a jugar a la azotea del edificio en compañía de otros dos menores, de 4 y 7 años. Jorge, con la intención de coger una pelota, subió por una escalerilla a un tejado en que había placas solares y depósitos de agua. Una vez arriba, perdió el equilibrio y agarró con la mano izquierda un cable eléctrico conductor de baja tensión, lo que provocó una fuerte descarga que le lanzó sobre otra terraza. María Juana, de 16 años, acudió a socorrer a su hermano y recibió otra descarga eléctrica. A consecuencia de las descargas, ambos menores sufrieron lesiones traumáticas y quemaduras, siendo las de Jorge de mayor gravedad. El cable, sin revestimiento aislante, se encontraba a una altura de 1,40 m, 10 cm inferior a la establecida en el Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

María Juana, en su nombre, y Claudio y Ángela, en representación de su hijo menor Jorge, demandan a "Iberdrola, S.A.", y solicitaron una indemnización de 81.708,38 €.

El JPI nº 1 de Sueca (10.10.1998) estimó en parte la demanda y condenó a pagar 7.422,5 € a María Juana y 10.553,77 € a los padres, como representantes del menor. La AP de Valencia (Sección 6ª, 1.6.1999) desestimó el recurso de apelación de la demandada y estimó el de los demandantes en el sentido de aumentar la indemnización de Jorge a 13.540,8 €. La AP mantuvo la proporción del 50% de culpa para cada una de las partes.

El TS desestimó el recurso de casación de "Iberdrola, S.A.", en cuyo primer motivo sostenía la culpa exclusiva de los padres de las víctimas:

"[L]a Audiencia en este caso lleg[a] a la conclusión de no considerar acreditado que la puerta de acceso a la terraza del edificio estuviera cerrada con llave y se facilitara por los padres el acceso a la terraza del menor accidentado… [N]o cabe dudar del incumplimiento por la Compañía eléctrica instaladora, responsable del cuidado y mantenimiento de la instalación, de la normativa administrativa en cuanto a la altura del cable conductor de corriente…, que después del accidente fue revestido de protección, sin que hubiera advertencia alguna del peligro que la instalación representaba" (FD. 2º).

Sesión 7ª
Causalidad de hecho

7.1. Causalidad / *Causation* **104**
7.1.1. Causalidad y omisión 105
7.1.2. Causalidad múltiple 110
7.1.3. Causalidad indeterminada 111
7.2. Causalidad genérica y específica / *Generic Causation and Specific Causation* **112**
7.3. Causalidad alternativa / *Alternative Causation* **112**
7.3.1. *Summers v. Tice* (33 Cal. 2d 80, 199 P.2d 1 (1948)) 112
7.3.2. *Ybarra v. Spangard* (*25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687*) 114
7.4. Causalidad concurrente / *Concurrent Causation* **115**
7.4.1. *Kingston v. Chicago Ry.* (191 Wis. 610, 211 N.W. 913 (1927)) 115
7.4.2. STS, 1ª, 816/2011, de 6 de febrero de 2012 116
7.4.3. STS, 1ª, 425/2009, de 4 de junio 118
7.4.4. STS, 1ª, 485/2008, de 28 de mayo 118
7.4.5. *Dillon v. Twin State* (85 N.H. 449, 163 A. 111 (1932)) 120
7.5. Causalidad sucesiva / *Succesive Causation* **121**
7.5.1. BGH NJW 1952, 1010 121
7.5.2. *Baker v. Willoughby* ([1970] 2 W.L.R. 50) 121
7.5.3. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla en accidente de esquí y responsabilidad civil médico-sanitaria. 121
7.6. Causalidad probabilística / *Probabilistic Causation* **122**

7.1. Causalidad / *Causation*

Causa, para los juristas, es *conditio sine qua non*, limitada normativamente por criterios de adecuación social. Es el "But-for Test". Es decir, la "conditio sine qua non", modulada por la apreciación social dominante –pero muy cambiante— sobre cuales son los roles sociales que determinan, para cada constelación de conductas peligrosas, las personas u organizaciones a cuyo cargo se ponen los riesgos generados.

La causalidad es, primariamente, una cuestión empírica y responde a la pregunta sobre por qué se produjo el daño, cuál fue su explicación científica, técnica o científico social.

La modulación o limitación normativa de la causalidad --en inglés *scope of liability* (antes: *proximate causation*); y en alemán, *objektive Zurechnungslehre*-- trata de evitar hacer responder a los padres por los actos de sus hijos o a los nietos por los de sus abuelos, aunque, como ambos ejemplos sugieren, la respuesta es frecuentemente muy difícil. Intuitivamente, los bomberos y las autoridades que los gobiernan están más directamente incumbidos en la tarea de atajar incendios que los ciudadanos en general; los policías lo están en las de prevenir y evitar delitos; los padres en las de velar por que sus hijos *menores de edad* no causen daños a terceros, etc. Si la pregunta es a quién incumbe prevenir accidentes, el test más fecundo para responderla es filtrar el análisis con la consideración de que si todos hemos de responder por todo, no hay división del trabajo posible, ni por tanto, desarrollo tecnológico.

Así, la causalidad es el territorio de los expertos, de los peritos. La imputación objetiva, de la legislación, la jurisprudencia, las propuestas razonadas de los letrados de las partes que ponen de manifiesto las razones y consecuencias de poner a cargo de alguien o de alguna organización tales o cuales conductas peligrosas.

El Restatement (Third) of Torts ofrece un buen marco analítico a la doble cuestión de la causalidad y de su acotación por el derecho.

§ 26 RTT Factual cause

Tortious conduct must be a factual cause of harm for liability to be imposed. Conduct is a factual cause of harm when the harm would not have occurred absent the conduct. Tortious conduct may also be a factual cause of harm under § 27.

§ 29. Limitations On Liability For Tortious Conduct

An actor's liability is limited to those harms that result from the risks that made the actor´s conduct tortious.

— Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Causalidad y Responsabilidad", 3ª ed., *InDret* 1/2006 (www.indret.com), págs. 3-7:

"En una primera aproximación, la causalidad, entendida como causalidad de hecho, se determina por mediación del criterio de la *conditio sine qua non* (*but-for test*): hay causalidad cuando el daño no hubiera ocurrido de no haberse realizado la conducta, por acción u omisión, del demandado.

> El problema práctico de este test radica en su naturaleza contrafactual. Requiere que el tribunal determine una causalidad hipotética: ¿qué habría ocurrido si el demandado no hubiera actuado como lo hizo? ¿Qué habría ocurrido de no omitir la conducta que se esperaba de él? Estas preguntas plantean serios problemas de prueba *("it is impossible to go back to the moment before the accident, «remove» the negligence of the defendant, and see what would have happened"* (ABRAHAM (2002), p. 101). El concepto de acción supone la causación de efectos y el de omisión, su ausencia, pero siempre que hacemos algo evitamos algo (lo que habría ocurrido si no hubiéramos hecho nada) y omitimos algo (lo que habríamos podido hacer pero no hemos hecho). Véase, MOSTERÍN (1987, p. 141).

7.1.1. Causalidad y omisión

La primera cuestión que se plantea es si podemos hablar de causalidad en la omisión. Filosóficamente, hay muchos trucos para rodear el problema de la causalidad en la omisión. Véase el siguiente que tomamos de la obra citada de DÍEZ/MOULINES (1998, p. 253): hay causas "propiciativas" (*contributing*), que contribuyen positivamente a la ocurrencia del efecto, y "resistivas" (*counteracting*), que contribuyen a su no ocurrencia: fumar es causa propiciativa de cáncer de pulmón, mientras que hacer ejercicio es una causa resistiva. Este carácter no es absoluto, pues puede alterarse en presencia de otras causas: la arena es causa propiciativa de accidentes de carretera, pero en presencia de hielo es causa resistiva.

La mayor parte de los casos de responsabilidad civil son pecados de falta de control o de vigilancia de hechos ajenos: la actuación descuidada del dependiente es causa propiciativa de daños; el control o vigilancia por parte del empresario es causa resistiva (véase art. 1903 CC). Por tanto, la omisión de este control o vigilancia remueve una causa resistiva y, en este sentido, podemos afirmar que, en cierto modo, está contribuyendo a la producción del daño.

La idea es que si el patrono y el empleado solvente, en el supuesto arquetípico, pudieran contratar libremente, entonces la existencia o inexistencia de un sistema de responsabilidad por el hecho ajeno no sería relevante. En la práctica lo es y mucho porque: i) la víctima sabe qué empresa le causó daños, pero no cuál de sus empleados; ii) los empleados suelen ser escasamente solventes; iii) en ausencia de responsabilidad, el patrono contrataría a los más insolventes (*judgement proof defendants*); iv) hay muchos costes de negociación entre patronos y obreros. Para un análisis más extenso de este problema, véase SALVADOR/ GÓMEZ (2002).

En España, la mayor parte de los recursos de casación resueltos por sentencia del Tribunal Supremo son casos de responsabilidad por omisión en la vigilancia o control de los hechos de otro. Así, en el caso Aznalcóllar resuelto por la **STS, 3ª, de 22 de noviembre de 2004**, la rotura de un dique de contención de una balsa de residuos mineros había producido el vertido de su contenido en un afluente del río Guadalquivir, el Guadiamar, cuyo cauce fue invadido por lodos contaminantes que dañaron la flora y la fauna del sistema hídrico. La balsa de residuos mineros era propiedad de Boliden Apirsa, SL, que, en marzo de 1996, había encargado el recrecimiento del dique de la balsa a Geocisa, SA que, a su vez, había asumido el control de la instalación. El Tribunal Supremo confirmó en lo sustancial el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.8.2002 en cuya virtud, conforme a los arts. 89, 108 f) y g) y 110.1 de la Ley 29/1985, de Aguas, había sancionado a Boliden Apirsa, SL con una multa de 601.012,1 € y le había condenado al pago de 2.870.181,66 € por los daños al dominio público hidráulico y a abonar 41.606.316,75 € por los gastos originados por la reposición del terreno al estado anterior a los hechos. Entre otros argumentos, el Tribunal Supremo fundamenta su decisión en clave de omisión: "*A Boliden Apirsa, S.L., le era exigible, como titular de la explotación minera el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad y la omisión de ese deber comporta ese elemento de culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el acuerdo de que trae causa este proceso. [...] A Boliden Apirsa, S.L., le es imputable la culpa en la elección de esa empresa [Geocisa] y la culpa por no haberse implicado más directamente en la vigilancia de unos instrumentos de control creados para mantener la seguridad en una situación de riesgo creada por ella en el ejercicio de su actividad*" (FD 11º).

STS, 1ª, 279/2011, de 11 de abril

"1. El marido y los hijos de Dª Azucena , fallecida el día 10 de enero de 2002 en accidente laboral sufrido cuando se hallaba trabajando en las instalaciones de la empresa Pirotecnia Ricardo Caballer S.A. y explotó la caseta número 15 en la que desarrollaba sus funciones de llenado manual de pólvora y montaje de carcasas, formularon demanda contra la citada mercantil, su aseguradora, Mussini S.A. de Seguros y Reaseguros, y contra la entidad contratada para la prevención de riesgos laborales, Asepeyo, Mutua de Accidentes, en reclamación de la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos, pretensión que sustentaban en los artículos 1902 y 1903 CC (LEG 1889, 27) , en el artículo 76 LCS (RCL 1980, 2295) , y en el incumplimiento, por parte del empleador, de la obligación contenida en la legislación laboral de adoptar las medidas adecuadas de protección y prevención de la salud de sus trabajadores.

2. La demanda, a la que se opusieron los demandados, fue parcialmente estimada por el Juzgado, que apreció únicamente la responsabilidad de Asepeyo con absolución de

los demás. En síntesis, y por lo que interesa a los efectos del recurso de casación, son sus principales razonamientos los siguientes:

a) que ninguna responsabilidad tuvo la empresa pirotécnica en el accidente, ni por culpa in eligendo [en la elección] ni por culpa in vigilando [en la vigilancia], puesto que cumplió adecuadamente con la obligación de velar por la salud y seguridad de sus empleados, principalmente, al contratar con Asepeyo la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales y poner a su disposición el debido asesoramiento y la participación de los trabajadores, incluida la fallecida, en jornadas de formación sobre los riesgos concretos en la actividad que desarrollaban, y además, por imponer a los trabajadores otras medidas de seguridad complementarias en el lugar de trabajo, sin constancia de irregularidad administrativa alguna imputable a dicha empresa en materia de seguridad, ni en la ejecución de las medidas ordenadas por Asepeyo (la inspección realizada por los técnicos de Asepeyo el día del siniestro no apreció irregularidad en el cumplimiento de la medida de seguridad indicada en el plan de prevención).

b) que tampoco la causa del accidente estuvo en un fallo humano imputable a la propia víctima.

c) que fue Asepeyo quien se apartó de la Guía elaborada por la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, en lo referente a las medidas a adoptar en las mesas de trabajo, puesto que omitió indicar que el recubrimiento con malla metálica era una simple recomendación (tras el accidente, la Asociación de Pirotécnicas de la Comunidad Valenciana desaconsejó a sus asociados esta medida) y también que debía ir acompañado de la colocación de "una resistencia de 10 K ohmios en serie con el conductor de tierra", omisión esta última - la mesa se recubrió con lámina metálica puesta directamente a tierra, sin la mencionada resistencia- que fue lo que facilitó la descarga de cargas electroestáticas sobre dicha superficie.

d) que aunque Asepeyo no era la responsable del funcionamiento y buena aplicación de las medidas preventivas señaladas en su plan, si estaba obligada a realizar ensayos o informes anteriores a su implantación, lo que no hizo (no realizó estudio alguno sobre electricidad estática en las mesas o sobre sensibilidad de las bolas de colores).

e) que el escaso tiempo transcurrido entre la implantación de la medida indicada en el plan y el accidente (2 o 3 horas) es un dato que corrobora que fue el recubrimiento de las mesas de madera con una tela metálica con toma de tierra y sin resistencia de 10 k ohmios lo que determinó la ignición de la pólvora y la consiguiente explosión que acabó con la vida de la trabajadora y de otro de sus compañeros.

4. Recurrida la citada sentencia en apelación por Asepeyo y por la parte actora en lo que le resultaba desfavorable, la AP acordó desestimar el recurso de la primera y estimar en parte el de los demandantes, en el sentido de extender la responsabilidad a la empresa de pirotecnia y a su aseguradora. En síntesis, en lo referente al concreto motivo de casación, la sentencia de apelación declaró:

a) la causa del siniestro fue la incorrecta instalación de la plancha de aluminio que debía recubrir la madera de la mesa de trabajo, por carecer el cable conductor a tierra de una resistencia en serie debido a la incorrecta redacción que de tal medida hizo la entidad Asepeyo.

b) la pirotécnica Ricardo Caballer, S.A., para la que trabajaba la fallecida, cumplió con la obligación de velar por su seguridad y salud al contratar con Asepeyo la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales e imponer a los trabajadores las medidas indicadas en el plan, entre ellas, la consistente en la

instalación de un recubrimiento metálico en las mesas de trabajo, contando además en el momento del siniestro con todas las autorizaciones administrativas.

c) sin embargo, en casos de actividades especialmente peligrosas, como la que se desarrollaba por la víctima, no es suficiente el cumplimiento de las normas y reglamentos, debiendo el empresario extremar su diligencia. En el presente caso no lo hizo e incurrió en culpa levísima tanto por no entregar a la empresa de electricidad que se encargó de ejecutar la medida de recubrir las mesas una copia por escrito de las directrices que había ordenado Asepeyo, y limitarse a comunicarlas telefónicamente (lo que provocó que la empresa Electro Pobla, S.L. instalase la lámina de aluminio sin tener delante un croquis o directiva de cómo hacerlo), como por no contrastar tampoco con otros técnicos la efectividad de dichas medidas habida cuenta de las dudas que existían desde el punto de vista científico. Esta negligencia lleva a estimar la responsabilidad de la pirotecnia por aplicación de la teoría del riesgo y, consecuentemente, la de su aseguradora Musini, S.A. de Seguros y Reaseguros.

5. Contra esta sentencia interpone recurso de casación la representación procesal de Musini, S.A. de Seguros y Reaseguros, al amparo del artículo 477.2.3º LEC. El recurso consta de un único motivo y ha sido admitido por superar la cuantía el límite legal.

(…)

SEGUNDO

- Enunciación del motivo único de casación.

El motivo se introduce con la fórmula:

«Único. Al amparo de los dispuesto en el artículo 479.4 de la LEC , en relación con el art. 477.3 LEC , se viene a denunciar la infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable para resolver cuestiones objeto de debate, sentada por esa Sala en cuanto a la interpretación y aplicación del artículo 1903.4 del C. Civil».

La aseguradora de la empresa de pirotecnia defiende que ni su asegurada, ni, por consecuencia, ella misma, deben responder solidariamente de las consecuencias del siniestro. Funda esta tesis en la ausencia de la relación de dependencia o jerarquía que exige el artículo 1903.4 CC , entre el causante del daño y la empresa que ha de responder por el hecho ajeno, al derivarse de los hechos probados que la causa de siniestro estuvo en una deficiente instalación del recubrimiento de aluminio de la mesa de trabajo, tarea a cargo exclusivamente de Asepeyo, como empresa especializada en la elaboración y ejecución del plan de prevención de riesgos laborales, no sometida en su actuación a las directrices de la empresa pirotécnica.

El motivo debe ser desestimado.

(…)

CUARTO

(…)

En efecto, tal y como se deduce de la simple lectura del FD Tercero de la sentencia recurrida, dedicado a justificar la estimación del recurso de la parte demandante, la Audiencia Provincial funda la responsabilidad de la empresa pirotécnica (y, por ende, de su aseguradora), única y exclusivamente en una negligencia propia, esto es, en la omisión de la específica diligencia, superior a la normal, que le era exigible en atención

al específico y extraordinario riesgo que entrañaba su actividad, diligencia que entiende no agotó la entidad Ricardo Caballer S.A. con la mera sujeción a la normativa reglamentaria ni con haber contratado la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales con una empresa especializada, en tanto que, para la Audiencia Provincial, la obligación de extremar su diligencia en aras a evitar cualquier daño a la integridad o salud de sus trabajadores le imponía además el deber de contrastar la eficacia de las medidas de seguridad recomendadas o impuestas por Asepeyo, ante la existencia de dudas de índole científico, e igualmente, el deber de transmitir estrictamente y por escrito las directrices de esta entidad a la empresa de electricidad que iba a encargarse de la ejecución material de las medidas contempladas en el plan (y en particular, de la medida consistente en recubrir con metal las mesas de trabajo, cuya incorrecta instalación, consecuencia directa de la incorrecta redacción de tal medida solo imputable a Asepeyo, fue la causa del siniestro).

(…)

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Musini, S.A., Seguros y Reaseguros, contra la sentencia de 26 de julio de 2006 (JUR 2007, 39877), dictada en grado de apelación por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en el rollo n.º 373/06 , dimanante del juicio ordinario n.º 195/03, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Paterna , cuyo fallo dice:

»Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Asepeyo, Mutua de Accidentes, contra la sentencia de fecha 1 de septiembre de 2005 dictada en los autos número 195/03 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Paterna .

»Estimamos en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal don Luis María , don Alvaro y doña Piedad , contra la misma resolución, la que revocamos en parte.

»Y, en su lugar, estimando en parte la demanda, condenamos solidariamente a la entidad Asepeyo Mutua de Accidentes, a Pirotecnia Ricardo Caballer S.A. y a su aseguradora Mussini a que indemnicen a los demandados en la suma de 112.071,30 €, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes, que para la aseguradora serán los que determina el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (RCL 1980, 2295), desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

»No hacemos expresa condena al pago de las costas causadas en ambas instancias»".

Obsérvese que, en la omisión, la ley establece un deber de actuar que el obligado incumplió: no hay causalidad sino incumplimiento de un deber (*breach of duty*), como en la negligencia.

En cualquier caso, la causalidad de hecho, ya sea por acción u omisión, es un mal criterio de imputación de daños, pues plantea una infinidad de problemas en casos de causación múltiple y causación indeterminada. A continuación se plantearán algunos de los más relevantes.

7.1.2. Causalidad múltiple

Lo normal es que haya demasiadas causas, es decir, que haya muchos eventos sin cuyo acaecimiento tampoco se habría producido el daño. La causalidad es un criterio de imputación demasiado amplio.

> Véase si no el siguiente concepto de causa total, que tomamos de uno de los mejores manuales de filosofía de la ciencia escritos en la pasada década: *"[c]ada acontecimiento tiene por lo general múltiples causas. [...] La causa total de un suceso e es la suma [...] de todos los eventos c_1, c_2, ... c_n tales que, de cada c_i (1…i…n), es cierto que de no haber ocurrido c_i, y permaneciendo todo lo demás igual, tampoco habría ocurrido e"* (DÍEZ/ MOULINES (1997, p. 146).
>
> Parecidamente, FUMERTON/KRESS (2001, p. 98): *"The problem is that, to get a set of conditions that is genuinely lawfully sufficient for some outcome, the set must contain indefinitely many conditions"*.

Cuando varios agentes contribuyan a causar un daño, su actuación conjunta puede crear un efecto sinérgico: la actuación de uno refuerza el efecto perjudicial de la del otro o viceversa, de forma tal que mientras la probabilidad de que cada conducta, aisladamente considerada, causara el daño es reducida, en cambio, la probabilidad de que la superposición de ambas lo cause es mucho más elevada que la suma de las probabilidades individuales. Parecidamente, KORNHAUSER/ REVESZ ((1998), p. 371 y (2000), p. 626 y ss.): si hay varios agentes potenciales de daños que actúan secuencialmente, el primero en actuar puede no causar ningún daño porque, por ejemplo, la cantidad de vertidos que realiza es por sí sola inocua. Pero los vertidos de quienes le siguen se suman a los anteriores y, entre todos, acaban por causar graves daños. Dicho de otro modo, talar medio bosque no es necesariamente grave, pero cortar los árboles restantes sería una catástrofe. La regla, tradicionalmente aplicada por los tribunales españoles, de la responsabilidad objetiva y solidaria de los cocausantes del daño no tiene en cuenta que el segundo agente es mucho más peligroso que el primero: el veneno está en la dosis.

> La concesión de acciones de regreso a quien ha pagado una indemnización por el todo limita la conclusión anterior, pero únicamente si el sistema judicial funciona razonablemente bien y gradúa la acción de regreso en función del incremento del daño causado en vez de hacerlo – en el ejemplo anterior - proporcionalmente al número de árboles talados. Además, requiere que el demandado en vía de regreso sea solvente.

En los casos de efecto sinérgico es muy discutido si hay o no un único modo lógico de imputar los daños a cada uno de los demandados (véase BEN-SHAHAR (2000), p. 659). Algunas propuestas, con todo, estimulan la reflexión de los jueces y magistrados llamados a decidir: una de ellas, por ejemplo, define el daño marginal de cada demandado, en casos de actuación simultánea de varios dañadores, teniendo en cuenta el promedio de todas las combinaciones posibles de actos dañinos; otra apunta al hecho de que si todos los demandados se comportaron de tal modo que habría bastado la actuación de cualquiera de ellos para causar todo el daño, el régimen de responsabilidad solidaria infraincentiva un comportamiento prudente de todos ellos, pues el daño sólo se causa una vez y la acción de regreso permitirá dividir su estimación proporcionalmente al número de causantes. En casos así resulta justificada una condena por importe superior a los daños causados.

7.1.3. Causalidad indeterminada

En el *Common Law*, la doctrina procesal civil en materia de prueba propugna que el demandado debe ser condenado si la probabilidad de que haya causado el daño es mayor que al 0'5 (*preponderance evidence rule)*, es decir, si es más probable que haya causado el daño que lo contrario. Esta tesis es polémica.

Para algunos, la regla de la preponderancia de la probabilidad positiva es correcta. Así, supongamos (con BEN- SHAHAR (2000) p. 654, siguiendo a KAYE (1982)) un caso en el que el daño es de 100 €, pero la probabilidad de que el demandado lo haya causado es sólo del 40%. Si se aplica la regla, el demandado será absuelto, pero a costa de un error probable de 40 € (0'4 x 100 = 40). Sin embargo, supóngase ahora que rige una regla de responsabilidad proporcional a la probabilidad de haber causado el daño, es decir, bastará con que la probabilidad sea mayor que cero, pero el importe de la condena se graduará de acuerdo con aquélla. Entonces, en el caso anterior el tribunal condenará al demandado a pagar 40 € al demandante, pero el coste del error esperado será 48 € en vez de 40 € (hay un 40% de probabilidad de que el demandado fuera el causante del daño; entonces, si causó daños de 100 €, es condenado a pagar 40 y deja de pagar 60: el coste de error esperado es de 0'4 x 60 = 24. Pero también hay un 60% de probabilidad de que el demandado no causara daño alguno, en cuyo caso pagará de más los 40 € a que será condenado: aquí el coste del error esperado es de 0'6 x 40 = 24. La suma de ambos errores, fruto de la aplicación de la regla de la responsabilidad proporcional es de 24 + 24 = 48. Hay una pérdida esperada neta de 8). La regla de la preponderancia de la probabilidad positiva es también defendida por otros (LEVMORE (1990)), que entienden que incentiva a los actores para que traten de reducir la incerteza del juicio aportando más pruebas. Por último, la regla mencionada puede reducir los costes de litigación, aunque sólo sea porque habrá menos casos que litigar.

Otros en cambio critican la tesis de la preponderancia de la probabilidad y favorecen una regla de responsabilidad proporcional. Supóngase un caso de concurrencia de causas (SHAVELL (1998), p. 212), en el que hay i) una infinidad de pequeños productores cuyas cuotas de mercado y probabilidad individual de causar daños son muy bajas; y ii) un gran productor con una cuota de mercado de más del 50%. Dado un daño imputable a alguna empresa de la industria y en ausencia de prueba sobre qué empresa lo causó, la regla tradicional llevará a que los pequeños productores sean infraincentivados a adoptar las precauciones justas, pues fácilmente evadirán toda responsabilidad, dadas las reducidas probabilidades de haberlos causado efectivamente. En cambio, el productor principal será sobreincentivado, pues, como autor de más del 50% de los daños probables, no podrá evitar la condena por la totalidad. Por eso, SHAVELL propone imponer responsabilidad en proporción a la probabilidad de causación de cada cual, por pequeña que resulte (*market share liability*). La tesis apunta a un inconveniente claro de la regla de la preponderancia de la probabilidad: distorsiona los incentivos de quienes sabiendo que es muy poco probable que su comportamiento genere algún daño lo llevan a cabo sistemáticamente, en la suposición de que nunca serán condenados (así, en el ejemplo del apartado anterior el demandado nunca sería condenado, pues la probabilidad de que su conducta causara el daño es sólo del 0'4. La doctrina suele referirse a esta cuestión con la expresión *recurring misses*, fallos repetidos).

Como señala BEN-SHAHAR (2000) las posiciones del debate reflejan dos puntos de partida distintos en materia de causalidad: quienes favorecen la primera tesis privilegian una

perspectiva *ex post* del derecho de daños y quienes son partidarios de la segunda ponen el acento en una visión *ex ante*, centrada en la idea de prevención de daños. Una síntesis ha sido intentada por PORAT/STEIN (1997), quienes se pronuncian por una regla de responsabilidad por incerteza *(liability for uncertainty)*: responderá por un daño cuya causa es incierta la parte que originó o tuvo la mejor oportunidad de evitar la incerteza, ello llevaría a las partes a optimizar sus inversiones y despejar *ex ante* la incertidumbre, de forma que *ex post,* la aplicación de las reglas ordinarias de responsabilidad, ya se encargarían de generar los incentivos óptimos para reducir el daño primario. Responde así quien está en mejor condición de preconstruir la prueba *(cheapest evidence providers*)".

7.2. Causalidad genérica y específica / *Generic Causation and Specific Causation*

La distinción entre causalidad genérica y específica es especialmente relevante en casos en que la víctima ha sido expuesta a una sustancia tóxica, como los medicamentos o los productos químicos. Mientras que la causalidad específica se refiere a la cuestión, común a todo caso de daños, de si la conducta del demandado efectivamente causó el daño al demandante, la causalidad genérica responde a la cuestión de si la conducta del demandado pertenece al tipo de actividad capaz generalmente de causar un daño del tipo sufrido por el demandante. La víctima de daños asociados a medicamentos deberá acreditar, para vencer en juicio, no sólo que ha consumido el concreto medicamento en circunstancias tales que hacen posible la materialización del daño -período de consumo, dosis, circunstancias personales de la víctima tales como la edad, los hábitos o antecedentes médicos y familiares- (causalidad específica), sino además, y de forma previa, que el producto es, conforme al estado de la ciencia y de la técnica disponible, idóneo o capaz en abstracto de producir aquel daño (causalidad genérica). El éxito de la acción de daños dependerá entonces de la validez de la prueba pericial que apoye la alegación de la víctima sobre la causalidad genérica (James A. Henderson Jr., Rucgard N. Pearson, Douglas A Kysar y John A. Siciliano (2007), *The Torts Process*, 7ª ed., Wolters Kluwer, Nueva York, pp. 106, 112-116, 2007). Sobre esta cuestión, véase el apartado relativo al análisis de los casos del US Common Law *Frye v. United States,* 293 F. 1013 .C. Cir. 1923, *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.,* 509 U.S. 579 (1993) y de la Regla 702 de las *Federal Rules of Rules*. En derecho español, rige la regla de libre apreciación por el juez de la prueba y también de la prueba pericial (art. 348 Ley de Enjuiciamiento Civil: "[e]l tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica").

7.3. Causalidad alternativa / *Alternative Causation*

Remisión: pluralidad de causantes de un mismo daño indivisible y responsabilidad solidaria (*joint and several liability*).

7.3.1. *Summers v. Tice* (33 Cal. 2d 80, 199 P.2d 1 (1948))

CARTER, J. Each of the two defendants appeals from a judgment against them in an action for personal injuries. Pursuant to stipulation the appeals have been consolidated.

Plaintiff's action was against both defendants for an injury to his right eye and face as the result of being struck by bird shot discharged from a shotgun. The case was tried by the court without a jury and the court found that on November 20, 1945, plaintiff and the two defendants were hunting quail on the open range. Each of the defendants was armed with a 12 gauge shotgun loaded with shells containing 7 1/2 size shot. Prior to going hunting plaintiff discussed the hunting procedure with defendants, indicating that they were to exercise care when shooting and to "keep in line." In the course of hunting plaintiff proceeded up a hill, thus placing the hunters at the points of a triangle. The view of defendants with reference to plaintiff was unobstructed and they knew his location.

Defendant Tice flushed a quail which rose in flight to a 10-foot elevation and flew between plaintiff and defendants. Both defendants shot at the quail, shooting in plaintiff's direction. At that time defendants were 75 yards from plaintiff. One shot struck plaintiff in his eye and another in his upper lip. Finally it was found by the court that as the direct result of the shooting by defendants the shots struck plaintiff as above mentioned and that defendants were negligent in so shooting and plaintiff was not contributorily negligent. [...]

The problem presented in this case is whether the judgment against both defendants may stand. It is argued by defendants that they are not joint tortfeasors, and thus jointly and severally liable, as they were not acting in concert, and that there is not sufficient evidence to show which defendant was guilty of the negligence which caused the injuries -- the shooting by Tice or that by Simonson.

Considering [this argument], we believe it is clear that the court sufficiently found on the issue that defendants were jointly liable and that thus the negligence of both was the cause of the injury or to that legal effect. .... It thus determined that the negligence of both defendants was the legal cause of the injury -- or that both were responsible. Implicit in such finding is the assumption that the court was unable to ascertain whether the shots were from the gun of one defendant or the other or one shot from each of them. The one shot that entered plaintiff's eye was the major factor in assessing damages and that shot could not have come from the gun of both defendants. It was from one or the other only. [...]

1. Dean Wigmore has this to say: "When two or more persons by their acts are possibly the sole cause of a harm, or when two or more acts of the same person are possibly the sole cause, and the plaintiff has introduced evidence that the one of the two persons, or the one of the same person's two acts, is culpable, then the defendant has the burden of proving that the other person, or his other act, was the sole cause of the harm. (b) . . . The real reason for the rule that each joint tortfeasor is responsible for the whole damage is the practical unfairness of denying the injured person redress simply because he cannot prove how much damage each did, when it is certain that between them they did all; let them be the ones to apportion it among themselves. Since, then, the difficulty of proof is the reason, the rule should apply whenever the harm has plural causes, and not merely when they acted in conscious concert. . . ." (Wigmore, Select Cases on the Law of Torts, § 153.)

2. When we consider the relative position of the parties and the results that would flow if plaintiff was required to pin the injury on one of the defendants only, a requirement that the burden of proof on that subject be shifted to defendants becomes manifest. They are both wrongdoers -- both negligent toward plaintiff. They brought about a situation where the negligence of one of them injured the plaintiff, hence it should rest with them each to absolve

himself if he can. The injured party has been placed by defendants in the unfair position of pointing to which defendant caused the harm. If one can escape the other may also and plaintiff is remediless. Ordinarily defendants are in a far better position to offer evidence to determine which one caused the injury. […]

> In addition to that, however, it should be pointed out that the same reasons of policy and justice shift the burden to each of defendants to absolve himself if he can – relieving the wronged person of the duty of apportioning the injury to a particular defendant, apply here where we are concerned with whether plaintiff is required to supply evidence for the apportionment of damages. If defendants are independent tortfeasors and thus each liable for the damage caused by him alone, and, at least, where the matter of apportionment is incapable of proof, the innocent wronged party should not be deprived of his right to redress. The wrongdoers should be left to work out between themselves any apportionment... Some of the cited cases refer to the difficulty of apportioning the burden of damages between the independent tortfeasors, and say that where factually a correct division cannot be made, the trier of fact may make it the best it can, which would be more or less a guess, stressing the factor that the wrongdoers are not in a position to complain of uncertainty. […]

The judgment is affirmed.

7.3.2. *Ybarra v. Spangard* (*25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687*)

GIBSON, C. J. This is an action for damages for personal injuries alleged to have been inflicted on plaintiff by defendants during the course of a surgical operation. The trial court entered judgments of nonsuit as to all defendants and plaintiff appealed.

On October 28, 1939, plaintiff consulted defendant Dr. Tilley, who diagnosed his ailment as appendicitis, and made arrangements for an appendectomy to be performed by defendant Dr. Spangard at a hospital owned and managed by defendant Dr. Swift. Plaintiff entered the hospital, was given a hypodermic injection, slept, and later was awakened by Drs. Tilley and Spangard and wheeled into the operating room by a nurse whom he believed to be defendant Gisler, an employee of Dr. Swift. Defendant Dr. Reser, the anesthetist, also an employee of Dr. Swift, adjusted plaintiff for the operation, pulling his body to the head of the operating table and, according to plaintiff's testimony, laying him back against two hard objects at the top of his shoulders, about an inch below his neck. Dr. Reser then administered the anesthetic and plaintiff lost consciousness. When he awoke early the following morning he was his hospital room attended by defendant Thompson, the special nurse, and another nurse who was not made a defendant.

Plaintiff testified that prior to the operation he had never had any pain in, or injury to, his right arm or shoulder, but that when he awakened he felt a sharp pain about half way between the neck and the point of the right shoulder. He complained to the nurse, and then to Dr. Tilley, who gave him diathermy treatments while he remained in the hospital. The pain did not cease but spread down to the lower part of his arm, and after his release from the hospital the condition grew worse. He was unable to rotate or lift his arm, and developed paralysis and atrophy of the muscles around the shoulder. He received further treatments from Dr. Tilley until March, 1940, and then returned to work, wearing his arm in a splint on the advice of Dr. Spangard. […]

We have no doubt that in a modern hospital a patient is quite likely to come under the care of a number of persons in different types of contractual and other relationships with each other. For

example, in the present case it appears that Drs. Smith, Spangard and Tilley were physicians or surgeons commonly placed in the legal category of independent contractors; and Dr. Reser, the anesthetist, and defendant Thompson, the special nurse, were employees of Dr. Swift and not of the other doctors. But we do not believe that either the number or relationship of the defendants alone determines whether the doctrine of res ipsa loquitur applies. Every defendant in whose custody the plaintiff was placed for any period was bound to exercise ordinary care to see that no unnecessary harm came to him and each would be liable for failure in this regard. Any defendant who negligently injured him, and any defendant charged with his care who so neglected him as to allow injury to occur, would be liable. The defendant employers would be liable for the neglect of their employees; and the doctor in charge of the operation would be liable for the negligence of those who became his temporary servants for the purpose of assisting in the operation. […]

The judgment is reversed.

7.4. Causalidad concurrente / *Concurrent Causation*

7.4.1. *Kingston v. Chicago Ry.* (191 Wis. 610, 211 N.W. 913 (1927))

OWEN, J. We therefore have this situation: The northeast fire was set by sparks emitted from defendant's locomotive. This fire, according to the finding of the jury, constituted a proximate cause of the destruction of plaintiff's property. This finding we find to be well supported by the evidence. We have the northwest fire, of unknown origin. This fire, according to the finding of the jury, also constituted a proximate cause of the destruction of the plaintiff's property. This finding we also find to be well supported by the evidence. We have a union of these two fires 940 feet north of plaintiff's property, from which point the united fire bore down upon and destroyed the property. We therefore have two separate, independent, and distinct agencies, each of which constituted the proximate cause of plaintiff's damage, and either of which, in the absence of the other, would have accomplished such result.

It is settled in the law of negligence that any one of two or more joint tortfeasors, or one of two or more wrongdoers whose concurring acts of negligence result in injury, are each individually responsible for the entire damage resulting from their joint or concurrent acts of negligence. This rule also obtains "where two causes, each attributable to the negligence of a responsible person, concur in producing an injury to another, either of which causes would produce it regardless of the other, . . . because, whether the concurrence be intentional, actual, or constructive, each wrongdoer, in effect, adopts the conduct of his co-actor, and for the further reason that it is impossible to apportion the damage or to say that either perpetrated any distinct injury that can be separated from the whole. The whole loss must necessarily be considered and treated as an entirety […]

It is […]conceivable that a fire so set might unite with a fire of so much greater proportions, such as a raging forest fire, as to be enveloped or swallowed up by the greater holocaust, and its identity destroyed, so that the greater fire could be said to be an intervening or superseding cause. But we have no such situation here. These fires were of comparatively equal rank. If there was any difference in their magnitude or threatening aspect, the record indicates that the northeast fire was the larger fire and was really regarded as the menacing agency. At any rate

there is no intimation or suggestion that the northeast fire was enveloped and swallowed up by the northwest fire. We will err on the side of the defendant if we regard the two fires as of equal rank.

According to well settled principles of negligence, it is undoubted that if the proof disclosed the origin of the northwest fire, even though its origin be attributed to a third person, the railroad company, as the originator of the northeast fire, would be liable for the entire damage. There is no reason to believe that the northwest fire originated from any other than human agency. It was a small fire. It had traveled over a limited area. It had been in existence but for a day. For a time it was thought to have been extinguished. It was not in the nature of a raging forest fire. The record discloses nothing of natural phenomena which could have given rise to the fire. It is morally certain that it was set by some human agency.

Now the question is whether the railroad company, which is found to have been responsible for the origin of the northeast fire, escapes liability because the origin of the northwest fire is not identified, although there is no reason to believe that it had any other than human origin. An affirmative answer to that question would certainly make a wrongdoer a favorite of the law at the expense of an innocent sufferer. The injustice of such a doctrine sufficiently impeaches the logic upon which it is founded. Where one who has suffered damage by fire proves the origin of a fire and the course of that fire up to the point of the destruction of his property, one has certainly established liability on the part of the originator of the fire. Granting that the union of that fire with another of natural origin, or with another of much greater proportions, is available as a defense, the burden is on the defendant to show that by reason of such union with a fire of such character the fire set by him was not the proximate cause of the damage. No principle of justice requires that the plaintiff be placed under the burden of specifically identifying the origin of both fires in order to recover the damages for which either or both fires are responsible.[…]

By the Court.--Judgment affirmed.

Daños causados por incendios y doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo conforme a la cual al actor, víctima de un incendio, le basta con probar que este tuvo su origen en la esfera de influencia del demandado

7.4.2. STS, 1ª, 816/2011, de 6 de febrero de 2012

Sobre las 0:15 horas del 1 de julio de 2004, mientras la plataforma remolque frigorífico matrícula AAA se encontraba realizando labores de carga en el establecimiento Supersol sito en la plataforma baja de Mercamadrid, sufrió un incendio, por cortocircuito en el compresor frigorífico, que afectó tanto a la mercancía como al edificio e instalaciones del supermercado. En esa fecha la plataforma remolque era propiedad de Carrocerías Lucas y su uso correspondía a D. Eusebio en virtud de contrato de préstamo de uso celebrado el 11 de febrero de 2004. La responsabilidad civil del remolque (obligatoria y suplementaria hasta 50 millones de euros) estaba asegurada con Mapfre mediante póliza suscrita el 17 de febrero de 2004. Con anterioridad (30 de diciembre de 2003) se había asegurado con la misma entidad la cabeza tractora. Ambas pólizas estaban en vigor al ocurrir el siniestro. Por su parte, la mercantil Dinosol Supermercados. S.L. (antes Ahold Supermercados, S.L.) era arrendataria del establecimiento Supersol al tiempo de ocurrir el incendio. En ese tiempo tenía en vigor la póliza de seguros suscrita bajo su antigua denominación con Allianz, Compañía de Seguros y

Reaseguros, S.A. que, en esencia y en los términos pactados, cubría los daños materiales, la pérdida de beneficios, la avería de maquinaria y el robo. De acuerdo con esta última póliza, Allianz abonó a Dinosol Supermercados la cantidad de 101.390,10 euros en concepto de indemnización por los daños sufridos por el incendio y objeto de cobertura.

Dinosol Supermercados, S.L. y Allianz Seguros, S.A. demandaron a D. Eusebio y a Mapfre. Dinosol Supermercados reclamó la indemnización correspondiente a los daños no cubiertos por la póliza mencionada (82.322,90 euros), y Allianz hizo lo propio con la indemnización que esta aseguradora asumió con cargo a la póliza (101.390,10 euros).

El JPI nº 4 de Majadahonda (Madrid), 6.6.2006, desestimó íntegramente la demanda al considerar que el incendio se había producido por caso fortuito. La AP Madrid, Secc. 13ª, 20.2.2008, desestimó el recurso de los demandantes, estimó la impugnación de Mapfre y confirmó, aunque con distintos razonamientos, el fallo absolutorio de primera instancia.

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por Dinosol Supermercados y Allianz en base a que "no existen razones para no calificar como hecho de la circulación [art. 3 RD 7/2001] el incendio que afectó al semirremolque asegurado de responsabilidad civil obligatoria y suplementaria en Mapfre, entidad que, consecuentemente, por tratarse de un siniestro no excluido de cobertura, sí se encuentra pasivamente legitimada frente a la reclamación efectuada de contrario" (…) A esta conclusión se llega valorando que el causante de los daños por los que se reclama es un semirremolque, mencionado expresamente como vehículo a motor en el artículo 2.1 RD 7/2001; que dicho vehículo no se encuentra comprendido en la exclusión del artículo 3.3 RD 7/2001, y que el incendio sobrevino cuando se encontraba estacionado en el lugar destinado a la realización de operaciones de carga y descarga del mismo, consustanciales a su condición de vehículo de transporte de mercancías, situación en que habría de mantenerse, no con vocación de permanencia, sino tan solo por el tiempo necesario para su finalización (lo que, como señaló el Juzgado al aludir a una situación de tránsito, da cuenta de la existencia de una situación de continuidad entre el hecho indudable de la circulación que representa la conducción del vehículo hasta ese lugar y el constituido por el abandono del mismo hasta el de entrega de la mercancía)" (FD 3º B).

El TS añade que "sentado que se trató de un hecho de la circulación, la responsabilidad del propietario o poseedor debe enjuiciarse desde la óptica del singular riesgo creado por la conducción de un vehículo a motor, que, contrariamente a lo señalado por la AP, sí se trata de una situación de especial riesgo, que comporta una presunción de culpa que corresponde destruir al agente, por encontrarse cercano a la fuente de peligro, y que hace que el problema se contraiga en este caso a valorar, desde el punto de vista de la causalidad, su relevancia causal, es decir, si su actuación negligente pudo ser causalmente determinante del resultado dañoso, entendida esa relación de causalidad, no solo desde el plano fenomenológico (causalidad física) sino también desde el plano jurídico, como posibilidad de que se le pueda imputar objetivamente (causalidad jurídica). [D]e manera que al propietario y al conductor sí les correspondía velar por la seguridad del mismo, incluyendo la de todos sus mecanismos, entre ellos, el sistema de refrigeración, en cuanto estaba íntimamente relacionado con la actividad a la que estaba principalmente destinado el vehículo. No cabe, como hace la AP, desvincular la causa física del incendio (cortocircuito en el grupo frigorífico) con los deberes exigibles de adecuado mantenimiento y conservación del vehículo, pues, por más que este hubiera sido cedido escasamente cinco meses antes y dispusiera de certificado oficial sobre su aptitud para ser usado para la finalidad con que estaba siéndolo en el momento del siniestro, su uso continuado

durante este tiempo -y por tanto, con posterioridad a dicha inspección- situaba al agente en una situación de control de la fuente de peligro que le obligaba a extremar su diligencia a fin de detectar posibles incidencias, averías o defectuosos funcionamientos, con objeto de prevenir daños como los ocasionados" (FD 5º B).

Y, en definitiva, el TS "fija la indemnización correspondiente al total de los daños y perjuicios derivados del siniestro en la suma de 173.619,19 euros. De esta cantidad, los demandados deberán indemnizar solidariamente a la demandante Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con la suma por esta satisfecha a su asegurado, de 101.390,10 euros. Y la diferencia, 72.229,09 euros, deberá ser abonada al perjudicado Dinosol Supermercados S.L." (FD 6º). Estas cantidades se incrementarán con los intereses legales desde la fecha de la reclamación extrajudicial (20.6.2005).

7.4.3. STS, 1ª, 425/2009, de 4 de junio

El 16 de febrero de 2000 se produjo un incendio en las naves industriales propiedad de Aceites Villanueva S.A. en la zona donde la sociedad demandada, José Molina Tornero, S.L., (con consta su vinculación legal con la propietaria) había almacenado material fácilmente inflamable, de desecho y cajas de madera fina y cartón.

Aceites Villanueva S.A. demandó a Mutua General de Seguros y a la viuda de José Molina Tornero.

El JPI nº 1 de Alciza (30.10.2003) estimó en parte la demanda y condenó a la viuda de José Molina Tornero a pagar 213.839,52 euros, y a Mutua General de Seguros 75.126 euros más 7.544 euros en concepto de desescombros. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora y modificó la indemnización debida por la Mútua (150.253,03 euros por daños y perjuicios y 5.868,69 euros por gastos de desescombro).

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la viuda de José Molina con base a la infracción del art. 1902 CC:"En los casos de incendio, la jurisprudencia salva las dificultades de prueba de su causa, <u>basando la imputación objetiva en la generación de un peligro jurídicamente desaprobado y en el control que se ejerce sobre las cosas que lo generan. De modo que admite un grado de razonable probabilidad cualificada, distinta de la certeza absoluta, en la reconstrucción procesal de la relación causal</u> - sentencias de 30 de noviembre de 2.001 (RJ 2001, 9919) ; 29 de abril de 2.002 (RJ 2002, 4971) ; 15 de febrero 2008 (RJ 2008, 2669)…" (FD. 4º).

7.4.4. STS, 1ª, 485/2008, de 28 de mayo

En la madrugada del 6.3.1997 se originó un incendio en la vivienda de Juan Antonio, lo cual provocó daños (no se especifican) en las zonas comunes del edificio donde se hallaba, así como en las viviendas de Rodolfo, Clemente, Carlos José y Raúl. Juan Antonio tenía sobre una alfombra del salón un alargador, al que se encontraban enchufados dos teléfonos y una lámpara.

La Comunidad de Propietarios y Rodolfo, Clemente, Carlos José y Raúl demandan a Juan Antonio y su aseguradora, y solicitan una indemnización de 1.792 € así como la reparación de los desperfectos ocasionados en las zonas comunes.

El JPI nº 4 de Sueca (19.1.1999) desestima la demanda. La AP de Valencia (Sección 6ª, 15.6.2000) estima en parte el recurso de apelación y condena al demandado a pagar la suma que se determine en ejecución de sentencia.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la aseguradora del demandado:

> "[H]a de mantenerse el dato de que el incendio se originó en la vivienda del demandado Juan Antonio, y más exactamente, en el enchufe múltiple utilizado por él en el salón comedor del piso… [L]a atribución a éste de la responsabilidad de los daños ocasionados por el fuego responde a la correcta aplicación de la más reciente doctrina de esta Sala, que se resume en la sentencia de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005, 1836)… [o] de 23 de noviembre de 2004 (RJ 2004, 7383) , en donde la imputación de la responsabilidad de los daños causados por un incendio se realizó en atención al control o vigilancia que el demandado ejercía sobre el ámbito doméstico, afirmando que "esta Sala viene declarando que no todo incendio es por caso fortuito y que no basta para llegar a tal conclusión que el siniestro se hubiera producido por causas desconocidas (SSTS, entre otras, de 9 de noviembre de 1993 [RJ 1993, 8973] , 29 de enero de 1996 [RJ 1997, 6365] , 13 de junio de 1998 [RJ 1998, 4687] , 11 de febrero de 2000 y 12 de febrero de 2000 [RJ 2001, 850]), de modo que, generado un incendio dentro del ámbito de control del poseedor de la cosa -propietario o quién está en contacto con ella- hay que presumir que le es imputable, salvo que pruebe que obró con toda la diligencia exigible para evitar la producción del evento dañoso (SSTS, entre otras, de 13 de junio de 1998 [RJ 1998, 4687] , 22 de mayo de 1999, 31 de enero y 11 de febrero de 2000, 12 de febrero [RJ 2001, 850] y 27 de abril de 2001, 24 de enero de 2002 [RJ 2002, 28]). [A]creditado el incendio causante del daño, -no importa que no esté probada la causa del mismo- 20 de abril de 2002 -no es suficiente expresar que no se ha acreditado cuál fue la causa del siniestro-, 27 de febrero (RJ 2003, 2152) y 26 de junio de 2003 (RJ 2003, 5960) -debe probarse el incendio, no el hecho, normalmente imposible, que constituye la causa concreta que lo provocó-".
>
> Esta misma orientación jurisprudencial se encuentra también en las Sentencias de 20 de mayo de 2005 (RJ 2005, 6693) [**citada por la STS, 1ª,15.2.2008, RJ 2669]** , 18 de julio de 2006 (RJ 2006, 5345) (FD. 2º):
>
> ["La sentencia de 20 de mayo de 2005 (RJ 2005, 6693)… precisa que, cuando se produce un incendio en un inmueble, al perjudicado le corresponde probar la realidad del mismo y que se produjo en el ámbito de operatividad del demandado, mientras que a quien tuvo la disponibilidad -contacto, control o vigilancia- de la cosa en que se originó el incendio le corresponde acreditar la existencia de la actuación intencionada de terceros o de serios y fundados indicios de que la causa hubiera podido provenir de agentes exteriores" (FD. 2º **STS, 1ª, 1ª,15.2.2008, RJ 2669, MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel:** Carlos y Ernesto realizaban obras en una vivienda cuando se originó un incendio en ella y dañó las viviendas de Dolores, Lorenzo y María Dolores, que fueron parcialmente indemnizados por la compañía aseguradora "La Unión y el Fénix Español, S.A.")].

7.4.5. *Dillon v. Twin State* (85 N.H. 449, 163 A. 111 (1932))

The defendant maintained wires to carry electric current over a public bridge in Berlin.

In the construction of the bridge there were two spans of girders on each side between the roadway and footway. In each span the girders at each end sloped upwards towards each other from the floor of the bridge until connected by horizontal girders about nineteen feet above the floor.

The wires were carried above the framework of the bridge between the two rows of girders.

To light the footway of the bridge at its center a lamp was hung from a bracket just outside of one of the horizontal girders and crossing over the end of the girder near its connection with a sloping girder. Wires ran from a post obliquely downward to the lamp and crossed the horizontal girder a foot or more above it. The construction of the wire lines over and upon the bridge is termed aerial. The wires were insulated for weather protection but not against contact.

The decedent and other boys had been accustomed for a number of years to play on the bridge in the daytime, habitually climbing the sloping girders to the horizontal ones, on which they walked and sat and from which they sometimes dived into the river. No current passed through the wires in the daytime except by chance.

The decedent, while sitting on a horizontal girder at a point where the wires from the post to the lamp were in front of him or at his side, and while facing outwards from the side of the bridge, leaned over, lost his balance, instinctively threw out his arm, and took hold of one of the wires with his right hand to save himself from falling. The wires happened to be charged with a high voltage current at the time and he was electrocuted.

The circumstances of the decedent's death give rise to an unusual issue of its cause. In leaning over from the girder and losing his balance he was entitled to no protection from the defendant to keep from falling. Its only liability was in exposing him to the danger of charged wires. If but for the current in the wires he would have fallen down on the floor of the bridge or into the river, he would without doubt have been either killed or seriously injured. Although he died from electrocution, yet, if by reason of his preceding loss of balance he was bound to fall except for the intervention of the current, he either did not have long to live or was to be maimed. In such an outcome of his loss of balance, the defendant deprived him, not of a life of normal expectancy, but of one too short to be given pecuniary allowance, in one alternative, and not of normal, but of limited, earning capacity, in the other.

If it were found that he would have thus fallen with death probably resulting, the defendant would not be liable, unless for conscious suffering found to have been sustained from the shock. In that situation his life or earning capacity had no value. To constitute actionable negligence there must be damage, and damage is limited to those elements the statute prescribes.

If it should be found that but for the current he would have fallen with serious injury, then the loss of life or earning capacity resulting from the electrocution would be measured by its value

in such injured condition. Evidence that he would be crippled would be taken into account in the same manner as though he had already been crippled.

His probable future but for the current thus bears on liability as well as damages. Whether the shock from the current threw him back on the girder or whether he would have recovered his balance, with or without the aid of the wire he took hold of, if it had not been charged, are issues of fact, as to which the evidence as it stands may lead to different conclusions.

Exception overruled.

7.5. Causalidad sucesiva / *Succesive Causation*

7.5.1. BGH NJW 1952, 1010

"[…W]enn der Verletzte durch Verschulden des Schädigers ein Bein verloren hat und es ihm 8 Jahre später infolge dieser Behinderung nicht gelingt, auf der Flucht vor plötzlich einsetzendem Artilleriebeschuß rechtzeitig den schützenden Bunker zu erreichen".

7.5.2. *Baker v. Willoughby* ([1970] 2 W.L.R. 50)

"The defendant negligently struck the plaintiff with his automobile, causing severe injury to the plaintiff's left leg and ankle. Some time later, but before trial, the plaintiff was shot in the already-disabled left leg during a robbery at his place of employment. As a result of the gunshot wound, the already disabled left leg had to be amputated. At trial, the defendant argued that he should be liable for the plaintiff's damages due to his disability only up to the time of the shooting. The trial judge rejected this argument but the court of appeal accepted it. The judgment of the court of appeal was reversed by the House of Lords, which ruled that the plaintiff's recovery for his disability was not affected by the second injury and amputation" (as quoted by HENDERSON et al., *The Torts Process*).

7.5.3. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla en accidente de esquí y responsabilidad civil médico-sanitaria.

El 7.1.1991 Marisol sufrió un accidente de esquí en Baqueira Beret que le causó una fractura de espina tibial, de la que fue auxiliada *in situ* y trasladada a Barcelona, donde fue atendida por el Dr. Carlos Antonio, que tenía contratado un seguro con Winterthur y pertenecía a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA". El tratamiento se prolongó hasta mayo de 1992, en cuyo transcurso la paciente se sometió a tres intervenciones. Finalmente, Marisol acudió a otro doctor para que acabase el tratamiento, pero le quedaron secuelas graves que consisten en limitación de la movilidad de la rodilla derecha, atrofia muscular y una cojera irreversible.

Marisol demandó al doctor Carlos Antonio, a Winterthur y a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA" y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 25 de Barcelona (7.4.1995) estimó en parte la demanda y condena a Carlos Antonio y a Winterthur al pago de 72.121,45 €. La AP de Barcelona (Sección 11ª, 8.5.1997) estimó el recurso de apelación, revoca la SJPI y absolvió a los condenados en la instancia previa.

El TS estimó el recurso interpuesto por la actora, revocó la SAP y confirmó la SJPI. Así, el Tribunal Supremo afirmó en su FD 3º:

"En el presente caso, hubo una actuación médica en un dilatado período de tiempo, con repetidas intervenciones quirúrgicas, con un proceso largo y doloroso y un resultado irreversible: una cojera en persona joven. En la relación fáctica basada esencialmente en las varias pruebas periciales se afirma que no hubo culpa o negligencia, lo cual no es un «factum» sino una «quaestio iuris» revisable en casación; se dice que la prueba pericial dice que no hay nexo causal entre la actuación médica y el resultado dañoso; pero no dice cómo ni porqué se ha producido éste; ni dice en ningún momento que la causa fuera ajena a aquella actuación, ni que fuera causada por fuerza mayor, ni que tuviera su origen en previas condiciones de la propia perjudicada.
En definitiva, una caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves, ni complicados, tienen un tratamiento largo y doloroso con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una cojera irreversible; lo cual crea una deducción de negligencia («res ipsa loquitus»), una apariencia de prueba de ésta (*Anscheisbeweis*), una culpa virtual (*faute virtuelle*).
No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad sino de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradichos por hechos considerados acreditados por prueba pericial. Se produce un suceso y un daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (no tiene sentido la aberrante frase antes transcrita: "... causa real fue el acto libre y voluntario de la parte actora"), ni se menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, por ende, la responsabilidad."

7.6. Causalidad probabilística / *Probabilistic Causation*

Un perro Labrador, LAB, adiestrado por la policía de fronteras para detectar drogas, está entrenado para ladrar cuando huele el rastro o residuo de ellas y acierta nueve de cada diez veces que ladra. Es un buen perro, pues tiene una tasa de un 90% de aciertos.

Si de cada 100 pasajeros de un avión procedente de un país andino, 1 lleva drogas y LAB efectivamente ladra a uno de ellos, MULE, ¿cuál es la probabilidad de que MULE lleve drogas?

Mucha gente, cuenta Ward FARNSWORTH (*The Legal Analyst. A Toolkit for Thinking about the Law*, The University of Chicago Press, 2007, capítulo 30, *The Base Rate*) diría que la probablidad es de un 90%. ¡Incorrecto! No preguntamos sobre la probabilidad de que LAB acierte sino sobre la de que MULE lleve drogas y esta última, de entrada es, como hemos dicho, 1%. Al pie de la escalerilla de un avión que acaba de aterrizar con cien pasajeros a bordo, LAB acertará como máximo una vez (pues sólo un pasajero de cada cien lleva drogas), pero olfateará a los otros 99, acertará con el 90% de los casos, pero se equivocará en el 10% de los restantes, es decir, ladrará equivocadamente a 9,99 pasajeros -redondeando: a 10-. De 11 ladridos, 1 identifica a un viajero con drogas. Una tasa correcta para soportar una legislación que permite registrar a los 11 de

cada 100, pero no para aguantar una que permita detenerlos con sola esa información, mucho menos condenarlos.

— *Product Rule*. Es la regla de la probabilidad compuesta: la probabilidad de que salga cara en dos tiradas consecutivas de una misma moneda es 0,5 x 0,5 = ,25, el producto, no la suma de las probabilidades individuales, tratándose de sucesos independientes. En derecho, las cosas no son tan sencillas: en un ejemplo famoso, citado por Ward Farnsworth (capítulo 29), el jurado tenía que decidir sobre si el capitán de un barco era responsable de la desaparición y probable muerte de un marinero que había caído media hora antes a las aguas frías del Atlántico sin que nadie cayera en la cuenta. El capitán decidió no virar la nave y, además, resultaba que no disponía de un cabo para tirárselo al marinero. imaginen que el jurado cree que el demandante tiene razón en afirmar la negligencia del capitán, pues de haber girado la nave a tiempo, habría tenido un 60% de probabilidad de encontrar al marinero vivo y si hubiera dispuesto de un cable o soga, de otro 60% de que el marinero se aferrara a ella y se salvara. A ojos del jurado, quizás el demandante debería ganar, pero si buscamos la probabilidad compuesta: 0,6 x 0,6 = 0,36, podemos concluir que el rescate habría sido poco probable. Podemos cambiar el ejemplo, pero el simple cálculo de probabilidades no resuelve todos los problemas. Así, si la omisión de llevar un cable se considera negligente en un 95% de los casos, pero la probabilidad de que arrojar un cabo en el momento justo inmediatamente posterior al grito de !Hombre al agua!, hace ello una diferencia? Una técnica usada por muchos abogados consiste en descomponer el hecho con probabilidad superior al 50% en varios que la tienen muy inferior.

— Falacia del Fiscal (*Prosecutor's Fallacy*). En un caso de California de finales de los años sesenta, *People v. Colllins*, una mujer había sido robada por el procedimiento del tirón. Un testigo declaró que había visto a la ladrona corriendo calle arriba y le describió como una mujer blanca con una cola de caballo, que conducía un coche amarillo acompañada por un hombre afroamericano con mostacho y barba. Al día siguiente, la policía detuvo a una mujer que respondía a tal descripción. Durante el juicio, el fiscal presentó el peritaje de un profesor de matemáticas para que testificara acerca de la regla de la probabilidad compuesta en el caso:
La probabilidad de que un coche fuera amarillo era de 1/10.
La de que un hombre llevara un mostacho, de 1/4.
La de que la mujer peinara cola de caballo, de 1/10.
La de que ella fuera rubia, 1/10.
La de que el hombre negro tuviera barba, de 1/10.
La de que el coche estuviera ocupado por una pareja interracial, de 1/100.

Fiscal y profesor explicaron al jurado que la probabilidad de que todas estas circunstancias fueran casuales podrían estimarse multiplicando las probabilidades individuales: 1/10 x 1/4 x 1/10, etc., cuyo resultado era de que había una probabilidad por un millón de que hubiera una pareja de tales características. El jurado dictó un veredicto de culpabilidad, pero el Tribunal Supremo californiano había abusado de su argumentación, pues ninguna de las bases de cálculo tenía ningún género de fundamento sólido. Más fácilmente: muchas probabilidades no eran independientes entre sí (por ejemplo, mucha gente que lleva barba también tiene bigote: llevar la una hace más probable llevar la otra). La falacia del fiscal consiste en presentar el caso como si el jurado hubiera de comparar las probabilidades de que el acusado sea culpable con otra persona escogida al azar. Pero la cuestión legal es cómo las probabilidades de que el acusado sea culpable se comparan con la posibilidad de que cualquier otro realmente lo fuera: si una persona en 100.000 tiene los rasgos incriminadores, pero diez en un millón también los tienen,

no deja de ser cierto que la probabilidad de que el primer imputado detenido sea culpable es de una contra diez: hay pues nueve probabilidades de que la detención haya sido equivocada.

The Conjunct Fallacy. Sigue Farnsworth: Linda tiene 32 años, es soltera, extrovertida y muy brillante; se graduó en filosofía, estuvo muy metida en temas de ecología y derechos de los animales, participó en manifestaciones contrarias a la energía nuclear. ¿Qué actividades son más probables que ejerza Linda, (1) cajera de banco o (2) cajera de banco y feminista activa? A Daniel Kahneman le dieron el premio Nobel por mostrar cómo la primera respuesta es mucho más probable que la segunda: (2) es un subconjunto de (1).

— Pablo SALVADOR/Antonio FERNÁNDEZ, "Causalidad y Responsabilidad", 3ª ed., *InDret* 1/2006 (www.indret.com), pp. 5-7:

"**Causalidad indeterminada**

En el *Common Law*, la doctrina procesal civil en materia de prueba propugna que el demandado debe ser condenado si la probabilidad de que haya causado el daño es mayor que al 0'5 (*preponderance evidence rule)*, es decir, si es más probable que haya causado el daño que lo contrario. Esta tesis es polémica.

Para algunos, la regla de la preponderancia de la probabilidad positiva es correcta. Así, supongamos (con BEN- SHAHAR (2000) p. 654, siguiendo a KAYE (1982)) un caso en el que el daño es de 100 €, pero la probabilidad de que el demandado lo haya causado es sólo del 40%. Si se aplica la regla, el demandado será absuelto, pero a costa de un error probable de 40 € (0'4 x 100 = 40). Sin embargo, supóngase ahora que rige una regla de responsabilidad proporcional a la probabilidad de haber causado el daño, es decir, bastará con que la probabilidad sea mayor que cero, pero el importe de la condena se graduará de acuerdo con aquélla. Entonces, en el caso anterior el tribunal condenará al demandado a pagar 40 € al demandante, pero el coste del error esperado será 48 € en vez de 40 € (hay un 40% de probabilidad de que el demandado fuera el causante del daño; entonces, si causó daños de 100 €, es condenado a pagar 40 y deja de pagar 60: el coste de error esperado es de 0'4 x 60 = 24. Pero también hay un 60% de probabilidad de que el demandado no causara daño alguno, en cuyo caso pagará de más los 40 € a que será condenado: aquí el coste del error esperado es de 0'6 x 40 = 24. La suma de ambos errores, fruto de la aplicación de la regla de la responsabilidad proporcional es de 24 + 24 = 48. Hay una pérdida esperada neta de 8). La regla de la preponderancia de la probabilidad positiva es también defendida por otros (LEVMORE (1990)), que entienden que incentiva a los actores para que traten de reducir la incerteza del juicio aportando más pruebas. Por último, la regla mencionada puede reducir los costes de litigación, aunque sólo sea porque habrá menos casos que litigar.

Otros en cambio critican la tesis de la preponderancia de la probabilidad y favorecen una regla de responsabilidad proporcional. Supóngase un caso de concurrencia de causas (SHAVELL (1998), p. 212), en el que hay i) una infinidad de pequeños productores cuyas cuotas de mercado y probabilidad individual de causar daños son muy bajas; y ii) un gran productor con una cuota de mercado de más del 50%. Dado un daño imputable a alguna empresa de la industria y en ausencia de prueba sobre qué empresa lo causó, la regla tradicional llevará a que los pequeños productores sean infraincentivados a adoptar las precauciones justas, pues

fácilmente evadirán toda responsabilidad, dadas las reducidas probabilidades de haberlos causado efectivamente. En cambio, el productor principal será sobreincentivado, pues, como autor de más del 50% de los daños probables, no podrá evitar la condena por la totalidad. Por eso, SHAVELL propone imponer responsabilidad en proporción a la probabilidad de causación de cada cual, por pequeña que resulte (*market share liability*). La tesis apunta a un inconveniente claro de la regla de la preponderancia de la probabilidad: distorsiona los incentivos de quienes sabiendo que es muy poco probable que su comportamiento genere algún daño lo llevan a cabo sistemáticamente, en la suposición de que nunca serán condenados (así, en el ejemplo del apartado anterior el demandado nunca sería condenado, pues la probabilidad de que su conducta causara el daño es sólo del 0'4. La doctrina suele referirse a esta cuestión con la expresión *recurring misses*, fallos repetidos).

Como señala BEN-SHAHAR (2000) las posiciones del debate reflejan dos puntos de partida distintos en materia de causalidad: quienes favorecen la primera tesis privilegian una perspectiva *ex post* del derecho de daños y quienes son partidarios de la segunda ponen el acento en una visión *ex ante*, centrada en la idea de prevención de daños. Una síntesis ha sido intentada por PORAT/ STEIN (1997), quienes se pronuncian por una regla de responsabilidad por incerteza *(liability for uncertainty)*: responderá por un daño cuya causa es incierta la parte que originó o tuvo la mejor oportunidad de evitar la incerteza, ello llevaría a las partes a optimizar sus inversiones y despejar *ex ante* la incertidumbre, de forma que *ex post,* la aplicación de las reglas ordinarias de responsabilidad, ya se encargarían de generar los incentivos óptimos para reducir el daño primario. Responde así quien está en mejor condición de preconstruir la prueba *(cheapest evidence providers*)".

Sesión 8ª
Imputación objetiva

8.1. Imputación objetiva / *Proximate Causation; Scope of Liability* 126
8.2. Previsibilidad / *Foreseeability* 128
8.2.1. Palsgraf v. Long Island R.R. (N248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928)) 128
8.2.2. STS, 1ª, 597/1996, de 19 de julio 130
8.3. *Proximate Cause* / Causalidad Adecuada / *Adäquanztheorie* 131
8.3.1. Stahlecker v. Ford Motor Company (266 Neb. 601, 667 N.W.2d 244 (2003)) 131
8.3.2. STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril 133
8.3.3. STS, 1ª, 377/2004, de 12 de mayo 133
8.3.4. STS, 3ª, de 18 de mayo de 2010 134
8.4. Riesgos generales de la vida /*General Life Risks* / *Erlaubte Risiken* 135
8.4.1. STS, 3ª, 29 de octubre de 1998 135
8.4.2. STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero. 136
8.5. Prohibición de regreso y posición de garante / *Remoteness/ Regressverbot und Garantenstellung* 137
8.6. Ámbito de protección de la norma /Harm within the Risk/ Schutzbereich der Norm 138
8.6.1. STS, 1ª, 902/1998, de 8 de octubre 138
8.6.2. STS, 3ª, 3 de noviembre de 2008 139
8.7. Provocación / *Provocation* / *Herausforderung* 139
8.8. Consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo / *Victim's consent and assumption of risk* / *Einverständigung, Tatbestand-ausschließenden Einwilligung und Handeln auf eigene Gefahr* 140
8.8.1. *Knight v. Jewett* (3 Cal. 4th 296, 834 P.2d 696, 11 Cal. Rptr. 2d 2 (1992)) 141
8.8.2. STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre 141
8.8.3. STS, 1ª, 580/2006, de 31 de mayo 142
8.8.4. STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo 143
8.8.5. Miller and Another v. Jackson and Others [1977] Q.B. 966 Court of Appeal (Civil Division), 1977-04-06 143

8.1. Imputación objetiva / *Proximate Causation; Scope of Liability*

La causalidad de hecho de los juristas, "*conditio sine qua non*" (*But-For test*), plantea, como vimos en la anterior Sesión 7ª, entre otros, un problema muy serio: la mayor parte de las leyes científicas –físicas, químicas, biológicas, psicológicas, económicas, sociológicas, etc.- no se formulan en términos de causalidad, pues la *conditio sine qua non* es muy poco excluyente, dice demasiado acerca de la determinación de un fenómeno, de la explicación y predicción de la realidad. Trasladado esto al territorio del derecho, significa que, con la causalidad en la mano, un juez o tribunal pueden imputar cualquier resultado a cualquier persona, por remota que haya sido su participación en la cadena causal. Nos podemos remontar a Adán y Eva, podemos atribuir los males de la patria a quienes nos conquistaron hace dos mil, mil o quinientos años y, desde luego, podemos condenar a los hijos en el vientre de sus madres. William Shakespeare, inventor de la condición humana, lo vio bien en el monólogo de Bruto, en el Acto II, Escena 2ª de su Julio César:

Th' abuse of greatness is when it disjoins
Remorse from power. And, to speak truth of Caesar,
I have not known when his affections swayed
More than his reason. But 'tis a common proof
That lowliness is young ambition's ladder,
Whereto the climber upward turns his face.
But when he once attains the upmost round,
He then unto the ladder turns his back,
Looks in the clouds, scorning the base degrees
By which he did ascend. So Caesar may.
Then, lest he may, prevent. And since the quarrel
Will bear no color for the thing he is,
Fashion it thus: that what he is, augmented,
Would run to these and these extremities.
And therefore think him as a serpent's egg—
Which, hatched, would as his kind grow mischievous—
And kill him in the shell.

De ahí que los juristas, que los hay y muchos, siempre hayan tratado de acotar o limitar, con criterios normativos, la ciega extensión de la causalidad. Los economistas, por su parte, también han puesto de manifiesto que la división del trabajo, condición del desarrollo tecnológico, resultaría imposible si todo el mundo hubiera de estar a cargo de todas los accidentes que ocurren, mientras que los sociólogos han puesto el acento en que a cada rol social corresponde un círculo de incumbencias: el ciudadano de a pie puede responder por no haber llamado a la policía o a los bomberos, pero no por no haberse comportado como el uno o el otro. En las páginas que siguen, se elencan algunos de los criterios más sensatos, más probados, comenzando por los de la previsiblidad y proximidad: el efecto ha de ser previsible para quien ha de cargar con sus consecuencias y no ha de ser tan remoto que acabemos en un mundo en el cual todos pueden ser condenados por cualquier acontecimiento desagradable o terrible, pues al fin y al cabo todos somos parte de ese todo y nada habría ocurrido en el vacío.

— Pablo SALVADOR/Antonio FERNÁNDEZ, "Causalidad y Responsabilidad", 3ª ed., *InDret* 1/2006 (www.indret.com):

"Las insuficiencias y excesos del principio causal han llevado a los juristas a construir criterios normativos de imputación objetiva que permitan modularlo, es decir, ampliarlo o restringirlo según convenga. En el *Common Law*, la causalidad entendida como *conditio sine qua non (cause in fact)* se matiza de acuerdo con una miríada de doctrinas sobre *proximate causation* con el objeto de descartar las causas más remotas (*remoteness test*), las más imprevisibles o improbables (*foresight test*) y las causas cuyo riesgo típico no llegó a materializarse efectivamente en el daño en cuestión (*harm-within-the-risk test)*. En el *Civil Law,* sobresale la cultura alemana de la imputación objetiva *(Objektive Zurechnung)*.

> El realismo jurídico intentó depurar el concepto de causa de toda connotación normativa, pero el intento fracasó y el libro más influyente sobre causalidad [HART/HONORÉ (1959) y (1985)] volvió a una concepción de la causalidad concebida como juicio fáctico-normativo que, basada en el sentido común, abarcaba la causalidad de hecho y la imputación objetiva (véase, críticamente, WRIGHT (1985), (1988)).

El problema es que muchos criterios de imputación objetiva se detienen en el nivel de las propuestas doctrinales. Pocas leyes los han hecho suyos, aunque podemos identificar algunos positivados de forma dispersa:

- Los arts. 154, 269, 389, 1596, 1903, 1905 y siguientes del Código Civil, que delimitan los roles sociales básicos a cuyo cargo se ponen los daños causados por personas distintas al demandado: padres, tutores, propietarios, empresarios, maestros.

- Los arts. 118, 120 y 121 del Código Penal de 1995 que, de forma paralela a lo establecido por el art. 1903 del Código Civil, definen roles familiares, sociales y económicos a los que la ley penal asocia el deber de responder civilmente por las consecuencias dañosas de los delitos y faltas cometidos por terceros a cargo o bajo el control o dependencia de quienes ejercen aquellos roles (padres, tutores, guardadores legales, empresarios, propietarios de vehículos, Administraciones públicas).

- En general, las disposiciones que regulan actividades, imponen deberes y delimitan con claridad posiciones de garante: por ejemplo, el art. 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza; el art. 1 de la Ley 22/1994; los arts. 139 y siguientes de la LRJAP.

- El art. 141 de la LRJAP según el cual *"sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley"* y que puede ser entendido, como veremos enseguida, en clave de riesgos generales de la vida.

La doctrina jurídica lleva más de un siglo discutiendo los tópicos sobre imputación y algunas propuestas han sido ocasionalmente utilizadas por la jurisprudencia. Las que siguen están tomadas, con algunas modificaciones, de la muy influyente obra del penalista alemán Günther JAKOBS ((1993), pp. 195 y ss., y (1996), pp. 90 y ss)".

— Véase, también, Martín García-Ripoll Montijano, *Imputación objetiva, causa próxima y alcance de los daños indemnizables*, Comares, Granada, 2008.

8.2. Previsibilidad / *Foreseeability*

8.2.1. Palsgraf v. Long Island R.R. (N248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928))

APPEAL from a judgment of the Appellate Division of the Supreme Court in the second judicial department, entered December 16, 1927, affirming a judgment in favor of plaintiff entered upon a verdict.

CARDOZO, Ch. J.

Plaintiff was standing on a platform of defendant's railroad after buying a ticket to go to Rockaway Beach. A train stopped at the station, bound for another place. Two men ran forward to catch it. One of the men reached the platform of the car without mishap, though the train was already moving. The other man, carrying a package, jumped aboard the car, but seemed unsteady as if about to fall. A guard on the car, who had held the door open, reached forward to help him in, and another guard on the platform pushed him from behind. In this act, the package

was dislodged, and fell upon the rails. It was a package of small size, about fifteen inches long, and was covered by a newspaper. In fact it contained fireworks, but there was nothing in its appearance to give notice of its contents. The fireworks when they fell exploded. The shock of the explosion threw down some scales at the other end of the platform, many feet away. The scales struck the plaintiff, causing injuries for which she sues.

The conduct of the defendant's guard, if a wrong in its relation to the holder of the package, was not a wrong in its relation to the plaintiff, standing far away. Relatively to her it was not negligence at all. Nothing in the situation gave notice that the falling package had in it the potency of peril to persons thus removed. Negligence is not actionable unless it involves the invasion of a legally protected interest, the violation of a right. "Proof of negligence in the air, so to speak, will not do" […]

If no hazard was apparent to the eye of ordinary vigilance, an act innocent and harmless, at least to outward seeming, with reference to her, did not take to itself the quality of a tort because it happened to be a wrong, […]

The risk reasonably to be perceived defines the duty to be obeyed, and risk imports relation; it is risk to another or to others within the range of apprehension[…]

Negligence, like risk, is thus a term of relation. Negligence in the abstract, apart from things related, is surely not a tort, if indeed it is understandable at all […]

The law of causation, remote or proximate, is thus foreign to the case before us. The question of liability is always anterior to the question of the measure of the consequences that go with liability. If there is no tort to be redressed, there is no occasion to consider what damage might be recovered if there were a finding of a tort.

ANDREWS, J. (dissenting).

But we are told that "there is no negligence unless there is in the particular case a legal duty to take care, and this duty must be one which is owed to the plaintiff himself and not merely to others." (Salmond Torts [6th ed.], 24.) This, I think too narrow a conception. Where there is the unreasonable act, and some right that may be affected there is negligence whether damage does or does not result. That is immaterial. Should we drive down Broadway at a reckless speed, we are negligent whether we strike an approaching car or miss it by an inch. The act itself is wrongful. It is a wrong not only to those who happen to be within the radius of danger but to all who might have been there— a wrong to the public at large. Such is the language of the street. Such the language of the courts when speaking of contributory negligence. Such again and again their language in speaking of the duty of some defendant and discussing proximate cause in cases where such a discussion is wholly irrelevant on any other theory. (Perry v. Rochester Line Co., 219 N. Y. 60.) As was said by Mr. Justice HOLMES many years ago, "the measure of the defendant's duty in determining whether a wrong has been committed is one thing, the measure of liability when a wrong has been committed is another." (Spade v. Lynn & Boston R. R. Co., 172 Mass. 488.) Due care is a duty imposed on each one of us to protect society from unnecessary danger, not to protect A, B or C alone.

The proposition is this. Every one owes to the world at large the duty of refraining from those acts that may unreasonably threaten the safety of others. Such an act occurs. Not only is he

wronged to whom harm might reasonably be expected to result, but he also who is in fact injured, even if he be outside what would generally be thought the danger zone. There needs be duty due the one complaining but this is not a duty to a particular individual because as to him harm might be expected. Harm to some one being the natural result of the act, not only that one alone, but all those in fact injured may complain. We have never, I think, held otherwise. Indeed in the *Di Caprio* case we said that a breach of a general ordinance defining the degree of care to be exercised in one's calling is evidence of negligence as to every one. We did not limit this statement to those who might be expected to be exposed to danger. Unreasonable risk being taken, its consequences are not confined to those who might probably be hurt.

Lego Law: Palsgraf v. Long Island Railroad -
http://www.youtube.com/watch?v=mDEbTudkjhc

8.2.2. STS, 1ª, 597/1996, de 19 de julio

El 12 de septiembre de 1987, hacia el atardecer, un tractor que remolcaba una voluminosa carga de paja subía por la calle de la Amargura de Santa Cristina de Valmadrigal (Valladolid) cuando, al poco de iniciar la cuesta, la paja rozó una línea de baja tensión que cruzaba la calle y cuyos cables habían perdido el aislante. Al contacto, saltó una chispa, la paja prendió, ardió toda la carga, algunas pavesas volaron, llevadas por el calor y el viento, hasta la ventana abierta de una casa vecina, ardió una cortina y con ella toda la casa. Sus propietarios demandaron 105.857 € al conductor del tractor, a su propietario, a la aseguradora con la que el propietario tenía contratado el seguro obligatorio de vehículos, a quien había sido propietario del remolque, así como a "Electromolinera de Valladolid" que explotaba la línea eléctrica y a la aseguradora de la responsabilidad civil de esta última. La Sentencia de primera instancia condenó a los demandados a pagar a los actores una indemnización de 59.748 €. En apelación, la Audiencia mantuvo la condena, especificando que el conductor, el propietario del tractor y la aseguradora debían responder de un 60% de la indemnización, y Electromolinera de Valladolid y su aseguradora, del 40% restante, pero absolvió al propietario del remolque pues entendió *"que era excesivo atribuir una responsabilidad in vigilando al propietario de un vehículo de por sí inmóvil"*. El Tribunal Supremo estimó en parte el recurso de casación de tres de los propietarios demandantes en el único sentido de imponer el pago de los intereses legales desde la sentencia de primera instancia y confirmó el resto de pronunciamientos de la SAP:

"[A]unque esta Sala tiene establecido que puede incluirse en el precepto (art. 1903), ampliado por analogía, a la relación de comodato y por tanto la conducta del dueño de un vehículo que lo cede a persona inexperta para conducir y causa con él un grave accidente (...) [E]n el caso que

nos ocupa (...) falta el presupuesto inexcusable de una relación jerárquica para la responsabilidad por hecho ajeno o indirecta (...) máxime si se tiene en cuenta, como hace la Audiencia, que el remolque es de por sí un objeto inmóvil, que solo puede ser arrastrado por otro, siendo al propietario y conductor de este (del automóvil) a quienes debe abarcar la responsabilidad, al último incluso por la colocación de la carga, sin que aparezca clara la incardinación del supuesto en el no 1o del art. 1908, para exigir tal responsabilidad [al propietario del remolque] (...), pues, repetimos, no aparece acción u omisión achacable (por indemostrada) al mismo, ni se le puede realizar una imputación puramente objetiva".

8.3. *Proximate Cause* / Causalidad Adecuada / *Adäquanztheorie*

8.3.1. Stahlecker v. Ford Motor Company (266 Neb. 601, 667 N.W.2d 244 (2003))

This is a civil action for damages resulting from the injury and wrongful death of Amy M. Stahlecker (Amy). Appellants, Susan Stahlecker and Dale Stahlecker, parents of the deceased and special administrators of her estate, alleged that during the early morning hours of April 29, 2000, Amy was driving a 1997 Ford Explorer equipped with Firestone Wilderness AT radial tires in a remote area of western Douglas County, Nebraska, when one of the tires failed, rendering the vehicle inoperable. They further alleged that Richard Cook encountered Amy "alone and stranded" as a direct result of the tire failure and that he assaulted and murdered her. The Stahleckers brought this action against Ford Motor Company (Ford), the manufacturer of the vehicle; Bridgestone/Firestone, Inc. (Firestone), the manufacturer of the tire; and Cook. The district court for Dodge County sustained demurrers filed on behalf of Ford and Firestone and dismissed the action as to those parties. We affirm.

The Stahleckers alleged that "long before April 29, 2000," Ford and Firestone had actual knowledge of "the defective nature of the Ford Explorer's Firestone tires and their propensity to unexpectedly blow out causing wide-ranging results that included stranding and rollovers." The Stahleckers alleged that Ford and Firestone withheld this knowledge from consumers and the general public and advertised the Ford Explorer equipped with Firestone tires as "dependable when used under similar circumstances as Amy was using them during the early morning hours of April 29, 2000."

In order to prevail in a negligence action, a plaintiff must establish the defendant's duty to protect the plaintiff from injury, a failure to discharge that duty, and damages proximately caused by the failure to discharge that duty. […]by alleging that Ford and Firestone failed to exercise reasonable care in designing and manufacturing their tires, and failed to warn users of potential tire defects, the Stahleckers have alleged the existence of a legal duty and a breach thereof by both Ford and Firestone. The remaining issue is whether the breach of this duty was the proximate cause of Amy's harm.

The proximate cause of an injury is "that cause which, in a natural and continuous sequence, without any efficient, intervening cause, produces the injury, and without which the injury would not have occurred." […] Stated another way, a plaintiff must meet three basic requirements in establishing proximate cause: (1) that without the negligent action, the injury would not have occurred, commonly known as the "but for" rule; (2) that the injury was a

natural and probable result of the negligence; and (3) that there was no efficient intervening cause[…]

As to the first requirement, a defendant's conduct is the cause of the event if "the event would not have occurred but for that conduct; conversely, the defendant's conduct is not a cause of the event if the event would have occurred without it." Haselhorst v. State, 240 Neb. at 899, 485 N.W.2d at 187. In this case, accepting as true the allegations of the operative amended petition, the first element of proximate causation is established. The petition alleges that Cook "found Amy alone and stranded as a direct result of the failure of the Firestone Wilderness AT Radial Tire and proceeded to abduct, terrorize, rape and murder Amy." Firestone concedes that under the factual allegations of the Stahleckers' petition, that " 'but for' " the failure of its tire, Amy would not have been at the place where she was assaulted and murdered.

The second and third components of proximate causation are somewhat interrelated. Was the criminal assault and murder the "natural and probable" result of the failure to warn of potential tire failure, or did the criminal acts constitute an effective intervening cause which would preclude any causal link between the failure to warn and the injuries and wrongful death for which damages are claimed in this action? An efficient intervening cause is a new, independent force intervening between the defendant's negligent act and the plaintiff's injury. […] This force may be the conduct of a third person who had full control of the situation, whose conduct the defendant could not anticipate or contemplate, and whose conduct resulted directly in the plaintiff's injury […].

This principle requires that we determine whether the duty owed to Amy by Ford and Firestone, as manufacturers and sellers of the allegedly defective tires, included a duty to anticipate and guard against criminal acts perpetrated against the users of such tires. […]

Generally, we have recognized a duty to anticipate and protect another against criminal acts where the party charged with the duty has some right of control over the perpetrator of such acts or the physical premises upon which the crime occurs […].

We have found no authority recognizing a duty on the part of the manufacturer of a product to protect a consumer from criminal activity at the scene of a product failure where no physical harm is caused by the product itself. […] The Stahleckers argue that a duty to anticipate criminal acts associated with product failure arises from their allegations that Ford and Firestone knew or should have known of "the potential for similar dangerous situations arising as a result of a breakdown of a Ford Explorer and/or its tires resulting in danger to its consumers and users from criminal activity, adverse weather conditions, inability to communicate with others or any combination thereof." They also allege that Ford and Firestone had or should have had "knowledge, to include statistical information, regarding the likelihood of criminal conduct and/or sexual assault against auto and tire industry consumers as a result of unexpected auto and/or tire failures in general." Assuming the truth of these allegations, the most that can be inferred is that Ford and Firestone had general knowledge that criminal assaults can occur at the scene of a vehicular product failure. However, it is generally known that violent crime can and does occur in a variety of settings, including the relative safety of a victim's home. The facts alleged do not present the type of knowledge concerning a specific individual's criminal propensity, or right of control over premises known to have been the scene of prior criminal activity, upon which we have recognized a tort duty to protect another from criminal acts. The Stahleckers have not and could not allege any special relationship between Ford and Firestone

and the criminal actor (Cook) or the victim of his crime (Amy) which would extend their duty, as manufacturers and sellers of products, to protect a consumer from harm caused by a criminal act perpetrated at the scene of a product failure […].

Although the operative amended petition alleges sufficient facts to establish that Ford and Firestone negligently placed defective products on the market which caused Amy to become stranded at night in a remote location, it alleges no facts upon which either Ford or Firestone would have a legal duty to anticipate and guard against the criminal acts which were committed at that location by another party. Therefore, the criminal acts constitute an efficient intervening cause which necessarily defeats proof of the essential element of proximate cause.

Affirmed.

8.3.2. STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril

Un atracador forcejeó e hirió con una navaja a la actora, una mujer que, de madrugada, había entrado en un local con cajero automático de la entidad bancaria luego demandada. El pestillo de la puerta estaba roto. La actora reclamó a la demandada una indemnización de 90.152 €. En primera instancia su demanda fue estimada en parte, pero la entidad demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda. El TS confirmó la decisión de la Audiencia con razones referidas a la causalidad adecuada:

"(…) para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la comisión u omisión -causa- y el daño o perjuicio resultante -efecto-, la doctrina jurisprudencial aplica el principio de causalidad adecuada, que exige que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; (...) una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados y debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria el efecto lesivo producido (...) [E]s precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo" (F.D. 2º).

Obsérvese el tránsito, sin solución alguna de continuidad, de la causalidad adecuada a la culpabilidad, entendida como infracción de un deber de precaución.

8.3.3. STS, 1ª, 377/2004, de 12 de mayo

Un perro, de raza doberman y cuyo propietario era Lázaro, se escapó, entró en la finca colindante y vecina, propiedad de Millán y Claudia, y comenzó a pelearse con el perro de éstos. Tras forcejear para separarlos, Millán sufrió una parada cardiaca que le provocó la muerte. Por estos hechos se iniciaron actuaciones penales que fueron archivadas por auto de 20.5.1996. La viuda de Millán viuda demandó a Lázaro y solicitó una indemnización de 55.896,18 €. El JPI nº 3 de Tortosa (17.11.97) estimó íntegramente la demanda en aplicación del art. 1905 CC que establece una responsabilidad objetiva del poseedor de animales: *"[e]l poseedor de un animal, o el que se sirva de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa*

del que lo hubiese sufrido". El demandado apeló y la AP de Tarragona (Sección 3ª, 3.2.1998) estimó en parte su recurso en el sentido de rebajar la cuantía de la indemnización a 27.948,08 € porque consideró la contribución de la propia víctima al daño:

"Respecto de si este infarto fue directamente causado por la pelea del perro del actor o bien fue una circunstancia casual (…) debemos concluir, con el Juez «a quo», que hubo una relación directa entre el hecho de que el perro del demandado penetrase en la finca del señor S. y el hecho de que éste muriese, y ello porque (…) lo cierto es que tenemos a una persona de 66 años con una gravísima dolencia cardíaca (…); tenemos, además, una situación de tensión, como es la pelea del propio perro, provocada por la invasión, por parte del perro del demandado, de su finca, siendo este perro mayor y de raza especialmente agresiva y fuerte; y, finalmente, un especial esfuerzo necesario para separar ambos perros. Del conjunto de estos factores se extrae la conclusión, basada en el informe forense (…) [de que] el esfuerzo exagerado (…) habrí[a] aumentado sus requerimientos de irrigación miocárdica que las válvulas coronarias no podían suplir, colapsando una de ellas (…).

[S]i atendemos a la teoría de la causalidad adecuada, según invoca la sentencia recurrida (…) y esto es que el resultado sea consecuencia virtual y suficiente de la determinación del evento dañoso, resulta que en este caso concurrió otra causa muy relevante, la previa grave enfermedad del fallecido, sin la cual no se podía haber producido el fallecimiento, causa que a su vez concurrió por una cierta imprudencia de la víctima, ya que, conocedor el señor S. como nadie de su grave estado, debería haber dejado que su esposa intentase separarlos o intentarlo con otros métodos (manguerazo de agua) o incluso dejar que se peleasen (…) Por tanto, hubo dos causas relevantes, la invasión por el perro y la intervención del señor S., pese a su enfermedad cardíaca, que por sí no hubieran dado lugar al desenlace, pero que juntas resultaron fatales, al interaccionar ambas entre sí, sin que pueda darse mayor relevancia a una y otra" (FD. 4º).

El TS desestimó el recurso de casación del demandado y confirmó la SAP:

[D]e una manera incuestionable y a través de una hermenéusis lógica y racional en la sentencia recurrida se llega a la conclusión basada en un informe pericial del médico forense que afirma que el "desenlace -muerte- era de preveer debido a estas placas ateromatosas obstructivas en las coronarias", que indican un enlace causal, preciso y directo entre la entrada violenta del perro y la muerte de [Lázaro]" (FD. 2º).

8.3.4. STS, 3ª, de 18 de mayo de 2010

El 10.11.2000, Salvador, quien cumplía condena de privación de libertad, impuesta por Sentencia de 15.11.2000, por sendos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, se fugó del Hospital Carlos de la Haya donde recibía tratamiento médico, tras liberarse de los grilletes que lo esposaban a la cama y aprovechando que el policía encargado de su custodia se encontraba en el aseo como consecuencia de una momentánea indisposición. El 13.4.2001, con ocasión de un altercado al haber varios coches mal aparcados, Salvador disparó a Fructuoso, causándole lesiones en una pierna que determinaron su amputación por encima de la rodilla y su incapacidad permanente total. La SAP de Alicante (Sección 1ª, 13.2.2004) condenó a Salvador como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas con la agravante de reincidencia y a indemnizar a Fructuoso en 4.717,26 euros por gastos

y en 300.000 euros por la secuela y daños morales.Fructuoso interpuso reclamación administrativa previa frente al Ministerio del Interior, que la desestimó en resolución de 26.2.2007. La SAN (4.6.2008) estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Fructuoso y, tomando como base la indemnización determinada en la vía penal, imputó a la Administración la mitad de la cantidad concedida por daños personales más los gastos (154.717,26 euros), porque "no puede dejarse de apreciarse una conducta en algún aspecto negligente en la custodia del preso" (FD 4º STS) y "de no haberse producido el funcionamiento anormal de los servicios públicos, la fuga no habría tenido lugar y, en consecuencia, tampoco la agresión… En suma, la intervención del tercero en la causación del daño tuvo gran relevancia pero no la intensidad bastante para romper totalmente el nexo causal" (FD 2º STS). El TS desestimó los recursos de casación interpuestos por ambas partes y confirmó la SAN:

"[E]s preciso que haya algún punto de conexión entre el daño y el servicio público, que puede ser por lo general "directo, inmediato y exclusivo", pero, en ocasiones basta [que sea] "indirecto, sobrevenido y concurrente con hechos dañosos de terceros o de la propia víctima"… Así, en la [STS, 3ª, 4.6.2002, RJ 6292] dijimos: "… que no son admisibles… restricciones derivadas de otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante o socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que –válidas como son en otros terrenos- irían en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La consideración de hechos que pueden determinar la ruptura del nexo causal, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor… a los cuales importa añadir el comportamiento de la víctima en la producción… del daño, o la gravísima negligencia de ésta…" (FD 3º).

"En supuestos similares… hemos declarado que… los perjudicados no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos derivados de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud del principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público, ya que la lesión causada al particular se asimilaría a una obligación pública… que… debe repartirse entre todos…" (FD 4º)

"[A]preciamos la existencia de una concurrencia de causas, determinante de una moderación en el quantum indemnizatorio…" (FD 4º).

Véase, en el mismo sentido, la STS, 1ª, 3.3.2010 (RJ 2441), en un caso en el que un preso falleció por agresión con arma blanca en los lavabos de la prisión: "la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización)" (FD 6º).

8.4. Riesgos generales de la vida /*General Life Risks / Erlaubte Risiken*

8.4.1. STS, 3ª, 29 de octubre de 1998

Un joven que se arrojó al mar desde un rompeolas murió ahogado. Su madre pretendió responsabilizar a la Junta de Cantabria por no haber señalizado el lugar como peligroso. En

vano: el mar siempre lo es y no es razonable señalizar toda la costa. Parecidamente, la **STS, 3ª, 8.4.2003** resuelve un caso en el que una viandante sufrió daños en sus rodillas al golpearse contra un muro a causa de un fuerte golpe de mar que superó el Muro de San Lorenzo del paseo marítimo de Gijón (Asturias). El Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de la actora sirviéndose de los criterios del riesgo general de la vida y de la asunción de riesgos por parte de la víctima, pues, debido al temporal, la policía municipal había cortado el tráfico en el paseo marítimo y había advertido a los viandantes de que tuvieran cuidado al transitar por la zona. El Tribunal afirmó:

"De ello se deduce la ruptura del nexo causal conforme a los criterios anteriormente mencionados, toda vez que las lesiones producidas no son imputables al funcionamiento del servicio público y sí al proceder de la accidentada hoy actora, toda vez que como señala la resolución recurrida «quien pese a la evidencia del temporal existente no dudó en circular por la zona donde lo hizo, sin duda convencida de que podía hacerlo sin riesgo alguno para su integridad física».

"Es por ello que pese a la obligación de la Administración demandada del mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles y paseos públicos locales, toda vez que las entidades de la Administración local tienen la obligación inexcusable de mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, en condiciones tales que la seguridad de quienes la utilizan esté normalmente garantizada, en el caso enjuiciado, no puede invocarse imprevisión de la Policía Municipal, al adoptar idénticas medidas que la propia reclamante, por lo que un hecho inesperado conlleva la imposibilidad de procurar medios adecuados para su evitación, toda vez que el golpe de mar que superó el «Muro» de San Lorenzo y alcanzó a la recurrente resultó inesperado, razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso interpuesto, sin que la prueba testifical practicada sea suficiente para desvirtuar lo anteriormente reseñado." (FD 3º).

8.4.2. STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero

La doctrina del riesgo general de la vida no sólo se aplica a riesgos derivados de causas naturales, sino también a riesgos creados por el ingenio humano. En este sentido, la STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero resolvióp un caso en el que la víctima falleció al ser arrollada por un tren mientras cruzaba por un paso a nivel en la estación de Benimámet (Valencia). Todas las señales funcionaban correctamente y el conductor no sólo había utilizado las señales acústicas correspondientes sino que, al advertir que alguien cruzaba la vía, disminuyó la velocidad hasta casi detener el tren en el momento de la colisión. El Tribunal desestimó el recurso interpuesto por los familiares de la víctima al afirmar que:

"[a]a causa eficiente del accidente fue la propia conducta de Dña. Marí Luz [...] Podría plantearse la existencia de responsabilidad por la propia existencia del paso a nivel en el ámbito urbano, mas entiende la Sala que los mismos -aun cuando sea deseable su desaparición por la paulatina conversión de las líneas en subterráneas en las zonas urbanas y así parece que se realiza con las de nueva construcción- son necesarios para el normal funcionamiento del servicio público y lo que es exigible a las Administraciones Públicas implicadas es el establecimiento de las medidas de seguridad legalmente previstas. Una vez establecidas éstas, en correcto funcionamiento y desplegada la diligencia exigible por los empleados (como es el caso), no puede imputarse a

dichas Administraciones la producción de accidentes por la inobservancia de las medidas por los usuarios" (FD 5º).

8.5. Prohibición de regreso y posición de garante / *Remoteness/ Regressverbot und Garantenstellung*

No cabe retroceder en el curso causal e imputar a un agente las consecuencias originadas por la interposición del comportamiento ilícito de un tercero. Así, no cabe responsabilizar al deudor que pagó una deuda al acreedor por el crimen que éste perpetró luego con armas adquiridas gracias al dinero pagado. La doctrina en cuestión sólo puede analizarse con precisión en sede de autoría y participación, materia muy alejada del objeto de estas notas. Aquí bastará con indicar que el demandado no responderá salvo que hubiera estado en posición de garante en el momento en que ocurrieron los hechos. En derecho civil y en materia de responsabilidad por culpa, los deberes de precaución de un agente social para con los demás, o bien se definen institucionalmente por la ley (padres, maestros, empleadores, propietarios, anfitriones, amigos), o bien se establecen primero social y después jurisprudencialmente para cada sector específico del tráfico.

El ejemplo clásico de prohibición del regreso es la interposición de una conducta dolosa de un tercero y sobre todo si es criminal. Así, la jurisprudencia de la Sala Tercera rechazaba históricamente las reclamaciones de las víctimas de delitos, pues consideraba que su comisión derivaba exclusivamente de la actuación voluntaria del delincuente, pero no del funcionamiento de los servicios públicos de seguridad ciudadana. Sin embargo, el criterio de la prohibición del regreso admite muchas modulaciones normativas y la evolución de la jurisprudencia española da razón de alguna muy significativa.

La **STS, 3ª, de 16 de diciembre de 1997** inició un cambio de nota: condenó a la Administración central del Estado a pagar 75.121 € a la viuda de la víctima de un robo con homicidio perpetrado por dos reclusos que disfrutaban de un permiso penitenciario. Otras han seguido después: por ejemplo, las **SSAN, Sala C-A, Secc. 4ª, de 30 de mayo de 2001** y **de 20 de marzo de 2002**: dos casos trágicamente gemelos protagonizados por los mismos delincuentes que cometieron sendos robos con homicidio consecutivos, el mismo día y contra dos taxistas; uno de los autores había sido objeto de una medida cautelar en un centro de internamiento de extranjeros en trámite de expulsión, posteriormente había cumplido una condena de dos semanas en prisión pero, en lugar de ser devuelto al centro de internamiento, había sido puesto en libertad, circunstancia que aprovechó para asaltar a sus víctimas con ayuda de un tercero. La primera sentencia condenó a la Administración a pagar 132.222,66 € y, la segunda, 120.202 €. También conforman esta línea jurisprudencial las SSTS, 3ª, 25.5.2000, 4.6.2002, 14.10.2004 y 18.5.2010 o la más reciente:

STS, 3ª, de 29 de noviembre de 2011

El 17.7.2002 se produjo un atraco en la oficina de Caja Madrid sita en la calle Toledo, número 77, de Madrid. Cesáreo, empleado de dicha entidad, recibió un disparo de Marino, a quien se le había concedido un permiso penitenciario de salida mediante Auto de 11.1.2002 del Juez de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León. Como consecuencia del disparo, Cesáreo sufrió una herida penetrante abdominal en hipocondrio izquierdo y quedó en situación de incapacidad permanente absoluta.

Cesáreo reclamó una indemnización de daños y perjuicios al Ministerio del Interior. La Secretaria General Técnica, por delegación del Ministro del Interior, desestimó la reclamación mediante resolución expresa de 16.6.2008.
Acto seguido, la víctima interpuso, contra la resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN. El 30.9.2009, la AN dictó sentencia con la cual estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por Cesáreo y condenó al Ministerio al pago de 250.000 euros, en concepto de daños y perjuicios, sin costas.

La Administración del Estado interpuso recurso de casación contra la sentencia de la AN. El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado y condena en costas a la Administración. En particular, el TS desestima el recurso de casación asumiendo que la Administración ha de responder de los daños derivados del fracaso de los permisos carcelarios. En efecto, la concesión de un permiso carcelario no implica la desaparición de la relación existente entre el interno y la Administración "consecuencia de la denominada relación de 'supremacía especial', de la que dimanan un conjunto de derechos y deberes entre ambos, y que no quedan en suspenso o desaparecen durante los periodos de permiso, sino que continúan, incluso fuera del centro penitenciario" (FJ 1o), sin desconocer que, en casos como los de autos, el hecho causante del resultado dañoso no dimana directamente de la actividad o de los servicios de la Administración.

El TS fundamenta su decisión sobre una doctrina jurisprudencial ya sentada por la Sala 3a (SSTS de 7.10.1997, 25.5.2000, 4.6.2002, 14.10.2004 y 18.5.2010), afirmando que "(...) la obligación de soportar individualmente el daño sufrido no puede imputarse a los perjudicados cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos derivados de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud del principio de la solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público (...)" (FD 3º).

De la Sala 2ª del Tribunal Supremo, véase la **STS, 2ª, 966/2001, de 29 de mayo**: recluso durante un permiso hirió y violó a una mujer. En este último caso en vía penal, el TS negó la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración *ex* artículo 121 del Código Penal porque los presos no son funcionarios públicos, al tiempo que sugirió reclamar por error judicial vía artículos 292 y ss. LOPJ.

8.6. Ámbito de protección de la norma /Harm within the Risk/ Schutzbereich der Norm

8.6.1. STS, 1ª, 902/1998, de 8 de octubre

Un trabajador había muerto atropellado por un camión cuando, al dirigir la operación de su carga, se situó tras un punto ciego del vehículo y éste le aplastó. En la demanda, su viuda e hijos alegaron que el conductor del camión no poseía el certificado de aptitud de manejo de maquinaria minera exigido por el art. 117 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 de abril). El TS confirmó las sentencias desestimatorias de las instancias, pues:

"[l]a ausencia de dicho permiso es irrelevante en este caso" (F.D. 2º).

8.6.2. STS, 3ª, 3 de noviembre de 2008

A las 11:30 h. del 29.11.1996, Patricia, celadora en el centro de especialidades del complejo hospitalario "Xeral Calde" (Lugo), dependiente del Servicio Gallego de Salud ("SERGAS"), bajaba en el ascensor de dicho complejo cuando, debido a un fallo mecánico, el ascensor cayo desde la 3ª planta, chocando con el amortiguador situado en el foso del sótano del edificio. Como consecuencia del accidente, Patricia sufrió traumatismos múltiples y precisó de atención psiquiátrica hasta 1998. La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo (29.1.1999) declaró que las secuelas derivadas del accidente de trabajo por Patricia eran constitutivas de invalidez permanente absoluta en grado de gran invalidez y reconoció el derecho de ésta a percibir una pensión mensual de 1.404,84 € con un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad.

Patricia demandó al "SERGAS" y a la Xunta de Galicia y solicitó una indemnización de 1.031.171,25 €, que la Consellería denegó por silencio administrativo. El TSJ Galicia (Sección 1ª, 3.3.2004) estimó el recurso contencioso administrativo y condenó a las administraciones codemandadas al pago de 300.500 €

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por el "SERGAS" y la Xunta de Galicia. El TS, tras desestimar los argumentos por los cuales la demandante debería haber llamado al proceso a la empresa fabricante del ascensor y la encargada de su mantenimiento, analizó el motivo central del recurso, a saber, si la existencia de una relación de empleo público entre víctima y Administración anulaba la responsabilidad patrimonial de esta última. El TS resolvió que, por más que el daño se habuiera producido en el desarrollo de una relación de servicio público, el accidente quedaba fuera de los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión, de manera que la lesión era antijurídica, máxime cuando la empleada no tuvo la más mínima intervención en el accidente (F. D. 5º).

8.7. Provocación / *Provocation* / *Herausforderung*

— STS, 2ª, de 26 de septiembre de 2005

La víctima, detenida ilegalmente por Víctor M. y Rafael, sufrió lesiones personales y daños en la ropa al arrojarse por la ventana para huir de sus captores cuando éstos la estaban amenazando con bisturís, cable eléctrico y una pistola para que se quitara la ropa. La SAP Madrid de 4.10.2004 condenó a los acusados, Víctor M. y Rafael, por sendos delitos de robo con intimidación, detención ilegal y delito contra la integridad moral, pero les absolvió de indemnizar a la víctima. El Tribunal Supremo, en cambio, estimó el recurso de casación, revocó la SAP e imputó objetivamente los daños a la conducta de los culpables condenándoles a indemnizar a la víctima con 21.600 € por las lesiones, 3.083,41 € por las secuelas y 81,30 € por los daños en la ropa. El Tribunal resolvió:

"En el caso que se analiza la situación coactiva o la presión ocasionada por el delito contra la integridad moral fue la desencadenante de las lesiones y daños sufridos. El perjudicado no se las produjo por su propia voluntad. Si existía algún resquicio para eludir la acción criminal, no puede impedírsele esa posibilidad, obligándole a soportar aquel delito y no consta que hubiera podido eludir la acción criminal sin tales riesgos, traducidos en daños corporales y materiales, que, por lo tanto, deben considerarse vinculados y objetivamente imputables a la acción delictiva anterior de los acusados, tipificada en el delito contra la integridad moral del art. 173.1 CP".

8.8. Consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo / *Victim's consent and assumption of risk / Einverständigung, Tatbestand-ausschließenden Einwilligung und Handeln auf eigene Gefahr*

No es imputable al agente el resultado dañoso cuando el bien jurídico lesionado es disponible y la víctima prestó su consentimiento al acto, como tampoco lo es en el caso en que la víctima asumió el riesgo del daño a un bien jurídico indisponible. Este criterio suele ser aplicado para exonerar de responsabilidad al demandado cuando el demandante participó voluntariamente en cualquier tipo de práctica deportiva, realizó una actividad peligrosa a sabiendas del riesgo que conllevaba o invadió una finca ajena sin consentimiento del titular.

En la práctica de diferentes deportes habitualmente se aplica la asunción del riesgo por parte de la víctima (JoséPIÑEIRO SALGUERO, *Responsabilidad civil, práctica deportiva y asunción de riesgos*, Civitas, Cizur Menor, 2009).

La primera sentencia que reconoció la asunción del riesgo durante la práctica deportiva fue la **STS, 1ª, de 22 de octubre de 1992**: un aficionado a la pelota vasca perdió un ojo al recibir un pelotazo de su contrincante. La víctima demandó a su contrincante y a la "Compañía Nacional Hispánica Aseguradora, SA" y solicitó una indemnización de 60.324,18 €. El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso interpuesto por la entidad demandada, revocó las sentencias estimatorias de la instancia y desestimó las pretensiones del actor. El Tribunal afirmó que *"en materia de juegos o deportes de este tipo la idea del riesgo que cada uno de ellos pueda implicar —roturas de ligamentos, fracturas óseas, etc.—, va ínsita en los mismos y consiguientemente quienes a su ejercicio se dedican lo asumen, siempre claro es que las conductas de los partícipes no se salgan de los límites normales ya que de ser así podría incluso entrar en el ámbito de las conductas delictivas dolosas o culposas*" (FD 5º).

Este criterio de imputación de daños ha sido aplicado continuadamente por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones: **STS, 1ª, 244/1999, de 18 de marzo**: esquiadora murió al chocar contra la caseta de un transformador eléctrico cuando descendía una pista de esquí sobre un plástico; **STS, 1ª, 859/2001, de 27 de septiembre**: alumna de un curso de golf golpeó con el palo a su monitora al errar un golpe; **STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre**: joven aficionado al rafting murió ahogado tras caer al agua y golpearse con una roca; **STS, 3ª, 1 de julio de 2002**: una participante en un encuentro de fútbol femenino sufrió una fractura compleja distal en el radio izquierdo.

El Tribunal Supremo también recurre a la asunción del riesgo en casos en los que la propia víctima realiza una actividad peligrosa a sabiendas del peligro que conllevaba. La **STS, 1ª, 215/1998, de 12 de marzo**nos muestra un caso de autopuesta en peligro por parte de la víctima: una tarde de julio y para aliviarse del agobiante calor, un joven de 17 años, que no sabía nadar, decidió refrescarse en una charca próxima a la carpintería en la que trabajaba. Al día siguiente, la Guardia Civil lo encontró ahogado. Los actores reclamaron 60.101 € a la empresa de carpintería. Las instancias desestimaron la demanda y el TS no admitió el recurso de los actores.

En último lugar, son relativamente frecuentes los casos de daños sufridos por una persona que se adentró en una finca ajena sin consentimiento de su propietario. En este sentido, véase la **STS, 1ª, 240/2004, de 2 de abril**: la víctima se adentró en una fábrica abandonada a través de un agujero de una de las vallas y, ya en el interior, accedió a un transformador de electricidad propiedad de "Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA" (FECSA) y se apoyó en un interruptor, a consecuencia de lo cual sufrió una descarga eléctrica que le provocó la pérdida de ambas manos. El TS estimó el recurso interpuesto por FECSA aplicando criterios de prohibición de regreso y de asunción del riesgo: la conducta ilícita del actor de acceder a una finca ajena y vallada para coger tuberías de cobre interfirió en el curso causal de los hechos y propició el accidente, con independencia del riesgo que entrañaba la actividad de suministro eléctrico. Además, tal conducta suponía la aceptación de un grave riesgo por el sujeto *"habida cuenta de la peligrosidad que entraña el acceso sin control a una edificación [...] por persona desconocedora de las contingencias nocivas inherentes a la misma"* (FD 2º).

8.8.1. *Knight v. Jewett* (3 Cal. 4th 296, 834 P.2d 696, 11 Cal. Rptr. 2d 2 (1992))

The plaintiff sued the defendant for personal injuries arising out of a touch football game. There was some dispute as to the defendant's conduct which caused the plaintiff's injury. According to the plaintiff, after the plaintiff caught a pass, the defendant ran into her from the rear, knocking her down, and stepping on her hand. The defendant's version was that he collided with the plaintiff in an unsuccessful attempt to intercept the pass. The defendant moved for summary judgment, arguing that the plaintiff assumed the risk of injury by participating in the game. The trial judge granted the motion, and that decision was affirmed by the Court of Appeal.

8.8.2. STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre

El día 14.5.1994 Luis A.A. concertó con la "Asociación Deportiva Cultural Lur" una excursión para practicar rafting en el río Gállego, en el transcurso de la cual tres participantes cayeron al agua. Dos de ellos fueron recogidos en piraguas de apoyo, pero no fue posible salvar a Luis A.A. a pesar de que el monitor Santiago L.U. intentó subirlo a la balsa agarrándolo del brazo. Luis A.A murió en el acto por parada cardio-respiratoria determinada por traumatismo craneoencefálico con hemorragia subdural.

José A. R., padre de la víctima, demanda a Santiago L. U., "Asociación Deportiva Cultural Lur" y a la "Compañía de Seguros y Reaseguros Hermes, SA Grupo Fortuna" y reclama una indemnización de 60.241 €.

El JPI nº 1 de Ejea de los Caballeros (9.1.1996) y la AP de Zaragoza (sección 2ª, 7.5.1996) desestiman la demanda.

El TS desestima el recurso de casación:

"La ausencia de culpa, incluso en su mínimo grado de levísima, excluye la imputación subjetiva, porque se ha agotado por los demandados la diligencia que las circunstancias exigían.

Pero tampoco se aprecia responsabilidad desde la perspectiva de un exclusivo criterio de imputación objetivo, pues si la generación de determinados riesgos puede acarrear la responsabilidad civil por daño, en el sistema de culpa extracontractual del art. 1902 CC no cabe

erigir el riesgo en factor único de la responsabilidad y es preciso que se dé una conducta adecuada para producir el resultado dañoso. En el caso es cierto que existía una situación de riesgo (como dice la Sentencia recurrida el «rafting» es una actividad deportiva consistente en el deslizamiento mediante bote neumático por aguas bravas que debe calificarse de peligrosa, porque tiene para los participantes un indudable riesgo de vuelco o caída al agua por el propio recorrido turbulento de las aguas), pero se trataba de una actividad voluntaria, cuyo peligro era conocido por el solicitante, y el accidente se produjo dentro del ámbito del riesgo asumido y aceptado. Hubo asunción de riesgo, y no concurrió por parte de los demandados ningún incremento o agravación del riesgo asumido. Esta conclusión responde al criterio que viene siguiendo en concreto esta Sala en relación con supuestos similares. Y aunque no son muchas las resoluciones en materia de accidentes con ocasión de prácticas deportivas, cabe señalar por su semejanza casuística las Sentencias de 22 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8399) (lesiones sufridas con ocasión de juego de pelota a pala), 20 de marzo de 1996 (RJ 1996, 2244) (accidente practicando el esquí), 20 de mayo de 1996 (RJ 1996, 3879) (colisión de lancha a motor con escollo sumergido a escasa profundidad en pantano) y 14 de abril de 1999 (RJ 1999, 3140) (accidente en curso de aprendizaje de parapente)" (FD. 4º).

8.8.3. STS, 1ª, 580/2006, de 31 de mayo

El 6.5.1989 y durante la 13ª etapa de la 44ª edición de la Vuelta Ciclista a España, que partía de Benasque con dirección a Jaca, uno de los participantes de un grupo de 180 ciclistas sufrió lesiones muy graves como consecuencia de la caída sufrida en el interior de un túnel insuficientemente iluminado con dos focos halógenos situados a unos 50 metros de la boca norte del túnel y diversas bombillas en el resto del recorrido. Antes de la carrera, su Director había indicado al Comisario de la misma que se habían tomado las medidas oportunas y que se cumplían todas las disposiciones. "Unipublic, S.A.", encargada de la organización y control de la carrera, había advertido del peligro al Jefe de la Unidad de Huesca de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, quien, a su vez, había encargado de forma verbal la iluminación a una empresa de Sabiñánigo.

Bruno demandó a "Unipublic, S.A." y "Caja de Seguros Reunidos, S.A." y solicitó una indemnización de 480.810 €.

El JPI de Boltaña (31.7.1998) estimó en parte la demanda y condenó a los demandados al pago de 360.607,26 € más el interés anual del 20% desde la fecha del siniestro. La AP de Huesca (15.7.1999) desestimó los recursos de apelación de los demandados, estimó el del actor y revocó la SJPI en el sentido de fijar la indemnización en 480.809,68 €.

El TS desestimó el recurso de casación de "Unipublic, S.A." y confirmó la SAP: "[f]unciones inherentes a la organización son (…) la de adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos propios de esta práctica deportiva, riesgos que son distintos de los que la propia competición genera y que, a diferencia de aquellos, los profesionales conocen y asumen voluntariamente como parte de su actividad (…) Es [la] falta de medidas de seguridad la que aparece como causa próxima y adecuada para producir el daño (…) [E]l daño aparecía como probable y lógico para quien organizaba la carrera y éste no se hubiera materializado de haberse celebrado en un escenario más favorable para la integridad y salud del ciclista" (F.D. 3º).

8.8.4. STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo

Asunción de riesgo en la práctica deportiva.

Hechos: el 16.11.1991, Luis Manuel, quien jugaba a golf en el "Club de Golf Terramar" de Sitges, falleció tras recibir el impacto de una pelota lanzada por Ismael, que se encontraba en una calle distinta y separada de la de la víctima por una arboleda que impedía la visualización entre los dos jugadores. El lanzamiento en cuestión había sido técnicamente incorrecto a causa del viento que soplaba en la zona.

Disposiciones estudiadas: arts. 1104 y 1902 CC.

Demanda: Lucía, viuda del fallecido, en su nombre y en el de sus hijos, demandó a Ismael, al "Club de Golf Terramar", "La Estrella S.A. de Seguros" y "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y solicitó una indemnización de 281.237 € de las tres primeras y de 1.803 € de la cuarta.

Procedimiento: el JPI nº 2 de Vilanova i la Geltrú (22.5.1996) estimó en parte la demanda y condenó al pago de 111.908 €, con el límite de 1.803 € para "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros". La AP de Barcelona (Sección 15ª, 12.5.1999) estimó los recursos de "Club de Golf Terramar", "La Estrella S.A. de Seguros" e Ismael, a quienes absolvió.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Lucía: "[l]a idea del riesgo, fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materiales peligrosos, y en los beneficios que a través de ello se obtienen, en modo alguno puede trasladarse a la práctica deportiva, no organizativa, para fundamentar un régimen de responsabilidad distinto del de la culpa. Se asume el riesgo desde la idea de que se conoce y se participa de él y de que el jugador es consciente de que no existe en el desarrollo de una buena práctica deportiva, más allá de lo que impone la actividad en concreto, porque confía en la actuación de los demás" (F.D. 3º).

8.8.5. Miller and Another v. Jackson and Others [1977] Q.B. 966 Court of Appeal (Civil Division), 1977-04-06

Injunction--Jurisdiction to grant--Nuisance--Houses built adjoining village cricket ground--Damage to property and potential danger to occupants--Action by householder for damages for negligence and nuisance and injunction against playing cricket--Liability established--Whether equitable remedy of injunction appropriate where public interest outweighing interest of private individuals.

Members of a village club played cricket in the evenings and at week-ends in the summer months on a small ground where cricket had been played since about 1905, when it was surrounded by agricultural fields. The ground was leased to the club by the owners, the National Coal Board, which in, 1965 sold part of the adjacent pasture land to the local council who in 1970 sold it to developers. A line of houses was built so sited that it was inevitable that so long as cricket was played on the ground some balls hit beyond the boundary would fall into the rear gardens or on to or against the houses, despite a six-foot concrete boundary fence.

In 1972 the plaintiffs bought one of the houses the rear garden of which had a boundary with the cricket ground. Soon after taking possession they began to complain of incidents causing

actual damage to their house and apprehension of personal injury which interfered with their enjoyment of their house and garden whenever cricket was being played; and though in 1975 the club increased the height of the boundary fence to 15 feet, some balls continued to land in adjacent properties.

In 1975 the plaintiffs brought an action claiming damages for negligence and alternatively for nuisance, and an injunction to restrain the club from playing cricket on the ground without first taking adequate steps to prevent balls being struck out of the ground on to their house or garden. The defendants denied negligence and nuisance and also claimed that the plaintiffs had contributed to any injury, loss, or damage they might prove by refusing offers to fit shutters and unbreakable glass at the rear of their premises. Reeve J. awarded the plaintiffs damages for personal inconvenience and interference with their past enjoyment of their property at £30 a year for five years, and granted them the injunction in the terms asked for.

On appeal by the defendants:

Held:
(1) (Lord Denning M.R. dissenting) that the defendants, so long as they played cricket on that ground, were guilty of negligence every time a ball came over the fence and caused damage, for the risk of injury to person and property was continuous and no reasonable method of eliminating that risk had been produced; they were also guilty of nuisance since their use of their land involved an unreasonable interference with their neighbours' use and enjoyment of their house and garden; and the neighbours were under no duty to mitigate that risk.

Per Geoffrey Lane L.J. The court is bound by the rule in Sturges v. Bridgman (1879) 11 Ch.D. 852, which has never been questioned, that it is no answer to a claim in nuisance for the defendant to show that the plaintiff brought the trouble on his own head by coming to live so close to the defendant's premises that he would inevitably be affected by the defendant's activities where no one had been affected before. It is not for this court to alter a rule which has stood for so long (post, pp. 986H - 987B).

Sturges v. Bridgman (1879) 11 Ch.D. 852, C.A., considered.

Per Lord Denning M.R. The use of the ground for cricket was a most reasonable use; and it does not suddenly become a nuisance because a neighbour chooses to come to a house in a position where it might occasionally be hit by a cricket ball (post, pp. 980G - 981A). Nor is it negligence so as to give rise to a claim for damages (post, p. 982C-D).

But (2) (*per* Lord Denning M.R. and Cumming-Bruce L.J.) that the court in exercising its equitable jurisdiction to grant or refuse an injunction was under a duty to have regard to the public interest; and where the effect of an injunction would prevent cricket being played on a ground where it had been played for over 70 years, the special circumstances were such that the greater interest of the public should prevail over the hardship to the individual householders by being deprived of their enjoyment of their house and garden while cricket was being played; and for that reason the injunction should be discharged and damages of £400 substituted for past and future inconvenience.

Decision of Reeve J. reversed.